

FLAVIA BAHIA MARTINS

CONFORME
NOVO
CPC

DIREITO CONSTITU CIONAL

CONTÉM 20 SIMULADOS NOVOS
DE ACORDO COM A LEI 13.300/2016 - MANDADO DE INJUNÇÃO



 EDITORA
JusPODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

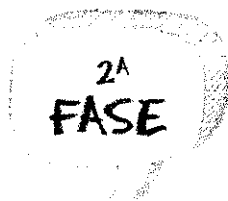
 6ª Edição
revista, ampliada e atualizada

FLAVIA BAHIA MARTINS



DIREITO CONSTITU CIONAL

CONTÉM 20 SIMULADOS NOVOS
DE ACORDO COM A LEI 13.300/2016 - MANDADO DE INJUNÇÃO



~~6ª~~ 6ª Edição
revista, ampliada e atualizada

2017

 EDITORA
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br



www.editorajuspodivm.com.br

Rua Mato Grosso, 175 – Pituba, CEP: 41830-151 – Salvador – Bahia
Tel: (71) 3363-8617 / Fax: (71) 3363-5050 • E-mail: fale@editorajuspodivm.com.br

Copyright: Edições JusPODIVM

Conselho Editorial: Dirley da Cunha Jr., Leonardo de Medeiros Garcia, Fredie Didier Jr., José Henrique Mouta, José Marcelo Vigliar, Marcos Ehrhardt Júnior, Nestor Távora, Robério Nunes Filho, Roberval Rocha Ferreira Filho, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo Reis Mazzei e Rogério Sanches Cunha.

Capa: Rene Bueno e Daniela Jardim (www.buenojardim.com.br)

Diagramação: Linotec Foto Composição e Fitolito Ltda. (linotec@linotec.com.br)

Fechamento desta edição: 26.09.2016.

Todos os direitos desta edição reservados à Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e da Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

APRESENTAÇÃO

Esta singela contribuição acadêmica nasceu do campo mais fértil que um professor – que encontrou com seu destino profissional em sala de aula – poderia ter como fonte de inspiração: o diálogo com os alunos.

O livro prestigia com destaque as principais peças processuais que podem ser cobradas na segunda fase da prova do Exame de Ordem (com análise teórica e prática), não descuida das questões discursivas, dos simulados para treinamento, além de apresentar uma compilação das principais decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre variados temas.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a obra foi completamente adaptada às novas regras processuais, com relação, por exemplo: à contagem de prazo, aos requisitos da petição inicial e às tutelas de urgência. Como o art. 1.046, § 2º, do NCPC manteve em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as normas que tratam das nossas principais petições iniciais (Mandado de Segurança, Habeas Data, Ação Popular, Ação Direta de Inconstitucionalidade, dentre outras) não sofreram modificações significativas pela nova legislação processual.

Com o advento da Lei 13.300/2016, o capítulo referente ao Mandado de Injunção também foi revisado e está em conformidade com a lei regulamentadora do remédio.

Apesar de despretensiosa, a obra foi elaborada com muito carinho e zelo, perfazendo uma conversa honesta entre professor e aluno, reconhecendo que todo professor continua também sendo aluno, ou seja, temos sempre algo a aprender.

Espero que o livro possa lhes servir para atingir seus objetivos profissionais!

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS..... 19

▶ Processo X Procedimento.....	19
▶ O Procedimento Comum no Processo de Conhecimento	19
▶ Procedimentos Especiais.....	20
▶ Atividade Jurisdicional – Estrutura	20
▶ Elementos da Ação.....	21
▶ Petição inicial (elementos gerais – procedimento comum)	22
▶ Análise dos principais requisitos da petição inicial	22
▶ O juízo a quem é dirigida (endereçamento).....	22
▶ O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir).....	24
▶ O pedido com as suas especificações (pedido padrão).....	24
▶ O valor da causa	25
▶ Tutela de urgência	25
▶ Tutela antecipada (arts. 303 e 304 do CPC).....	26
▶ Tutela cautelar (arts. 305 a 310 do CPC)	26
▶ Tutela de evidência.....	27
▶ Pedido de gratuidade de justiça	27
▶ Contagem de prazos no CPC.....	28
▶ Contestação.....	28

CAPÍTULO 2

MANDADO DE INJUNÇÃO 29

▶ Histórico, natureza jurídica e conceito	29
▶ Modalidades.....	30
▶ Pressupostos do remédio.....	30
▶ Da Omissão Normativa.....	31
▶ Intervenção do Ministério Público	31
▶ Polo passivo.....	31

► Tutela de Urgência.....	32
► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais.....	32
► Produção de Provas.....	32
► Efeitos do mandado de injunção.....	32
► Competência.....	34
► Caso concreto e elaboração da peça.....	36

CAPÍTULO 3

HABEAS DATA..... 41

► Histórico, natureza jurídica e conceito.....	41
► Objeto.....	42
► Definição de “caráter público”.....	42
► Legitimidade ativa.....	43
► Polo passivo.....	43
► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais.....	43
► Produção de Provas.....	43
► Intervenção do Ministério Público.....	43
► Tutela de Urgência.....	43
► Comprovação de recusa por parte da autoridade administrativa.....	44
► Hipóteses de não cabimento do HD.....	44
► <i>Habeas Data</i> e pessoa jurídica.....	45
► Competência.....	46
► Caso concreto e elaboração da peça.....	47

CAPÍTULO 4

AÇÃO POPULAR..... 51

► Histórico, natureza jurídica e conceito.....	51
► Espécies.....	52
► Legitimidade ativa.....	52
► Polo passivo.....	52
► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais.....	53
► Produção de Provas.....	53
► Condições específicas.....	53
► O papel do Ministério Público.....	54
► Tutela de Urgência.....	54

► A gratuidade.....	54
► Enunciados da súmula do STF	55
► Competência	55
► Caso concreto e elaboração da peça	57
► Caso Concreto XVIII Exame.....	60

CAPÍTULO 5

HABEAS CORPUS 63

► Histórico, natureza jurídica e conceito	63
► Espécies	64
► Legitimidade ativa	64
► Gratuidade	65
► O paciente	65
► Polo passivo.....	65
► Tutela de Urgência.....	65
► <i>Habeas corpus</i> e prisão do militar.....	65
► <i>Habeas corpus</i> e Comissão Parlamentar de Inquérito	66
► Produção de Provas.....	66
► Hipóteses de não cabimento do <i>Habeas corpus</i>	66
► Competência	67
► Caso concreto e elaboração da peça	68

CAPÍTULO 6

MANDADO DE SEGURANÇA 73

► Histórico, natureza jurídica e conceito	73
► Celeridade	74
► Modalidades.....	74
► Espécies	76
► Condições específicas. Natureza residual do instituto	77
► Polo passivo.....	78
► Da prova	79
► Mandado de segurança e processo legislativo inconstitucional	79
► Hipóteses de não cabimento do <i>mandamus</i>	80
► Custas processuais	81
► Intervenção obrigatória do Ministério Público.....	81
► Tutela de urgência	81

► Direitos protegidos pelo Mandado de Segurança Coletivo	81
► Recursos	82
► Enunciados da Súmula do STF	82
► Competência	83
► Caso concreto e elaboração da peça	85

CAPÍTULO 7

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (OU AÇÃO ORDINÁRIA) 89

► Caso concreto e elaboração da peça	90
--	----

CAPÍTULO 8

DIFERENÇAS PRINCIPAIS ENTRE A AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (OU AÇÃO ORDINÁRIA) E O MANDADO DE SEGURANÇA 95

CAPÍTULO 9

RECLAMAÇÃO 97

► Hipóteses de cabimento e legitimidade ativa	97
► Reclamação para preservação da competência do Tribunal – art. 988, I, do CPC e art. 102, inciso I, alínea “I”, da CRFB/88	97
► Reclamação para garantia da autoridade de decisão do Tribunal – art. 988, II, do CPC e art. 102, inciso I, alínea “I”, da CRFB/88	98
► Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – art. 988, III, do CPC e art. 103-A, § 3º, da CRFB/88	98
► Reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC) – art. 988, IV, do CPC	99
► Procedimento	99
► Tutela de urgência	100
► Jurisprudência do STF sobre a Reclamação	100
► Caso concreto e elaboração da peça	101

CAPÍTULO 10

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 105

► Objeto	105
► Legitimidade ativa	106
► Capacidade postulatória	109

► Concessão de medidas cautelares.....	110
► O procurador-geral da República.....	110
► O advogado-geral da União.....	110
► Dicas para identificar o cabimento das ações do controle concentrado na prova	110
► Caso concreto e elaboração da peça	111
► Caso Concreto XVI Exame.....	114
► Gabarito comentado pela Banca	117

CAPÍTULO 11

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 121

► Objeto	121
► Concessão de medidas cautelares.....	122
► O procurador-geral da República.....	122
► O advogado-geral da União.....	122
► Caso hipotético.....	122

CAPÍTULO 12

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO 127

► Objeto	127
► Legitimação Ativa	128
► Concessão de medidas cautelares.....	128
► O procurador-geral da República.....	129
► O advogado-geral da União.....	129
► Caso cobrado no XIX Exame	129

CAPÍTULO 13

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 131

► Que é preceito fundamental?	131
► Cláusula de subsidiariedade.....	132
► Objeto	132
► Legitimidade Ativa.....	132
► Concessão de medidas cautelares.....	133
► O procurador-geral da República.....	133
► O advogado-geral da União.....	133
► Caso cobrado no XX Exame de Ordem	133

CAPÍTULO 14**AÇÃO CIVIL PÚBLICA 137**

- ▶ Natureza jurídica e conceito 137
- ▶ Direitos metaindividuais 137
- ▶ Espécies 139
- ▶ Legitimidade ativa 140
- ▶ Polo passivo 140
- ▶ Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais 140
- ▶ Produção de Provas 141
- ▶ O papel do Ministério Público 141
- ▶ Tutela de Urgência 141
- ▶ Competência 141
- ▶ Diferenças entre a ACP e o mandado de segurança coletivo 142
- ▶ Caso hipotético 143

CAPÍTULO 15**AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 145**

- ▶ Legitimados ativos 145
- ▶ Legitimado passivo 146
- ▶ Competência 146
- ▶ Sigilo 146
- ▶ Prazo 146
- ▶ Prova pré-constituída 146
- ▶ Tutela de urgência 147
- ▶ Participação do Ministério Público 147
- ▶ Caso hipotético 147

CAPÍTULO 16**DA CONTESTAÇÃO 149**

- ▶ Preliminares da Contestação 150
- ▶ Defesa de mérito 152
- ▶ Estrutura da Contestação 152
- ▶ Caso hipotético 153

CAPÍTULO 17	
VISÃO GERAL DOS RECURSOS	155
▶ Princípios norteadores	156
▶ Objetivos principais do Recurso	156
▶ Efeitos dos recursos	157
▶ Natureza da “decisão”	157
▶ Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito	158
 CAPÍTULO 18	
APELAÇÃO	159
▶ Caso concreto	160
 CAPÍTULO 19	
AGRAVOS	165
▶ Agravo de Instrumento	165
▶ Caso concreto – cobrado na 2ª fase de Dir. Administrativo	167
▶ Elaboração e identificação do recurso	167
▶ Agravo Interno	170
▶ Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário	170
 CAPÍTULO 20	
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	173
 CAPÍTULO 21	
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL	177
▶ Recurso Ordinário Constitucional para o STF	177
▶ Recurso Ordinário Constitucional para o STJ	178
▶ Caso concreto	179
 CAPÍTULO 22	
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL	183
▶ Recurso Extraordinário	184
▶ Súmulas STF	186
▶ Recurso Especial	186
▶ Súmulas STJ	187
▶ Caso concreto	188

► Comentários da Banca [Comentários feitos quando ainda vigente o CPC/1973.]	192
--	-----

CAPÍTULO 23

PARECER JURÍDICO	195
-------------------------------	------------

► Cabimento	195
► Estrutura simples da peça	195
► Peça cobrada no XVII Exame	196
► Peça	197
► Comentários da Banca	198
► Distribuição dos pontos – Parecer	199
► Gabarito Comentado – ADI	200

CAPÍTULO 24

QUESTÕES DE EXAMES DE ORDEM – SEGUNDA FASE COM GABARITO	203
--	------------

CAPÍTULO 25

JURISPRUDÊNCIA DO STF 2015 E 2016	295
--	------------

INFORMATIVOS 2015	295
--------------------------------	------------

+ “Amicus curiae”: recorribilidade e legitimidade	295
+ Vinculação a salário mínimo e criação de órgão	296
+ Energia elétrica e competência para legislar	296
+ Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União – 1	297
+ Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União – 2	297
+ Revisão de remuneração de servidores públicos e iniciativa legislativa	298
+ Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 1	298
+ Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 2	299
+ Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 3	299
+ Competência concorrente para legislar sobre educação	300
+ Repercussão geral	301
+ Poder Executivo e quinto constitucional	301
+ Lei municipal e vício de iniciativa	302

+ TCU: medida cautelar de indisponibilidade de bens e tomada de contas especial.....	302
+ Art. 27 da Lei 9.868/1999 e suspensão de julgamento – 4.....	303
+ Publicidade de bebidas alcoólicas e omissão legislativa – 1.....	304
+ Publicidade de bebidas alcoólicas e omissão legislativa – 2.....	305
+ STF e competência em decisões negativas do CNMP.....	305
+ EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 1.....	306
+ EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 2.....	307
+ EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 3.....	307
+ EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 4.....	308
+ EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 5.....	309
+ Norma estadual e princípio da simetria	310
+ Sistema majoritário e fidelidade partidária – 1	311
+ Sistema majoritário e fidelidade partidária – 2	312
+ Efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória	313
+ Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão – 1.....	313
+ Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão – 2.....	314
+ Concurso público e limite de idade	315
+ Constituição estadual e separação de poderes – 1	316
+ Constituição estadual e separação de poderes – 2	316
+ Emenda parlamentar e pertinência temática.....	317
+ Modificação de decisão judicial pelo TCU e coisa julgada – 3	317
+ Obras emergenciais em presídios: reserva do possível e separação de poderes – 1.....	318
+ Obras emergenciais em presídios: reserva do possível e separação de poderes – 2.....	319
+ Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 6	320
+ Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 6	321
+ Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 7	322
+ Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 8	322
+ ADI e financiamento de campanha eleitoral – 18.....	324
+ ADI e financiamento de campanha eleitoral – 19.....	325
+ Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 1	326

+ Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 2	326
+ Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 3	327
+ Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 4	328
+ Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo” - 1	329
+ Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo” - 2	330
+ Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo” - 3	330
+ Parlamentar e imunidade	331
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 1	332
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 2	333
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 3	334
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 4	334
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 5	335
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 6	336
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 7	337
+ Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 8	338
INFORMATIVOS 2016	339
+ Sigilo e fiscalização tributária - 4	339
+ Sigilo e fiscalização tributária - 5	339
+ Sigilo e fiscalização tributária - 6	341
+ Fornecimento de informações financeiras ao fisco sem autorização judicial - 5	341
+ Inquérito: corrupção passiva e lavagem de dinheiro - 1	342
+ CNJ: férias de 60 dias e justiça estadual - 1	343
+ CNJ: férias de 60 dias e justiça estadual - 2	344
+ Licença-maternidade e discriminação entre gestação e adoção - 1	344
+ Licença-maternidade e discriminação entre gestação e adoção - 2	345
+ ADI e revalidação de diplomas obtidos no exterior	345
+ ADI: despesas com pessoal e Lei de Diretrizes Orçamentárias	346
+ Exercício do cargo de Ministro de Estado por membro do Ministério Público e vedações constitucionais - 1	346
+ Exercício do cargo de Ministro de Estado por membro do Ministério Público e vedações constitucionais - 2	347
+ ADI: Tribunal de Contas estadual e vício de iniciativa	348
+ Auditoria do TCU e participação de servidor indiretamente afetado	348
+ ADI: “Impeachment” e ordem de votação - 1	348

+ ADI: "Impeachment" e ordem de votação - 2	349
+ ADI: "Impeachment" e ordem de votação - 3	350
+ "Impeachment" e ordem de votação - 1	350
+ "Impeachment" e ordem de votação - 2	351
+ Magistratura: triênio para ingresso na carreira e momento de comprovação	351
+ MS e perda de nacionalidade brasileira	352
+ Competência da União em telefonia	353
+ Emenda parlamentar e aumento de despesa	353
+ Fazenda Pública e atuação em juízo - 1	353
+ Fazenda Pública e atuação em juízo - 2	354
+ Fazenda Pública e atuação em juízo - 3	355
+ Parlamentar e afastamento do cargo - 1	356
+ Parlamentar e afastamento do cargo - 2	357
+ Parlamentar e afastamento do cargo - 3	358
+ Parlamentar e afastamento do cargo - 4	358
+ Magistratura e limites de despesas médicas e odontológicas conferidas por lei estadual	359
+ EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 6	360
+ EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 7	361
+ EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 8	361
+ Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária - 4	362
+ Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária - 5	363
+ Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária - 6	364
+ Distribuição de medicamento e necessidade de registro sanitário - 1	365
+ Distribuição de medicamento e necessidade de registro sanitário - 2	365
 CAPÍTULO 26	
SIMULADOS	367
Simulado 1	369
Simulado 2	374
Simulado 3	379
Simulado 4	384
Simulado 5	389

Simulado 6.....	395
Simulado 7.....	400
Simulado 8.....	406
Simulado 9.....	411
Simulado 10.....	416
Simulado 11.....	421
Simulado 12.....	426
Simulado 13.....	431
Simulado 14.....	436
Simulado 15.....	441
Simulado 16.....	446
Simulado 17.....	451
Simulado 18.....	456
Simulado 19.....	462
Simulado 20.....	467

CAPÍTULO 1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesse Capítulo estudaremos as noções iniciais do processo, os elementos da ação, o pedido de gratuidade de justiça, as tutelas de urgência, a estrutura da petição inicial e da contestação.

► Processo X Procedimento

O processo é o meio utilizado para solucionar os litígios. O Direito Processual Civil prevê duas espécies de processo: o de conhecimento (ou de cognição) e o de execução.

No **Processo de conhecimento** as partes levam ao conhecimento do juiz, os fatos e fundamentos jurídicos, para que ele possa substituir por um ato seu a vontade de uma das partes.

O **Processo de execução** está regulamentado no Livro II do CPC, a partir do seu art. 771. É o meio pelo qual alguém é levado a juízo para solver uma obrigação que tenha sido imposta por lei ou por uma decisão judicial.

Enquanto o processo forma uma relação processual em busca da pretensão jurisdicional, o procedimento é o modo e a forma como os atos do processo se movimentam. Procedimento, segundo alguns autores, é expressão sinônima a rito.

► O Procedimento Comum no Processo de Conhecimento

O processo de conhecimento é o mais importante na segunda fase de Direito Constitucional, de acordo com o conteúdo programático apresentado pela banca. Nele, encontramos o procedimento comum, regulamentado no Título I do Livro I do CPC (art. 318 e seguintes).

De acordo com o art. 318 do CPC:

“Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.

Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.”

► Procedimentos Especiais

Os procedimentos especiais estão previstos no CPC e em leis esparsas, conforme ocorre com o mandado de segurança e o habeas data. No CPC, podemos encontrar no Título III, as seguintes ações:

DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS...

► Atividade Jurisdicional – Estrutura

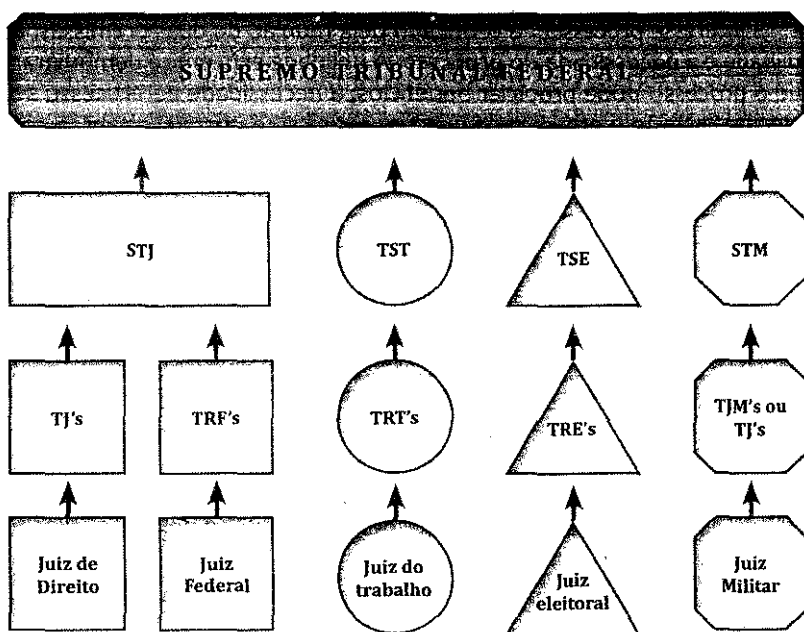
A estrutura do Estado é estabelecida com base na forma federativa, que admite duas ordens de organização: Federal e Estadual. Portanto, coexistem a Justiça Federal, que tem as competências previstas expressamente na Constituição, e a Justiça Estadual, cabendo-lhe a competência residual.

Quanto à competência disposta na Constituição Federal, o Judiciário estrutura-se em 2 (dois) âmbitos: comum e especializado. Portanto, a Justiça Federal pode ser: comum ou especializada (Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar). Já na Justiça Estadual há somente a Justiça Militar especializada.

São órgãos do Poder Judiciário, na forma do art. 92, I a VII, da CRFB/88:

- a) o Supremo Tribunal Federal;
- b) o Conselho Nacional de Justiça;
- c) o Superior Tribunal de Justiça;
- d) o Tribunal Superior do Trabalho;
- e) os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- f) os Tribunais e Juízes do Trabalho;
- g) os Tribunais e Juízes Eleitorais;
- h) os Tribunais e Juízes Militares;
- i) os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional (art. 92, § 1º e § 2º). O Conselho Nacional de Justiça também tem sede em Brasília, mas é desprovido de atividade jurisdicional.



► Elementos da Ação

Os elementos da ação configuram os requisitos da ação exigidos pela lei para que seja viável a análise da pretensão apresentada na petição inicial. A ausência de um deles gera a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 17 c/c art. 337, XI, do CPC). São eles:

- Legitimidade das Partes;
- Interesse Processual.

A *legitimidade das Partes* (“*ad causam*” ou legitimidade para agir) pode ser conceituada como o poder jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute um determinado conflito. A legitimidade pode ser exclusiva (atribuída a um único sujeito), concorrente (atribuída a mais de um sujeito), ordinária (o legitimado discute direito próprio) e extraordinária (o legitimado, em nome próprio, discute direito alheio). Diz respeito ao polo ativo e passivo da demanda.

O *interesse processual* é verificado pela reunião de duas premissas: a utilidade e a necessidade do processo. A utilidade está em se demonstrar que o processo pode propiciar benefícios; a necessidade do processo se constata quando o proveito de que se precisa só é possível alcançar por meio do Judiciário, ou seja, a solução amigável não foi atingida.

► **Petição inicial (elementos gerais – procedimento comum)**

A petição inicial, em termos simples, é a responsável por provocar a atividade jurisdicional do Estado e é por meio dela que o autor formula a sua pretensão, pretendendo a sua satisfação pela decisão judicial.

Na forma do art. 319, do CPC, são requisitos da petição inicial:

- A) O juízo a quem é dirigida (endereçamento);
- B) Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu (qualificação das partes);
- C) O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir);
- D) O pedido com as suas especificações (pedido);
- E) O valor da causa;
- F) As provas com que o Autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (requerimento de provas);
- G) A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

► **Análise dos principais requisitos da petição inicial**

► **O juízo a quem é dirigida (endereçamento)**

- Qual é a justiça competente? Especializada (trabalhista, militar, eleitoral) ou Comum (residual)?
- A competência para julgamento é de Tribunal (de 2ª instância ou Superior) ou de juiz monocrático (federal ou estadual)?
- Se não for competente a Justiça Especializada, a competência será da Justiça Comum (estadual ou federal).

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem partes...” (CRFB/88)

Cada Estado, na estrutura da Justiça Federal, recebe a denominação de seção judiciária, e cada seção judiciária compõe-se de diversas subseções, através das quais são distribuídas as varas pelo interior e capital. Em um paralelo com a Justiça Estadual, as subseções equivalem às comarcas, pois embora estabelecidas em municípios-sede, abrangem os municípios vizinhos, de forma a facilitar o deslocamento dos jurisdicionados. Atualmente, por exemplo, na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, existem 21 subseções, considerando-se a Capital do Estado. As subseções gaúchas estão sediadas nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Erechim, Carazinho, Cruz Alta, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santana do Livramento, Uruguaiana, Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santiago. Já na Seção Judiciária de Pernambuco, existem 11 subseções, sediadas nos municípios de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra Talhada.

Assim dispõe o artigo 110, da CRFB/88:

“Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei”.

A justiça comum estadual é residual!

A Justiça estadual é dividida em Comarcas e Varas:

JUSTIÇA ESTADUAL	
Comarca	Varas
é uma divisão territorial e pode representar a área de um Município ou de vários Municípios	divisão especializada das Comarcas

OBS: Uma Comarca pode ter uma Vara Única ou ser dividida em Varas: Criminais, Fazenda Pública, Cíveis...

EXEMPLOS DE ENDEREÇAMENTO:

- EXM^o. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- EXM^o. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ... VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO...

- EXM^o. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ... VARA ... DA COMARCA DE

Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu

- Acrescentamos também nacionalidade e RG.
- Em todas as petições iniciais devemos indicar o art. 77, V, do CPC, informando o endereço residencial ou profissional onde o advogado receberá intimações.

Exemplos:

Nome, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável) ..., profissão..., portador do RG nº ... e do CPF nº ... , residente e domiciliado ..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado (ou que esta subscreve), conforme procuração anexa, com escritório ..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. ..., vem impetrar (MS, MI, HC, HD) ou ajuizar (AP, ACP) ... em face de...

Nome, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..., com sede..., por seu advogado infra-assinado (ou que esta subscreve), conforme procuração anexa, com escritório ..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. ..., vem impetrar (MS, MI, HC, HD) ou ajuizar (AP, ACP) ... em face de...

► O fato e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir)

A causa de pedir inclui os fatos apresentados pela banca e os fundamentos jurídicos do pedido que devem conter a base constitucional, infraconstitucional, súmulas, direito processual e material.

► O pedido com as suas especificações (pedido padrão)

Exemplo:

Em face do Exposto, requer a V. Ex^a..

a) A citação do réu ou interessado¹ (arts. 238 e 239, caput, do CPC – o requerimento para a citação do réu ou do interessado):

1. Atenção com a legislação específica.

b) A procedência do pedido para... (art. 319, IV, do CPC – o pedido, com as suas especificações);

c) A condenação do réu no ônus da sucumbência (art. 85, caput, do CPC);

d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos (art. 319, VI, do CPC – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados);

e) A juntada dos documentos em anexo (art. 320, do CPC – A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação).

► O valor da causa

Art. 291 do CPC: “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”

Como a banca estabeleceu em dois casos concretos (abaixo apresentados) o valor de R\$ 1.000,00 para efeitos procedimentais, seguimos esse entendimento, a não ser que um novo valor seja apresentado na peça.

OAB – 2010.3 – Gabarito Comentado – 2ª Fase – Constitucional	<i>Habeas Data</i> – Valor da causa – R\$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos procedimentais – Pontuação: 0,5
OAB – 2010.2 – Gabarito Comentado – 2ª Fase – Constitucional	MS – Valor da causa: pode ser R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais – Pontuação: 0,5

Na Ação Popular, nas Ações Ordinárias e na Ação Civil Pública – indicar normalmente o valor do contrato ou do dano apresentado pela banca, caso contrário, escrever R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

► Tutela de urgência

A tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC) é gênero que compreende duas espécies: tutela antecipada e tutela cautelar, que exigem urgência na concessão do Direito e reclamam o preenchimento dos mesmos requisitos.

Ambas independem de cognição exauriente, bastando a cognição sumária, que permite ao juiz a concessão de uma tutela de urgência baseando-se meramente em um juízo de probabilidade.

Vale ressaltar que com a concessão das tutelas de urgência não há a satisfação jurídica completa, pois no sistema processual brasileiro apenas os julgamentos de mérito com cognição exauriente tem essa aptidão (coisa julgada material), tornando indiscutível e imutável a decisão, entregando a satisfação jurídica à parte vencedora.

Em ambas caberá à parte convencer o juiz de que se não houver proteção imediata poderá haver o perecimento de seu direito.

► Tutela antecipada (arts. 303 e 304 do CPC)

A tutela antecipada se presta a satisfazer efetivamente o direito da parte e dependerá de requerimento expresso da parte interessada na petição inicial.

De acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante ressaltar que a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso, de acordo com o *caput* do art. 304 do CPC. Trata-se da chamada estabilização da tutela antecipada.

► Tutela cautelar (arts. 305 a 310 do CPC)

Trata-se de tutela de urgência com natureza cautelar. De acordo com o art. 305 do CPC: A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser apresentado pelo autor nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Assim como na tutela antecipada, de acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

► Tutela de evidência

A tutela de evidência, diferentemente da tutela de urgência, independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e será concedida, na forma do art. 311 do CPC, quando:

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documental-mente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

De acordo com o parágrafo único do citado dispositivo, nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

► Pedido de gratuidade de justiça

- Somente quando o enunciado da questão indicar que há hipossuficiência.
- Colocar antes dos “Fatos”. Não precisa repetir nos Pedidos.

Não há um momento procedimental **específico** para o Autor ou Réu requererem o benefício da gratuidade de justiça. É dizer: **não há preclusão**. Nada obsta a apreciação de pedido de gratuidade de justiça em segunda instância ou na instância extraordinária, pois de acordo com o art. 99, *caput*, do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”

Exemplo:

Com base no art. 99, § 3º, do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CRFB/88 o Autor requer a V. Exª. a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que está desempregado e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

► Contagem de prazos no CPC

De acordo com o estabelecido no art. 219, do CPC, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

► Importante destacar, ainda, o seguinte dispositivo:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

► Contestação

A contestação é o meio processual utilizado pelo réu para opor-se formal ou materialmente ao direito do autor ou formular pedido contraposto. Como regra geral, o autor terá deduzido uma pretensão em juízo e o réu irá defender-se, e essa defesa, normalmente, é a contestação.

O conteúdo da contestação, segundo o art. 336, do CPC: toda a matéria de defesa, razões de fato e de direito, impugnação das alegações do Autor, produção de provas específicas...

Os aspectos específicos sobre a Contestação serão estudados em capítulo próprio.

CAPÍTULO 2

MANDADO DE INJUNÇÃO

Art. 5º, CRFB/88. LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

► Histórico, natureza jurídica e conceito

O mandado de injunção foi uma grande aposta da constituinte de 1988 para curar a doença da inefetividade das normas constitucionais que contagiou toda a história do constitucionalismo brasileiro. As normas constitucionais de eficácia limitada dependentes de regulamentação sempre estiveram presentes nas Constituições anteriores, que foram sucessivamente revogadas sem que tivessem cumprido a promessa constitucional para a sociedade brasileira.

Conforme assevera José Afonso da Silva², o remédio está intimamente ligado à ideia de que as normas jurídicas escritas não podem prever tudo, mas, mesmo na falta de norma expressa, não pode o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça de direito (art. 5º, XXXV); há de encontrar meio de solucionar o caso submetido à sua apreciação, aplicando o velho princípio de que na falta de normas escritas e princípios gerais de Direito que lhe possibilitem essa apreciação, cumpre-lhe dispor para o caso concreto como se legislador fosse, exercendo uma forma de juízo de equidade.

A sua fonte mais próxima no direito comparado é o *writ of injunction* do Direito norte-americano, onde tem sido cada vez mais utilizado para a defesa da proteção da pessoa humana, impedindo violações aos direitos fundamentais, num caráter mais proibitivo do que o nosso instituto.

À semelhança dos demais remédios constitucionais, possui igualmente natureza jurídica dúplice, sendo ao mesmo tempo ação constitucional e

2 AFONSO DA SILVA, José. *Comentário Contextual à Constituição*, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 165.

ação cível. O mandado de injunção é um remédio constitucional sobre procedimento especial, dirigido à tutela de direitos subjetivos constitucionais, cujo exercício esteja impedido pela ausência de norma reguladora.

A Lei 13.300/16, publicada no dia 24 de junho de 2016, finalmente regulamentou o mandado de injunção, depois de quase 28 (vinte e oito) anos de omissão do Congresso Nacional.

► Modalidades

- **Mandado de injunção individual:** deverá ser impetrado por pessoa natural ou jurídica cujo direito fundamental esteja à mingua de uma norma que o regulamente;
- **Mandado de injunção coletivo:**

Art. 12 da Lei 13.300/16: O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;

II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes, indistintamente, a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria.

► Pressupostos do remédio

Para a propositura da ação em referência, na via individual ou coletiva, devem ser preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) inexistência da norma regulamentando o direito fundamental reconhecido constitucionalmente; e b) ser o impetrante beneficiário direto do direi-

to. Não pode, por exemplo, quem não é servidor público pleitear em juízo a elaboração da lei de greve para o serviço público (art. 37, VII da CRFB/88).

► Da Omissão Normativa

A omissão normativa a ser combatida pelo mandado de injunção pode ser total ou parcial, de acordo com o que dispõe o art. 2º, da Lei 13.300/16: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”

► Intervenção do Ministério Público

A intervenção do Ministério Público é obrigatória, por conta da aplicação do art. 7º, da Lei 13.300/16. Portanto, pedimos na inicial do mandado de injunção a intimação do representante do Ministério Público.

► Polo passivo

O sujeito passivo da ação será a pessoa estatal que tenha o dever de elaborar a norma regulamentadora e está em mora, seja autoridade, órgão ou entidade responsável. Se a norma for de iniciativa privativa (atenção com o art. 61, § 1º da CRFB/88), a legitimidade passiva *ad causam* deverá ser preenchida por quem deveria ter oferecido o projeto de lei e não o fez.³ O art. 4º, da Lei 13.300/16, ainda indica que a petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além do órgão impetrado, a pessoa jurídica que ele integra ou aquela a que está vinculado.

3 “O mandado de injunção nem autoriza o Judiciário a suprir a omissão legislativa ou regulamentar, editando o ato normativo omitido, nem, menos ainda, lhe permite ordenar, de imediato, ato concreto de satisfação do direito reclamado: mas, no pedido, posto que de atendimento impossível, para que o Tribunal o faça, se contém o pedido de atendimento possível para a declaração de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciência ao órgão competente para que a supra” (STF, MI 168/RS; Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.03.1990, DJ 20.04.1990) e no mesmo sentido: “Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a exercitou, não há direito constitucional já criado, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora” (STF, MI 444-QQ/MG, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 29.09.1994, DJ 04.11.1994).

► Tutela de Urgência

A tutela de urgência não é admitida, até o momento, em sede de mandado de injunção.

► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais

Como o art. 14, da Lei 13.300/16, determina a aplicação subsidiária da lei do Mandado de Segurança, por força do art. 25 da Lei 12.016/09 não se pleiteia a condenação em honorários advocatícios, apenas em custas processuais.

► Produção de Provas

Diante do seu procedimento especial, não se pede a produção de provas, apenas a juntada de documentos.

► Efeitos do mandado de injunção

Esse é, sem dúvidas, o aspecto mais polêmico que envolve o remédio ora analisado. Destacaremos as quatro correntes doutrinárias de maior relevância sobre o assunto:

- a) posição não concretista: de acordo com esse posicionamento, em nome da harmonia e separação entre os poderes (art. 2º da CRFB/88), o Poder Judiciário não poderia suprir a omissão da norma faltante, tampouco determinar prazo para o legislador elaborar a lei, restando a sentença tendo efeito apenas de declarar a mora legislativa. Esta é a posição clássica do STF,⁴ que durante muitos anos produziu um verdadeiro sentimento de “frustração constitucional” para a população brasileira;
- b) posição concretista geral: segundo essa corrente, o Poder Judiciário poderia solucionar a omissão legislativa, regulamentando-a com

4 “O mandado de injunção nem autoriza o Judiciário a suprir a omissão legislativa ou regulamentar, editando o ato normativo omitido, nem, menos ainda, lhe permite ordenar, de imediato, ato concreto de satisfação do direito reclamado: mas, no pedido, posto que de atendimento impossível, para que o Tribunal o faça, se contém o pedido de atendimento possível para a declaração de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciência ao órgão competente para que a supra” (STF, MI 168, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21.03.1990, DJ 20.04.1990) e no mesmo sentido: “Tratando-se de mera faculdade conferida ao legislador, que ainda não a exercitou, não há direito constitucional já criado, e cujo exercício esteja dependendo de norma regulamentadora” (STF, MI 444-QO, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 29.09.1994, DJ 04.11.1994).

produção de efeitos *erga omnes*. Este posicionamento atribui ao Judiciário o papel de legislador positivo. Recentemente o plenário do STF aplicou essa teoria na questão relativa ao direito de greve do servidor público, do art. 37, VII da CRFB/88,⁵ cuja regulamentação ainda não foi feita pelo legislador;

- c) posição concretista individual direta: por meio dessa teoria, o Judiciário poderá aplicar por analogia lei já existente para resolver o caso específico, tendo a decisão efeito *inter partes*. O STF decidiu de acordo com essa teoria em caso sobre a ausência de lei complementar sobre a aposentadoria, anunciada pelo art. 40, § 4º da CRFB/88.⁶
- d) posição concretista intermediária: de acordo com essa teoria, o Poder Judiciário além de comunicar a omissão ao órgão competente deverá fixar-lhe prazo para a edição da norma faltante. Em 2007, essa posição foi adotada em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão,⁷ que será analisada com detalhes em capítulo próprio.

5 “O Tribunal concluiu julgamento de três mandados de injunção impetrados, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais Cíveis do Espírito Santo – SINDIPOL, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa – SINTTEM, e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP, em que se pretendia fosse garantido aos seus associados o exercício do direito de greve previsto no art. 37, VII, da CF (...). O Tribunal, por maioria, conheceu dos mandados de injunção e propôs a solução para a omissão legislativa com a aplicação, no que couber, da Lei nº 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada. (...) (STF, MI 712/PA, Plenário, DJE 31.10.2008, Rel. Min. Eros Grau, STF, MI 708/DF, Plenário, DJE 31.10.2008, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STF, MI 670/ES; Min. Rel. Maurício Corrêa; Plenário; DJE 31.10.2008, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, Informativo nº 485).

6 “Na linha da nova orientação jurisprudencial fixada no julgamento do MI 721/DF (DJ 30.11.2007), o Tribunal julgou procedente pedido formulado em mandado de injunção para, de forma mandamental, assentar o direito do impetrante à contagem diferenciada do tempo de serviço em decorrência de atividade em trabalho insalubre, após a égide do regime estatutário, para fins de aposentadoria especial de que cogita o § 4º do art. 40 da CF. Tratava-se, na espécie, de writ impetrado por servidor público federal, lotado, na função de tecnólogo, na Fundação Oswaldo Cruz, que pleiteava fosse suprida a lacuna normativa constante do aludido § 4º do art. 40, assentando-se o seu direito à aposentadoria especial, em razão do trabalho, por 25 anos, em atividade considerada insalubre, ante o contato com agentes nocivos, portadores de moléstias humanas e com materiais e objetos contaminados. Determinou-se, por fim, a comunicação ao Congresso Nacional para que supra a omissão legislativa” (STF, MI 758/DF, Plenário, DJE 26.09.2008, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1º.07.2008, Informativo nº 513).

7 “O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de

Apesar de todo o avanço jurisprudencial, a lei 13.300/16, no art. 8º, adotou uma posição mais conservadora (concretista intermediária) sobre a decisão do Mandado de Injunção. Senão vejamos:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I – determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

► Competência

A competência para processo e julgamento do mandado de injunção será fixada de acordo com a autoridade, órgão ou entidade a que caiba a edição da norma regulamentadora.

A Constituição também trata da competência originária e recursal para processo e julgamento do remédio constitucional em sede do STF⁸ e do STJ.⁹

Mato Grosso, para reconhecer a mora do Congresso Nacional em elaborar a lei complementar federal a que se refere o § 4º do art. 18 da CF, na redação dada pela EC nº 15/96, e, por maioria, estabeleceu o prazo de 18 meses para que este adote todas as providências legislativas ao cumprimento da referida norma constitucional” (STF, ADI 3.682/MT, Plenário, DJE 06.09.2007; Rel. Min. Gilmar Mendes, 09.05.2007, Informativo nº 466).

- 8 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente: (...)

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

II – julgar, em recurso ordinário:

a) (...) o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”

- 9 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: (...)

Responsável pela edição da norma	Fundamento legal	Competência
• Presidente da República • Congresso Nacional • Câmara dos Deputados • Senado Federal • Tribunal de Contas da União • Tribunais Superiores • STF	Art. 102, I 'q' CRFB	STF
Órgão ou entidade federal, da Administração direta ou indireta, exceto os casos de competência do STF, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Justiça Federal*.	Art. 105, I, 'h' CRFB	STJ
Autoridades previstas nas Constituições Estaduais.	Art. 125 § 1º CRFB	• TJ • G – Governador • P – Prefeito de Capital • S – Secretário de Estado • Mesa da Assembleia Legislativa
Competência residual	Art. 125 § 1º CRFB	Juiz Estadual (Vara Cível)

Quadro comparativo do MI e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

Para defender a Constituição da síndrome de inefetividade das normas constitucionais, além do mandado de injunção, o constituinte também importou, inspirado no Direito português, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para evitar dúvidas sobre as diferenças entre as duas ações, apresentamos abaixo quadro comparativo com os principais destaques sobre o tema.

PARÂMETRO	MI	ADO
Origem	Direito norte-americano	Direito português
Natureza jurídica	Remédio constitucional – processo subjetivo	Ação do controle concentrado de constitucionalidade – processo objetivo

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.”

PARÂMETRO	MI	ADO
Base legal	Art. 5º, LXXI da CRFB/88 e Lei 13.300/16	Art. 103, § 2º da CRFB/88 e Lei nº 9.868/99
Legitimidade ativa	Depende da modalidade. MI individual e MI coletivo	Art. 103, I a IX da CRFB/88
Finalidade	Defesa de normas constitucionais relacionadas a direitos fundamentais, dependentes de regulamentação	Defesa de normas constitucionais dependentes de regulamentação
Efeitos da decisão	Via de regra, <i>inter partes</i>	<i>erga omnes</i>
Competência	STF, STJ, TJs dos Estados	STF
Tutela de Urgência	Não é admitida	É admitida

► Caso concreto e elaboração da peça

(OAB 2007.2)

Joana Augusta laborou, durante vinte e seis anos, como enfermeira do quadro do hospital universitário ligado a determinada universidade federal, mantendo, no desempenho de suas tarefas, em grande parte de sua carga horária de trabalho, contato com agentes nocivos causadores de moléstias humanas bem como com materiais e objetos contaminados. Em conversa com um colega, Joana obteve a informação de que, em razão das atividades que ela desempenhava, poderia requerer aposentadoria especial, com base no § 4º do art. 40 da Constituição Federal de 1988. A enfermeira, então, requereu administrativamente sua aposentadoria especial, invocando como fundamento de seu direito o referido dispositivo constitucional. No dia 30 de novembro de 2008, Joana recebeu notificação de que seu pedido havia sido indeferido, tendo a administração pública justificado o indeferimento com base na ausência de lei que regulamente a contagem diferenciada do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aposentadoria especial, ou seja, sem uma lei que estabeleça os critérios para a contagem do tempo de serviço em atividades que possam ser prejudiciais à saúde dos servidores públicos, a aposentadoria especial não poderia ser concedida. Nessa linha de entendimento, Joana deveria continuar em atividade até que completasse o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de serviço. Inconformada, Joana procurou escritório de advocacia, objetivando ingressar com ação para obter sua aposentadoria especial. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Joana, redija a petição inicial

da ação cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos:

- a) competência do órgão julgador;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) argumentos de mérito;
- d) requisitos formais da peça judicial proposta.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

EXM^o. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

Joana Augusta, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., enfermeira, portadora do RG nº... e do CPF nº..., endereço eletrônico ..., residente e domiciliada..., nesta cidade, por seu advogado, conforme procuração anexa ..., com escritório ..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 5º, LXXI da CRFB/88 e na Lei 13.300/16, vem impetrar MANDADO DE INJUNÇÃO em face de ato omissivo do Presidente da República, que poderá ser encontrado na sede funcional...

I - SÍNTESE DOS FATOS

A impetrante trabalhou durante vinte e seis anos como enfermeira do quadro do hospital universitário ligado a determinada universidade federal, mantendo, no desempenho de suas tarefas, contato com agentes nocivos causadores de moléstias humanas bem como com materiais e objetos contaminados, ou seja, trabalho considerado de risco.

Ao ser informada de que poderia obter a aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40, III, da CRFB/88, a impetrante requereu administrativamente sua aposentadoria, tendo a administração pública indeferido o pedido com base na ausência de lei complementar que regulamente a contagem diferenciada do tempo.

Joana Augusta, portanto, não pode exercer o direito fundamental à aposentadoria especial em razão da falta da lei que a regulamente, o que enseja a propositura do mandado de injunção ora apresentado.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Na forma do art. 5º, LXXI, da CRFB/88, o mandado de injunção é o remédio constitucional responsável pela defesa em juízo de direito fundamental previsto na Constituição ainda pendente de regulamentação.

De acordo com o art. 2º da Lei 13.300/16: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente.”

De acordo com o inciso III, § 4º, do art. 40 da CRFB/88 é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata o artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, dentre eles, os casos de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, justamente a situação em que se encontra a impetrante, que é titular de um direito fundamental ainda pendente de regulamentação.

O remédio ora em análise foi impetrado em face de ato omissivo do Presidente da República, tendo em vista que a matéria relativa à aposentadoria de servidores é de sua iniciativa privativa, na forma do art. 61, § 1º, II, c, da CRFB/88.

Ademais, compete ao STF processar e julgar originariamente o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, segundo dispõe o art. 102, I, q, da CRFB/88.

III – DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL

Até 2007 o STF adotava a posição não concretista geral e de acordo com esse entendimento, em nome da separação entre os poderes (art. 2º, da CRFB/88), o Poder Judiciário não poderia suprir a omissão da norma faltante, tampouco fixar prazo para o legislador elaborar a lei, restando a sentença produzindo efeito apenas para declarar a mora legislativa.

Desde 2007, entretanto, o Tribunal vem mudando de entendimento e tem adotado posições concretistas, aplicando por analogia leis já existentes para suprir a omissão normativa, ora atribuindo efeitos subjetivos *erga omnes*, ora *inter partes*.

No que tange especialmente à ausência da Lei Complementar anunciada pelo art. 40, § 4º, a Corte tem aplicado a Lei 8213/91, no que couber, até que seja suprida a referida omissão inconstitucional.

Apesar de todo o avanço jurisprudencial, a Lei 13.300/16, no art. 8º, adotou uma posição mais conservadora (concretista intermediária) sobre a decisão do Mandado de Injunção. Senão vejamos:

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para:

I – determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;

II – estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.

Parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso I do caput quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma.

IV – DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer-se:

- a) a notificação da autoridade omissa no endereço fornecido na inicial, para que, querendo, preste as informações que entender pertinentes do caso;
- b) a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada;
- c) a intimação do Representante do Ministério Público;
- d) a condenação do Impetrado em custas processuais;
- e) que o pedido seja ao final julgado procedente para que o Tribunal estabeleça o prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora;
- f) a juntada de documentos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 3

HABEAS DATA

Art. 5º, CRFB/88. LXXII – “conceder-se-á *habeas data*:

- a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
- b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

► Histórico, natureza jurídica e conceito

A criação do *habeas data* pelo constituinte de 1988 tem estreita relação com os “anos de chumbo” vivenciados pelos brasileiros na época da ditadura militar. Como é fato notório, autoridades faziam uso da prática repugnável de colher informações sobre a vida das pessoas que se insurgiam contra o regime, numa completa violação ao direito fundamental à intimidade.

A influência do direito comparado sobre a criação do instituto é normalmente associada ao *Freedom of Information Act* americano de 1974, ainda que a ação também tenha previsão na Constituição de Portugal de 1976¹⁰ e na Constituição da Espanha de 1978.

É uma ação constitucional e também de natureza cível, de procedimento especial, dirigida ao conhecimento ou retificação, como também, anotação, contestação ou explicação de dados pessoais constantes de bancos de dados ou, assentamentos de entidades governamentais ou

10 “Art. 35º 1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei”. E ainda: “4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei.”

de caráter público. É gratuita para todas as pessoas, na forma do art. 5º, LXXVII, da CRFB/88 e ainda recebe tratamento infraconstitucional pela Lei nº 9.507/1997.

O *habeas data* não tem por finalidade permitir acesso a informações públicas – papel do mandado de segurança – mas sim, a dados pessoais (nome, filiação, saúde, escolaridade, trabalho etc.), sobre a pessoa do impetrante, desde que não estejam protegidas pelo sigilo, em respeito ao disposto na parte final do art. 5º, XXXIII, da CRFB/88.

► Objeto

De acordo com a previsão constitucional, a ação é cabível para: “a) conhecimento de informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de **caráter público**; b) retificação de informações pessoais”; e, ainda, de acordo com o art. 7º, III, da Lei nº 9.507/97, para: “c) a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

► Definição de “caráter público”

A pessoa jurídica de direito privado, desde que seja de caráter público, pode ser sujeito passivo de uma ação de *habeas data*. De acordo com o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 9.507/1997, considera-se de caráter público: “... todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações”. Daí por que o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e o SERASA podem eventualmente figurar no polo passivo da ação.

Como é possível se concluir, se a natureza dos dados armazenados for privada, ou seja, não voltada ao conhecimento público, não caberá o ajuizamento da ação (como exemplo, as informações constantes no setor de recursos humanos de empresas privadas).¹¹

11 “*Habeas Data*. Illegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a revelação, à ex-empregada, do conteúdo da ficha de pessoal, por não se tratar, no caso, de registro de caráter público, nem atuar o impetrado na condição de entidade Governamental (Constituição, art. 5º, LXXII, a e art. 173, § 1º, texto original)” (STF, RE 165.304/MG; Plenário, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 19.10.2000, DJ 15.12.2000).

► Legitimidade ativa

Em razão da natureza personalíssima da ação, somente o titular do dado pode ajuizar o *habeas data*, seja pessoa natural ou jurídica, nacional ou estrangeira. Ressalte-se que, para fins de preservação da memória do *de cujus*, a jurisprudência¹² admite a impetração da ação pelos seus herdeiros.

► Polo passivo

Podem figurar no polo passivo da ação, autoridade coatora da Administração Pública, direta ou indireta, ou qualquer dos poderes ou órgãos destes. Eventualmente, responsáveis por pessoas jurídicas de direito privado de caráter público também podem compor o polo passivo da demanda.

► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais

Diante da gratuidade da ação (art. 5º, LXXVII, da CRFB/88) não se pleiteia a condenação em honorários advocatícios, tampouco em custas processuais.

► Produção de Provas

Não se pede a produção de provas, tendo em vista o procedimento especial, previsto no art. 19, da Lei 9.507/97.

► Intervenção do Ministério Público

A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é obrigatória, nos termos do art. 12 da Lei 9.507/97.

► Tutela de Urgência

Não há previsão expressa na lei de tutela de urgência em *Habeas Data*. A doutrina, no entanto, admite a concessão de tutela antecipada com fundamento no art. 300 do CPC, determinando-se, assim, a comprovação dos requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

12 TFR, HD 1-DF, DJU 02.05.1989, Seção I, p. 6.774.

► **Comprovação de recusa por parte da autoridade administrativa**

De acordo com a Súmula nº 2 do STJ: *Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.*

Nesse mesmo sentido, a Lei nº 9.507/1997, assim dispõe no parágrafo único do art. 8º: “A petição inicial deverá ser instruída com prova: I – da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; II – da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou III – da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão”.

Como a demonstração da tentativa de acesso à informação ou a sua retificação e complementação administrativa antes do ajuizamento da ação judicial é razoável e comprova o interesse de agir do impetrante, o STF entendeu que essa exigência não afronta a Constituição.¹³

► **Hipóteses de não cabimento do HD**

- Acesso a dados públicos;
- Acesso a dados sobre terceiros;
- Acesso à certidão denegada (a não ser que a banca informe que a única forma de acesso ao dado pessoal é por meio da certidão);
- Acesso a informações sobre os critérios utilizados na correção de provas de concurso/ acesso à prova/ revisão de prova;
- Acesso ao processo administrativo denegado;
- Acesso à autoria do denunciante.

► **Decisão importante do STF sobre o Habeas Data:**

“O “*habeas data*” é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação

¹³ “(...) O acesso ao *habeas data* pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no *habeas data*. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do *habeas data*” (RHD 22/DF, Min. Rel. Marco Aurélio, Plenário, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, j. 19.09.1991, DJ 1º.09.1995).

dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Essa a conclusão do Plenário, que proveu recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de o contribuinte, por meio do aludido remédio constitucional, acessar todas as anotações incluídas nos arquivos da Receita Federal, com relação a todos os tributos de qualquer natureza por ele declarados e controlados pelo Sistema Integrado de Cobrança – Sincor, ou qualquer outro, além da relação de pagamentos efetuados para a liquidação desses débitos, mediante vinculação automática ou manual, bem como a relação dos pagamentos sem liame com débitos existentes. No caso, o recorrente, ao intentar obter informações relativas às anotações constantes dos arquivos da Receita Federal, tivera o pedido negado, tendo em vista esses dados não se enquadrarem, supostamente, na hipótese de cadastro público. O Colegiado afirmou que o “*habeas data*” seria ação constitucional voltada a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela, constantes de arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas (CF, art. 5º, LXXII, a). Estaria à disposição dos cidadãos para que pudessem implementar direitos subjetivos obstaculizados, alcançáveis por meio do acesso à informação e à transmissão de dados. A sua regulamentação legal (Lei 9.507/1997) demonstraria ser de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que fossem ou que pudessem ser transmitidas a terceiros, ou que não fossem de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária dessas informações... “(STF, RE 673707/MG, rel. Min. Luiz Fux, 17.6.2015)

► *Habeas Data* e pessoa jurídica

O STJ entendeu que a ação é cabível para atender a empresa que queira obter os extratos de depósitos de FGTS efetuados junto à Caixa Econômica Federal (CEF). O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) entendia que tais dados não eram pessoais e que os bancos de dados da CEF não eram públicos, já que usados apenas por si mesma.

A empresa alegava que os depósitos eram feitos em contas de sua titularidade, apenas vinculados individualmente aos empregados para garantir o eventual recebimento futuro. O ministro Castro Meira afirmou que o *habeas data* não seria cabível no caso de um extrato comum de conta bancária, que deveria ser tratado como matéria de consumidor, não interferindo nisso o fato de a empresa detentora do dado ser ou não pública.

Porém, no caso do FGTS, a Caixa assume função estatal de gestora do fundo, conforme definido em lei, justificando a concessão do *habeas data* (REsp 1.128.739).

O próprio STJ, porém, traz precedente (REsp 929.381) em que se concedeu habeas data contra a Caixa para que fornecesse extrato bancário comum. O ministro Francisco Falcão reconheceu como correta a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) que afirmou a legitimidade passiva da empresa pública para ação de habeas data, por exercer atividade do poder público.

► Competência

A competência para julgamento do *habeas data* será fixada de acordo com a autoridade coatora, e não em virtude da natureza do ato impugnado.

A Constituição prevê a competência originária e recursal para processo e julgamento do remédio constitucional em análise para o STF¹⁴ e STJ.¹⁵

Responsável pelas Informações	Fundamento legal	Competência
– Presidente da República – Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal – Tribunal de Contas da União – PGR – STF	Art. 102, I, 'd' CRFB e art. 20, I, 'a', Lei 9.507/97.	STF
– Ministro de Estado – STJ	Art. 105, I, 'b' CRFB e art. 20, I, 'b', Lei 9.507/97.	STJ

- 14 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente: (...) d) (...) o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

II – julgar, em recurso ordinário: a) (...) o *habeas data* decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;”

- 15 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente (...)

b) o *habeas data* contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;”

Responsável pelas informações	Fundamento legal	Competência
– TRF – Juiz Federal	Art. 20, I, 'c', Lei 9.507/97.	TRF
– Autoridade federal, exceto os casos de competência dos tribunais federais.	Art. 20, I, 'd', Lei 9.507/97.	Juiz Federal
Autoridades previstas nas Constituições Estaduais.	Art. 20, I, 'e', Lei 9.507/97.	– TJ – G – Governador – P – Prefeito de Capital – S – Secretário de Estado – Mesa da Assembleia Legislativa
Competência residual	Art. 20, I, 'f', Lei 9.507/97.	Juiz Estadual (Vara Cível)

Em resumo:

De acordo com a Lei 9507/97:

Art. 20. O julgamento do habeas data compete:

I – originariamente:

a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

b) ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;

c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal;

d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado;

f) a juiz estadual, nos demais casos.

► **Caso concreto e elaboração da peça**

(OAB 2010.3)

Tício, brasileiro, casado, engenheiro, na década de setenta, participou de movimentos políticos que faziam oposição ao Governo então instituí-

do. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado, organizados por agentes federais. Após longos anos, no ano de 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo o seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório, na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Tício, inconformado, procura aconselhamentos com seu sobrinho Caio, advogado, que propõe apresentar ação judicial para acessar os dados do seu tio.

Na qualidade de advogado contratado por Tício, redija a peça cabível ao tema, observando:

- a) competência do Juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça inaugural.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça

EXM^o. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

Tício, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n^o ... e do CPF n^o ..., endereço eletrônico ..., residente e domiciliado ..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa ..., com escritório ..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. 5^o, LXXII da CRFB/88 e da Lei n^o 9507/97 vem impetrar o presente *HABEAS DATA* em face do Ministro de Estado da Defesa, com sede funcional ..., aduzindo para tanto o que abaixo se segue.

I - SÍNTESE DOS FATOS

Na década de setenta o impetrante participou de movimentos políticos que faziam oposição ao Governo então instituído. Por força de tais atividades, foi vigiado pelos agentes estatais e, em diversas ocasiões, preso para averiguações. Seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência vinculados aos órgãos de Segurança do Estado, organizados por agentes federais.

Em 2010, Tício requereu acesso à sua ficha de informações pessoais, tendo o seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas. Esse foi o último ato praticado pelo Ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório, na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, o que claramente viola a intimidade e vida privada do impetrante e fundamenta a propositura do presente *HABEAS DATA*.

II - DA PROVA DA RECUSA À INFORMAÇÃO

Conforme já narrado, o impetrante teve o seu pedido indeferido, em todas as instâncias administrativas, conforme documentação anexa, comprovando o requisito essencial para a impetração do *HABEAS DATA*, de acordo com o art. 8^o, I, da Lei 9507/97.

III - DOS FUNDAMENTOS

O art. 5^o, LXXII, da CRFB/88 dispõe que o *HABEAS DATA* é o remédio constitucional responsável pela defesa em juízo dos dados pessoais que se pretenda conhecer ou retificar.

A referida ação também encontra fundamento na Lei 9507/97 que ampliou as hipóteses de cabimento do remédio, permitindo que também seja utilizado para a complementação de dados pessoais, de acordo com o art. 7^o, III.

O direito à informação é um direito fundamental consagrado pelo texto constitucional no art. 5^o, XXXIII.

Conforme previsto no art. 5^o, X, da CRFB/88, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado, inclusive, o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A competência para julgamento do *HABEAS DATA* é fixada de acordo com a autoridade coatora. Sendo assim, por força do art. 105, I, b, da CRFB/88, tendo em vista que a autoridade coatora é o Ministro de Estado da Defesa, o foro competente para julgamento da ação é o STJ.

Também é importante ressaltar que o impetrante é o titular do dado pessoal que se pretende conhecer por meio desta, o que está em harmonia com a natureza personalíssima da ação.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a V.Exª:

- a) que seja notificada a autoridade coatora dos termos da presente a fim de que preste demais informações que julgar necessárias;
- b) a procedência do pedido de *habeas data*, para que seja assegurado ao Impetrante o acesso às informações de seu interesse;
- c) a intimação do Representante do Ministério Público;
- d) a juntada dos documentos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº ...

CAPÍTULO 4

AÇÃO POPULAR

Art 5º, CRFB/88. LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

► Histórico, natureza jurídica e conceito

A origem da ação popular está ligada à história do direito romano. Os jurisconsultos romanos denominavam *actiones populares* a ação que amparava direito próprio do povo. Era utilizada à época para a defesa de mares, rios, praças públicas e sepulturas, por exemplo.¹⁶ Durante a passagem pela sociedade feudal não houve evolução da referida ação genuína do povo, porque a simbiose cidadão-Estado não existia nesse momento da história. Já no período mais moderno ela foi acolhida pela Bélgica em 1836, pela França em 1837 e na Itália em 1859.

No Brasil, o primeiro texto constitucional que lhe deu guarida foi o de 1934, não sendo mantida em 1937 face ao autoritarismo do regime, retornando à história brasileira a partir de 1946, e a partir daí foi protegida pelas demais Constituições.

Ressalte-se que em 1988 o seu objeto foi ampliado, tendo em vista que pelos textos anteriores a proteção da ação popular era apenas dirigida ao patrimônio público das entidades federativas.

Hoje, pode-se dizer que é um remédio constitucional, de procedimento comum, colocado à disposição de qualquer cidadão para a invalidação de ato ou contrato administrativo, ilegal, ilegítimo ou ilícito e lesivo ao patrimônio público, cultural, histórico ou ambiental, com previsão constitucional e infraconstitucional de acordo com a Lei nº 4.717/1965. O ato impugnado pode ser comissivo ou omissivo.

16 AFONSO DA SILVA, José. *Ação Popular Constitucional, doutrina e processo*, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 17 a 30.

A ação popular possui natureza jurídica híbrida, pois, além de remédio constitucional em defesa dos direitos difusos, é também uma importante manifestação de direito público subjetivo político, tendo em vista que só pode ser proposta pelo cidadão.

► Espécies

AÇÃO POPULAR PREVENTIVA:	AÇÃO POPULAR REPRESSIVA:
antes de consumada a lesão	após a consumação do dano, com prazo de 5 (cinco) anos para a sua propositura, na forma do art. 21 da Lei nº 4.717/65

► Legitimidade ativa

A propositura da ação é exclusiva do cidadão, que em regra geral é o brasileiro nato ou naturalizado devidamente alistado, em gozo de seus direitos políticos. Analfabetos, maiores de setenta anos e os que estão entre dezesseis a dezoito (segundo parte da doutrina, dispensada a assistência¹⁷), desde que devidamente alistados, também poderão ajuizar a ação popular. Os inalistáveis (estrangeiros e conscritos), os inalistados e as pessoas jurídicas,¹⁸ por conseguinte, não podem ajuizar a ação. Os portugueses equiparados, desde que estejam devidamente alistados e se houver reciprocidade com os brasileiros equiparados em Portugal, poderão também apresentá-la.

Destaque-se que a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita mediante o título de eleitor, na forma do art. 1º, § 3º, da Lei nº 4.717/65.

► Polo passivo

Os arts. 1º e 6º da Lei nº 4.717/1965 determinam que todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem como pessoas naturais, beneficiárias diretas ou indiretas da lesão ao direito de todos, deverão compor o polo passivo da ação popular, ou seja, há um verdadeiro litisconsórcio passivo necessário.

17 Nesse sentido, José Afonso da Silva, Ary Florêncio Guimarães e Nelson Carneiro, em AFONSO DA SILVA, José. *Ação Popular Constitucional, doutrina e processo*, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 174/175. Em sentido contrário, Manoel Jorge e Silva Neto, *Curso de Direito Constitucional*, 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen juris, 2008, pp. 779/780.

18 *Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular* (Súmula nº 365, STF).

Com isso, temos: a) pessoas públicas ou privadas e entidades mencionadas no artigo 1º da Lei de ação popular; b) autoridades, funcionários ou administradores que tiverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato; c) aqueles que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão e os beneficiários do ato.

Atenção!

- Todos os beneficiários do ato ou contrato impugnado são litisconsortes necessários e a falta de citação é causa de nulidade absoluta do processo;
- A pessoa jurídica de direito público ou privado que figurar no polo passivo poderá: (1) contestar a ação, se entender que o ato é lícito e que o pedido não tem fundamento; (2) silenciar e atuar ao lado do autor. Se assim optar, apesar de figurar no polo passivo irá atuar como espécie de assistente simples do autor.

► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais

Por força do art. 12, da Lei 4717/65, pede-se a condenação em honorários advocatícios e em custas processuais.

► Produção de Provas

Pede-se a produção de provas, tendo em vista o rito ordinário da ação popular, previsto no art. 7º, da Lei 4717/65.

► Condições específicas

Hoje a ação popular existe para tutelar o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, de forma bem aberta. A interpretação aqui deve ser a mais ampla possível, na medida em que o objetivo do constituinte foi o de ampliar esse instrumento e de fortalecer o controle da cidadania sobre a coisa pública. Com isso, em nossa opinião não há que se falar mais da necessária comprovação do binômio lesividade e ilegalidade do ato impugnado, sendo cada um dos fundamentos da ação popular tutelados de maneira autônoma. É possível então se afirmar que um ato legal, mas que tenha ferido a moralidade administrativa possa ser impugnado em sede do rémédio constitucional.

Ressalte-se que atos de conteúdo jurisdicional não podem ser impugnados por meio de ação popular, existindo as vias recursais adequadas para seu combate.¹⁹

► O papel do Ministério Público

O Ministério Público participará de todas as ações populares na qualidade de fiscal da lei, entretanto, a Lei nº 4.717/65 ainda prevê duas outras hipóteses de participação: se o autor desistir da ação, serão publicados editais nos prazos e condições ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação (art. 9º) e, ainda: caso decorridos 60 (sessenta) dias de publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 (trinta) dias seguintes, sob pena de falta grave (art. 16).

► Tutela de Urgência

A tutela de urgência é admitida na forma do art. 5º § 4º, da Lei 4717/65 e, possui natureza ora de cautelar, ora de tutela antecipada, daí se aplicar também o art. 300, do CPC. Com isso, é importante comprovar os requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No XVIII Exame de Ordem, a banca adotou a medida cautelar em sede de Ação Popular.

► A gratuidade

De acordo com a previsão constitucional, a ação popular será gratuita se proposta de boa-fé (independente do êxito ou não na ação), sendo determinada a sua condenação se tiver sido proposta de má-fé.

19 “Os atos de conteúdo jurisdicional – precisamente por não se revestirem de caráter administrativo – estão excluídos do âmbito de incidência da ação popular, notadamente porque se acham sujeitos a um sistema específico de impugnação, quer por via recursal, quer mediante utilização de ação rescisória. (...) Tratando-se de ato de índole jurisdicional, cumpre considerar que este, ou ainda não se tornou definitivo – podendo, em tal situação, ser contestado mediante utilização dos recursos previstos na legislação processual –, ou, então, já transitou em julgado, hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito da causa, expor-se-á à possibilidade de rescisão (...)” (STF, Pet 2.018-Agr/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.08.2000, DJ 16.02.2001).

► Enunciados da súmula do STF

- Súmula 365: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.”
- Súmula 101: “O mandado de segurança não substitui a ação popular.”

► Competência

A fixação da competência para julgamento da ação popular, na forma do art. 5º, *caput*, da Lei nº 4.717/65 levará em consideração o local de origem do ato ou omissão a serem impugnados. Normalmente, se o patrimônio lesado for da União, a competência será da Justiça Federal, se estadual ou municipal, será da Justiça Estadual.

Não há prerrogativa de foro funcional na Ação Popular!

O art. 109, I, da CRFB/88 dispõe que: compete à justiça federal julgar as ações em que esteja no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. As outras pessoas integrantes da administração pública não deslocam competência para a justiça federal. Então, nas ações contra estados, municípios e Sociedades de economia mista (mesmo que federal), a competência é da justiça estadual.

Exemplos:

União, Autarquia, Empresa Pública e Fundação Pública Federal	Estados, DF, Municípios, suas autarquias e fundações públicas	Sociedades de Economia Mista
Juiz Federal de 1º grau.	Juiz Estadual de 1º grau – Vara de Fazenda Pública, pois são pessoas jurídicas de direito público.	Juiz Estadual de 1º grau – Vara Cível (residual).

Importante ressaltar que em regra geral não há competência originária de órgão colegiado para apreciação de ação popular,²⁰ sendo esta do

20 “A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com

juiz de primeiro grau (federal ou estadual). Haverá, entretanto, competência originária do STF,²¹ nos seguintes casos:

- a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, “n” da CRFB/88);
- as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta (art. 102, I, “f” da CRFB/88).

base na letra n do inciso I, segunda parte, do art. 102 da Constituição Federal” (STF, AO 859-QO/AP; Min. Rel. Ellen Gracie; Plenário, Rel. p/ o ac. Min. Maurício Corrêa, j. 11.10.2001, DJ 1ª.08.2003). Nesse sentido, “O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União” (STF, Pet 2.018-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.08.2000, DJ 16.02.2001).

- 21 Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC nº 45/2004): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal – com as únicas ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro –, jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irroque a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual – a exemplo do Presidente da República – ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na esfera cível – como sucede no mandado de segurança – ou na esfera penal – como ocorre na ação penal originária ou no *habeas corpus* – estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição, com a EC nº 45/04, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiados e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular” (STF, Pet 3.674-QO/DF; Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04.10.2006, DJ 19.12.2006).

► Caso concreto e elaboração da peça**(OAB – VI EXAME)**

Esculápio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na capital do Estado de WYK, é comunicado por amigos que a Administração do Estado está providenciando um plano de obras custosas e pretendendo que elas sejam entregues, independentemente de licitação, a empresas com vínculos pessoais com dirigentes do seu partido político. Os valores correspondentes às obras são incluídos no orçamento, observado o devido processo legislativo. Quando da realização das obras, aduz a necessidade de urgência diante de evento artístico de grande repercussão a realizar-se em aproximadamente um ano, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório e designa três empresas para repartir as verbas orçamentárias, cabendo a cada uma realizar parte da obra preconizada. As empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. aceitam, de bom grado, o encargo e assinam os contratos com a Administração. O valor das obras corresponde a um bilhão de reais. Inconformado com esse fato, Esculápio da Silva, cidadão que gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública e está em dia com seus direitos políticos, procura orientação jurídica e, após, resolve ajuizar a competente ação.

Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível, observando:

- a) competência do juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) os requisitos formais da peça;
- e) tutela de urgência.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^o. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA... VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO WYK

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

Esculápio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº... e do CPF nº... endereço eletrônico... portador do título de eleitor nº..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, com escritório... endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. 5º, LXXII da CRFB/88 e da Lei nº 4717/65, vem ajuizar AÇÃO POPULAR em face do Governador do Estado WYK, do Estado WYK, Mastodonte S.A, Mamute S.A e Dente de Sabre S.A., com endereços...

I – SÍNTESE DOS FATOS

O autor foi comunicado por amigos que a Administração do Estado está providenciando um plano de obras custosas e pretendendo que elas sejam entregues, independentemente de licitação, a empresas com vínculos pessoais com dirigentes do seu partido político.

Quando da realização das obras, a Administração aduz a necessidade de urgência diante de evento artístico de grande repercussão a realizar-se em aproximadamente um ano, o que inviabilizaria a realização de procedimento licitatório e designa três empresas para repartir as verbas orçamentárias, cabendo a cada uma realizar parte da obra preconizada.

As empresas Mastodonte S.A., Mamute S.A. e Dente de Sabre S.A. aceitam o encargo e assinam os contratos irregulares com a Administração. O valor das obras corresponde a um bilhão de reais, numa clara violação ao erário, o que justifica a apresentação da presente ação popular.

II – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência na Ação Popular está presente no art. 5º, § 4º, da Lei 4717/65 e também no art. 300 do CPC e, para alguns autores possui natureza de medida cautelar.

Demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III – LEGITIMIDADE ATIVA

O autor gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública e está em dia com seus direitos políticos, conforme documentação anexa, portanto, satisfaz plenamente o requisito da cidadania, presente no art. 1º, § 3º da lei 4717/65.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

O polo passivo da Ação Popular é formado por um litisconsórcio passivo necessário, conforme estabelece os arts. 1º e 6º da lei 4717/65, daí porque todas as autoridades e empresas envolvidas e indicadas acima devem responder à presente ação.

V – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O Art. 5º, LXXIII, da CRFB/88 prevê que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de enti-

dade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A referida ação também se encontra regulamentada na Lei 4717/65 e é um importante instrumento em defesa dos direitos difusos.

A licitação é a regra da transparência administrativa e a sua obrigatoriedade está prevista no art. 37, XXI, da CRFB/88, que assim dispõe: "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

A necessidade de procedimento licitatório está em harmonia com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem nortear toda a Administração Pública, segundo dispõe o art. 37, *caput* da CRFB/88.

Além do que, os contratos ora impugnados são lesivos ao patrimônio do Estado e ilegais, tendo em vista que a Constituição e a Lei 8.666/93 determinam a obrigatoriedade da licitação, salvo nas hipóteses legais, que não se aplicam ao caso ora apresentado.

VI - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

- a) a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato impugnado;
- b) que seja julgado procedente o pedido para a invalidação do contrato irregular;
- c) a citação dos réus nos endereços acima indicados;
- d) a intimação do Representante do Ministério Público;
- e) a condenação do Réu em custas e em honorários advocatícios;
- f) a produção de todos os meios de provas em direito admitidas;
- g) a juntada de documentos.

Em cumprimento ao art. 319, VII do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação.

Dá-se à causa o valor de um bilhão de reais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado

OAB nº ...

► Caso Concreto XVIII Exame

Após receber “denúncia de irregularidades” em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, que possui sede no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal determina a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos. Neste âmbito, são colhidas provas robustas de superfaturamento e fraude nos quatro últimos contratos celebrados por esta Autarquia Federal, sendo certo que estes fatos e grande parte destas provas acabaram divulgados na imprensa. Assim é que o cidadão Pedro da Silva, indignado, procura se inteirar mais sobre o acontecido, e acaba ficando ciente de que estes contratos foram realizados nos últimos 2 (dois) anos com a multinacional M e ainda estão em fase de execução. Mas não só. Pedro obtém, também, documentos que comprovam, mais ainda, a fraude e a lesão, além de evidenciarem a participação do presidente da Autarquia A, de um Ministro de Estado e do presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M. Diante deste quadro, Pedro, eleitor regular e ativo do Município do Rio de Janeiro/RJ, indignado com o descaso pela moralidade administrativa na gestão do dinheiro público, pretende mover ação judicial em face dos envolvidos nos escândalos citados, objetivando desfazer os atos ilegais, com a restituição à Administração dos gastos indevidos, bem como a sustação imediata dos atos lesivos ao patrimônio público.

Na condição de advogado (a) contratado (a) por Pedro, considerando os dados acima, elabore a medida judicial cabível, utilizando-se do instrumento constitucional adequado. (Valor: 5,00).

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não será pontuada.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^o. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA... VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

Pedro da Silva, nacionalidade, estado civil (ou existência de união estável), profissão, portador do RG nº... e do CPF nº..., endereço eletrônico..., portador do título de eleitor nº..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. 5º, LXXIII da CRFB/88 e da Lei nº 4717/65, vem ajuizar AÇÃO POPULAR em face da Autarquia Federal A, do Presidente da Autarquia Federal A, do Ministro de Estado, do Presidente da Comissão de Licitação, da Multinacional M e do Diretor Executivo da Multinacional M, com endereços:

I - SÍNTESE DOS FATOS

O autor teve acesso, depois de divulgação pela imprensa, a documentos que comprovam fraude e lesão aos cofres públicos, tendo o Ministério Público Federal determinado a abertura de inquérito civil e penal para apurar os fatos.

Havia uma denúncia de irregularidades em contratos administrativos celebrados pela Autarquia Federal A, e, inclusive, provas robustas de superfaturamento e fraude nos quatro últimos contratos celebrados pela mesma, nos últimos dois anos, com a multinacional M, que ainda se encontram em fase de execução.

Ademais, diversos documentos evidenciam a participação do Presidente da Autarquia A, de um Ministro de Estado e do Presidente da comissão de licitação, bem como do diretor executivo da multinacional M.

II - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência na Ação Popular está presente no art. 5º, § 4º, da Lei 4717/65 e também no art. 300 do CPC. Para muitos doutrinadores, trata-se de uma verdadeira cautelar.

Demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III - LEGITIMIDADE ATIVA

O autor gosta de participar ativamente da defesa da Administração Pública e está em dia com seus direitos políticos, conforme documentação anexa, portanto, satisfaz plenamente o requisito da cidadania, presente no art. 1º, § 3º da lei 4717/65.

IV - LEGITIMIDADE PASSIVA

O polo passivo da Ação Popular é formado por um litisconsórcio passivo necessário, conforme estabelece os arts. 1º e 6º da lei 4717/65, daí porque todas as autoridades e empresas envolvidas e indicadas acima devem responder à presente ação.

V - FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O art. 5º, LXXIII, da CRFB/88 prevê que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de enti-

dade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A referida ação também se encontra regulamentada na Lei 4717/65 e é um importante instrumento em defesa dos direitos difusos.

Os contratos firmados, em razão do superfaturamento, afrontam a moralidade administrativa e a legalidade, apresentando grande lesividade para o patrimônio público, conforme art. 3º e art. 4º, III, c, ambos da Lei nº. 4.717/65.

Dessa forma, a presente ação tem como objeto a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, conforme art. 5º, LXXIII, da CRFB/88 e art. 1º da Lei nº. 4.717/65.

VI - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

- a) a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos contratos administrativos superfaturados;
- b) que seja julgado procedente o pedido para a declaração de nulidade dos contratos administrativos superfaturados;
- c) a citação dos réus nos endereços acima indicados;
- d) a intimação do Representante do Ministério Público;
- e) a condenação do Réu em custas e em honorários advocatícios;
- f) a produção de todos os meios de provas em direito admitidas;
- g) a juntada de documentos;
- h) a condenação dos responsáveis ao ressarcimento dos danos causados.

Em cumprimento ao art. 319, VII, do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou de mediação.

Dá-se à causa o valor de mil de reais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado

OAB nº ...

CAPÍTULO 5

HABEAS CORPUS

Art. 5º, CRFB/88. LXVIII – conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

► Histórico, natureza jurídica e conceito

Historicamente, foi a primeira garantia de direito fundamental, concedida pelo Rei João Sem-Terra (Inglaterra), na Magna Carta de 1215 e formalizada pelo *Habeas Corpus Act* em 1679. No Brasil, Dom Pedro I emitiu, em 1821, um Alvará, consagrando a liberdade de locomoção. Em 1830, a garantia passou a ser chamada de *Habeas Corpus* e só era utilizada pelo Código Criminal, sendo consagrada em sede constitucional a partir de 1891 e mantida a partir daí em todos os demais textos constitucionais, com a exceção do período ditatorial, pois o A-I 5 de 13 de dezembro de 1968 suspendeu a garantia de *habeas corpus* nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular (art. 10).

O *Habeas Corpus* tem natureza jurídica híbrida, pois é uma ação penal popular (art. 5º, LXVIII da CRFB/88) e ainda é uma ação penal não condenatória (arts. 647 e ss. do CPP). É um remédio constitucional dirigido à tutela da liberdade de locomoção, ameaçada ou lesada em decorrência de violência ou coação eivada de ilegalidade – ato comissivo ou omissivo contrário à lei – ou abuso de poder. Em sede penal, também é utilizado para trancar um inquérito policial ou uma ação penal em face de ato atípico ou ilegal.

Para que seja cabível o remédio deve haver ao menos ameaça ao direito de locomoção do paciente. Assim, quando não houver risco ao direito ambulatorial, não será cabível a impetração do *habeas corpus*.

Além disso, a ação de *habeas corpus* demanda prova pré-constituída, ou seja, deve estar de plano demonstrada a privação da liberdade ou o risco de privação da liberdade. A questão de mérito a ser enfrentada é se a restrição ao direito de ir e vir do paciente decorreu de conduta ilegal ou abusiva.

Em razão da importante tutela da liberdade de locomoção, o *habeas corpus* tem prioridade de julgamento sobre todos os demais remédios constitucionais!

► Espécies

HC preventivo	HC repressivo, suspensivo ou liberatório
para evitar a consumação da lesão à liberdade de locomoção, hipótese na qual é concedido o “salvo-conduto”;	é utilizado com o propósito de liberar o paciente quando já consumada a coação à sua liberdade de locomoção. O pedido é o alvará de soltura.

► Legitimidade ativa

Em nome do princípio da universalidade, qualquer pessoa natural,²² nacional ou estrangeira,²³ em favor de si ou de outra pessoa, ou pessoa jurídica, em favor de pessoa natural, poderá ajuizar a ação. O Ministério Público também poderá apresentar a ação (art. 654, CPP) e o próprio juiz ou Tribunal, verificada a ilegalidade da prisão, poderá conceder o *habeas corpus* de ofício.

22 STF, HC nº 86.307/SP, Primeira Turma, j. 17.11.2005 “A ação de *habeas corpus* pode ser ajuizada por qualquer pessoa, independente de sua qualificação profissional. Não é exigível linguagem técnico-jurídica. Entretanto, o *habeas corpus* não pode servir de instrumento para ataques às instituições (Rel. Min. Carlos Britto, DJ 26.05.2006) e ainda “O Código de Processo Penal, em consonância com o texto constitucional de 1988, prestigia o caráter popular do *habeas corpus* ao admitir a impetração por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. Assim não é de se exigir habilitação legal para impetração originária do writ ou para interposição do respectivo recurso ordinário”(STF, HC nº 80.744/MG, Segunda Turma, j. 27.03.2001, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 28.06.2002).

23 “Inquestionável o direito de súditos estrangeiros ajuizarem, em causa própria, a ação de *habeas corpus*, eis que esse remédio constitucional – por qualificar-se como verdadeira ação popular – pode ser utilizado por qualquer pessoa, independentemente da condição jurídica resultante de sua origem nacional” (STF, HC nº 72.391 QO/DF, Plenário, j. 08.03.1995, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.03.1995).

Não é necessária a capacidade postulatória do advogado (é o único dos remédios constitucionais judiciais que a dispensa), sendo vedada, entretanto, a petição apócrifa (sem assinatura) ou em língua estrangeira.

► **Gratuidade**

O *habeas corpus* é uma ação gratuita, de acordo com o art. 5º, LXXVII da CRFB/88. Portanto, não há recolhimento de custas ou condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. No entanto, como se trata da ação judicial, é necessário indicar valor da causa na petição inicial, o que não guarda relação com o caráter gratuito da ação.

► **O paciente**

O paciente é quem está ameaçado ou já foi lesionado no seu direito de locomoção, em nome de quem se postula a ordem. Poderá, inclusive, ajuizar a ação para salvaguardar a própria liberdade.

► **Polo passivo**

A ação é dirigida contra a autoridade coatora, que é normalmente juiz, promotor, delegado de polícia, Tribunal etc. No entanto a jurisprudência dominante já admite o HC contra ato de particular. Hipóteses: clínicas médicas, abrigos, manicômios.

Existe ainda a concessão do *habeas corpus* de ofício, ainda que o pedido original não possa ser conhecido. Neste caso o Poder Judiciário pode atuar no tocante à extensão da ordem, deferindo a quem ou além do pedido.

► **Tutela de Urgência**

Como o HC é uma ação impugnativa autônoma admite concessão de liminar. O fundamento está nos arts. 649 e 660, § 2º do CPP. Possui natureza cautelar e por isso devem ser comprovados os requisitos: *periculum in mora* e *fumus boni iuris* ou ainda probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

► **Habeas corpus e prisão do militar**

De acordo com o art. 142, § 2º, da CRFB/88, não seria inicialmente cabível a utilização do remédio em sede de punições disciplinares militares, entretanto são necessários alguns esclarecimentos.

A vedação à utilização do remédio em sede militar diz respeito à análise do mérito da prisão. De acordo com o art. 5º, XXXV, da Constituição não se pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito. Com isso, prisões disciplinares ilegais (com vício de competência, forma, devido processo legal) podem e devem ser questionadas por meio de *habeas corpus*, segundo entendimento do próprio STF.²⁴

► **Habeas corpus e Comissão Parlamentar de Inquérito**

Como a CPI coletará provas para uma possível ação penal a ser ajuizada, conforme o caso, pelo Ministério Público, o STF tem entendido que o *Habeas Corpus* é o remédio adequado para: permitir que o investigado seja ouvido na qualidade de testemunha (o magistrado, por exemplo); permitir que o investigado ou a testemunha seja assistido por advogado durante a audiência da CPI e, também, para garantir que a testemunha não seja obrigada a assinar o compromisso de somente dizer a verdade.

► **Produção de Provas**

Não se pede a produção de provas, tendo em vista o rito sumário do HC que não admite a dilação probatória.

► **Hipóteses de não cabimento do Habeas corpus**

Como o remédio não pode ser utilizado em qualquer situação, transcrevemos abaixo entendimentos sumulados do STF em que não se afigura possível a sua utilização:

- **Súmula nº 693:** Não cabe *habeas corpus* contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.
- **Súmula nº 694:** Não cabe *habeas corpus* contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.
- **Súmula nº 695:** Não cabe *habeas corpus* quando já extinta a pena privativa de liberdade.

24 STF, HC nº 70.648-7/RJ, Rel. Min. Moreira Alves. Primeira Turma, j. 09.11.1993. DJ 04.03.1994.

► Competência

A competência para processar e julgar o *habeas corpus* é definida tanto pela autoridade coatora como pela qualidade do paciente e, além disso, a relação hierárquica também é importante critério de fixação de competência. Senão vejamos:

STF – art. 102, I, 'd' e 'f', da CRFB:	
quando for paciente:	– Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (ressalvado o disposto no art. 52, I), membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente; – autoridade ou funcionário com foro especial junto ao STF.
quando for autoridade coatora:	– Tribunal Superior (STJ, TSE, TSM); – autoridade ou funcionário com foro especial junto ao STF.
quando o HC se referir a crime de competência originária do STF	

STJ – art. 105, I, 'c', da CRFB:	
quando for paciente:	– autoridades que tenham foro especial junto ao STJ (nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais);
quando for autoridade coatora:	– autoridades que tenham foro especial junto ao STJ (nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais); – Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (ressalvado o disposto no art. 52, I); – Tribunal sujeito a jurisdição do STJ.

Atenção!!

Se pacientes	Se coatores
competência do STF para julgar o HC	competência do STJ para julgar o HC
– Ministros de Estado; – Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; – Membros do MPU que oficiem perante tribunais: MP Militar, MP Trabalho, MP Federal e MP DF. Se for membro do Ministério Público Estadual que officie perante tribunais, no caso os Procuradores de Justiça, a competência será do TJ ao qual esteja vinculado.	

TRF e TJ, por equiparação: art. 108, I, 'd', CRFB
• quando o coator for juiz federal (TRF) ou juiz estadual (TJ). • membros do MPF e do MPE (apesar da inexistência de previsão legal expressa). Todo HC parte de uma premissa – de que foi praticada ilegalidade ou arbitrariedade. Assim, se está sendo imputada ilegalidade ao membro do MP, é necessário que o HC seja julgado pela autoridade no qual possui foro especial. • No caso do JECRIM – seja a autoridade coatora juiz ou promotor – o HC será apreciado pela Turma Recursal. • O HC ou MS impetrado contra ato da Turma Recursal será julgado ao TJ ou TRF. Os juizes da Turma Recursal continuam a ser juizes de 1º grau.

Importante destacar que foi cancelada a Súmula nº 690 do STF, que dizia: *Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais*”. Concluiu a Corte que a competência para julgamento desse habeas corpus seria do Tribunal de Justiça local, e não sua.

► **Caso concreto e elaboração da peça**

(30º Exame de Ordem)

Maria adquiriu um veículo popular por meio de contrato de arrendamento mercantil (leasing), em 60 prestações de R\$ 800,00. A partir da 24.ª prestação, Maria começou a ter dificuldades financeiras e resolveu vender o veículo a Pedro, o qual se comprometeu a pagar as prestações vincendas e vencidas. Tal fato não foi comunicado ao agente financeiro, já que havia o risco de o valor da prestação ser majorado. Pedro deixou de pagar mais de cinco prestações, o que suscitaria rescisão contratual. O agente financeiro houve por bem propor ação de busca e apreensão do veículo, tenta-

tiva essa que restou frustrada em face de Maria não possuir o veículo em seu poder, já que o alienara a Pedro. O agente financeiro pediu a transformação, nos mesmos autos, da ação de busca e apreensão em ação de depósito e requereu a prisão de Maria, por ser depositária infiel do referido veículo. O juiz competente determinou a prisão civil de Maria até que ela devolvesse o referido veículo ou pagasse as prestações em atraso. Maria não tem mais o veículo em seu poder e perdeu o seu emprego em virtude da prisão civil. Dois dias depois da efetivação da prisão, o advogado contratado interpôs, inicialmente, recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão judicial, o qual não foi conhecido pelo tribunal, diante da ausência de documento imprescindível ao seu processamento. Ingressou com ação de rito ordinário contra Pedro, com pedido de tutela antecipada, visando receber as prestações em atraso, ação essa que foi extinta sem julgamento de mérito. Ingressou, ainda, com ação de rito ordinário contra o arrendador discutindo algumas cláusulas do contrato de arrendamento, ação essa que continua em curso, sem sentença. Maria continua presa. Por ter perdido a confiança nesse advogado, ao qual pagou os honorários devidos e do qual recebeu o devido substabelecimento, sem reservas de poderes, Maria resolveu contratar os serviços de outro advogado. Diante da situação hipotética apresentada, na condição de atual advogado de Maria, redija um texto que contenha a peça judicial mais apropriada ao caso, a ser apresentada ao órgão judicial competente, com os argumentos que reputar pertinentes.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXMº SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO...

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

MARIA, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., profissão..., portadora do RG nº... e do CPF nº..., endereço eletrônico..., residente e domiciliada..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CRFB/88 e no art. 647 do CPP, vem impetrar a presente ordem de *HABEAS CORPUS* REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR em favor da própria liberdade, que está cerceada por decisão judicial... pelos motivos que a seguir expõe:

I – DOS FATOS

Maria adquiriu um veículo popular por meio de contrato de arrendamento mercantil (leasing), em 60 prestações de R\$ 800,00. A partir da 24.ª prestação, a imputante começou a ter dificuldades financeiras e resolveu vender o veículo a Pedro, o qual se comprometeu a pagar as prestações vincendas e vencidas. Tal fato não foi comunicado ao agente financeiro, já que havia o risco de o valor da prestação ser majorado. Pedro deixou de pagar mais de cinco prestações, o que suscitaria rescisão contratual.

O agente financeiro houve por bem propor ação de busca e apreensão do veículo, tentativa essa que restou frustrada em face de Maria não possuir o veículo em seu poder, já que o alienara a Pedro. Pediu, então, a transformação, nos mesmos autos, da ação de busca e apreensão em ação de depósito e requereu a prisão de Maria, por ser depositária infiel do referido veículo. A autoridade coatora determinou a prisão civil de Maria até que ela devolvesse o referido veículo ou pagasse as prestações em atraso.

Como se demonstrará a seguir, a prisão do depositário infiel é ilegal, ensejando a propositura do presente *Habeas Corpus*.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

O fundamento da tutela de urgência em sede de *Habeas Corpus* é extraído dos arts. 649 e 660, § 2º do CPP e possui natureza cautelar.

O *fumus boni iuris* é comprovado de acordo com os fatos e provas que instruem o presente remédio.

Já o *periculum in mora* encontra respaldo na violação ao direito fundamental de ir e vir de Maria diante da prisão manifestamente ilegal.

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acordo com o art. 5º, LXVIII, da CRFB/88 será concedido *habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O remédio também é respaldado pela legislação processual penal, a partir do art. 647.

O art. 5º, XV, da CRFB/88 dispõe que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Em 2008, o STF decidiu que o Pacto de San José da Costa Rica possui natureza supralegal e que revogou a legislação ordinária que versava sobre o tema, restando não aplicável a disposição do art. 5º, LXVII, da CRFB/88.

De mais a mais, a Súmula Vinculante 25 proíbe a referida prisão: "É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito".

IV - DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer a V. Exª. que:

- a) Determine a notificação da autoridade coatora;
- b) Conceda o pedido liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, confirmando posteriormente a concessão do presente remédio;
- c) Junte os documentos anexos;
- d) Intime o representante do Ministério Público.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

MANDADO DE SEGURANÇA

Art. 5º, CRFB/88. LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

- a) partido político com representação no Congresso Nacional;
- b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”.

► Histórico, natureza jurídica e conceito

Constitucionalmente, o mandado de segurança individual foi acolhido pelo Direito brasileiro em 1934, fruto da evolução da doutrina brasileira do *habeas corpus*, com inspiração no recurso de amparo mexicano. O remédio permaneceu ao longo das demais Constituições brasileiras, exceto na de 1937, em face do autoritarismo do regime. A ação, na sua modalidade coletiva, é produto da Constituição de 1988.

O *mandamus* é recoberto de natureza jurídica mista, pois é ao mesmo tempo um remédio constitucional e, em seu aspecto processual, é uma ação cível de procedimento especial, pois não se admite a dilação probatória e deve ser instruída por meio de prova pré-constituída.

Dirige-se à tutela de direito individual e coletivo, líquido e certo, não amparável por nenhum dos demais remédios constitucionais, diante de sua natureza residual, que esteja sendo ameaçado ou lesado em decorrên-

cia de ato de autoridade pública ou agente delegado, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Encontra respaldo legal no art. 5º, LXIX e LXX, da CRFB/88 e na Lei nº 12.016/2009.

► Celeridade

A **celeridade** é a principal característica do rito do MS. O art. 20 da Lei 12.016/09 prevê que:

Art. 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus.

§ 1º Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator.

§ 2º O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder de 5 (cinco) dias.

► Modalidades

- **MS Individual** (art. 5º, LXIX): O impetrante é o titular do direito líquido e certo, como por exemplo: a pessoa natural, os órgãos públicos, as universalidades de bens (espólio, massa falida etc.), a pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, domiciliada no Brasil ou no exterior²⁵. Também pode ser utilizado por Mesas do Con-

25 “A legitimidade *ad causam* no mandado de segurança pressupõe que o impetrante se afirme titular de um direito subjetivo próprio, violado ou ameaçado por ato de autoridade; no entanto, segundo assentado pela doutrina mais autorizada (cf. Jellinek, Malberg, Duguit, Dabin, Santi Romano), entre os direitos públicos subjetivos, incluem-se os chamados direitos-função, que têm por objeto a posse e o exercício da função pública pelo titular que a detenha, em toda a extensão das competências e prerrogativas que a substantivem: incensurável, pois, a jurisprudência brasileira, quando reconhece a legitimação do titular de uma função pública para requerer segurança contra ato do detentor de outra, tendente a obstar ou usurpar o exercício da integridade de seus poderes ou competências: a solução negativa importaria em ‘subtrair da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito’. A jurisprudência – com amplo respaldo doutrinário (v.g., Victor Nunes, Meirelles, Buzaid) – tem reconhecido a capacidade ou ‘personalidade judiciária’ de órgãos coletivos não personalizados e a propriedade do mandado de segurança para a defesa do exercício de suas compe-

gresso, do Senado, da Câmara dos Deputados, Presidências dos Tribunais, Chefias do Poder Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

- **MS Coletivo** (art. 5º, LXX): O Mandado de Segurança Coletivo pode ser impetrado por:
 - a) partido político com representação no Congresso Nacional, ainda que o partido esteja representado em apenas uma das Casas Legislativas, não se exigindo a pertinência com os interesses de seus membros, tendo em vista a sua importância para assegurar o sistema representativo adotado pelo país,²⁶ e
 - b) organização sindical, entidade de classe e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O requisito de um ano em funcionamento hoje só é exigido para as associações, com o intuito de evitar que sejam criadas apenas para a im-

tências e do gozo de suas prerrogativas. Não obstante despidido de personalidade jurídica, porque é órgão ou complexo de órgãos estatais, a capacidade ou personalidade judiciária do Ministério lhe é inerente – porque instrumento essencial de sua atuação – e não se pode dissolver na personalidade jurídica do estado, tanto que a ele frequentemente se contrapõe em juízo; se, para a defesa de suas atribuições finalísticas, os tribunais têm assentado o cabimento do mandado de segurança, este igualmente deve ser posto a serviço da salvaguarda dos predicados da autonomia e da independência do Ministério Público, que constituem, na Constituição, meios necessários ao bom desempenho de suas funções institucionais. Legitimação do Procurador-Geral da República e admissibilidade do mandado de segurança reconhecidas, no caso, por unanimidade de votos” (STF, MS 21.239/DF, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 05.06.1991, DJ 23.04.1993). Nesse sentido também: “Ao estrangeiro, residente no exterior, também é assegurado o direito de impetrar mandado de segurança, como decorre da interpretação sistemática dos arts. 153, *caput*, da Emenda Constitucional de 1969 e do 5º, LXIX da Constituição atual. Recurso extraordinário não conhecido” (STF, RE 215.267/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. 24.04.2001, DJ 25.05.2001).

- 26 Com algumas restrições, como exemplo: “Uma exigência tributária configura interesse de grupo ou classe de pessoas, só podendo ser impugnada por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Precedente: RE 213.631, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07.04.2000. O partido político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, impugnar majoração de tributo” (STF, RE 196.184/AM, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. 27.10.2004, DJ 18.02.2005).

petração do remédio.²⁷ Ademais, segundo jurisprudência consolidada, como se trata de substituição processual (os legitimados defendem em nome próprio interesses alheios), não há necessidade de autorização expressa de cada um dos associados.²⁸

► Espécies

MS preventivo	MS repressivo
quando há ameaça de lesão	quando a lesão já ocorreu. Nesse caso, deve ser obedecido o prazo decadencial de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato que se deseja impugnar, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Por ser decadencial, esse prazo não se interrompe ou suspende, nem mesmo por pedido de reconsideração formulado na via administrativa (Súmula 430 STF)

O **MS preventivo** em regra será considerado **declaratório**, limitando-se a afirmar o juiz que assiste razão ao Impetrante, que não poderá ter seu direito ofendido.

Ex.: Fábio quer se inscrever em concurso, e no edital há previsão que tem que apresentar diploma, que ele ainda não tem, no momento da inscrição no concurso, o que é vedado pela súmula 266 do STJ. O MS será preventivo, porque ainda não houve lesão ao direito do Impetrante (ainda não houve recusa da inscrição). O juiz irá declarar que o Impetrante tem o direito de se inscrever sem apresentar o documento naquele momento.

27 “Legitimidade do sindicato para a impetração de mandado de segurança coletivo independentemente da comprovação de um ano de constituição e funcionamento” (STF, RE 198.919/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 15.06.1999, DJ 24.09.1999).

28 “O inciso LXX do art. 5º da Constituição Federal encerra o instituto da substituição processual, distanciando-se da hipótese do inciso XXI, no que surge no âmbito da representação. As entidades e pessoas jurídicas nele mencionadas atuam, em nome próprio, na defesa de interesses que se irradiam, encontrando-se no patrimônio de pessoas diversas. Descabe a exigência de demonstração do credenciamento” (STF, RMS 21.514/DF; Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.1993, DJ 18.06.1993.) Nesse sentido: “A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5º, LXX. Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação” (STF, RE 193.382/SP; Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 28.06.1996, DJ 20.09.1996).

O mesmo fundamento – súmula 266 do STJ – pode ser utilizado em **MS repressivo**, em que o juiz deve proferir sentença **desconstitutiva**. Ex.: Matheus que passou pela fase preliminar do concurso e antes da 2ª fase, é eliminado do certame por não ter apresentado o diploma. Como já houve decisão da Comissão de Concurso eliminando o candidato, o MS será repressivo. Não basta assim que a sentença seja declaratória, deverá o juiz proferir sentença desconstituindo o ato ilegal.

► Condições específicas. Natureza residual do instituto

De acordo com a previsão constitucional, o mandado de segurança é cabível quando não houver outro meio capaz de defender o direito violado, dada a sua natureza residual. Pode ser impetrado em face de ato comissivo ou omissivo do Poder Público, ou de agente delegado de serviço público, desde que não haja outro remédio especial para a proteção ao direito.

A Constituição faz menção ainda a direito líquido e certo, expressão que sofre crítica pertinente de Hely Lopes Meirelles²⁹:

“a atual expressão direito líquido e certo substituiu a precedente, da legislação criadora do mandado de segurança, direito certo e inconteste. Nenhuma satisfaz. Ambas são impróprias e de significação equivocada. (...) O direito, quando existente, é sempre líquido e certo; os fatos é que podem ser imprecisos e incertos, exigindo comprovação a esclarecimentos para propiciar a aplicação do direito invocado pelo postulante. Então, para o autor, o direito líquido e certo... é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Além das condições de ação genéricas (legitimidade das partes, interesse de agir e pedido juridicamente possível), para que possa se valer do MS é necessário atender também a outros requisitos:

1) **Não ser caso de nenhum dos demais remédios constitucionais** – O que demonstra o caráter residual do MS.

29 MEIRELLES, Hely Lopes. *Mandado de Segurança...*, 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 13.

2) Direito líquido e certo – comprovado por meio de prova pré-constituída (em regra, documental).

Importante! A complexidade da matéria jurídica não impede a utilização do MS, nos termos da súmula 625 do STF.

3) Ato coator – É ato ou omissão de autoridade pública (ato praticado ou omitido por pessoa investida de parcela de poder público), eivado de ilegalidade ou abuso de poder. As expressões “ilegalidade ou abuso de poder” estão previstas na CRFB, no art. 5º, LXIX, mas é certo que ilegalidade é gênero, e abuso de poder é espécie. Isso porque os elementos do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) devem todos ser respeitados, sob pena de ilegalidade, e abuso de poder pode ser vício de competência (excesso de poder) ou de finalidade (desvio de finalidade).

Importante! Não é possível a utilização do MS preventivo para questionar lei em tese (súmula 266 do STF).

4) Tempestividade – caso se trate de MS repressivo.

► Polo passivo

Pode ser sujeito passivo da ação de mandado de segurança, autoridade coatora ou quem lhe faça às vezes, como é o caso do agente delegado no exercício da função pública. Autoridade coatora deve ser entendida como a que possui poder de decisão na esfera administrativa sob a sua competência e não a pessoa que executa ordens superiores. De outra parte, podemos entender que agente delegado é quem está executando um serviço público por meio de uma das modalidades permitidas pelo ordenamento jurídico (na forma do art. 175 da CRFB/88, permissionárias ou concessionárias de serviços públicos, por exemplo).

Numa interpretação ampliativa do dispositivo seria possível defender a possibilidade de impetração de mandado de segurança em face de ilegalidade cometida por diretor de estabelecimento particular de ensino, que embora pertencente à iniciativa privada, exerce serviço público constitucionalmente amparado (educação).

A autoridade coatora deve ser quem praticou o ato ou quem tenha poderes para corrigir o ato. O art. 6º, § 3º, da Lei do MS prevê que “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Ato praticado por delegação → O art. 5º, inciso LXIX da CRFB prevê que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A lei 12.016/09, no art. 1º, § 1º também prevê expressamente:

§ 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

A súmula 510 também diz respeito ao ato coator:

Súmula 510 STF – “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

Ou seja, se o ato coator for praticado por pessoa natural ou jurídica no exercício de atribuições do poder público, é essa pessoa que será a autoridade coatora, e não o ente da federação que delegou os poderes.

Na prova da segunda fase, indicamos no polo passivo do mandado de segurança a autoridade coatora e a pessoa jurídica a que esta integra, na forma do art. 6º, da Lei 12.016/09. Ex.: Governador do Estado X e Estado X; Diretor da Empresa Pública Y e Empresa Pública Y.

► Da prova

A peça inicial do mandado de segurança deverá ser instruída com provas pré-constituídas, pois não se admite a dilação probatória. Com isso, os documentos que lastreiam a prova da pretensão deverão ser apresentados de plano pelo impetrante, ressaltando-se o caso de solicitação ao juiz da causa que determine à autoridade coatora ou a alguma repartição pública que ofereçam documentos que estejam sob o seu poder, conforme dispõe o art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

► Mandado de segurança e processo legislativo inconstitucional

A jurisprudência do STF tem permitido a utilização do remédio constitucional em apreço para coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas que não estejam em harmonia com o processo legislativo constitucional, desde que a ação seja proposta por parlamentar, tendo

em vista ter sido ele eleito para participar de processos legislativos que estejam em harmonia com a Constituição Federal.³⁰

► Hipóteses de não cabimento do *mandamus*

O art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009 preceitua que não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. Bem, nesse caso, se os efeitos da lesão estão suspensos pelo recurso, não haveria interesse na propositura do mandado de segurança, entretanto, nada impede que o interessado abandone a via administrativa para pleitear a tutela judicial. Importante destacar que não há necessidade de esgotamento da instância administrativa para a propositura da ação, o que seria flagrantemente inconstitucional. Já os incisos II e III do art. 5º destacam que não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e; de decisão judicial transitada em julgado.

Segundo o art. 1º, § 2º, da lei sob comento, também não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Sobre o tema, o STJ decidiu que a imposição de multa decorrente de contrato, ainda que de cunho administrativo, não é ato de autoridade e, sim, de gestão contratual – contra o qual não cabe mandado de segurança. Para o Tribunal os atos de gestão não possuem o requisito da supremacia, por isso são meros atos da administração e não atos administrativos³¹.

30 “O parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. Legitimidade ativa do parlamentar, apenas. Precedentes do STF: MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (*leading case*), RTJ 99/1031; MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello, RDA 191/200; MS 21.303-Agr/DF, Ministro Octavio Gallotti, RTJ 139/783; MS 24.356/DF, Ministro Carlos Velloso, DJ 12.09.2003” (STF, MS 24.642/DF, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.2004, DJ 18.06.2004).

31 STJ, REsp 1.078.342/PR. Min. Rel. Luiz Fux. Primeira Turma, j. 09.02.2010, DJ 15.03.2010.

► Custas processuais

O MS exige o pagamento de custas, salvo se o impetrante for beneficiário da gratuidade de justiça (art. 99, § 3º, do CPC). Como é uma ação, tem que ter valor da causa, que deve corresponder ao benefício econômico almejado. O art. 25 da Lei 12.016/09 prevê expressamente que não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsão da Súmula 512 do STF.

► Intervenção obrigatória do Ministério Público

Por força do art. 12 da Lei 12.016/09, o Ministério Público deverá atuar como fiscal da lei em todos os Mandados de Segurança.

► Tutela de urgência

É possível a concessão da medida cautelar na forma do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, portanto, devem ser comprovados os requisitos: *fumus boni iuris* e *periculum in mora* ou probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

ATENÇÃO: O ART. 7º, § 2º PREVÊ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MS. SÃO QUATRO AS HIPÓTESES:			
compensação de créditos tributários;	entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior;	reclassificação ou equiparação de servidores públicos;	concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

► Direitos protegidos pelo Mandado de Segurança Coletivo

Na forma do art. 21, parágrafo único, da Lei nº 12.016/2009, os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I – coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica e; II – individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito dessa lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Com isso concluímos que direitos difusos não são objeto do mandado de segurança coletivo.

Os requisitos para a impetração do Mandado de segurança individual (tempestividade, ato coator, direito líquido e certo) também devem ser preenchidos para a impetração da ação na modalidade coletiva.

► Recursos

- Da decisão que concede ou denega a liminar: caberá agravo de instrumento (art. 7º § 1º, da Lei nº 12.016/09);
- Da sentença concessiva ou denegatória: caberá apelação (art. 14, da Lei nº 12.016/09);
- Do acórdão denegatório da segurança proferido em única instância pelos Tribunais (TRF e TJ), cabe Recurso Ordinário Constitucional ao STJ;
- Do acórdão denegatório da segurança proferido em única instância pelos Tribunais Superiores (STJ, STM, TSE e TST), cabe Recurso Ordinário Constitucional ao STF;
- Do acórdão concessivo da segurança em única ou última instância pelos Tribunais (TRF e TJ), caberá RE ou RESP, desde que preenchidos os requisitos específicos dos recursos excepcionais.

► Enunciados da Súmula do STF

- **Súmula nº 266:** Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
- **Súmula nº 267:** Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
- **Súmula nº 268:** Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
- **Súmula nº 269:** O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
- **Súmula nº 430:** Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
- **Súmula nº 510:** Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança ou a medida judicial.
- **Súmula nº 512:** Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.
- **Súmula nº 623:** Não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, n, da Constituição,

dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do Tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros.

- ▶ **Súmula nº 624:** *Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.*
- ▶ **Súmula nº 625:** *Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.*
- ▶ **Súmula nº 629:** *A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.*
- ▶ **Súmula nº 630:** *A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.*
- ▶ **Súmula nº 632:** *É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.*

▶ Competência

A competência para julgamento do mandado de segurança será fixada de acordo com a autoridade coatora, e não em virtude da natureza do ato impugnado.

A Constituição prevê também competência originária e recursal para processo e julgamento do mandado de segurança para o STF³² e STJ³³.

32 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente: (...)

d) o mandado de segurança (...) contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

II – julgar, em recurso ordinário:

a) (...) o mandado de segurança, (...) decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”

33 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: (...)

b) os mandados de segurança (...) contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

II – julgar, em recurso ordinário: (...)

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;”

Autoridades Coatoras	Previsão	Competência
– Presidente da República; – Mesa da Câmara dos Deputados; – Mesa do Senado Federal; – Tribunal de Contas da União; – Procurador-Geral da República; – Supremo Tribunal Federal;	Art. 102, I, "d" CRFB	STF
– Ministro de Estado; – Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; – Superior Tribunal de Justiça.	Art. 105, I, "b" CRFB	STJ
– TRF – Juiz Federal	Art. 108, I "c" CRFB	TRF
Autoridades federais, excetuadas competências dos Tribunais Federais	Art. 109, VIII CRFB	Juiz Federal
Autoridades definidas na Constituição Estadual	Art. 125, § 1º, CRFB e Constituição Estadual	– TJ – G – Governador – P – Prefeito de Capital – S – Secretário de Estado – Mesa da Assembleia Legislativa
Autoridades definidas na Constituição Estadual	Art. 125, § 1º, CRFB e Constituição Estadual	Juiz Estadual
Quando o ato questionado tiver relação com matéria trabalhista, qualquer que seja a autoridade coatora.	Art. 114, IV	Justiça do Trabalho

A competência da justiça federal para julgamento do MS restará configurada nas hipóteses do art. 2º, da Lei nº 12.016/09: “Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada”.

Podemos também aplicar o art. 20, da Lei 9.507/97 para fixar a competência para julgamento do MS.

Art. 20. O julgamento do *habeas data* compete:

I – originariamente:

- ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
- ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;

- c) aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal;
- d) a juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
- e) a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado;
- f) a juiz estadual, nos demais casos.

► Caso concreto e elaboração da peça

(OAB 2010.2)

Mévio de Tal, com quarenta e dois anos de idade, pretende candidatar-se a cargo vago, mediante concurso público, organizado pelo Estado X, tendo, inclusive, se matriculado em escola preparatória. Com a publicação do edital, é surpreendido com a limitação, para inscrição, dos candidatos com idade de, no máximo, vinte e cinco anos. Inconformado, apresenta requerimento ao responsável pelo concurso, que aduz o interesse público, tendo em vista que, quando mais jovem, maior tempo permanecerá no serviço público o aprovado no certame, o que permitirá um menor déficit nas prestações previdenciárias, um dos problemas centrais do orçamento do Estado na contemporaneidade.

O responsável pelo concurso é o Governador do Estado X. Não há previsão legal para o estabelecimento de idade mínima, sendo norma constante do edital do concurso. Não há necessidade de produção de provas e o prazo entre a publicação do edital e da impetração da ação foi menor que 120 (cento e vinte) dias.

Na qualidade de advogado contratado por Mévio, redigir a peça cabível ao tema, observando: a) competência do Juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) os requisitos formais da peça inaugural; e) necessidade de tutela de urgência.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXMº SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO X

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

Mévio de Tal, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., profissão..., portador do RG nº... e do CPF nº..., endereço eletrônico..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos do art. 5º, LXIX da CRFB/88 e da Lei nº 12.016/09, vem impetrar MANDADO DE SEGURANÇA em face do Governador do Estado X, que pode ser encontrado na sede funcional... e do Estado X.

I – TEMPESTIVIDADE

A presente ação é tempestiva, tendo em vista que o prazo entre a publicação do edital e da impetração da ação foi inferior a 120 (cento e vinte) dias, satisfazendo assim o requisito exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/09.

II – SÍNTESE DOS FATOS

O impetrante, com quarenta e dois anos de idade, pretende candidatar-se a cargo vago, mediante concurso público, organizado pelo Estado X, entretanto, com a publicação do edital, foi surpreendido com a limitação, para inscrição, dos candidatos com idade de, no máximo, vinte e cinco anos.

Inconformado, apresentou requerimento ao responsável pelo concurso, que aduziu o interesse público, tendo em vista que, quando mais jovem, maior tempo permanecerá no serviço público o aprovado no certame, o que permitirá um menor déficit nas prestações previdenciárias, um dos problemas centrais do orçamento do Estado na contemporaneidade.

Não há previsão legal para o estabelecimento de idade mínima, sendo norma constante do edital do concurso, o qual viola claramente o princípio da legalidade, ensejando a propositura do presente mandado de segurança.

III – TUTELA DE URGÊNCIA

A previsão para concessão da tutela de urgência no mandado de segurança está presente no art. 7º, III da Lei 12.016/09 e tem natureza de medida cautelar.

O *fumus boni iuris* reside nos argumentos de fato e de direito apresentados na presente e comprovados mediante a documentação anexa.

Já o *periculum in mora* também se encontra demonstrado tendo em vista que o prazo de inscrição do concurso se esgotará em breve.

IV – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Na forma do art. 5º, LXIX, da CRFB/88, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O mandado de segurança também está regulamentado pela Lei 12.016/09, que no art. 1º reforça a natureza residual do Instituto.

O acesso a cargos públicos tem assento constitucional, consoante se pode aferir do exame da norma do art. 37, II, da CRFB/88, que impõe a acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público.

A jurisprudência não tem acolhido que normas editalícias, sem previsão legal e com manifesta afronta às normas constitucionais, restrinjam o limite de idade, admitindo a restrição quando houver previsão legal, desde que adequado ao cargo postulado.

O ato do Governador do Estado X violou nitidamente o Princípio da Igualdade e da legalidade, presentes no art. 5º, I e II e no art. 37, *caput*, ambos da CRFB/88.

Além disso, o referido ato contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extraídos implicitamente do art. 5º, LIV da CRFB/88.

O direito líquido e certo do Impetrante é comprovado mediante os documentos que seguem em anexo, cumprindo o requisito da prova pré-constituída, exigido pelo art. 6º, *caput* da Lei 12.016/09.

V - DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer-se:

- a) a concessão da cautelar para suspender o ato do Governador e permitir que o impetrante realize a inscrição no concurso;
- b) a notificação da autoridade coatora, o Governador do Estado X, para que preste as informações que entender pertinentes do caso;
- c) que seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada;
- d) a intimação do Representante do Ministério Público;
- e) a condenação do Impetrado em custas processuais;
- f) a juntada dos documentos anexos;
- g) que ao final seja julgado procedente o pedido para garantir ao Impetrante o direito de se inscrever no concurso pretendido.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

► Modelo Simples de Mandado de Segurança Coletivo

EXM^o. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ... VARA ... DA COMARCA DE ... DO ESTADO...

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

PARTIDO POLÍTICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº... e no TSE sob o nº..., endereço eletrônico..., por seu Diretório Nacional, com sede em..., por seu advogado infra-assinado doc..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos da Lei 12.016/09 e no artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal Brasileira, vem impetrar **MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO** contra ato ilegal praticado pelo Diretor Geral do..., que poderá ser encontrado na sede funcional..., vinculado à ... (pessoa jurídica a que pertence), com sede...

I – DA TEMPESTIVIDADE

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

III – DOS FATOS

IV – DOS FUNDAMENTOS

V – DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

VI – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer-se:

a) a notificação da autoridade coatora, para que preste as informações que entender pertinentes do caso;

b) que seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada;

c) a intimação do Representante do Ministério Público;

d) a juntada dos documentos;

e) a condenação do Impetrado ao pagamento das custas processuais;

f) que ao final seja julgado procedente o pedido para...

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 7

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (OU AÇÃO ORDINÁRIA)

A ação de procedimento comum (ou ação ordinária) é uma petição inicial simples, regida pelo Código de Processo Civil e que admite a dilação probatória, ou seja, não há necessidade de existência de prova pré-constituída para apresentação da ação. Na qualificação inicial é suficiente escrever "Ação de Procedimento Comum" ou "Ação Ordinária" e nos pedidos ela pode ser: de indenização, de anulação de ato administrativo, de cobrança, de obrigação de fazer...

As petições iniciais correspondentes a essas ações são estruturadas de acordo com os arts. 319 e 320, do CPC.

Nas ações ordinárias, havendo urgência, é possível pleitear a antecipação de tutela, desde que comprovados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300, do CPC.

Na elaboração da peça, além dos requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC, não se deve esquecer o pedido de condenação em custas e honorários.

Com relação ao endereçamento, as ações de procedimento comum (do mesmo modo que a ação popular) não têm prerrogativa de foro, com isso, a ação será endereçada ao juiz singular, federal ou estadual, conforme o caso. Por exemplo, o art. 109, I, da CRFB/88 define que: compete à justiça federal julgar as ações em que esteja no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. As outras pessoas integrantes da administração pública não deslocam competência para a justiça federal. Então, nas ações contra estados, municípios e Sociedades de economia mista (mesmo que federal), a competência é da justiça estadual.

A fundamentação do direito material é extraída da própria Constituição. Ex.: ação na área da saúde (arts. 6º e 196), da educação (art. 205), dos concursos públicos (art. 37, II, IV)...

► Caso concreto e elaboração da peça

(OAB – IX EXAME)

José, brasileiro, desempregado, domiciliado no Município “ABC”, capital do Estado “X”, chegou a um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo (CTI) – sentindo fortes dores de cabeça. José aguardou atendimento na fila da emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital, que, entre outros comportamentos aviltantes, debocharam do fato de José estar de pé há tanto tempo esperando atendimento. Após tamanha espera e sofrimento, o quadro de saúde de José agravou-se e ele entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Adamastor, também desempregado, pai de José, revela que, segundo laudo do médico responsável, seu filho necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois José corre risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer. Informa ainda que o médico mencionou a existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades de onde José se encontra internado, todos possuidores de CTI. Ocorre que José e Adamastor são economicamente hipossuficientes, de modo que não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Indignado com todo o ocorrido, e ansioso para preservar a saúde de seu filho, Adamastor o procura para, na qualidade de advogado, identificar e minutar a medida judicial adequada à tutela dos direitos de José em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra e que seja levado em consideração o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

Segundo a banca apresentou inicialmente no espelho de correção, não caberia mandado de segurança no caso narrado pelas seguintes razões:

- 1) É inviável a postulação de perdas e danos em sede de MS.
- | 2) Inexistem autoridades coatoras no enunciado.
- 3) Haveria necessidade de produção de provas testemunhal e pericial para aferição dos danos e do risco de vida.

► Peça processual

EXMº. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA... VARA FEDERAL... DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO X.

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

José, representado por seu pai Adamastor, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., profissão..., portador do RG nº... e do CPF nº..., endereço eletrônico..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 319, do CPC vem ajuizar AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM em face do Município "ABC", do Estado "X" e da União.

I – DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Com base no art. 99, § 3º, do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CRFB/88 o Autor requer a V. Exª. a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que está desempregado e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

II – SÍNTESE DOS FATOS

O Autor chegou a um hospital municipal que não possui Centro de Tratamento Intensivo (CTI) sentindo fortes dores de cabeça e aguardou atendimento na fila da emergência pelo período de 12 (doze) horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital, que, entre outros comportamentos aviltantes, debocharam dele estar de pé há tanto tempo esperando atendimento.

Após tamanha espera e sofrimento, o quadro de saúde de José agravou-se e ele entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se e sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo.

Adamastor, também desempregado, pai de José, revela que, segundo laudo do médico responsável, seu filho necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois José corre risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde e, inclusive, o de morrer, daí a necessidade de ajuizamento da presente ação.

III – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência na Ação Ordinária é extraída do art. 300 do CPC e possui natureza de tutela antecipada.

Deve haver a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV – FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A saúde é um direito fundamental, de acordo com os arts. 6º e 196 da Constituição da República.

A responsabilidade pelo cuidado da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência é cumulativa entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, na forma do art. 23, II, da CRFB/88.

Diante do tratamento vexatório sofrido por José no hospital municipal, o direito à reparação por danos morais em face do Município é respaldado pelo art. 37, § 6º da CRFB/88, que aduz: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

V - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se:

a) a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata transferência de José ao CTI mais próximo;

b) que seja julgado procedente o pedido para condenar os Réus à internação de José no referido CTI;

c) a citação do Município, do Estado e da União para contestar a ação;

d) a condenação do Município ABC à reparação dos danos morais sofridos pelo autor;

e) a condenação dos Réus em custas e em honorários advocatícios;

f) a produção de todos os meios de provas em direito admitidas;

g) a juntada de documentos.

h) a intimação do representante do Ministério Público.

Em cumprimento ao art. 319, VII do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado

OAB nº ...

Após a apresentação de inúmeros recursos em defesa do mandado de segurança como instrumento mais célere para tutelar a vida de José, a banca aceitou o remédio pleiteado, segundo o espelho abaixo. (Espelho formulado quando vigente o CPC/1973)

Quesito avaliado	Valores
Endereçamento da petição inicial: Vara Federal da Seção Judiciária de "X" (0,10)	0,00 / 0,10
Qualificação das partes: José / representado por Adamastor (0,10) Representantes do município ABC e/ou Estado "X" e/ou União (0,30)	0,00 / 0,10 / 0,30 / 0,40
Pedido de gratuidade de justiça: preenchimento dos requisitos contidos no art. 4º, da Lei 1.060/50. (0,10)	0,00 / 0,10
Fundamentação para a pretensão: 1. Direito à internação e ao fornecimento de tratamento de saúde adequado, com base no Art. 196, da Constituição da República (1,0); 2. Pleito de reconhecimento de solidariedade entre o Município, o Estado e a União (1,0). 3. Caracterização do ato abusivo das autoridades indicadas na inicial (1,0)	0,00 / 1,00 / 2,00 / 3,00
Pedido de liminar. <i>Fumus boni juris</i> (0,15) e <i>periculum in mora</i> (0,15). Demonstração concreta de aparência do bom direito e de perigo na demora da prestação jurisdicional.	0,00 / 0,15/0,30
Pedidos: 1. Requerimento para notificação dos representantes do Município (0,20) e do Estado (0,20) e da União (0,20). 2. Procedência do pedido para condenar a União, o Estado e o Município, através dos seus representantes, a promoverem a internação do autor em CTI; (0,20) 3. Requerimento de intervenção do Ministério Público (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,40 / 0,60 / 0,80/1,00
Atribuição de valor à causa. (0,10)	0,00 / 0,10

CAPÍTULO 8

DIFERENÇAS PRINCIPAIS ENTRE A AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM (OU AÇÃO ORDINÁRIA) E O MANDADO DE SEGURANÇA

Para evitar que o examinando confunda na prova o Mandado de segurança e a Ação ordinária, é importante destacarmos as principais diferenças entre as duas ações, apresentadas no quadro abaixo.

CRITÉRIO	AÇÃO ORDINÁRIA	MANDADO DE SEGURANÇA (individual ou coletivo)
Dilação probatória	Admite-se o pedido de produção de provas.	Não se admite a dilação probatória.
Prazo	Não há prazo específico para o ajuizamento das ações em geral.	Na via repressiva, o remédio deverá ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte dias).
Autoridade Coatora	Não precisa estar indicada no caso narrado.	Normalmente é indicada no caso proposto.
Indenização	Admite o pedido de indenização e de cobrança.	Como não permite a dilação probatória, não há, em regra, pedido de indenização e de cobrança.
Prerrogativa de Foro	Não há prerrogativa de Foro. Proposta perante juiz singular, federal ou estadual, conforme o caso.	Há prerrogativa de Foro Funcional na Constituição Federal e nas Constituições Estaduais.



RECLAMAÇÃO

A Reclamação está regulamentada no CPC entre os arts. 988 e 993 e, ainda, encontra fundamento na Constituição Federal, que trata da Reclamação de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, I e art. 103-A, §3º) e do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), como veremos adiante.

► Hipóteses de cabimento e legitimidade ativa

De acordo com o art. 988, do CPC, a parte interessada ou o Ministério Público, poderão apresentar Reclamação para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

► Reclamação para preservação da competência do Tribunal – art. 988, I, do CPC e art. 102, inciso I, alínea “I”, da CRFB/88

As competências (originárias e recursais) do STF se esgotam na Constituição Federal. Caso o juiz singular ou o Tribunal viole uma das atribuições da Corte, previstas no art. 102, I a III da CRFB/88, caberá Reclamação.

Um mandando de segurança contra o Presidente da República, por exemplo, impetrado perante um juízo federal de primeiro grau, acarreta em usurpação da competência do Supremo, tendo em vista a norma contida no artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição, sendo cabível o ajuizamento de reclamação perante a Corte Suprema.

► **Reclamação para garantia da autoridade de decisão do Tribunal – art. 988, II, do CPC e art. 102, inciso I, alínea “I”, da CRFB/88**

A reclamação para garantia da autoridade de decisão do Tribunal tem por objetivo impor a autoridade do julgado, ou seja, fazer com que ele seja respeitado.

No âmbito do Supremo, a reclamação pode ter por escopo garantir a autoridade de uma decisão proferida em processo subjetivo. Se a Corte, em sede de recurso extraordinário, mandado de segurança ou *habeas corpus*, por exemplo, profere determinada decisão, o desrespeito, por parte de outro juízo ou autoridade administrativa, a esta decisão, dá ensejo ao ajuizamento de reclamação perante o STF.

► **Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade – art. 988, III, do CPC e art. 103-A, § 3º, da CRFB/88**

A terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional está vinculada ao descumprimento de súmula vinculante. De acordo com o art. 7º da Lei 11.417/06: “Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação”. Com relação às decisões administrativas, entretanto, a lei trouxe a necessidade de um contencioso administrativo obrigatório, conforme dicção do § 1º do art. 7º: “Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas”.

De acordo com o art. 103-A, § 3º, da CRFB/88: “Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ademais, a reclamação pode ter por escopo garantir a autoridade de uma decisão proferida em processo objetivo. Dessa forma, se a Corte, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, decidir declarar a invalidade de uma norma e posteriormente o Tribunal de Justiça resolver aplicar

essa lei já declarada inconstitucional pelo Tribunal, caberá Reclamação. Do mesmo modo, se a autoridade administrativa contrariar a decisão do STF, também caberá Reclamação.

Não cabe Reclamação em face de decisão que descumprir enunciado de Súmula não vinculante!

- **Reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC) – art. 988, IV, do CPC**

Nesses casos, será competente para julgar a Reclamação o Tribunal cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir, de acordo com o art. 988, § 1º, do CPC.

Importante ressaltar que as hipóteses de cabimento previstas no art. 988, incisos III e IV, compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

ATENÇÃO!! A Reclamação não é admissível após o trânsito em julgado da decisão reclamada e para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, de acordo com o art. 988, § 5º, do CPC.

Ressalte-se que a Súmula nº 734 do STF já afirmava não ser cabível reclamação contra decisão judicial transitada em julgado.

► Procedimento

A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao Presidente do Tribunal. Depois, será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível, de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 988, do CPC.

Na forma do art. 989, do CPC, o relator, ao despachar a reclamação:

“I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.”

O Ministério Público terá vista do processo por cinco dias após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado, na reclamação que não houver formulado.

De acordo com o art. 992, do CPC: “Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.”

Vale destacar que a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação, nos termos do § 6º do art. 988, do CPC.

► Tutela de urgência

De acordo com o art. 989, II, do CPC, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300, *caput*, do CPC.

► Jurisprudência do STF sobre a Reclamação

“Inexiste ofensa à autoridade de Súmula Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema.” (Rcl 6.449-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-11-2009, Plenário, DJE de 11-12-2009).

“Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do STF destituída de efeito vinculante. Precedentes. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos Ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC 45/2004).” (Rcl 3.284-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 1º-7-2009, Plenário, DJE de 28-8-2009).

“(…) somente as decisões concessivas das liminares em ADIs e ADCs é que se dotam de efeito vinculante. Não as denegatórias. Ante a natureza subjetiva do processo, as decisões proferidas em reclamação não têm

eficácia *erga omnes* (contra todos).” (Rcl 3.424-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 11-10-2007, Plenário, DJE de 1º-8-2008).

“Reclamação não é recurso e não se destina a examinar o ato impugnado com vistas a repudiá-lo por alguma invalidade processual-formal ou corrigi-lo por erros em face da lei ou da jurisprudência.” (Rcl 3.800-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 2-2-2006, Plenário, DJ de 9-6-2006.)

“A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 17-2-2010, Plenário, DJE de 9-4-2010.)

“Impossibilidade de utilização de reclamação quando há recurso apropriado e cabível contra a decisão reclamada.” (Rcl 5.159-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 26-6-2007, Primeira Turma, DJ de 10-8-2007.)

► Caso concreto e elaboração da peça

(34º Exame de Ordem)

Um contingente de servidores públicos do município A, inconformado com a política salarial adotada pelo governo municipal, decidiu, após ter realizado paralisação grevista sem qualquer sucesso, tomar providências para fazer valer um suposto direito a reajuste de 15% sobre o vencimento básico percebido. O referido valor corresponderia a um aumento remuneratório real, equiparando ao reajuste obtido, nos últimos três anos, por diversas classes profissionais. Os servidores públicos procuraram a entidade sindical correspondente e esta decidiu ajuizar, na justiça comum, ação ordinária a fim de satisfazer o pleito apresentado. Dada a premência do tempo em ver reconhecido, pelo Judiciário, o reajuste de 15%, a entidade sindical formulou, na própria petição inicial, pedido de antecipação de tutela, sob a alegação de que, na situação, estavam em jogo verbas de caráter nitidamente alimentar, o que reforçaria a necessidade de um provimento judicial mais célere.

Ao fazer uma primeira análise, o juiz do feito decidiu indeferir o pedido de tutela antecipada. Após pedido de reconsideração formulado pela entidade sindical, o juiz decidiu reverter seu primeiro posicionamento e optou por deferir o pedido de tutela antecipada, determinando a imediata implantação em folha de pagamento do reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos servidores públicos.

Inconformado com a decisão judicial, o município decidiu contratar serviços advocatícios para promover as medidas cabíveis e reverter a situação o quanto antes, em virtude do iminente impacto orçamentário do reajuste concedido. O advogado tentou, por todos os modos possíveis, suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada no tribunal de justiça competente, sem ter obtido êxito.

A antecipação de tutela continua mantida, em toda sua extensão, e o mérito da ação ainda não foi apreciado. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-MC 4, assim decidiu: “Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, *“ex nunc”*, e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutelar antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Art. 1º da Lei nº 9.494, de 10/9/1997, sustando-se, igualmente *“ex nunc”*, os efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido”.

Diante da situação hipotética apresentada, na condição de advogado do município A, redija a peça judicial.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^a. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

MUNICÍPIO A, pessoa jurídica de direito público interno, com sede..., endereço eletrônico..., neste ato representado por seu procurador, conforme procuração anexa, com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 102, I, "I", da CRFB/88 e no art. 988, III, do CPC, vem apresentar RECLAMAÇÃO em face da decisão do Tribunal de Justiça..., que descumpriu a decisão do STF proferida na cautelar da ADC nº 4.

I – DA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC-MC 4, assim decidiu: "Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se suspender, *ex nunc*", e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do Art. 1º da Lei nº 9.494, de 10/9/1997, sustando-se, igualmente *ex nunc*", os efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido".

Mesmo sabendo dessa decisão vinculante da Corte, o juiz de primeiro grau optou por deferir o pedido de tutela antecipada formulado pela entidade sindical, determinando a imediata implantação em folha de pagamento do reajuste de 15% sobre o vencimento básico dos servidores públicos.

O Reclamante tentou reverter a decisão perante o Tribunal de Justiça competente, mas não obteve êxito, o que configura claro desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADC-MC 4, motivando a propositura da presente Reclamação.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência da Reclamação está prevista no art. 989, II, do CPC.

Demonstração do preenchimento dos seguintes requisitos, estabelecidos no art. 300, *caput*, do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Na forma do art. 102, I, I, da CRFB/88, a Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, dentre outras hipóteses de cabimento.

E, ainda, de acordo com o art. 988, III, do CPC, caberá a Reclamação para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

As normas procedimentais relativas à Reclamação estão previstas no CPC, entre os arts. 988 e 993.

Os efeitos vinculantes e *erga omnes* da cautelar em ADC são estabelecidos pelo art. 21, da lei 9868/99: "O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo".

No caso ora analisado, além de o Juiz ter concedido a tutela antecipada contra a Fazenda, o Tribunal teve a oportunidade de reverter a decisão e não o fez, o que viola a autoridade da decisão da Corte.

IV – DOS PEDIDOS

Pelas razões acima expostas, o Reclamante requer:

- a) a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão impugnada e que ao final seja cassada a decisão para preservar a jurisdição constitucional;
- b) a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação;
- c) a oitiva da autoridade Reclamada para apresentar informações;
- d) a oitiva do Procurador-Geral da República;
- e) a juntada dos documentos anexos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº ...

CAPÍTULO 10

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. 102, CRFB/88. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

1 – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

A Ação direta de inconstitucionalidade é a principal ação do controle concentrado federal abstrato de constitucionalidade e visa defender a Supremacia da Constituição.

Se o conflito tem como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual que contraria a CRFB/88, a competência é do STF, conforme previsão no art. 102, I, “a” da CRFB/88 e a Lei 9868/99.

► Objeto

Segundo Clèmerson Merlin Clève,³⁴ podem ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade: as emendas constitucionais, atos normativos formalmente legislativos (leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos etc.), tratados internacionais, desde que integrem o ordenamento jurídico atual, leis distritais que tenham como tema matéria de competência estadual. Ressalte-se que não cabe ADI de lei ou ato normativo anterior à Constituição, nem de lei ou ato normativo municipal.

Como a ação realiza controle repressivo de constitucionalidade, projetos de leis e propostas de emendas não podem ser objeto da ADI.

34 CLÈVE, Clèmerson Merlin. *A fiscalização abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro*. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

► Legitimidade ativa

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, as regras da legitimação ativa para a propositura da ADI, ADC, ADO e ADPF passaram a ser idênticas. Houve alteração do art. 103 para incluir a possibilidade de provocação do STF pelos órgãos do Distrito Federal, conforme já era previsto na Lei nº 9.868/1999. Em relação à ADPF, a Lei nº 9.882/1999 dispõe que são seus autores os mesmos legitimados para a ADI. Portanto, de acordo com o novo texto do art. 103 da CRFB/88 e art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade (que pode ser por ação ou por omissão), a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, os seguintes órgãos, entidades ou pessoas:

- I – o Presidente da República;
- II – a Mesa do Senado Federal;
- III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa;
- V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI – o Procurador-Geral da República;
- VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Tais legitimados ativos são capazes de provocar a jurisdição constitucional em seus próprios nomes, porém para defender interesse que é de todos, qual seja, a proteção da Constituição da República Federativa do Brasil. É a chamada legitimação extraordinária, apresentada em rol taxativo no art. 103, I a IX, da CRFB/88

Tão logo foi promulgada a Constituição de 1988, a Suprema Corte brasileira passou a fazer interpretação restritiva da legitimação para agir, procedendo a uma classificação dos autores destas ações em dois grupos, o dos **legitimados universais** e o dos **legitimados especiais**, exigindo, destes últimos, demonstração do interesse de agir.

Do primeiro grupo, denominado de universal, não se exige a demonstração do interesse de agir ou a pertinência temática (relação de adequação que deve existir entre o ato normativo impugnado e os interesses defendidos pelo legitimado), posto que do exercício de suas próprias com-

petências decorre a responsabilidade pela preservação da Constituição. Isso significa que eles podem propor ação para exame da constitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo. São eles:

- o Presidente da República;
- a Mesa do Senado Federal;
- a Mesa da Câmara dos Deputados;
- o Procurador-Geral da República;
- o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- partido político com representação no Congresso Nacional (desde que tenha representação em pelo menos uma das Casas legislativas e que a ação seja proposta por seu Diretório Nacional).

Segundo o STF,³⁵ a perda da representatividade do partido no curso do julgamento, não prejudica o prosseguimento da ação, tendo em vista que o momento de aferição sobre a existência ou não da representação é quando da proposição da ação. Ademais as ações do controle versam sobre matéria de ordem pública e interesse não disponível.

Do segundo grupo – os especiais – é exigida a pertinência temática. De acordo com a jurisprudência do STF,³⁶ precisam demonstrar interesse de agir para que a ação seja conhecida, os legitimados do art. 103, IV, V e

35 “Retomando o julgamento de mérito de ação direta ajuizada pelo Partido Social Trabalhista-PST contra o art. 99 e § 1º da Lei nº 9.610/1998 – que preveem um único escritório central para a arrecadação e distribuição de direitos autorais decorrentes de execução pública musical –, o Tribunal, apreciando questão de ordem suscitada pelo Min. Sepúlveda Pertence, que pedira vista do processo na Sessão Plenária de 19.06.2002, decidiu que, embora tenha havido, na nova legislatura, a perda de representação parlamentar no Congresso Nacional do autor da ação (o que, em tese, extingue a legitimização do partido político para prosseguir, perante o STF, no polo ativo do processo de controle normativo abstrato), é de se determinar o prosseguimento da ação ante a peculiaridade de que, no início do julgamento da ação, o Partido ainda estava devidamente representado no Congresso Nacional” (STF, ADI (QO) 2.054-DF, Min. Rel. para acórdão: Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 17.10.2003).

36 “(...) A jurisprudência do STF erigiu o vínculo da pertinência temática à condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade ativa *ad causam* do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe no âmbito nacional, por Mesas das Assembleias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal”(…) (STF, ADI 1096 MC/RS, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.03.1995, DJ 22.09.1995).

IX, da CRFB/88. Em outras palavras, somente poderão ser autores destas ações se comprovarem que a norma impugnada interfere de alguma forma nos interesses da unidade federativa à qual pertencem ou do grupo de pessoas que representam. Assim, para que o Governador do Estado da Bahia, por exemplo, possa ser legitimado para uma ADI proposta contra ato normativo editado pelo Estado do Rio de Janeiro terá que comprovar a influência desta norma fluminense sobre os interesses baianos, sob pena de a ação não ser conhecida.

São legitimados especiais:

- a Mesa de Assembleia Legislativa e a Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- o Governador de Estado e do Distrito Federal;
- confederação sindical³⁷ ou entidades de classe de âmbito nacional.³⁸

As Confederações Sindicais devem ser formadas de acordo com o art. 535, da CLT: “As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na Capital da República”.

37 “O Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgamentos, tem entendido que apenas as confederações sindicais têm legitimidade ativa para requerer ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), excluídas as federações sindicais e os sindicatos nacionais” (ADI 1.599-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 26.02.1998, DJ 18.05.2001) “Preliminarmente, não tenho como legitimadas à ação as Federações sindicais autoras (Federação Nacional dos Estivadores, Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco e Arrumadores, e Federação dos Portuários). Cuida-se de entidades sindicais que não atendem ao requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição, porque seu nível não é de Confederação sindical. São entidades sindicais de segundo grau. Nesse sentido, as decisões do Plenário nas ADINs nos 433-DF, 853-6-DF, 868-4-DF (...)” (ADI 929-MC/DF, Min. Rel. Néri da Silveira, Plenário, j. 13.10.1993, DJ 20.06.1997).

38 “ADIn: legitimidade ativa: ‘entidade de classe de âmbito nacional’ (art. 103, IX, CF): compreensão da ‘associação de associações’ de classe. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.2004, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau – as chamadas ‘associações de associações’ – do rol dos legitimados à ação direta. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática, pois o pagamento da contribuição criada pela norma impugnada incide sobre as empresas cujos interesses, a teor do seu ato constitutivo, a requerente se destina a defender” (ADI 15/DF, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.06.2007, DJ 31.08.2007).

Já as entidades de classe de âmbito nacional devem ser criadas de acordo com o art. 8º, da Lei nº 9.096/95, ou seja, devem ter representantes em pelo menos nove estados da Federação. Em jurisprudência clássica, o STF havia firmado entendimento no sentido de que essas organizações coletivas precisavam ter na sua base de composição apenas pessoas naturais, mas em decisão plenária mais recente³⁹ a Corte decidiu que as “associações de associações” (ou associações de segundo grau, formadas por pessoas jurídicas) de âmbito nacional possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, desde que os interesses que unem os seus componentes (pessoas naturais ou jurídicas) sejam homogêneos, ou seja, de uma classe ou categoria específica.

► Capacidade postulatória

Não se exige de todos os legitimados ativos que constituam advogados para a propositura das ações do sistema concentrado. O STF entende que a capacidade postulatória já foi conferida aos mesmos pela própria Constituição,⁴⁰ exceto no caso dos partidos políticos, das confederações sindicais e das entidades de classe. Estes têm que estar representados por

39 “Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação ativa: ‘entidade de classe de âmbito nacional’: compreensão da ‘associação de associações’ de classe: revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal. O conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista, pouco importando que a eles diretamente se filiem os membros da respectiva categoria social ou agremiações que os congreguem, com a mesma finalidade, em âmbito territorial mais restrito. É entidade de classe de âmbito nacional – como tal legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX) – aquela na qual se congregam associações regionais correspondentes a cada unidade da Federação, a fim de perseguirem, em todo o País, o mesmo objetivo institucional de defesa dos interesses de uma determinada classe. Nesse sentido, altera o Supremo Tribunal sua jurisprudência, de modo a admitir a legitimação das ‘associações de associações de classe’, de âmbito nacional, para a ação direta de inconstitucionalidade” (ADI 3.153-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.08.2004, Plenário, DJ 09.09.2005.) No mesmo sentido: ADI 2.797/DF; Plenário e ADI 2.860, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.09.2005, Plenário, DJ 19.12.2006.

40 “(...) O Governador de Estado e as demais autoridades e entidades referidas no art. 103, incisos I a VII, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados à instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem ex vi, da própria norma constitucional, de capacidade postulatória (...)” (STF, ADI 127 MC QO/AL, Plenário, Min. Rel. Celso de Mello, j. 20.11.1989, DJ 04.12.1992).

procuradores devidamente constituídos nos autos, na forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999.

► Concessão de medidas cautelares

Na forma do art. 11 da Lei nº 9.868/1999 é possível a concessão de medidas liminares, de eficácia geral, produzindo, via de regra, efeitos temporais *ex nunc* (ultra ativos) e excepcionalmente *ex tunc* (retroativos) com a determinação da suspensão da norma até a decisão final.

► O procurador-geral da República

Na forma do art. 103, § 1º, da CRFB/88: “O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.” Portanto, pede-se a sua intimação (ou oitiva) em sede de ADI.

► O advogado-geral da União

De acordo com os art. 103, § 3º, da CRFB/88, ele tem a missão de fazer a defesa da norma impugnada: “Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado”. Com isso, pedimos a citação do AGU em sede de ADI.

► Dicas para identificar o cabimento das ações do controle concentrado na prova

EXPRESSÕES:	“Erga omnes”, “efeitos vinculantes”
	“Análise em abstrato”
	“Ação do controle concentrado”
	“Lei em tese ou ausência da lei em tese”
	“Efeitos para todos os indivíduos no território brasileiro”
	“Ação contra a lei em si”

► **Caso concreto e elaboração da peça**

(VII EXAME DE ORDEM)

O Estado KKY editou norma determinando a gratuidade dos estabelecimentos privados vinculados a estabelecimentos comerciais, como supermercados, hipermercados, shopping centers, determinando multas pelo descumprimento, estabelecendo gradação nas punições administrativas e delegando ao PROCON local a responsabilidade pela fiscalização dos estabelecimentos relacionados no instrumento normativo. Tício, contratado como advogado Junior da Confederação Nacional do Comércio, é consultado sobre a possibilidade de ajuizamento de medida judicial, apresentando seu parecer positivo quanto à matéria, pois a referida lei afrontaria a CRFB. Em seguida, diante desse pronunciamento, a Diretoria autoriza a propositura da ação judicial constante do parecer. Na qualidade de advogado elabore a peça cabível, observando:

- a) competência do Juízo;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados;
- d) requisitos formais da peça;
- e) tutela de urgência.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^a. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL!

(pular aproximadamente 5 linhas para todas as petições iniciais)

Confederação Nacional do Comércio, pessoa jurídica de direito privado, entidade de âmbito nacional, inscrita no CNPJ sob o nº., com sede em..., por seu advogado infra-assinado..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com fundamento no art. 102, I, "a", da CRFB/88 e na Lei nº 9.868/99, em face da lei do Estado KWY, elaborada pelo Governador do Estado e pela Assembleia Legislativa, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que passa a expor.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

De acordo com o art. 102, I, a da CRFB/88 caberá ADI em face de lei ou ato normativo federal ou estadual que viole a Constituição Federal.

A lei estadual, como se demonstrará ao longo da presente ação, viola a Lei Maior sob os aspectos formais e materiais, por isso deverá ser declarada inconstitucional.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA ESPECIAL DA CONFEDERAÇÃO

A Confederação Nacional do Comércio é legitimada ativa para a propositura da ADI, de acordo com o art. 103, IX, da CRFB/88.

Ademais, a Autora possui representantes em pelo menos nove Estados da Federação, como determina o art. 8º da Lei 9096/95 e os interesses dos seus membros são homogêneos.

A pertinência temática também é comprovada pela relação harmoniosa entre o objeto da ação – uma lei que afeta os interesses do Comércio – e os membros que compõem a referida organização coletiva.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A possibilidade de concessão de medida cautelar em sede de ADI se encontra nos arts. 10 a 12 da Lei nº 9868/99 e possui natureza cautelar.

O *fumus boni iuris* se justifica pelos argumentos apresentados ao longo da petição e pela documentação anexa.

Já o *periculum in mora* é comprovado tendo em vista os prejuízos que o Comércio sofrerá caso a referida norma seja mantida.

IV – DOS FUNDAMENTOS

- Art. 102, I, "a", CRFB/88

- Lei nº 9.868/99

- Art. 1º, IV, CRFB/88 – violação material

- Art. 5º, XXII, CRFB/88 – violação material

- Art. 22, I, CRFB/88 – violação formal

V - DOS PEDIDOS

Em face do exposto, a Confederação requer:

- a) a concessão da medida cautelar para suspender a norma impugnada e que, ao final, seja julgado procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade da lei;
- b) a juntada dos documentos em anexo;
- c) que sejam solicitadas informações ao Governador do Estado e à Mesa da Assembleia Legislativa estadual;
- d) a citação do Advogado-Geral da União;
- e) a oitiva do Procurador-Geral da República.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento,

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

► Caso Concreto XVI Exame

A Assembleia Legislativa do Estado Y edita, em 1º de março de 2015, a Lei nº 8888, que estabelece que a concessionária exploradora do serviço de fornecimento de energia elétrica no território do Estado fica obrigada a remover, sem qualquer ônus para os interessados, os postes de sustentação à rede elétrica que estejam causando transtornos aos proprietários e aos promitentes compradores de terrenos. Ressalta-se que não há qualquer Lei Complementar que autorize excepcionalmente ao Estado Y dispor sobre a questão, sendo certo que, ao contrário, no âmbito federal existe norma expedida pela agência reguladora que autoriza a remoção desses postes de energia, cujo serviço fica às expensas dos usuários interessados. Há notícia também de que o Governador do Estado Y vetou integralmente o projeto de Lei Estadual, mas restou superado pela vontade da Assembleia Legislativa do Estado, que, ao final, promulgou a referida Lei. Diante da relevância e da urgência da questão, o partido político “Para Frente Brasil” – PFB, representado unicamente por um Deputado Federal, procura os seus serviços para objetar contra a Lei Estadual, por entender que a norma estadual viola diretamente a Constituição Federal.

Considerando os dados acima, formule a peça adequada, fazendo introito sobre a legitimidade ativa e observando que o partido entende ser urgente a questão. (Valor: 5,00)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^a. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(pular aproximadamente 5 linhas para todas as petições iniciais)

Partido Político Para Frente Brasil, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº... e no TSE sob o nº..., por seu Diretório Nacional, com sede em ..., por seu advogado infra-assinado..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com fundamento no art. 102, I, "a", da CRFB/88 e na Lei nº 9.868/99, em face da Lei Estadual 8888, elaborada pelo Governador do Estado e Assembleia Legislativa do Estado, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que passa a expor.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

De acordo com o art. 102, I, a da CRFB/88 caberá ADI em face de lei ou ato normativo federal ou estadual que viole a Constituição Federal.

A lei estadual, como se demonstrará ao longo da presente ação, viola a Lei Maior sob os aspectos formais e materiais, por isso deverá ser declarada inconstitucional.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

O autor é legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, VIII da CRFB/88 e não precisa comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88.

Além disso, possui representação no Congresso Nacional e foi criado de acordo com a Lei 9.096/95, estando, portanto, plenamente habilitado para o ajuizamento desta ADI.

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

A possibilidade de concessão de medida cautelar em sede de ADI se encontra nos arts. 10 a 12 da Lei nº 9868/99 e possui natureza cautelar.

O *fumus boni iuris* se justifica pelos argumentos apresentados ao longo da petição e pela documentação anexa.

Já o *periculum in mora* é comprovado tendo em vista os prejuízos que o Comércio sofrerá caso a referida norma seja mantida.

IV – DOS FUNDAMENTOS

– Art. 102, I, "a", CRFB/88;

– Lei nº 9.868/99;

– afronta ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade – violação material;

– Art. 175, parágrafo único, III, da CRFB/88 – cabe a União definir, por meio de lei, a política tarifária;

– Art. 22, IV, da CRFB/88 – violação formal;

– Art. 21, XII, "b", da CRFB/88 – violação formal.

V – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o Partido requer:

- a) a concessão da medida cautelar para suspender a norma impugnada e que, ao final, seja julgado procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade da lei;
- b) a juntada dos documentos em anexo;
- c) que sejam solicitadas informações ao Governador do Estado e à Mesa da Assembleia Legislativa estadual;
- d) a citação do Advogado Geral da União;
- e) a oitiva do Procurador-Geral da República.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

► Caso concreto do XIII Exame de Ordem

O Presidente da República editou o Decreto nº 5.555, estabelecendo a obrigatoriedade, como exigência à obtenção do diploma de graduação em engenharia, de um elevado aproveitamento nas disciplinas do curso, e, para inscrição nos Conselhos Regionais, a conclusão de uma pós-graduação com carga horária mínima de 480 horas de aula. A medida tem por objetivo conferir maior controle sobre a formação do profissional, num momento de expansão das obras de infraestrutura no país.

A Confederação Sindical dos Engenheiros, entidade que reúne 18 (dezoito) Federações de sindicatos em diferentes Estados, cada uma com ao menos 10 (dez) sindicatos, procura os seus serviços para impugnar o Decreto expedido pelo Presidente da República, salientando que o mesmo viola diretamente a Constituição, sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável, tendo em vista a aproximação do final de ano, época em que, tradicionalmente, são formados milhares de bacharéis em todo o território nacional.

Considerando a hipótese acima, formule a peça adequada.

► Gabarito comentado pela Banca

A peça a ser elaborada consiste em uma petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), a qual terá, por objeto, o Decreto expedido pelo Presidente da República, e, como parâmetros, diversos dispositivos da Constituição da República.

De início, deve-se destacar que os decretos do Chefe do Poder Executivo podem ser regulamentares ou autônomos. Na jurisprudência do STF, somente se admite a propositura de ação direta tendo por objeto decreto autônomo, aquele que inova autonomamente na ordem jurídica, e não o decreto que tenha por escopo regulamentar a lei. Isso porque o decreto regulamentar não possui autonomia normativa. Se o decreto apenas fere a lei, ou desborda dos limites regulamentares, abrir-se-á a via do controle de legalidade, e não do controle de constitucionalidade.

Desse modo, o examinando deve destacar a autonomia normativa do Decreto em questão, tendo em vista a ausência de lei da qual decorra aquele ato normativo.

A competência para julgamento da Ação Direta é do Supremo Tribunal Federal, e para essa corte deve ser endereçada a petição inicial.

Somente possuem legitimidade para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade aqueles explicitados no rol do artigo 103 da Constituição. No caso em análise, a Confederação Sindical dos Engenheiros tem legitimidade com base no inciso IX do citado dispositivo: entidade de classe de âmbito nacional. Deve ser demonstrado o preenchimento dos requisitos constantes dos Artigos 533 a 535 da CLT (“as Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 Federações” e “é facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação”), uma vez que tais requisitos são exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ainda em relação à legitimidade, o examinando deve identificar que o Supremo Tribunal Federal erigiu o requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa ad causam para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. O examinando deve demonstrar, assim, a pertinência temática, na medida em que a Confederação sindical atuará na defesa do interesse de uma classe diretamente atingida pelo decreto impugnado.

O Presidente da República, que editou a norma impugnada, deve ser indicado no polo passivo da ação.

O examinando deve formular pedido de concessão da medida cautelar, a fim de suspender a vigência do decreto cuja inconstitucionalidade arguiu. Os pressupostos à concessão da medida são o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. O primeiro é demonstrado pela direta e frontal violação às normas constitucionais que estabelecem o princípio da separação de poderes, o princípio da legalidade e a liberdade de exercício de profissão; o segundo, pela proximidade da conclusão do curso de milhares de bacharéis, que restarão impossibilitados de concluir o curso e/ou obter a inscrição nos Conselhos Regionais com base em exigência sem previsão legal.

No mérito, o examinando deve demonstrar que o Decreto, a um só tempo, viola o princípio da separação de poderes (pois ingressa em atividade legislativa não autorizada pela Constituição, em violação à separa-

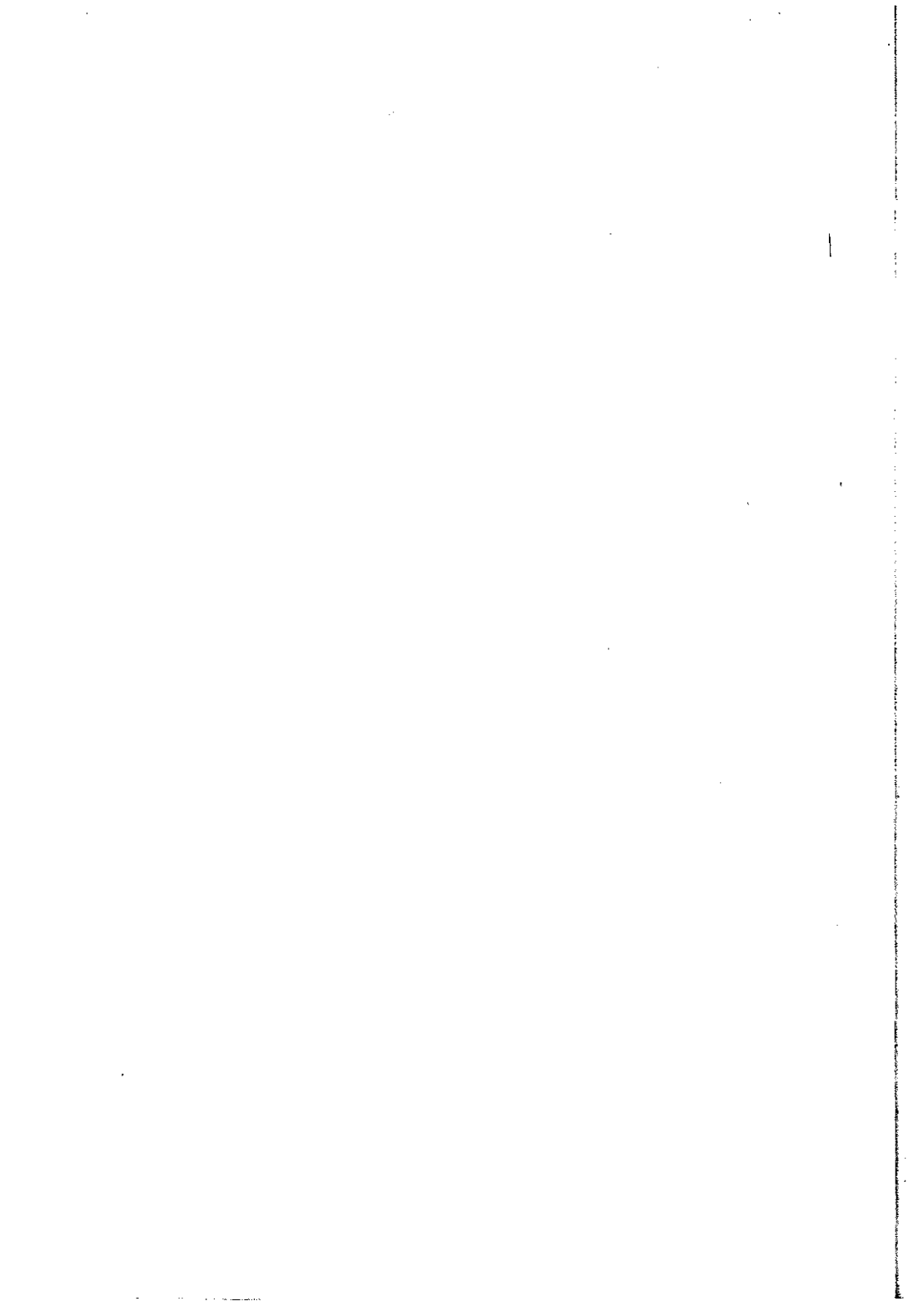
ção constitucional de funções entre cada um dos Poderes) e o princípio da legalidade (pois restringe direitos e disciplina matéria sujeita à lei em sentido formal).

O examinando deve demonstrar, ainda, que o Decreto viola o princípio da liberdade de exercício de atividades ou profissões, inscrito no artigo 5º, XIII da CRFB, que estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Por fim, deve ser apontada a violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, pois a medida prevista na lei, ainda que adequada à finalidade declarada, falha nos subprincípios da necessidade (que impõe a utilização, dentre as possíveis, da medida menos gravosa para atingir determinado objetivo) e da proporcionalidade em sentido estrito (que impõe a análise da relação custo-benefício da norma avaliada, de modo que o ônus imposto pela norma seja inferior ao benefício por ela engendrado, sob pena de inconstitucionalidade).

O examinando deve formular, expressamente, pedido de concessão da medida cautelar (a fim de suspender a vigência e a eficácia do decreto impugnado, pena de restar consolidada a violação) e, ao final, pedido de declaração da inconstitucionalidade do Decreto.

Deve ser requerida a oitiva do Ministério Público e da AGU.



CAPÍTULO 11

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

A ação declaratória de constitucionalidade surgiu com a promulgação da EC nº 03/1993, que alterou a redação do então art. 102, I, a, da CRFB/88, contemplando-a ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, com propósito contrário ao dela e com o objeto mais restrito.

A finalidade da ação é a de obter do STF uma decisão de cunho declaratório, quanto à constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo federal sobre o qual existiam sérias divergências jurisprudenciais, de acordo com o art. 14, III, da Lei nº 9.868/1999, afastando-se, dessa maneira, a insegurança jurídica gerada pela emissão de decisões judiciais contraditórias a respeito de lei ou ato normativo federal, que têm a seu favor a “presunção de constitucionalidade”.

► Objeto

O objeto da ADC é lei ou ato normativo primário federal, que pode ser também analisado em sede de ADI, excluídos os de âmbito estadual. Destarte, indispensável a demonstração do interesse de agir por meio de decisões que apresentem as controvérsias judiciais acerca da constitucionalidade da norma.

A legitimidade ativa e a capacidade postulatória seguem as mesmas regras já analisadas no capítulo da ADI.

► Concessão de medidas cautelares

Na forma do art. 21 da Lei nº 9.868/1999, é admissível, em sede de ADC, a concessão de liminares, dotadas de efeitos vinculantes. A concessão de liminar pode levar à suspensão do julgamento dos processos que tratem da norma objeto da ação até o julgamento definitivo da ADC. Caso este não ocorra em até 180 (cento e oitenta dias), cessarão os efeitos da liminar.

► O procurador-geral da República

Na forma do art. 103, § 1º, da CRFB/88: “O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.” Portanto, pede-se a sua intimação (ou oitiva) em sede de ADC.

► O advogado-geral da União

Não há previsão legal de atuação do AGU em sede de ADC.

► Caso hipotético

Diante da preocupação internacional com a violência doméstica e familiar contra a mulher e tendo em vista os diversos tratados internacionais ratificados, foi sancionada a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O Partido Político ABC criou departamento próprio para efetuar pesquisas sobre o número de casos de violência dessa natureza em determinadas localidades do país. Com a pesquisa concluída, constatou-se percentual significativo de decisões judiciais que entendiam pela não aplicação da referida lei. Dentre os argumentos apresentados, verificou-se como principal, o Princípio da isonomia previsto no art. 5º, I da CRFB/88. Inconformado com as decisões conflitantes, que ora aplicam a referida lei, ora afastam sua incidência sob o argumento de sua inconstitucionalidade, o Diretório Nacional do Partido Político, que possui representação no Congresso Nacional, deseja, em nome do partido, ver declarada a harmonia da lei para com o texto constitucional, a fim de que seja alcançado efeito para todos os indivíduos no território brasileiro. Afirma, ainda, a necessidade de solução urgente, já que há outras inúmeras ações pendentes de julgamento.

Na qualidade de advogado, redija a peça cabível atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos:

- a) competência do órgão julgador;
- b) legitimidade ativa e passiva;
- c) argumentos a favor da constitucionalidade da referida lei;
- d) tutela de urgência;
- e) requisitos formais da peça judicial proposta.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^a. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais).

PARTIDO POLÍTICO ABC, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº... e no TSE sob o nº..., por seu Diretório Nacional, com sede em ..., com fundamento no art. 102, I, "a" da CRFB/88, e nos dispositivos pertinentes da Lei nº 9868/99, por seu advogado infra-assinado..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE em defesa da Lei Federal nº 11.340/06, elaborada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que passa a expor.

I - DO OBJETO DA AÇÃO

Diante da preocupação internacional com a violência doméstica e familiar contra a mulher, e tendo em vista os diversos tratados internacionais ratificados, foi sancionada a lei ordinária federal 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Infelizmente, após a realização de uma pesquisa, constatou-se percentual significativo de decisões judiciais que entendem pela não aplicação da referida lei, sob o argumento principal de que a norma supostamente violaria o princípio da isonomia previsto no art. 5º, I da CRFB/88, por isso se faz necessária a confirmação de sua constitucionalidade.

II - DA LEGITIMIDADE ATIVA

O autor é legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, VIII da CRFB/88 e não precisa comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88.

Além disso, possui representação no Congresso Nacional e foi criado de acordo com a Lei 9096/95, estando, portanto, plenamente habilitado para o ajuizamento da presente ADC.

III - DA RELEVANTE CONTROVÉRSIA JUDICIAL

Conforme já relatado, após a realização de uma pesquisa, constatou-se percentual significativo de decisões judiciais que entendem pela não aplicação da referida lei, sob o argumento principal de que a norma supostamente atingiria o princípio da isonomia previsto no art. 5º, I da CRFB/88, o que comprova a relevante controvérsia judicial, requisito para a propositura da presente, segundo estabelece o art. 14, III, da Lei 9868/99.

IV - DA TUTELA DE URGÊNCIA

A possibilidade de concessão de medida de urgência em sede de ADC se encontra no art. 21, da Lei nº 9.868/99 e possui natureza cautelar.

O *fumus boni iuris* se justifica pelos argumentos apresentados ao longo da petição e pela documentação anexa.

Já o *periculum in mora* é comprovado pela existência de inúmeras decisões contróvertidas sobre a aplicação da norma objeto da ação, o que pode causar dano irreparável para as mulheres vítimas de violência.

V – DOS FUNDAMENTOS

A Ação Declaratória de Constitucionalidade tem sede no art. 102, I, a, da CRFB/88 e também na Lei 9.868/99.

O seu objetivo é o de confirmar a constitucionalidade de uma norma federal, cuja compatibilidade com a Constituição esteja sendo alvo de controvérsia judicial relevante, como é o caso da Lei nº 11.340/06.

Importante destacar que a referida norma configura um importante avanço na defesa da mulher, que ainda é vítima de violência doméstica no Brasil e no mundo.

Ademais, a lei reforça o compromisso firmado pela Constituição de 1988, que no seu art. 226, § 8º dispõe que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

VI – DOS PEDIDOS

Pelas razões acima expostas, o Partido requer:

a) que seja concedida cautelar para o fim de determinar que os juízes e Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da Lei Federal 11.340/06 e que seja ao final declarada a constitucionalidade da norma;

b) a juntada de documentos;

c) que sejam solicitadas informações ao Presidente da República e à Mesa do Congresso Nacional;

d) a oitiva do Procurador-Geral da República.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

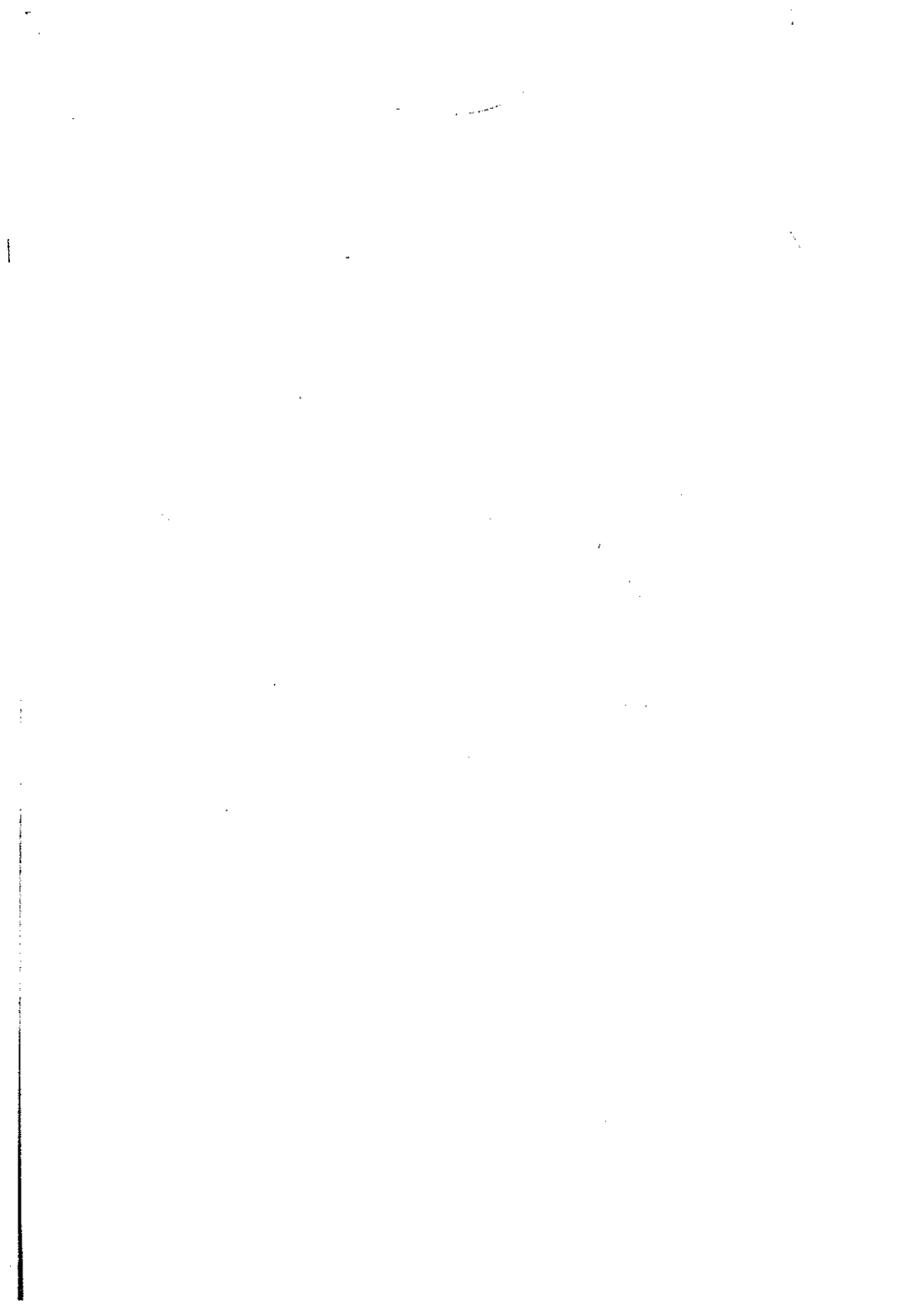
Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...



CAPÍTULO 12

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

Art. 103, § 2º, CRFB/88 – Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

O Constituinte de 1988 buscou inspiração na Carta portuguesa de 1976 para introduzir na realidade nacional a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, consagrando que não é inconstitucional apenas a norma que contraria o texto da Constituição, mas também, a inexistência da norma anunciada para que a Constituição possa se tornar real para o seu povo.

Recentemente a ADO ganhou reforço com a edição da Lei nº 12.063/2009 que acrescentou normas processuais relativas à ação na Lei nº 9.868/1999.

► Objeto

O fundamento da impugnação em sede de ADO, de acordo com o art. 103, § 2º, da CRFB, é o comportamento omissivo por parte do Poder Público. Pressupõe:

- 1) não cumprimento, pelo Poder Público competente para legislar naquele caso, da determinação de editar certa e determinada norma. Sendo assim, há o descumprimento de uma **ordem constitucional específica**;
- 2) a norma constitucional a ser regulamentada ter **eficácia limitada**.

Ressalte-se que na hipótese da Constituição atribuir mera faculdade de editar a norma ao legislador, ou determinar a realização de uma política pública específica, não cabe qualquer controle judicial por meio de ADO.

A omissão normativa pode ser total ou parcial.

► Legitimação Ativa

Os mesmos da ADI genérica, ou seja, os relacionados no art. 103, I a IX, da CRFB, aplicando-se, inclusive, as mesmas considerações tecidas sobre os legitimados universais e especiais e também no que tange à capacidade postulatória.

► Concessão de medidas cautelares

Não se admitia a concessão de medidas liminares em sede de ADO, haja vista que o STF, de acordo com a posição clássica, não pode atuar como legislador positivo.⁴¹

Entretanto, com a nova previsão da Lei nº 9.868/1999, é pacífica a possibilidade de concessão de cautelar, senão vejamos nos dispositivos abaixo transcritos:

Art. 12-F. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no art. 22, poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

41 “Desrespeito à Constituição. Modalidades de comportamentos inconstitucionais do Poder Público. (...) Salário mínimo. Satisfação das necessidades vitais básicas. Garantia de preservação de seu poder aquisitivo. (...) Salário mínimo. Valor insuficiente. Situação de inconstitucionalidade por omissão parcial. (...) **Inconstitucionalidade por omissão. Descabimento de medida cautelar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar incabível a medida liminar nos casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. Marco Aurélio; ADIn 267-DF, Rel. Min. Celso de Mello), eis que não se pode pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF. A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de identificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente. Impossibilidade de conversão da ação direta de inconstitucionalidade, por violação positiva da Constituição, em ação de inconstitucionalidade por omissão (violação negativa da Constituição)” (STF, ADI 1.439/DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.05.1996, DJ 30.05.2003) (grifamos).**

§ 1º A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. (...)

► O procurador-geral da República

Na forma do art. 12-E, § 3º, da Lei 9868/99, o Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo, por 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo para informações. Portanto, pede-se a sua intimação (ou oitiva) em sede de ADO.

► O advogado-geral da União

Não há necessidade de pleitear a atuação do AGU em sede de ADO.

► Caso cobrado no XIX Exame

Determinado partido político, que possui dois deputados federais e dois senadores em seus quadros, preocupado com a efetiva regulamentação das normas constitucionais, com a morosidade do Congresso Nacional e com a adequada proteção à saúde do trabalhador, pretende ajuizar, em nome do partido, a medida judicial objetiva apropriada, visando à regulamentação do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O partido informa, por fim, que não se pode compactuar com desrespeito à Constituição da República por mais de 28 anos. Considerando a narrativa acima descrita, elabore a peça processual judicial objetiva adequada. (Valor: 5,00)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^o. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

PARTIDO POLÍTICO ..., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº... e no TSE sob o nº..., por seu Diretório Nacional, com sede em ..., por seu advogado infra-assinado..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem propor a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO, com base no art. 103, §2º, da CRFB/88 e na Lei nº 9868/99 em face da Mesa do Congresso Nacional, tendo em vista a falta de norma regulamentadora do art. 7º, XXIII, da CRFB/88, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que passa a expor.

I – DA OMISSÃO INCONSTITUCIONAL

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

O autor é legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, VIII da CRFB/88 e não precisa comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88.

Além disso, possui representação no Congresso Nacional e foi criado de acordo com a Lei 9.096/95, estando, portanto, plenamente habilitado para o ajuizamento desta ADO.

III – DOS FUNDAMENTOS

– Art. 103, § 2º, da CRFB/88

– Lei 9.868/99

– Art. 7º, XXIII, da CRFB/88

Orientação do STF sobre a omissão inconstitucional

IV – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o Partido requer:

a) seja julgado procedente o pedido, para que seja declarada a mora legislativa do Congresso Nacional na elaboração da Lei específica do Art. 7º, inciso XXIII, da CRFB/88;

b) a juntada dos documentos anexos;

c) a oitiva da Mesa do Congresso Nacional;

d) a oitiva do Procurador-Geral da República.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 13

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

Art. 102, § 1º, CRFB/88. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, as mudanças ocorridas com o controle de constitucionalidade brasileiro com o advento da nova Constituição não conseguiram suprir algumas lacunas ainda existentes quanto à análise: do direito pré-constitucional, da controvérsia constitucional sobre normas revogadas e ainda, sobre o controle de constitucionalidade do direito municipal face à Constituição Federal.⁴²

Dentro desse panorama, nasceu a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), prevista no art. 102, § 1º, da CRFB/88. O referido dispositivo, entretanto, determinava a elaboração de uma norma regulamentando a nova ação, o que só foi feito em 1999, com a edição da Lei nº 9.882. Com isso, a ADPF ficou no completo “limbo jurídico” durante praticamente 11 (onze) anos!

► Que é preceito fundamental?

O parâmetro de proteção da ADPF, ao contrário da ADI é mais restrito, afinal é uma arguição de descumprimento de uma porção constitucional limitada: os preceitos fundamentais. Ainda que a Lei nº 9.882/1999 não tenha definido exatamente o conceito de preceito fundamental, de acordo com o STF,⁴³ configuraria o rol não exaustivo de preceitos funda-

42 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.305.

43 ADPF 33/PA, Plenário. Min. Rel. Gilmar Mendes, j. 07.12.2005, DJ 27.10.2006.

mentais: os direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 17), as cláusulas pétreas (art. 60, § 4º) e os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII). Uadi Lammêgo Bulos⁴⁴ ainda acrescenta ao rol já exposto de preceitos fundamentais os relativos aos princípios fundamentais (arts. 1º e 2º) e os que regem a Administração Pública (art. 37, *caput*).

► Cláusula de subsidiariedade

O art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 apresenta o caráter residual da ADPF quando afirma que só será admitida quando inexistir outro meio eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental.

Segundo orientação do STF, quando couber alguma das ações do controle concentrado federal para afastar a lesividade (ADI ou ADC, por exemplo), não caberá ADPF.

Em reforço ao caráter subsidiário da ação, o STF decidiu que se lei municipal violar ao mesmo tempo norma da Constituição Federal e da Constituição do Estado (norma de observância obrigatória), a lei deverá ser objeto de uma Representação de Inconstitucionalidade, com base no art. 125, § 2º, da CRFB, e não da ADPF.⁴⁵

► Objeto

Diante do caráter residual da ADPF, podem ser objeto da ação: normas pré-constitucionais, atos normativos secundários, leis distritais de natureza municipal e normas municipais.

► Legitimidade Ativa

De acordo com o art. 103, I a IX, da CRFB/88 c/c art. 2º da Lei nº 9.882/1999, os legitimados para a propositura da ADPF são os mesmos que podem ajuizar as demais ações do controle concentrado abstrato federal, vedada a propositura por cidadão, de acordo com o entendimento do STF.

44 LAMMÊGO BULOS, Uadi. *Constituição Federal Anotada*, 8ª ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.030.

45 STF, ADPF 100, Min. Rel. Celso de Mello, *Inf.* 532.

► Concessão de medidas cautelares

Conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 9.882/99, o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ainda acrescenta o § 3º: “a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”.

► O procurador-geral da República

Na forma do art. 7º, parágrafo único, da Lei 9.882/99, o Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá vista do processo, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações. Portanto, pedimos a intimação (ou oitiva) do PGR em sede de ADPF.

► O advogado-geral da União

Não há necessidade de pleitear a atuação do AGU em sede de ADPF.

► Caso cobrado no XX Exame de Ordem

O Prefeito do Município Alfa, preocupado com a adequada conduta no seu mandato, procura o presidente nacional do seu partido político Beta, o qual possui representação no Congresso Nacional, e informa que a Lei Orgânica do Município Alfa, publicada em 30 de maio de 1985, estabelece, no seu art. 11, diversas condutas como crime de responsabilidade do Prefeito, entre elas o não atendimento, ainda que justificado, a pedido de informações da Câmara Municipal, inclusive com previsão de afastamento imediato do Prefeito a partir da abertura do processo político. Informou, também, que a mesma Lei Orgânica, em seu art. 12, contém previsão que define a competência de processamento e julgamento do Prefeito pelo cometimento de crimes comuns perante Justiça Estadual de primeira instância. Por fim, informou que, em razão de disputa política local, houve recente representação oferecida por Vereadores da oposição com o objetivo de instaurar processo de apuração de crime de responsabilidade com fundamento no referido art. 11 da Lei Orgânica, a qual poderá ser analisada a qualquer momento. O partido político, após o devido trâmite interno estabelecido no seu estatuto, conclui que a norma municipal está em dissonância com a CRFB/88 e decide adotar providência judicial em relação

ao tema. Considerando a situação narrada, na condição de advogado(a) do partido político Beta, utilizando-se do instrumento constitucional adequado, elabore a medida judicial de controle objetivo cabível. (Valor: 5,00)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^o. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

PARTIDO POLÍTICO Beta, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº.. e no TSE sob o nº., endereço eletrônico ..., por seu Diretório Nacional, com sede..., vem, por seu advogado infra assinado..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, propor a presente ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL, com fundamento no art. 102, § 1º, da CRFB/88 e na Lei nº 9882/99 em face dos arts. 11 e 12 da Lei Orgânica do Município Alfa pelos motivos a seguir apresentados.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA

O autor é legitimado ativo para a propositura da ação, de acordo com o art. 103, VIII da CRFB/88 e não precisa comprovar a pertinência temática diante da sua importância para o regime democrático, na forma do art. 17, da CRFB/88.

Além disso, possui representação no Congresso Nacional e foi criado de acordo com a Lei 9096/95, estando, portanto, plenamente habilitado para o ajuizamento desta ADPF.

III – DO CABIMENTO DA ADPF – INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE SANAR A LESIVIDADE

– Art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99.

– Art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/99.

IV – DA IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

– Art. 2º (violação ao princípio da separação de poderes);

– Art. 22, inciso I, (violação à competência legislativa privativa da União); e

– Art. 29, *caput* e inciso X (que dispõem sobre os municípios e sobre as respectivas leis orgânicas, as quais devem observar os preceitos da Constituição da República, especialmente garantindo aos Prefeitos a prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça em crimes comuns).

– Súmula Vinculante 46 do STF: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

V – DA MEDIDA CAUTELAR

– Art. 5º, § 3º, da Lei 9.882/99.

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto requer:

a) que seja concedida a medida cautelar para sustar a eficácia do art. 11 e, por consequência, seja suspenso o trâmite da representação por crime de responsabilidade oferecida em desfavor do Prefeito. Posteriormente, que o pedido seja julgado procedente para que os arts. 11 e 12 sejam revogados em razão da incompatibilidade material com a Constituição;

- b) que seja ouvido o Procurador-Geral da República;
- c) que sejam ouvidos o Congresso Nacional e o Presidente da República;
- d) que sejam juntados os documentos anexos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fins procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 14

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

► Natureza jurídica e conceito

A ação civil pública é uma ação coletiva, de procedimento comum, que visa defender interesses metaindividuais, segundo preceitua o art. 1º, da Lei 7.347/85:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

II – ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

V – por infração da ordem econômica;

VI – à ordem urbanística;

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014).

VIII – ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei nº 13.004, de 2014, que entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial – 25/6/2014).

Possui natureza condenatória (art. 3º, da Lei 7.347/85), mas, à semelhança da ação popular, também pode pleitear a invalidação de ato ou contrato administrativo, ilegal, ilegítimo ou ilícito e lesivo ao patrimônio público, cultural, histórico ou ambiental. O ato impugnado também pode ser comissivo ou omissivo.

Segundo a doutrina majoritária, aplicamos à ação civil pública, por analogia, dispositivos da Lei nº 4.717/1965.

► Direitos metaindividuais

O art. 81, do CDC assim estabelece:

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

- I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
- II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
- III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Direitos Difusos são aqueles que se referem a grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexistente um vínculo jurídico ou fático muito preciso, possuindo objeto indivisível entre os membros da coletividade, compartilhável por número indeterminável de pessoas.

A titularidade é de pessoas indeterminadas e indetermináveis, vez que não há como determinar quem será beneficiado. Concerne a toda coletividade ou a parcelas dela, que não são possíveis de identificar, tendo em vista que são unidas por uma simples circunstância de fato ou contingencial extremamente mutável, o fato de residirem em determinado local ou região.

São características desses direitos: a inexistência de vínculo jurídico definido entre as partes; a impossibilidade de apropriação exclusiva e de quantificação da sua fruição; a indivisibilidade do objeto; ausência de vinculação a órgãos ou instituições (são fluidos na sociedade, estão distribuídos igualmente).

Exemplos apresentados pela doutrina relacionados ao meio ambiente: o direito ao ar puro, à preservação das espécies animais, à limpeza das águas, dentre outros.

São conceituados pelo Código de Defesa do Consumidor como transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

Direitos Coletivos também são inerentes a pessoas indeterminadas a princípio, mas determináveis, já que há uma relação jurídica que vincula os titulares do direito, sendo possível determinar o grupo de pessoas, pelo fato de existir um vínculo mais sólido entre elas.

O objeto é indivisível, e isso porque satisfaz a todos ao mesmo tempo. Os coletivos distinguem-se dos difusos, ambos indivisíveis, pela sua origem, na medida em que nestes o vínculo relaciona-se a dados acidentais ou factuais, enquanto naqueles a ligação dos integrantes do grupo, categoria ou classe decorre de uma relação jurídica.

São características desses direitos: o mínimo de organização em relação à identificação da titularidade; interesses de grupos ou classes determinadas; vínculo jurídico básico, comum a todos os integrantes do grupo.

Exemplos trazidos pela doutrina: membros de determinada categoria de trabalhadores, representada por certo sindicato, no sentido de que não ocorra alteração da regulamentação da jornada de trabalho ou do pagamento de horas diferenciadas.

Os direitos individuais homogêneos não são coletivos na sua essência, são formalmente coletivos devido ao tratamento processual que é dispensado a eles por opção do legislador. São Interesses de grupos determinados ou determináveis que compartilham danos divisíveis ou autônomos em razão de um fato comum.

Os titulares são determinados ou determináveis; essencialmente individuais, pois poderiam ser reparados em demandas individuais; o objeto final é divisível ou autônomo (normalmente associado à reparação de dano) e possuem origem comum.

Exemplos doutrinários: adquirentes de determinado medicamento que apresenta a mesma falha de produção, danosa à saúde dos usuários; venda de veículos produzidos por uma montadora contendo defeito em série que ocasiona danos similares aos adquirentes; investidores da bolsa de valores que sofreram lesão em razão de cobrança de taxa indevida na compra de ações de certa empresa.

► Espécies

Ação civil pública preventiva:	Ação civil pública repressiva:
antes de consumada a lesão	após a consumação do dano, com prazo de 5 (cinco) anos para a sua propositura, na forma do art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

► Legitimidade ativa

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública;

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V – a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

► Polo passivo

Aplicamos ao polo passivo da ACP, por analogia, os arts. 1º e 6º da Lei nº 4.717/1965. Os dispositivos determinam que todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem como pessoas naturais, beneficiárias diretas ou indiretas da lesão ao direito de todos, deverão figurar no polo passivo da ação, ou seja, há um verdadeiro litisconsórcio passivo necessário. Com isso, temos: a) pessoas públicas ou privadas e entidades mencionadas no artigo 1º da Lei de Ação Popular; b) autoridades, funcionários ou administradores que tiverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato; c) aqueles que por omissão tiverem dado oportunidade à lesão e os beneficiários do ato.

Atenção! Todos os beneficiários do ato ou contrato impugnado são litisconsortes necessários e a falta de citação é causa de nulidade absoluta do processo;

► Condenação em honorários advocatícios e em custas processuais

Por força do art. 12, da Lei 4.717/65, pede-se a condenação em honorários advocatícios e em custas processuais na Ação Civil Pública.

► Produção de Provas

Pede-se a produção de provas, tendo em vista o rito ordinário, previsto no art. 7º, da Lei 4.717/65.

► O papel do Ministério Público

O art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/85 determina que se o Ministério Público não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.

► Tutela de Urgência

A tutela de urgência é admitida na forma do art. 12, da Lei 7.347/85 e, na prática, muitas vezes possui natureza de verdadeira tutela antecipada, daí se aplicar também o art. 300, do CPC. Com isso, é importante comprovar os requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

► Competência

A fixação da competência para julgamento da ação civil pública (art. 2º, da Lei 7.347/85) é determinada em razão do local do dano e segue a regra da ação popular, ou seja, será processada em primeira instância. Normalmente, se o patrimônio lesado for da União, a competência será da Justiça Federal, se estadual ou municipal, será da Justiça Estadual.

Não há prerrogativa de foro funcional na ACP.

O art. 109, I, da CRFB/88 dispõe que: compete à justiça federal julgar as ações em que esteja no polo ativo ou passivo a União, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas públicas. As outras pessoas integrantes da administração pública não deslocam competência para a justiça federal. Então, nas ações contra estados, municípios e Sociedades de economia mista (mesmo que federal), a competência é da justiça estadual.

Exemplos:

União, Autarquia, Empresa Pública e Fundação Pública Federal	Estados, DF, Municípios, suas autarquias e fundações públicas
Juiz Federal de 1º grau.	Juiz Estadual de 1º grau – Vara de Fazenda Pública, pois são pessoas jurídicas de direito público.

Importante ressaltar que em regra geral não há competência originária de órgão colegiado para apreciação de ação civil pública, sendo esta do juiz de primeiro grau (federal ou estadual). Haverá, entretanto, competência originária do STF, nos seguintes casos:

- a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, “n”, da CRFB);
- as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta (art. 102, I, “f”, da CRFB).

► Diferenças entre a ACP e o mandado de segurança coletivo

A ação civil pública deve ser proposta no prazo de 5 anos, sendo repressiva (art. 21 da Lei 4.717/65 por analogia), enquanto o MS coletivo tem que ser impetrado no prazo máximo de 120 dias (art. 23 da Lei 12.016/09).

Os legitimados para a ACP estão elencados no art. 5º da Lei 7.347/85; os legitimados do MS coletivo encontram-se no art. 21 da Lei 12.016/09;

Dilação probatória: Havendo necessidade de produção de provas não será possível a utilização do MS coletivo, vez que o seu rito é sumário. Na ACP, admite-se a dilação probatória.

A competência para julgamento da ACP é fixada em razão do local onde ocorre o dano; no MS coletivo leva-se em conta a autoridade coatora.

No que tange ao objeto, enquanto o MS coletivo se presta a tutelar os direitos individuais homogêneos e os direitos coletivos em sentido estrito, a ACP tem como objeto, além dos apontados, os direitos difusos.

A ação civil pública possui natureza condenatória e pode pleitear eventuais reparações ao patrimônio comum, o que não se permite, em regra, em sede de MS Coletivo.

► Caso hipotético

O Prefeito do Município de Harmonia, localizado no Estado da Alegria e candidato à reeleição, determinou a instalação de outdoors nos edifícios históricos da cidade com o símbolo da campanha eleitoral e ainda dispensou o procedimento licitatório para contratar a empresa “Rápido Expresso” para colocação dos referidos outdoors.

O chefe do Executivo ainda admitiu, diretamente, no serviço público, sem concurso público, Mévio, Caio e Tício, para ajudá-lo na campanha eleitoral.

A “Associação Força Contra a Corrupção”, em funcionamento há dois anos, procura o seu escritório de advocacia, por meio de seu representante legal, Esculápio Neves, para fins de ajuizamento de uma ação em face dos danos causados ao patrimônio público do Município de Harmonia.

Na ação judicial cabível, aborde, necessariamente: a) a legitimidade ativa, b) a legitimidade passiva, c) os dispositivos constitucionais e legais violados pela autoridade indicada na situação problema, d) a tutela de urgência.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^o. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA... VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE HARMONIA DO ESTADO DA ALEGRIA

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

ASSOCIAÇÃO FORÇA CONTRA A CORRUPÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº..., endereço eletrônico..., com sede em..., por meio de seu representante legal, Esculápio Neves, vem, por seu advogado infra-assinado doc..., com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento nos termos da Lei 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do Prefeito do Município de Harmonia, do Município de Harmonia, da empresa "Rápido Expresso", de Mévio, Caio e Tício, que podem ser encontrados nos endereços...pelas razões que passa a expor.

I – SÍNTESE DOS FATOS

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

III – DA TUTELA DE URGÊNCIA

IV – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Violação aos princípios da: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37, *caput*, da CRFB/88).

- Violação aos seguintes dispositivos:

- art. 37, § 1º,

- art. 37, II,

- art. 37, XXI (todos da CRFB/88)

- Lei 7347/85

V – PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Associação que V. Ex^a. determine:

a) a concessão da tutela de urgência para retirada dos outdoors, desfazimento do contrato administrativo sem licitação e das contratações sem concurso público;

b) a citação dos réus nos endereços indicados na inicial;

c) a intimação do representante do Ministério Público;

d) a produção de todos os meios de prova em direito admitidas e a juntada de documentos;

e) a condenação dos réus em honorários advocatícios e custas processuais;

f) a procedência dos pedidos para confirmar a tutela de urgência.

Em cumprimento ao art. 319, VII do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 15

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) é uma ação eleitoral prevista na Constituição Federal, que tem por objetivo impugnar o mandato eletivo obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

O seu fundamento constitucional é extraído do art. 14, § 10 e § 11:

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.”

► Legitimados ativos

Segundo orientação majoritária, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar 64/90 para definição da legitimidade ativa. Portanto, podem ajuizar a AIME: Partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público.

Não há previsão de legitimidade ativa do cidadão para a propositura da ação.

► Legitimado passivo

Candidato diplomado, que pode ser, por exemplo: Vereador, Prefeito, Governador, Deputado Estadual...

► Competência

A competência é definida pelo juízo da diplomação, na forma do art. 2º, da Lei Complementar 64/90:

TSE – expede o diploma de	– Presidente; e – Vice-Presidente da República.	Exmº. Sr. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
TRE – expede o diploma de	– governadores e vices; – deputados estaduais e federais; – senadores e suplentes.	Exmº. Sr. Dr. Juiz Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da... Região.
Junta Eleitoral – expede o diploma de	– prefeitos e vice-prefeitos; e – vereadores.	Exmº. Sr. Dr. Juiz Eleitoral da ... Zona Eleitoral da Comarca de...

► Sigilo

Vale ressaltar que a tramitação da ação é sigilosa, nos termos do art. 14, § 11, da CRFB/88, que determina o segredo de justiça. Isso quer dizer que, embora o julgamento seja público, o andamento do processo se dá em segredo de justiça.

► Prazo

O prazo para ajuizar a ação é de 15 dias contados da diplomação, sendo que tal prazo tem natureza decadencial, não sendo interrompido nos sábados, domingos e feriados, e excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

► Prova pré-constituída

Na forma do art. 14, § 10, da CRFB/88, a ação deve ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

► Tutela de urgência

Podemos aplicar o art. 300, do CPC, comprovando-se os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

► Participação do Ministério Público

Pedimos a intimação do representante do MP em todas as Ações de Impugnação de Mandato Eletivo.

Efeitos da decisão na AIME:

- Cassação do mandato eletivo;
- Anulação dos votos.

► Caso hipotético

Tício, candidato a Vereador do Município WYX, resolveu distribuir dentaduras e remédios aos idosos eleitores da localidade em troca de votos, fato esse comprovado por vários documentos que registraram a referida compra. Em dezembro de 2012, após vencer as eleições, foi diplomado no referido cargo.

De posse de documentos que comprovam a irregularidade da campanha, Mévio, também candidato ao cargo, mas não eleito, ainda no prazo previsto na legislação, resolve ingressar com uma ação para invalidar a diplomação de Tício.

Elaboração e identificação da peça:

Regra dos 5 passos:	
Passo 1	resumo do caso
Passo 2	legitimidade ativa
Passo 3	legitimidade passiva
Passo 4	escolha da ação
Passo 5	órgão competente

► Peça processual

EXM^a. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA...ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE WYX DO ESTADO...

(pular aproximadamente 5 linhas em todas as petições iniciais)

MÉVIO, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., profissão..., portador da cédula de identidade nº ..., inscrito no CPF nº ..., endereço eletrônico ..., residente e domiciliado..., nesta cidade, vem, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, com escritório ..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 14, § 10, da CRFB/88 e na LC 64/90, ajuizar a presente **AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO** em face de Tício, diplomado no cargo de Vereador no dia... pelos motivos que a seguir expõe.

I – DA TEMPESTIVIDADE

No dia ... o Réu foi diplomado no cargo de Vereador do Município WYX. A presente impugnação é tempestiva, porque ajuizada dentro do prazo constitucional de 15 (quinze) dias contados da diplomação, segundo prevê o art. 14, § 10, da CRFB/88.

II – DOS FATOS

III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

IV – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer:

- a) a procedência do pedido para invalidar o diploma eleitoral obtido fraudulentamente e com abuso de poder econômico/político;
- b) A notificação do Réu para apresentar informações;
- c) A intimação do Ministério Público;
- d) A juntada de documentos;
- e) A condenação em honorários advocatícios e custas processuais;

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos procedimentais.

Termos em que

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº ...

CAPÍTULO 16

DA CONTESTAÇÃO

A petição inicial provoca a atividade jurisdicional do Estado, mas em nome da ampla defesa, do contraditório e do ideal de justiça, o juiz não pode decidir o caso apenas com base nas alegações formuladas pelo Autor; a parte contrária também precisa ser ouvida.

O Código de Processo Civil prevê duas espécies principais de respostas do Réu:

Contestação	Reconvenção
meio de defesa processual e material considerado mais importante; (art. 335, do CPC)	tem por objetivo garantir que o réu deduza uma pretensão de mérito em face do autor; (art. 343, do CPC)

A que mais nos interessa na segunda fase de Direito Constitucional é a Contestação, a principal peça de defesa do Réu.

A contestação é o meio processual utilizado pelo réu para opor-se formal ou materialmente ao direito do autor ou formular pedido contraposto. Como regra geral, o autor terá deduzido uma pretensão em juízo e o réu irá defender-se, e essa defesa, normalmente, é a contestação.

O prazo para apresentação da Contestação é de 15 dias, na forma do art. 335, do CPC.

A ausência de contestação gera a revelia, na forma do art. 344, do CPC. O art. 336, do CPC determina que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Então, os argumentos de defesa são divididos em preliminar (defesa processual) e mérito.

► Preliminares da Contestação

Segundo o art. 337, do CPC, antes de discutir o mérito, o réu deve alegar as preliminares, que se dividem em dilatórias ou peremptórias.

Dilatória é a defesa que retarda o andamento da marcha processual, não tem força para extingui-la, não provoca a extinção do processo sem julgamento de mérito. Ex.: incompetência absoluta.

Já a defesa peremptória é fulminante. Arguida e aceita extinguirá o processo SEM julgamento do mérito (art. 485, do CPC). Ex.: Litispendência, Coisa Julgada etc.

São defesas processuais dilatórias, com base no art. 337, do CPC.

I – INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução (art. 239, § 1º, do CPC).

II – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA

Juiz absolutamente incompetente é aquele a que falta competência para a causa, em razão da matéria, da pessoa ou da função (art. 62, do CPC). Exemplos de incompetência quanto à matéria: a ação deveria ter sido proposta na justiça federal, mas foi ajuizada na justiça estadual, ou então, a matéria é criminal, mas a ação foi ajuizada perante uma Vara Cível.

III – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

De acordo com o art. 293, do CPC: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

VII! – CONEXÃO

Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, do CPC). No caso de acolhimento da preliminar, os autos são remetidos ao juiz que teve preventa sua competência (art. 58, do CPC).

IX – INCAPACIDADE DA PARTE, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU FALTA DE AUTORIZAÇÃO

Levam-se em conta os pressupostos de constituição e desenvolvimento para que a relação processual se estabeleça e se desenvolva eficazmente.

Se acolhido pelo juiz não extingue, desde logo o processo, mas sim enseja oportunidade à parte contestada para sanar o vício encontrado (art. 321, do CPC).

Se o autor não cumprir a diligência, é que, então, haverá a extinção do processo. Assumindo a *defesa processual dilatória* a figura de *exceção peremptória* (parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, I, do CPC).

XII – FALTA DE CAUÇÃO OU DE OUTRA PRESTAÇÃO QUE A LEI EXIGE COMO PRELIMINAR

O juiz, ao acolher tal arguição deve ensejar oportunidade ao autor para sanar a falha.

Se não houver o suprimento, no prazo determinado, a preliminar assumirá *força de peremptória* e o juiz decretará, então, a extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 485, X, do CPC).

XIII – INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De acordo com o art. 100, do CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

São defesas processuais peremptórias, com base no art. 337, do CPC.

IV – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Por extinguir o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC).

V – PEREMPÇÃO

Por extinguir o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, V, do CPC).

VI – LITISPENDÊNCIA

Há *litispendência* quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3º, do CPC). Uma ação é *idêntica* à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC), requisito necessário para haver litispendência.

A litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, V do CPC.

VII – COISA JULGADA

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4º, do CPC).

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC).

A coisa julgada leva à extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, V do CPC.

X – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

O juízo arbitral (Lei 9.307 / 1996) é modo de excluir a jurisdição estatal para solucionar o litígio. Se as partes convencionaram o compromisso para julgamento através de árbitros, será ilegítima a atitude de propor ação judicial sobre a mesma lide.

Haverá a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, VII, do CPC, quando houver o acolhimento, pelo juiz, da alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência.

XI – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL

Ocorre quando não concorrem as condições necessárias para que o juiz possa examinar o mérito da causa, relativo à legitimidade das partes ou ao interesse processual do autor (art. 485, VI, do CPC).

► Defesa de mérito

A defesa de mérito é baseada na relação jurídica material, ou seja, envolve o próprio assunto apresentado na petição inicial. O réu deverá impugnar todos os argumentos apresentados pelo autor, buscando a improcedência do pedido e provocando a extinção do processo com julgamento de mérito.

► Estrutura da Contestação

Os requisitos da Contestação podem ser obtidos a partir dos incisos do próprio art. 319 do CPC:

- endereçamento ao Juiz ou Tribunal que determinou a citação do réu e indicação do número do processo;
- nomes das partes;
- defesa processual e posteriormente defesa de mérito;
- síntese dos fatos;
- conclusão (ou pedido) – pela extinção do feito sem ou com decisão de mérito; requerimento de provas, condenação do autor nos ônus sucumbenciais...

Não há valor da causa na Contestação.

► Caso hipotético

Tício, brasileiro, casado, vereador, nascido e domiciliado em Porto Alegre – RS, indignou-se ao saber, em janeiro de 2014, por meio da imprensa, que Caio, Deputado Estadual e candidato à reeleição (além de seu desafeto político), estaria envolvido em processo licitatório fraudulento e que havia realizado inúmeras reformas suntuosas e desnecessárias em seu gabinete utilizando o dinheiro público. O Deputado declarara em entrevistas que os gastos com a reforma seriam necessários para a manutenção da representação adequada ao cargo que exerce e que todo o procedimento havia sido realizado de acordo com a lei. Sem provas contra o Deputado, mas inconformado com a suspeita anunciada pela mídia, Tício procurou ajuda de profissional da advocacia para aconselhar-se a respeito da providência legal que poderia ser tomada no caso e o advogado ajuizou uma Ação Popular contra Caio perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tendo em vista que se tratava de Deputado Estadual com foro por prerrogativa de função. O Tribunal determinou que Caio se manifestasse sobre a ação.

Na qualidade de advogado(a) constituído(a) por Caio, redija a medida judicial mais apropriada em sua defesa.

► Peça processual

EXMº. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

(3 linhas, em média)

Processo nº ...

(2 linhas, em média)

Caio, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., Deputado estadual, portador do RG nº e do CPF nº..., endereço eletrônico ..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, com escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, vem à presença de V. Exª., nos termos do art. 336, do CPC, apresentar a presente CONTESTAÇÃO à ação popular proposta por Tício, já qualificado na petição inicial, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DA SÍNTESE DA INICIAL

II – PRELIMINARMENTE

– DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

III – MÉRITO

IV – DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, requer o réu a V. Exª.:

- a) preliminarmente, seja reconhecida a defesa processual apresentada pelo réu;
- b) no mérito, que julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor nos ônus da sucumbência;
- c) provar o alegado por todos os meios de prova previstos em lei, especialmente pelos documentos ora juntados aos autos.

Termos em que

Pede deferimento.

Local... e Data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 17

VISÃO GERAL DOS RECURSOS

Proferida uma decisão judicial, é comum que a parte que sucumbiu não fique satisfeita com o resultado que não a beneficiou e, com isso, tentará reverter o que foi decidido por meio de um dos recursos previstos no ordenamento jurídico.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira⁴⁶: “recurso é o remédio voluntário, idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”.

Espécies de recursos previstos no CPC

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

- I - apelação;
- II - agravo de instrumento;
- III - agravo interno;
- IV - embargos de declaração;
- V - recurso ordinário;
- VI - recurso especial;
- VII - recurso extraordinário;
- VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
- IX - embargos de divergência.

46 Barbosa Moreira, José Carlos. *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. V, p. 233, Editora Forense, 2005.

► Princípios norteadores

- **Princípio do duplo grau de jurisdição:** Para grande parte da doutrina, não constitui garantia constitucional, pois, além de inexistir previsão expressa (há referência do texto constitucional apenas à competência dos tribunais para julgamento de recursos e acesso à justiça), a própria CRFB/88 admite hipóteses de instância única (competência originária dos Tribunais Superiores, por exemplo). Pode ser considerado um princípio implícito.
- **Princípio da singularidade:** A regra é a de que para cada decisão haja apenas um recurso adequado para impugná-la.
- **Princípio da taxatividade:** Os recursos estão expressamente previstos em lei (CPC, Lei dos Juizados Especiais Cíveis, dentre outras).
- **Princípio da Fungibilidade:** Dá-se dá diante da existência de zona cinzenta sobre o recurso cabível, tendo como requisitos a dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro, e respeito ao prazo.

► Objetivos principais do Recurso

O erro na decisão que pode embasar o cabimento do recurso pode ser *in procedendo* e/ou *in judicando*.

O erro *in procedendo* consiste no erro do juiz ao proceder. É um erro de forma. O magistrado inobserva os requisitos formais necessários para a prática do ato, culminando num decisório nulo. É o exemplo da sentença que falta parte dispositiva ou a que concede pedido que a parte autoral não postulou (sentença *extra petita*). Diante disso, o recorrente deve pleitear a INVALIDAÇÃO da sentença e não a sua REFORMA.

De outro norte, no que atine ao **erro *in judicando***, este consiste no ato pelo qual o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, seja porque erra na interpretação da lei, seja por que não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma. O magistrado erra ao julgar. Tal erro recai sobre o próprio conteúdo que compõe o litígio. É erro material. Enseja a REFORMA da decisão e não INVALIDAÇÃO.

Nada impede que o recorrente aponte, em um mesmo recurso, a existência de erro de forma e de julgamento.

► Efeitos dos recursos

- **Suspensivo:** suspende os efeitos da decisão impedindo a sua consumação até o julgamento do recurso. Sendo a sentença condenatória, o efeito suspensivo obsta a execução provisória da decisão.
- **Devolutivo:** comum a todos os recursos, este efeito adia a formação da coisa julgada e propicia o exame do mérito do recurso.

► Natureza da "decisão"

- **Decisão Interlocutória:** o juiz decide algum incidente no processo (concessão de tutela de urgência ou não...), mas não põe fim ao processo.
- **Sentença:** é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, conforme o art. 203, § 1º, do CPC.
- **Acórdão:** quando se tratar de decisão do **órgão colegiado do Tribunal**, nos termos do art. 204, do CPC.
- **Decisão monocrática:** proferida pelo relator do recurso.

Recursos cabíveis:

Em 1º grau de jurisdição:	• Da sentença, cabe Apelação (art. 1.009, do CPC) • De determinadas decisões interlocutórias cabe Agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC) • Do Despacho, decisão que simplesmente dá andamento ao processo e não é dotada de caráter decisório, não cabe recurso (art. 1.001, do CPC)	
No Tribunal:	• Dos Acórdãos, podem caber:	• Recurso Ordinário Constitucional • Recurso Extraordinário • Recurso Especial • Embargos de Divergência
	• Das decisões monocráticas dos Relatores:	• Agravo interno • Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário

Obs.: Os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer espécie de decisão!

► Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito

Para que um recurso seja admitido, a legislação processual prevê uma série de exigências que precisam ser cumpridas. Apenas se observados os pressupostos de admissibilidade é que os recursos serão apreciados no seu mérito, pelo órgão competente.

No juízo de admissibilidade é preciso comprovar, necessariamente, os seguintes requisitos: a legitimidade, o interesse, a tempestividade, o cabimento e o preparo.

Pedimos ao Juízo que avaliará a admissibilidade do recurso (por meio de uma Peça de Interposição) que ele seja “conhecido e recebido” e, ao Juízo de Mérito, que o recurso seja “conhecido e provido”.

Não há valor da causa nos recursos.

CAPÍTULO 18

APELAÇÃO

O art. 1.009 do CPC indica que da sentença caberá apelação (arts. 485 e 487, do CPC). Relembramos que sentença é o ato em que há resolução do mérito ou em que o processo é extinto em primeiro grau (no âmbito estadual ou federal), sem resolução do mérito, conforme o art. 203, § 1º, do CPC.

A Apelação permite a ampla proteção ao direito subjetivo do recorrente, admitindo a análise das matérias de direito e de fato.

Segundo o art. 1.010, do CPC, a apelação será interposta por petição dirigida ao juiz da causa (a peça de interposição) e, na sequência, a petição com as razões recursais deve ser dirigida ao órgão colegiado julgador. A petição de interposição hoje na Apelação é uma formalidade que deve ser cumprida com o intuito de que o Juízo de origem determine a intimação do recorrido para oferecer as contrarrazões. Não há mais juízo de admissibilidade na apelação.

Também é importante destacarmos que na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC: “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Com isso, quando a decisão interlocutória não puder ser impugnada por meio do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), poderá ser questionada em preliminar de apelação, ou, até mesmo, como objeto principal do recurso.

A apelação será recebida em seu efeito devolutivo, e de acordo com o art. 1.012, do CPC, também terá efeito suspensivo.

Entretanto, o § 1º do citado dispositivo trata de hipóteses, além de outras previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. É o caso da sentença que:

- I - homologa divisão ou demarcação de terras;
- II - condena a pagar alimentos;
- III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Na forma do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interpor e para responder a Apelação é de 15 (quinze) dias.

Além disso, salvo concessão de gratuidade de justiça, é preciso recolher o preparo e custas de porte de remessa e de retorno (art. 1.007, do CPC) e a guia de recolhimento deverá ser anexada à peça processual.

Remissões importantes!

Lei 9.597/97	Lei 4.717/65	Lei 12.016/09
Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o <i>habeas data</i> cabe apelação.	Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.	Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

► Caso concreto

(OAB XI Exame)

Fábio é universitário, domiciliado no Estado K e pretende ingressar no ensino superior através de nota obtida pelo Exame Nacional, organizado pelo Ministério da Educação. Após a divulgação dos resultados, Fábio é surpreendido com seu baixo desempenho nas questões discursivas, a transparecer que não corrigiram adequadamente sua prova, ou deixaram de lançar ou somar as notas das questões, o que inviabiliza seu ingresso na entidade preferida. Não há previsão de vista de prova e nem de recurso administrativo no edital, sendo certo que existe agente público do Ministério da Educação responsável pelo exame em cada estado da federação, denominado de Coordenador Estadual do Exame Nacional, sediado na capital. Fábio requereu vista de prova e revisão da mesma ao Coordenador Estadual do Exame Nacional, tendo o seu pedido sido indeferido, por ausência de previsão editalícia. Inconformado, Fábio contrata advogado que impetra mandado de segurança, objetivando ter

vista da prova, tendo a liminar sido indeferida, sem interposição de recurso. Após trinta dias de tramitação, surge sentença que julga improcedente o pedido, confirmando a legalidade da recusa de acesso à prova por falta de previsão no edital. A decisão restou clara, sem qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Fábio, por meio do seu advogado, apresenta o recurso pertinente.

Redija a peça recursal cabível ao tema. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

Elaboração e identificação da peça:

3 Passos:	
Passo 1	identificação da decisão objeto do recurso
Passo 2	verificar o recurso cabível para impugnar a decisão
Passo 3	verificar se há ou não peça de interposição

► Peça processual

(primeira folha, peça de interposição)

**EXM^o. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA ... VARA FEDERAL ... DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO ESTADO K. (Juízo recorrido)**

(3 linhas, em média)

Processo n^o:...

(2 linhas, em média)

Fábio, já qualificado nos autos do Mandado de Segurança de número em epígrafe, que move em face do Coordenador Estadual do Exame Nacional, inconformado com a sentença proferida às fls. ..., vem, por seu advogado, conforme procuração anexa, com escritório..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, interpor, tempestivamente, a presente APELAÇÃO nos termos do artigo 1.009, do CPC, esperando que V. Exa determine o requerimento da intimação do recorrido para oferecer as contrarrazões, e, que os autos sejam remetidos ao Tribunal Regional Federal da ... Região.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB n^o...

(segunda folha)

AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ... REGIÃO

(1 linha)

APELANTE: FÁBIO

(1 linha)

APELADO: Coordenador Estadual do Exame Nacional

(1 linha)

RAZÕES DE APELAÇÃO

I. TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo, tendo em vista que foi interposto no prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

II. CABIMENTO

O recurso cabível em face de uma sentença de juiz de primeiro grau é a apelação, segundo prevê o art. 1.009, do CPC.

A apelação em face de sentença denegatória de mandado de segurança também está presente no art. 14, da Lei 12.016/09.

III. PREPARO

O preparo e o porte de remessa e de retorno foram devidamente recolhidos, na forma do art. 1.007, do CPC.

IV. BREVE RELATO DOS FATOS

(narrativa dos principais atos do processo até a sentença = inicial, defesa, principais atos probatórios e a sentença).

Por sua vez, o Magistrado recorrido prolatou sentença julgando improcedente o pedido formulado pelo ora Apelante e, como será demonstrado a seguir, a sentença merece ser reformada.

III. RAZÕES PARA REFORMA.

(fundamentos jurídicos para a reforma ou anulação da sentença recorrida)

Art. 5º, LXIX

Lei 12.016/09

Princípio da legalidade (Art. 5º, II, da CRFB/88)

Princípio da publicidade (Art. 37, *caput*, da CRFB/88)

Direito de petição (Art. 5º, XXXIV, da CRFB/88)

IV. PEDIDOS

Por todo o exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para reforma da sentença recorrida para acolher o pedido inicial...

Requer, ainda, a condenação do Recorrido nos ônus da sucumbência.

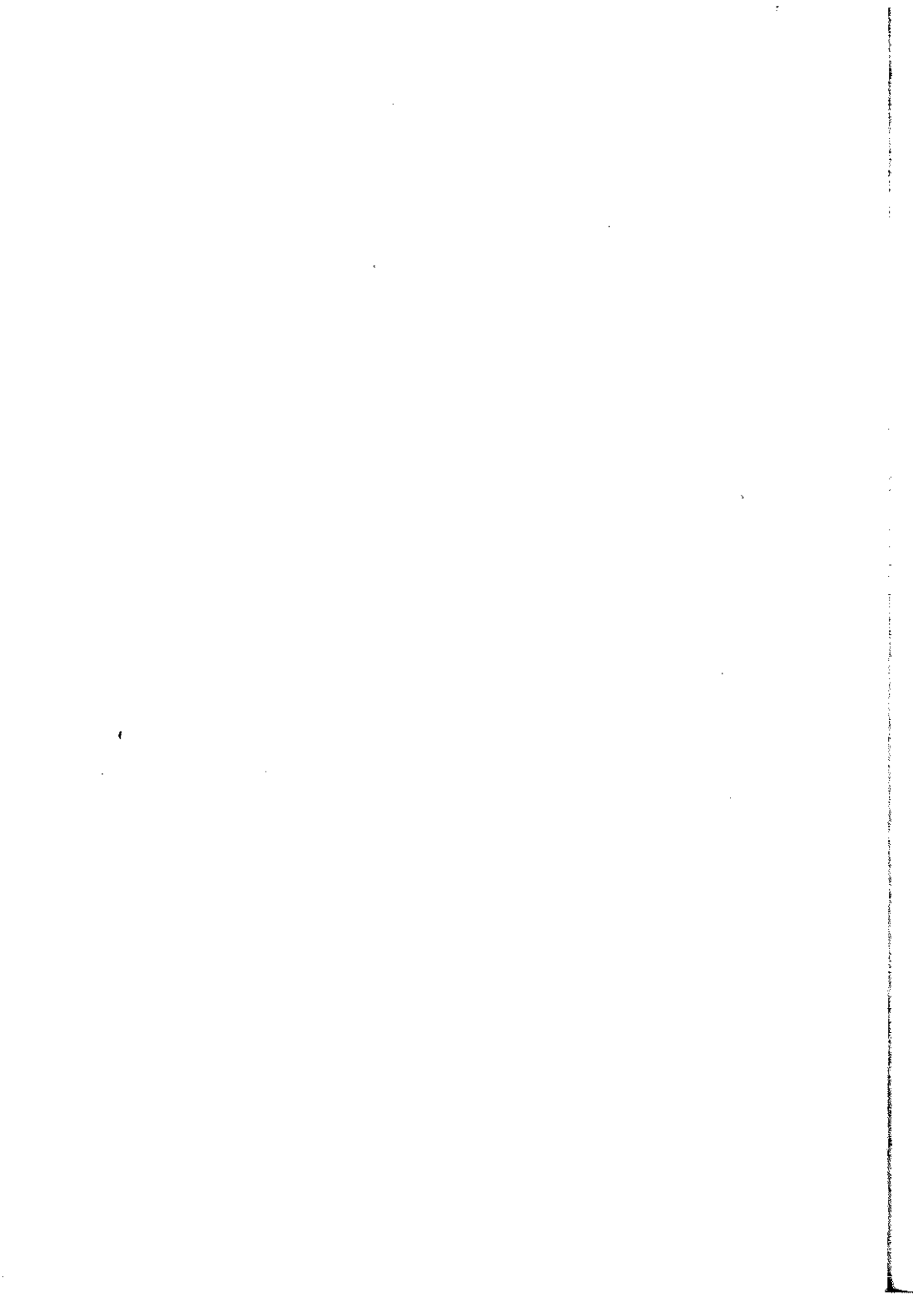
Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...



CAPÍTULO 19

AGRAVOS

Os agravos são recursos cabíveis em face de decisões interlocutórias, ou seja, aquelas proferidas antes da prolação da sentença, tais como: as que deferem ou não a apresentação de provas (ex.: oitiva de testemunhas, provas documentais), as decisões relativas à gratuidade de justiça...

São dois tipos de agravo, segundo a doutrina:

contra decisão de 1º grau:	contra decisão de 2º grau:
Agravo de instrumento.	o agravo pode ser interno, ou agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário.

Estudaremos a seguir os principais aspectos de cada um dos Agravos.

► Agravo de Instrumento

1) **BASE LEGAL:** Arts. 1.015 a 1.020, do CPC.

2) **CABIMENTO:** É o recurso cabível em face de decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de 1º grau, mas apenas quando versarem sobre: tutelas provisórias; mérito do processo; rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC; decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário; outros casos expressamente referidos em lei. São hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.

3) **PRAZO:** 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC).

4) **PROCEDIMENTO:**

- Não há necessidade de peça de interposição.
- Há preparo (arts. 1.007 e 1.017, § 1º, do CPC).
- É encaminhado diretamente ao Tribunal.
- A petição deve atender aos requisitos do art. 1.016, do CPC e ser instruída na forma do art. 1.017, do CPC, conforme abaixo transcrito:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I – os nomes das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”	“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. [...]”.
---	---

- Recebido o AI no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator adotará as providências previstas no art. 1.019, do CPC, no prazo de cinco dias.

5) **TUTELA DE URGÊNCIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO**

O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

Para pleitear a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante deverá comprovar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com base no art. 300, do CPC.

► Caso concreto – cobrado na 2ª fase de Dir. Administrativo

Norberto, brasileiro, desempregado e passando por sérias dificuldades econômicas, domiciliado no Estado “X”, resolve participar de concurso público para o cargo de médico de hospital estadual. Aprovado na fase inicial do concurso, Norberto foi submetido a exames médicos, através dos quais se constatou a existência de tatuagem em suas costas. Norberto, então, foi eliminado do concurso, com a justificativa de que o cargo de médico não era compatível com indivíduos portadores de tatuagem.

Inconformado, Norberto ajuizou ação ordinária em face do Estado, de competência de vara comum, com pedido liminar, na qual requereu (i) a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso; e (ii) que lhe fosse deferida a possibilidade de realizar as demais etapas do certame, com vaga reservada.

1. O juízo de 1ª instância indeferiu o pedido liminar, em decisão publicada ontem, pelos seguintes motivos: 1. Os pedidos de anulação do ato de eliminação e de reserva de vaga não seriam possíveis, pois significariam atraso na conclusão do concurso;

2. A Administração Pública possui poder discricionário para decidir quais são as restrições aplicáveis àqueles que pretendem se tornar médicos no âmbito do Estado, de forma que o autor deverá provar que a decisão foi equivocada.

Diante do exposto, e supondo que você seja o advogado de Norberto, elabore a medida judicial cabível contra a decisão publicada ontem, para a defesa dos interesses de seu cliente, abordando as teses, os fundamentos legais e os princípios que poderiam ser usados em favor do autor.

► Elaboração e identificação do recurso

3 Passos:	
Passo 1	identificação da decisão objeto do recurso
Passo 2	verificar o recurso cabível para impugnar a decisão
Passo 3	verificar se há ou não peça de interposição

► Peça processual

EXM^a. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO X

(3 linhas, em média)

Processo nº:...

(2 linhas, em média)

Norberto, já qualificado nos autos da Ação Ordinária que move em face do Estado X, inconformado com a decisão de fls. ..., vem, por seu advogado, conforme procuração anexa, com escritório..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, interpor, tempestivamente, **AGRAVO DE INSTRUMENTO** nos termos do artigo 1.015, do CPC, esperando que seja conhecido e provido de acordo com as razões a seguir apresentadas.

Em cumprimento ao art. 1.016, IV, do CPC, informa o agravante nome e endereço dos advogados constantes do processo:

Pejo agravante:

Pelo agravado:

I – DA TEMPESTIVIDADE

II – DO CABIMENTO

III – DO PREPARO

IV – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

V – DA DOCUMENTAÇÃO (art. 1.017, I, do CPC)

VI – SÍNTESE DOS FATOS

VII – DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO

(de acordo com a Banca)

Em primeiro lugar, é necessário que o examinando identifique, no caso concreto, a violação do princípio da legalidade tendo em vista que as restrições de acesso aos cargos e empregos públicos devem estar previstas em lei.

Em segundo lugar, o examinando deve alegar a violação ao princípio do livre acesso aos cargos públicos que determina que só podem ser exigidos requisitos diferenciados de acesso quando a natureza ou complexidade do cargo a ser ocupado o exigirem (Art. 37, I e II, da CRFB/88).

Também se atribuirá pontuação para o examinando que identifique o fundamento 2 da decisão agravada como equivocado tendo em vista a aplicação, *in casu*, dos princípios da proporcionalidade/razoabilidade, que delimitam o exercício do poder discricionário, tendo em vista que a referida restrição (tatuagem) não tem qualquer relação com o desempenho do cargo de médico, eis que não é medida adequada, necessária nem proporcional em sentido estrito, para que a Administração atinja os fins que pretende com a restrição ilegítima.

Por último, há que se refutar os argumentos de que "Os pedidos de anulação do ato de eliminação e de reserva de vaga não seriam possíveis, pois significariam atraso na conclusão do concurso", haja vista que não foi formulado qualquer pedido de suspensão ou interrupção do mesmo, mas tão somente que fosse garantido ao agravante o direito de prestar as fases seguintes do concurso.

VIII - CONCLUSÃO

Diante do exposto, requer este Agravante que seja reconsiderada a presente decisão para fins de...

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e Data...

Advogado...

OAB nº...

► Agravo Interno

1) **BASE LEGAL:** Art. 1.021, do CPC.

2) **CABIMENTO:**

- É o recurso cabível em face de certas decisões monocráticas tomadas por parte do relator de um recurso, a fim de que seja o mesmo apreciado pelo órgão colegiado competente.
- O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, de acordo com o art. 1.021, § 2º, do CPC.

3) **PRAZO:** 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC).

4) **PROCEDIMENTO:**

- Não há preparo.
- Há peça de interposição dirigida ao Relator do Recurso e as Razões ao Tribunal.
- Há possibilidade de juízo de retratação, ou seja, o relator poderá voltar atrás em sua decisão.
- Se o relator não se retratar, proferirá o seu voto e apresentará o processo em mesa para julgamento do colegiado.
- Se o agravo interno for provido, o recurso (inicialmente não admitido) terá seguimento para julgamento colegiado.
- Há possibilidade de imposição de multa caso o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, na forma do § 4º do art. 1.021, do CPC.

Atenção! Na forma dos parágrafos únicos dos arts. 4º, 12-C e 15 da Lei nº 9.868/99, da decisão do relator que indeferir liminarmente petição inicial inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente em sede de ADI, ADO e ADC, caberá agravo interno. O mesmo se aplica para a ADPF de acordo com o § 2º do art. 4º da Lei nº 9.882/99.

► Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário

1) **BASE LEGAL:** Art. 1.042, do CPC.

2) **CABIMENTO:** É o recurso cabível especificamente em face da decisão que não admitir o recurso especial ou o recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

3) **PRAZO:** 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC).

4) **PROCEDIMENTO:**

- Deverá ser interposto um agravo para cada recurso não admitido.
- Há peça de interposição e a petição deverá ser dirigida ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de origem.
- Não há preparo (art. 1.042, § 2º, do CPC: “independe do pagamento de custas e despesas postais”).
- O agravado será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias.
- Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente.

CAPÍTULO 20

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Segundo estabelece o art. 1.022, do CPC, são oponíveis os embargos de declaração contra decisão (seja ela interlocutória, sentença ou acórdão) a fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

O prazo para a oposição (o termo adequado é opor e não interpor embargos) é de 5 dias (art. 1.023, do CPC) e a sua propositura interrompe o prazo para a interposição de outros recursos.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final (art. 1.026, § 3º, do CPC).

Ademais, de acordo com o § 4º, do art. 1.026, do CPC, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios.

Não há peça de interposição, sendo o recurso dirigido diretamente ao juiz monocrático ou ao relator da decisão ou do recurso.

Não há preparo (art. 1.023, do CPC).

Aspectos importantes:

- **Súmula 98 do STJ:** Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
- **Súmula 211 do STJ:** Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal *a quo*.
- Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.868/99, a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ADI ou em ADC não pode ser objeto de ação rescisória, bem como é irrecorrível, **ressalvada a possibilidade de oposição de embargos de declaração**.
- Em regra, não cabe a oposição de embargos de declaração para fins de **modulação dos efeitos da decisão de mérito proferida em sede de controle concentrado**, salvo no caso de ter havido pedido nesse sentido antes do julgamento da ação e não ter o STF se manifestado sobre o mesmo, tampouco modulado os efeitos. Há que se ressaltar que, em caso recente, esta regra foi mitigada (Ver ADI nº 3601).

► Modelo simples de Embargos de Declaração

EXM^o. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA...VARA...DA COMARCA DE...DO ESTADO...
(Ou Tribunal, dependendo do caso)

NOME, nacionalidade..., estado civil (ou existência de união estável)..., profissão..., portador do RG nº. e do CPF nº..., endereço eletrônico..., residente e domiciliado..., nesta cidade, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa..., com escritório ..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, com fundamento no art. 1.022, do CPC, nos autos da Ação... que move em face de (ou que lhe é movida por), vem opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** nos termos a seguir aduzidos.

I – TEMPESTIVIDADE

II – SÍNTESE DOS FATOS

III – DA OMISSÃO (OU DA OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO)

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, aguarda o Embargante sejam os presentes embargos conhecidos e providos, para que a sentença (ou acórdão) embargada seja completada no tocante à omissão...

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e Data...,

Advogado...

OAB nº...

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL

Os recursos podem ser divididos entre ordinários e extraordinários. São ordinários aqueles recursos que tenham por objeto próximo a proteção do direito subjetivo do recorrente, que permitam a discussão das matérias de direito e de fato e que tenham admissibilidade geral não se sujeitando a requisitos especialíssimos (Ex.: a Apelação). Os extraordinários (RE e RESP), com sede na Constituição, restringem a análise à matéria de direito, exigem a comprovação de prequestionamento, além de outras condições de admissibilidade.

Nesse sentido, o Recurso Ordinário Constitucional (ROC), denominada por alguns autores de “Apelação Constitucional”, é verdadeiramente um recurso ordinário muito embora sua previsão seja constitucional.

O ROC é dirigido ao STF e ao STJ, exclusivamente nas hipóteses disciplinadas nos art. 102, II, e 105, II, da CRFB/88. Não há ROC fora da Constituição!

► Recurso Ordinário Constitucional para o STF

Na forma do art. 102, II, a, da CRFB/88, o STF julgará pelo presente recurso, as decisões **DENEGATÓRIAS** proferidas em *habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* e mandado de injunção, em **ÚNICA** instância, pelos tribunais superiores (são casos em que os tribunais superiores têm competência originária para julgamento do remédio).

Por se tratar de recurso cabível apenas quando houver decisões denegatórias nas ações constitucionais mencionadas, apenas o impetrante tem legitimidade para interpô-lo, de forma que o réu, ante uma decisão concessiva, deverá valer-se de outro recurso.

Decisão denegatória significa além da decisão que julga improcedente o pedido, as que extinguem o processo sem apreciação do mérito.

O art. 102, II, b, da CRFB/88, estabelece que também caberá ROC em face de sentença proferida no julgamento de crime político⁴⁷ (art. 109, IV), ou seja, diferentemente dos demais casos, esse é um ROC em face de decisão de primeiro grau da justiça federal!

O prazo para interposição do recurso ordinário constitucional nas hipóteses acima apresentadas é de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC).

Salvo nas hipóteses de ROC em *habeas data* e em *habeas corpus* (diante da gratuidade dos dois institutos), há necessidade de recolhimento do preparo e das custas com o porte de remessa e de retorno (art. 1.007, do CPC).

O recurso é dividido na peça de interposição e nas razões recursais. Poderá ser interposto perante o Presidente do tribunal recorrido (STJ, TST, TSE ou STM) ou no caso do art. 102, II, b, perante o juízo de primeiro grau federal. A petição de interposição hoje no ROC é uma formalidade que deve ser cumprida com o intuito de que o Juízo de origem determine a intimação do recorrido para oferecer as contrarrazões. Não há mais juízo de admissibilidade no ROC.

No âmbito infraconstitucional o ROC é regulamentado pelos arts. 1.027 e 1.028, do CPC.

► Recurso Ordinário Constitucional para o STJ

O art. 105, II, "a", da CRFB/88, estabelece que o STJ julgará pelo presente recurso, as decisões **DENEGATÓRIAS** proferidas em "habeas-corpus" decididos em **ÚNICA** ou **ÚLTIMA** instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (casos em que os referidos tribunais tem competência originária ou recursal para o julgamento do *habeas corpus*).

Na forma do art. 30, da Lei 8038/90 o prazo para a interposição do recurso na hipótese acima é de 5 dias e não há recolhimento de preparo ou pagamento das demais custas, tendo em vista a natureza gratuita do instituto.

47 Para alguns autores, crimes políticos seriam os definidos pela Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional).

Art. 1º – Esta Lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: I – a integridade territorial e a soberania nacional; II – o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; III – a pessoa dos chefes dos Poderes da União.

Já o art. 105, II, b, da CRFB/88, estabelece que o STJ julgará pelo presente recurso, as decisões **DENEGATÓRIAS** proferidas em mandado de segurança decididos em **ÚNICA** instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (casos em que os referidos tribunais tem competência originária para o julgamento do remédio).

O art. 105, II, c, da CRFB/88, estabelece que também caberá ROC em face de sentença proferida no julgamento das causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (art. 109, II, da CRFB/88), ou seja, mais um ROC em face de sentença de juiz singular federal.

O prazo para interposição do recurso ordinário constitucional nas hipóteses acima apresentadas é de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC) e, diferentemente do ROC em *habeas corpus*, há necessidade de recolhimento do preparo e das custas com o porte de remessa e de retorno (art. 1.007, do CPC).

O recurso é dividido na peça de interposição e nas razões recursais. Poderá ser interposto perante o Presidente do tribunal recorrido (TJ ou TRF) ou no caso do art. 105, II, c, da CRFB/88, perante o juízo de primeiro grau federal. Como dissemos acima, tendo em vista que não há mais juízo de admissibilidade no ROC, a petição de interposição é uma formalidade que deve ser cumprida com o intuito de que o Juízo de origem determine a intimação do recorrido para oferecer as contrarrazões.

► Caso concreto

(OAB IV EXAME)

Tício, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no município M, inconformado com ato praticado pelo Governador do seu Estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça local, órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso alegando a violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, o acesso à Justiça e os atinentes à Administração Pública. Não houve deferimento da gratuidade de Justiça. Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível, contra a decisão que denegou a segurança, observando: a) competência do Juízo; b) legítimi-

dade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) os requisitos formais da peça; e) adequação do recurso.

Elaboração e identificação do recurso:

3 Passos:	
Passo 1	identificação da decisão objeto do recurso
Passo 2	verificar o recurso cabível para impugnar a decisão
Passo 3	verificar se há ou não peça de interposição

► Peça Processual

1ª página (peça de interposição)

EXM^o. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA...
(Juízo recorrido)

(3 linhas)

Processo n^o...

(2 linhas)

Tício, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no município M, nos autos do Mandado de Segurança de número em epígrafe, que move em face do Governador do Estado..., inconformado com a decisão proferida às fls. ..., que denegou a segurança pretendida, vem, por seu advogado, conforme procuração anexa, com escritório..., nesta cidade, endereço que indica para os fins do art 77, V, do CPC, Interpor, tempestivamente, o presente RECURSO ORDINÁRIO nos termos do artigo 105, II, b, da CRFB/88 e dos arts. 1.027 e 1.028, do CPC, esperando que V. Exa determine o requerimento da intimação do recorrido para oferecer as contrarrazões e que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB n^o...

2ª página (peça de razões)

AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECORRENTE: Tício

RECORRIDO: Governador do Estado...

RAZÕES DE RECURSO

I - DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo, tendo em vista que foi interposto no prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

II - DO CABIMENTO DO RECURSO

O recurso cabível em face de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios é o recurso ordinário para o STJ, na forma do art. 1.027, II, a, do CPC.

O presente recurso também está previsto no art. 105, II, b, da CRFB/88.

III - PREPARO

O preparo e o porte de remessa e de retorno foram devidamente recolhidos, na forma do art. 1.007, do CPC.

IV - DA SÍNTESE DOS FATOS**V - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

Direito ao Mandado de Segurança – CRFB, art. 5º, LXIX / Lei 12.016/09.

Direito à propositura de ação popular – CRFB, art. 5º, LXXIII/Lei 4717/65.

Direito de petição – CRFB, art. 5º, XXXIV

Direito de acesso a informações – CRFB, art. 5º, XXXIII

VI - DOS PEDIDOS

Face ao acima exposto, o Recorrente pede seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a decisão _____, além da condenação do Recorrido nos ônus sucumbenciais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

CAPÍTULO 22

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL

Como visto no capítulo anterior, o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial são considerados em sentido amplo “recursos extraordinários” e não permitem uma ampla análise de fatos, restringindo a matéria ao aspecto objetivo, de direito, além de estabelecerem requisitos específicos para a sua interposição.

O recurso extraordinário visa à unidade da aplicação da matéria constitucional, a defesa da supremacia da Constituição e o recurso especial busca uniformizar a aplicação do direito federal (infraconstitucional), evitando, assim, regionalização da interpretação da norma federal no país.

O RE e o RESP são dirigidos ao STF e ao STJ, exclusivamente nas hipóteses disciplinadas nos art. 102, III, e 105, III, da CRFB/88, após esgotados todos os recursos ordinários admissíveis, segundo a súmula 281 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.

O prazo para interposição dos dois recursos é de 15 dias, seguindo a previsão do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Há necessidade de recolhimento do preparo e das custas com o porte de remessa e de retorno, na forma do art. 1.007, do CPC.

A estrutura dos dois recursos é dividida na peça de interposição e nas razões recursais. Na forma do art. 1.029, do CPC, ambos são interpostos perante o Presidente ou o Vice-Presidente do tribunal recorrido e, em caso de admissão, são remetidos ao STF ou ao STJ conforme o caso.

Quanto aos requisitos de admissibilidade, a súmula 282 do STF assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,

na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. O enunciado exige a comprovação do prequestionamento, ou seja, o recorrente precisa comprovar que o direito discutido no bojo do recurso já foi ventilado e apreciado pelo Tribunal de origem, ou seja, a matéria não é “nova”, não está sendo discutida pelos Tribunais Superiores originariamente, mas de forma extraordinária.

► Recurso Extraordinário

As hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário estão previstas no art. 102, III, alíneas a, b, c, d, da CRFB/88 que serão a seguir analisadas em destaque.

Compete ao STF:

Art. 102: III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

A regra geral é a de que o RE tenha por objeto acórdão de Tribunal, entretanto, admite-se, eventualmente, a interposição do recurso em face de decisão de Turma de Juizado Especial.

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

“Contrariar” significa não aplicar, aplicar indevidamente a norma constitucional e é a hipótese mais comum de cabimento do RE, em defesa da Supremacia da Constituição.

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

Nessa hipótese o Tribunal anterior realizou o controle difuso, incidental de constitucionalidade. “lei federal” deve ser compreendida como a norma elaborada pelo Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, Ex.: lei ordinária federal, lei complementar federal, medida provisória...

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.

“Lei local” é a norma primária estadual, distrital ou municipal; leis ordinárias, complementares... Já “ato de governo” local significa o ato administrativo praticado por agente público no âmbito do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no plano estadual, distrital ou municipal, tais como: decretos, portarias, circulares etc..

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Como a decisão sobre o conflito federativo está sob a responsabilidade do STF, quando a decisão recorrida confirma a constitucionalidade de uma lei estadual, distrital ou municipal em face de uma norma federal, é também cabível o recurso extraordinário. É uma hipótese muito comum envolvendo os arts. 22 e 24, da CRFB/88.

Com a reforma promovida pela EC nº 45/2004, além de fundamentar o recurso extraordinário em uma das hipóteses do art. 102, III, da CRFB/88 e de comprovar o prequestionamento, o recorrente deverá, com base no § 3º do art. 102, demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Trata-se de mais um requisito de admissibilidade do recurso, ou como dizem alguns doutrinadores, instrumento de filtragem recursal, também previsto no art. 1.035, do CPC.

Importante destacarmos que a preliminar da repercussão geral é ônus do recorrente e deverá ser feita na mesma petição do recurso, e que o órgão competente para apreciá-la é somente o Supremo Tribunal Federal.

Segundo afirma Luís Guilherme Marinoni,⁴⁸ a repercussão geral é formada pelo binômio: relevância + transcendência, ou seja, a questão debatida deverá ser relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Presente o binômio, caracterizada estaria a repercussão geral da controvérsia e o Supremo deveria admitir o recurso e apreciá-lo no mérito.

Não há necessidade, imperioso destacar, que a controvérsia seja importante sob todos os ângulos da análise, basta que seja caracterizada a relevância em uma dessas perspectivas. Nesse sentido, entendemos que as questões tributárias, previdenciárias, as ações coletivas, relativas à educação e à saúde, pela sua própria natureza, deverão estar, em regra, incluídas na relevância da repercussão geral, mas de qualquer forma compete ao STF a aferição efetiva em cada caso concreto.⁴⁹

48 MARINONI, Luís Guilherme. *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário*, 1ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

49 A título de exemplo, são algumas das matérias com repercussão geral, de acordo com a jurisprudência do STF:

Como o Procurador-Geral da República atua em todos os processos de competência do STF, devemos pleitear a sua oitiva (ou intimação) no Recurso Extraordinário.

► Súmulas STF

- Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
- Súmula 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
- Súmula 281: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.
- Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
- Súmula 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
- Súmula 640: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.
- Súmula 735: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.

► Recurso Especial

As hipóteses de cabimento do Recurso Especial estão previstas no art. 105, III, alíneas a, b, c, da CRFB/88 que serão a seguir analisadas em destaque.

“IMUNIDADE. EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. Surge com repercussão geral definir o alcance de imunidade quanto à Contribuição Social sobre o Lucro no que a Corte de origem refutou a não incidência do tributo” (STF, RE 564.413/SC, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.12.2007, DJ 14.12.2007);

“DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEIS SOBRE PLANOS DE SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Há repercussão geral na questão sobre a aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes da sua vigência, à luz do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República” (STF, RE 578.801 RG/RS, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16.10.2008, DJ 31.10.2008).

Compete ao STJ:

Art. 105: III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

Somente acórdãos proferidos por Tribunais (TJ ou TRF) podem ser objeto do RESP. As decisões das Turmas de Juizados especiais estão excluídas de apreciação. SÚMULA Nº 203, STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida, nos limites sua competência, por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

Essa é a hipótese mais comum de cabimento do RESP. A decisão recorrida viola o direito federal, aplicando-o indevidamente ou negando-lhe vigência. “Lei federal” deve ser compreendida como a norma elaborada pelo Congresso Nacional ou pelo Presidente da República, Ex.: lei ordinária federal, lei complementar federal, medida provisória...

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

“Ato de governo local” é aquele praticado por agentes públicos dotados de certa parcela de poder, independentemente se Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário desde que no plano estadual, distrital ou municipal. “Lei federal” deve ser compreendida de forma ampla, como já explicado. Atenção! Aqui é ato de governo local e não lei local (que dá ensejo ao RE).

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Aqui a divergência no tocante a aplicação do direito federal é entre Tribunais distintos. Súmula 13, do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”.

O requisito da repercussão geral já estudado não se aplica ao recurso especial.

► Súmulas STJ

► **Súmula 7:** A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

► **Súmula 83:** Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

- ▶ **Súmula 86:** Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento.
- ▶ **Súmula 126:** É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
- ▶ **Súmula 203:** Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais.

▶ Caso concreto (OAB X Exame)

O Tribunal de Justiça do Estado J julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do município W, tendo o acórdão declarado constitucional norma da lei orgânica municipal que dispôs que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. No prazo recursal foram ofertados embargos declaratórios, improvidos.

Contratado como advogado pelo Prefeito do Município, após a decisão proferida nos embargos declaratórios, apresente a peça cabível. (Valor: 5,0).

Elaboração e identificação do recurso

3 Passos:	
Passo 1	identificação da decisão objeto do recurso
Passo 2	verificar o recurso cabível para impugnar a decisão
Passo 3	verificar se há ou não peça de interposição

► Peça Processual**1ª página (peça de interposição)****EXMº. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA]**

(3 linhas)

Processo nº...

(2 linhas)

Prefeito do Município W, já devidamente qualificado nos autos do processo em referência, por seu advogado infra-assinado, conforme procuração anexa, por escritório..., endereço que indica para os fins do art. 77, V, do CPC, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual, vem interpor, tempestivamente, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 102, III, a, da CRFB/88, em face do acórdão que declarou constitucional norma da lei orgânica municipal, esperando que seja conhecido e recebido, juntada a guia de recolhimento anexa e, depois de cumpridas as formalidades processuais necessárias, sejam os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

2ª página (peça de razões)**AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL****RECORRENTE:** Prefeito do Município W**RECORRIDA:** Câmara Municipal**Razões de Recurso****I – DA TEMPESTIVIDADE**

O presente recurso é tempestivo, tendo em vista que foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 1.003, § 5º do CPC.

II – DO CABIMENTO

Na forma do art. 102, III, a, da CRFB/88, compete ao STF, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.

O Acórdão objeto do presente recurso violou claramente o art. 83, da CRFB/88 ao declarar constitucional norma da lei orgânica municipal que dispõe que o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal.

O recurso extraordinário também se encontra previsto no art. 1.029 e ss., do CPC.

III – DO PREPARO

A guia de recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e de retorno acompanha o presente recurso, satisfazendo o requisito do art. 1.007, do CPC.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

A matéria objeto do recurso foi prequestionada na origem, tendo em vista que o objetivo da ADI estadual era a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal, preenchendo assim o requisito do prequestionamento previsto na súmula 282, do STF.

V – DA REPERCUSSÃO GERAL

A matéria possui repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da parte na causa, pois o tema pode ser espalhado para as demais leis orgânicas municipais. Portanto, satisfeito o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, § 3º, da CRFB/88 e no art. 1.035, do CPC.

VI – DA SÍNTESE DOS FATOS

VII – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Menção ao princípio da simetria ou norma de observância obrigatória (0,50)

CRFB, Art. 29, *caput* (0,50).

CRFB, Art. 49, III OU CRFB, Art. 83 (0,50).

VIII – DOS PEDIDOS

Face ao acima exposto, o Recorrente pede seja dado provimento ao presente Recurso para reformar a decisão e confirmar a inconstitucionalidade da Lei Orgânica impugnada, a intimação do Procurador-Geral da República, além da condenação do Recorrido nos ônus sucumbenciais.

Termos em que,

Pede deferimento.

Local... e data...

Advogado...

OAB nº...

► Peça cobrada no XII Exame

Após mais de 40 (quarenta) dias de intensa movimentação popular, em protestos que chegaram a reunir mais de um milhão de pessoas nas ruas de diversas cidades do Estado, e que culminaram em atos de violência, vandalismo e depredação de patrimônio público e particular, o Governador do Estado X edita o Decreto nº 1968.

A pretexto de disciplinar a participação da população em protestos de caráter público, e de garantir a finalidade pacífica dos movimentos, o Decreto dispõe que, além da prévia comunicação às autoridades, o aviso deve conter a identificação completa de todos os participantes do evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Além disso, prevê a revista pessoal de todos, como forma de preservar a segurança dos participantes e do restante da população.

Na qualidade de advogado do Partido Político “Frente Brasileira Unida”, de oposição ao Governador, você ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado X, alegando a violação a normas da Constituição do Estado referentes a direitos e garantias individuais e coletivos (que reproduzem disposições constantes da Constituição da República).

O Plenário do Tribunal de Justiça local, entretanto, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado, de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Decreto estadual, por entender compatíveis as previsões constantes daquele ato com a Constituição do Estado, na interpretação que restou prevalecente na corte. Alguns dos Desembargadores registraram em seus votos, ainda, a impossibilidade de propositura de ação direta tendo por objeto um decreto estadual.

Entendendo que a decisão da corte estadual, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada, e que não apenas as disposições do Decreto são inconstitucionais como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional, os dirigentes do Partido pedem que você proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão.

Elabore a peça judicial adequada.

► **Comentários da Banca [Comentários feitos quando ainda vigente o CPC/1973.]**

A peça a ser elaborada consiste em um Recurso Extraordinário contra decisão proferida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do Art. 102, III, c da CRFB/88.

No caso, a ação direta de controle tendo como parâmetro a Constituição do Estado, tem previsão no Art. 125, § 2º da Constituição da República. É possível a interposição de Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da mesma, a fim de que seja apreciada, pelo Supremo Tribunal Federal, a norma da Constituição da República repetida na Constituição Estadual, mas interpretada, pelo Tribunal de Justiça local, em sentido incompatível com o da Constituição da República.

O Recurso deve ser endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça local, com as razões recursais dirigidas ao Supremo Tribunal Federal.

O Partido Político é o recorrente. Recorrido é o órgão do qual emanou a norma impugnada (isto é, o Governador do Estado). Apesar de não constar do voto vencedor a impossibilidade de controle de constitucionalidade de decreto por meio de ação direta, o examinando deve demonstrar o cabimento da via eleita para a impugnação do Decreto estadual, pois, a despeito de se tratar de um Decreto, não é um ato de regulamentação da lei, mas ato normativo primário, que inova autonomamente na ordem jurídica. O examinando deve indicar, em sua peça, todos os elementos que permitam o seu conhecimento e também o seu provimento, afastando, desde o início, argumentos desfavoráveis à pretensão que defende.

O examinando deve demonstrar o cumprimento do requisito da Repercussão Geral, que encontra previsão no Art. 102, § 3º da Constituição, e que deve ser demonstrado pela existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ou seja, a questão suscitada não pode ser benéfica somente para o caso concreto proposto, mas para o interesse da coletividade, na forma do Art. 543-A, § 1º, do CPC. No caso apresentado, a repercussão geral pode ser demonstrada pela ofensa a direitos fundamentais titularizados por toda a coletividade, uma vez que a norma cria restrição excessiva ao exercício de direito constitucionalmente assegurado, e o faz sem previsão em lei.

No mérito, o examinando deve demonstrar que o decreto impugnado viola o princípio da legalidade, na formulação do Art. 5º, II da Constituição da República, uma vez que não se pode criar restrição a direito senão em virtude de lei.

O decreto viola o Art. 5º, XVI, da Constituição, que assegura o direito de reunião em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, qualquer outra exigência que venha a ser formulada como condição de exercício do direito é inconstitucional.

Ainda ocorre a violação ao Art. 5º, da CRFB, que trata do princípio da liberdade de expressão.

Por fim, deve ser indicada a violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, pois, ainda que se entendesse possível a restrição ao direito de reunião, a restrição veiculada pelo decreto, no caso analisado, falha nos subprincípios da necessidade (que impõe a utilização, dentre as possíveis, da medida menos gravosa para atingir determinado objetivo) e da proporcionalidade em sentido estrito (que impõe a análise da relação custo/benefício da norma avaliada, de modo que o ônus imposto pela norma seja inferior ao benefício por ela engendrado, sob pena de inconstitucionalidade).

O examinando, ao final, deve formular pedido de reforma da decisão recorrida, para fim de ver declarada a inconstitucionalidade do Decreto editado pelo Governador do Estado, bem como requerer a notificação do Ministério Público.

CAPÍTULO 23

PARECER JURÍDICO

► Cabimento

O parecer jurídico deve ser elaborado quando for expressamente solicitado pela banca examinadora, que deverá sugerir peça opinativa confeccionada por especialista, uma resposta a uma consulta formulada ou até mesmo um parecer sobre determinado tema.

É importante esclarecer que apesar da baixa complexidade da peça no que tange a sua estrutura, a mesma deve explorar todos os argumentos constitucionais, infraconstitucionais e eventuais entendimentos doutrinários e jurisprudenciais relacionados ao tema proposto.

Não há estrutura estabelecida por lei para elaboração da peça, não tendo forma obrigatória a ser seguida. Entretanto, vale ressaltar que a mesma deve apresentar, destacadamente, o nome PARECER JURÍDICO, a identificação do interessado (apresentado pela banca), uma EMENTA, que nada mais é do que o texto reduzido aos pontos essenciais, e os tópicos de introdução (ou relatório), fundamentação e conclusão. Também há necessidade de que o parecer seja datado e assinado pelo advogado, com indicação de sua inscrição na OAB.

► Estrutura simples da peça

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO:

EMENTA*:

I – INTRODUÇÃO: Trata-se de uma consulta efetuada por ___ sobre ___; cuida-se de...;

II – FUNDAMENTAÇÃO: Doutrina, jurisprudência, amparo legal, pode ser dividida em tópicos;

III – CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima narrado, opinamos por...; de todo o exposto, entendemos que...; do exposto, conclui-se que...

S.M.J

É o parecer.

Ou

É o parecer, submetido à elevada consideração de ...

Ou

É o parecer que submeto à elevada consideração de ...

Local e data.

Nome do advogado...

OAB nº...

EMENTA*: A Ementa deve apresentar uma síntese do assunto do parecer, e pode ser deixado um espaço para que seja elaborada ao final, quando já redigida a peça, estando organizados todos os argumentos em frases curtas e objetivas.

► Peça cobrada no XVII Exame

O Partido Político “Z”, que possui apenas três representantes na Câmara dos Deputados, por entender presente a violação de regras da CRFB, o procura para que, na qualidade de advogado especialista em Direito Constitucional, se posicione sobre a possibilidade de ser obtida alguma medida judicial em face da Lei Estadual “Y”, de janeiro de 2015, que contém 3 (três) artigos. De acordo com a exposição de motivos do projeto que culminou na Lei Estadual “Y”, o seu objetivo é criar, no âmbito estadual, ambiente propício às discussões políticas de âmbito nacional, e, para alcançar esse objetivo, estabelece, em sua parte dispositiva, novas regras eleitorais, sendo estabelecidas, em seu artigo 1º, regras temporais sobre a criação de partidos políticos; em seu artigo 2º fica retirada a autorização para que partidos políticos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado; e, por fim, em seu artigo 3º fica estabelecida a vigência imediata da referida legislação. Elabore a peça adequada, considerando a narrativa acima. (Valor: 5,00)

► Peça

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Partido Político "Z"

EMENTA: Inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual "Y". Legitimidade do partido para ajuizar ADI. Partido Político com representação no Congresso Nacional. Possibilidade. Competência do STF. Cabimento de medida cautelar.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de uma consulta efetuada pelo Partido Político "Z", que tem apenas três representantes na Câmara dos Deputados, sobre a possibilidade de obtenção de medida judicial em face da Lei Estadual "Y", por suposta violação de regras da Constituição Federal. A referida lei objetiva criar no âmbito estadual ambiente propício às discussões políticas de âmbito nacional, estabelecendo regras temporais sobre a criação de partidos políticos, a retirada da autorização para que partidos com menos de cinco Deputados Federais possam ter acesso gratuito ao rádio e à televisão na circunscrição do Estado e dispõe que a sua vigência será imediata.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

a) Da inconstitucionalidade da Lei Estadual "Y"

A Lei Estadual "Y" padece de inconstitucionalidade formal, pois afronta o art. 22, I e IV, da CRFB/88, que preceitua que compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre: direito eleitoral e sobre telecomunicações e radiodifusão.

Há, ainda, inconstitucionalidade material, já que a referida lei afronta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, LIV, da CRFB/88), e também ao pluripartidarismo (art. 1º, V, da CRFB/88) e, ainda, ao direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, estabelecido no art. 17, *caput*, e § 3º, da CRFB/88.

b) Cabimento da ADI de competência do Supremo Tribunal Federal

Será possível ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade para a realização do controle concentrado de constitucionalidade da Lei Estadual "Y", perante o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art. 102, I, "a", da CRFB/88.

c) Da Legitimidade Ativa do Autor

O partido político "Z" é legitimado ativo para propor a ação direta de inconstitucionalidade, pois está devidamente representado no Congresso Nacional, de acordo com o art. 103, VIII, da CRFB/88 e art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868 de 1999.

Importante ressaltar que basta a representação em pelo menos uma das Casas legislativas, e que a ação seja proposta por seu Diretório Nacional.

d) Do cabimento da Medida Cautelar

A tutela jurisdicional cautelar (art. 11, da Lei 9.868/99) se faz necessária, de modo a suspender a eficácia da Lei Estadual “Y” até que seja definitivamente julgada a ação direta de inconstitucionalidade, pois estão presentes no caso os requisitos do *fumus boni iuris*, pela clareza dos vícios de inconstitucionalidade apontados, e do *periculum in mora*, em razão do constrangimento ao exercício de atividade lícita e constitucional pelos partidos políticos.

III – CONCLUSÃO:

Tendo em vista o acima narrado, opinamos pela inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y” e a possibilidade de ser ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a formulação do requerimento de medida cautelar.

S.M.J

É o parecer.

Local e data.

Nome do advogado...

OAB nº...

► Comentários da Banca

O examinando deverá elaborar um parecer com o objetivo de responder à consulta formulada.

O parecer deve possuir uma ementa que contenha as palavras chaves relacionadas à temática abordada.

O relatório do parecer deve descrever a consulta formulada e a indicação do respectivo consulente.

Na fundamentação do parecer, o examinando deve sustentar, em primeiro lugar, a inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y”.

Deve argumentar que a Lei Estadual “Y” afronta o disposto no Art. 22, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil [Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (...) IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (grifos)], logo, padece de inconstitucionalidade formal. Em relação à inconstitucionalidade material, o examinando deverá demonstrar a afronta ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, como também ao Art. 1º, V (pluralismo político) e ao Art. 17, caput e § 3º, da Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil de 1988 [(Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, (...)) § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (grifos)].

Ainda na fundamentação, o examinando deve posicionar-se sobre o cabimento da ação direta de inconstitucionalidade para a realização do controle concentrado de constitucionalidade da Lei Estadual “Y”, que deve ser ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Deve ser igualmente ressaltada a legitimidade ativa do Partido Político “Z”, representado pelo presidente de sua Comissão Executiva Nacional, por possuir representação no Congresso Nacional, tal qual dispõe o Art. 103, VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e o Art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868, de 1999.

Por fim, a fundamentação deve expor o cabimento da medida cautelar, de modo a suspender a eficácia da Lei até que seja definitivamente julgada a ação direta de inconstitucionalidade. O examinando deve demonstrar que a tutela jurisdicional cautelar se faz necessária, pois estão suficientemente demonstrados os requisitos do *fumus boni iuris*, pela clareza dos vícios de inconstitucionalidade apontados, e do *periculum in mora*, isso em razão do constrangimento decorrente do impedimento ao exercício de atividade lícita e constitucional dos partidos políticos.

Na conclusão do parecer, o examinando deve sustentar a inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y” e a possibilidade de ser ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a formulação do requerimento de media cautelar.

O parecer deve ser datado e assinado pelo advogado, com indicação de sua inscrição na OAB.

► Distribuição dos pontos – Parecer

Item	Pontuação
1. Emenda (Palavras chaves) (0,10).	0,00 / 0,10
2. Relatório: descrição da consulta (0,10) com indicação do consulente (0,10).	0,00 / 0,10 / 0,20
3. Resposta à consulta: (fundamentação)	
3.1 Da inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y”	

Item	Pontuação
a. O examinando deverá argumentar que a Lei Estadual “Y” padece de inconstitucionalidade formal (0,60) por afrontar o Art. 22, I e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil (0,10) porque compete privativamente à União legislar, entre outros, sobre: direito eleitoral e sobre telecomunicações e radiodifusão; (0,60)	0,00 / 0,60 / 0,70 / 1,20 / 1,30
b. Em relação à inconstitucionalidade material (0,30), o examinando deverá demonstrar a afronta ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, (0,30) como também ao pluripartidarismo (0,60) (Art. 1º, V, da CF/88) (0,10)	0,00 / 0,30 / 0,40 / 0,60 / 0,70 / 0,90 / 1,00 / 1,20 / 1,30
c. e ao direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, (0,60) na forma do Art. 17, caput, e § 3º, da CF/88 (0,10).	0,00 / 0,60 / 0,70
3.2 Cabimento da ADI (0,50)	0,00 / 0,50
3.3 Competência do Supremo Tribunal Federal (0,10)	0,00 / 0,10
3.4 Da Legitimidade Ativa do Autor – O examinando deverá argumentar que a exigência para a legitimação ativa para a ação estão presentes, ou seja, representação no Congresso Nacional, (0,20) segundo o Art. 103, VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil 1988 e do Art. 2º, VIII da Lei nº 9.868 de 1999 (0,10).	0,00 / 0,20 / 0,30
3.5. Do cabimento da Medida Cautelar – O examinando deverá demonstrar que a tutela jurisdicional cautelar se faz necessária, pois estão suficientemente demonstrados os requisitos do <i>fumus boni iuris</i> , pela clareza dos vícios de inconstitucionalidade apontados (0,10), e do <i>periculum in mora</i> , isso em razão do constrangimento ao exercício de atividade lícita e constitucional pelos partidos políticos (0,10).	0,00 / 0,10 / 0,20
4. Conclusão – inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y” e possibilidade do ajuizamento da ADI perante o STF, inclusive com medida cautelar (0,20)	0,00 / 0,20
5. Data, assinatura e OAB – (0,10).	0,00 / 0,10

- A banca nesse exame aceitou também a ADI como gabarito da peça processual apresentada, conforme verificamos abaixo:

► Gabarito Comentado – ADI

O examinando deverá elaborar uma petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Lei nº 9868/1999). A petição deve ser direcionada ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. A ação deve ser ajuizada pelo Partido Político “Z”, representado pelo presidente de sua Comissão Executiva Nacional. A legitimidade ativa decorre do fato de o Partido Político “Z” possuir representação no Congresso Nacional. O examinando deverá argumentar que a Lei Estadual “Y” afronta o disposto no Art. 22, I e IV, da

Constituição da República Federativa do Brasil [Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho (...) IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; (grifos)]. Em relação à inconstitucionalidade material, o examinando deverá demonstrar a afronta ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, como também ao Art. 1º, V (pluralismo político) e ao Art. 17, caput e § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [(Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, (...) § 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei (grifos)]. Deve ser pedida a medida cautelar, de modo a suspender a eficácia da Lei até que seja definitivamente julgada a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. O examinando deve demonstrar que a tutela jurisdicional cautelar se faz necessária, pois estão suficientemente demonstrados os requisitos do *fumus boni iuris*, pela clareza dos vícios de inconstitucionalidade apontados, e do *periculum in mora*, isso em razão do constrangimento decorrente do impedimento ao exercício de atividade lícita e constitucional dos partidos políticos. Deve ser formulado o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual “Y”. Devem ser solicitadas informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado, órgãos responsáveis pela edição do ato normativo e ouvidos o Advogado Geral da União e o Procurador Geral da República. A petição deve ser datada e assinada pelo advogado.

CAPÍTULO 24

QUESTÕES DE EXAMES DE ORDEM – SEGUNDA FASE COM GABARITO

► FGV Projetos

► 2010.2

01. (OAB – Exame 2010.2) O Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou projeto de lei complementar modificando artigos do Código Civil, nos termos do art. 22, I da CRFB. Três meses após a entrada em vigor da referida lei, o Presidente da República editou medida provisória modificando novamente os referidos artigos do Código Civil com redação dada pela lei complementar. Analise a constitucionalidade dos atos normativos mencionados.

► Gabarito comentado

São basicamente duas as diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária: (i) enquanto a primeira demanda um quórum de aprovação de maioria absoluta, a segunda pode ser aprovada por maioria simples (presente à sessão a maioria absoluta dos membros da casa legislativa); (ii) há determinadas matérias que só podem ser reguladas por meio de lei complementar e estas matérias estão definidas expressamente no texto constitucional. Não existe, portanto, hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, uma vez que esta não decorre daquela. Ambas decorrem da Constituição. Este entendimento, que conta com o apoio da maioria dos doutrinadores, já foi confirmado pelo STF (RE419.629). Uma lei complementar que disponha sobre matéria para a qual a Constituição não exige maioria absoluta (típica de lei complementar) poderá ser modificada por lei ordinária. É dizer, neste caso, será uma lei complementar com status de lei ordinária. Embora a Constituição determine que não será objeto de medida provisória a matéria reservada a lei complementar, tal vedação não afeta o caso em tela, pois a matéria de que trata a referida lei complemen-

tar (direito de família) não é reservada a lei complementar, podendo neste caso ser modificada por medida provisória. Ambos os atos normativos, portanto, são constitucionais.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
Inexistência de hierarquia	0 / 0,5
Por não haver hierarquia, mas hipótese de incidência, uma lei complementar pode ser revogada por uma ordinária quando aquela não estiver na sua área de incidência	0 / 0,5

02. (OAB – Exame 2010.2) Uma lei estadual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada junto ao STF. Supondo que o Tribunal tenha se pronunciado, neste caso, pela inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, explique o conceito acima, apontando quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade neste caso.

► **Gabarito comentado**

A inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é uma modalidade de declaração de inconstitucionalidade prevista na Lei 9868/99 que tem como consequência a declaração de inconstitucionalidade de uma determinada interpretação, sem afetar o texto da norma. É dizer, o texto da norma permanece inalterado, mas determinada interpretação que a princípio poderia ser feita da norma é considerada inconstitucional. Esta modalidade de declaração de inconstitucionalidade tem importantes consequências nos processos de fiscalização abstrata, como é o caso da ADI (citada na questão), pois a declaração de inconstitucionalidade não do texto da norma, mas de sua interpretação, terá eficácia *erga omnes* (contra todos) e efeito vinculante, conforme dispõe o parágrafo único do art. 28 da Lei 9868: “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
O conceito de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto	0 / 0,5
Efeitos – eficácia contra todos e efeito vinculante	0 / 0,5

03. (OAB – Exame 2010.2) O Conselho Federal da OAB ajuizou, junto ao STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), tendo por objeto um artigo de uma lei federal em vigor desde 2005, sendo manifesta a pertinência temática do dispositivo impugnado com o exercício da advocacia. O STF entende que o referido dispositivo legal é inconstitucional, mas por fundamento distinto do que fora apresentado pelo Conselho Federal da OAB na ADI, tendo o STF inclusive declarado a inconstitucionalidade desse mesmo dispositivo no julgamento de um caso concreto, em Recurso Extraordinário (RE).

Com base nas informações acima, responda:

I – o STF pode julgar a ADI procedente a partir de fundamento diverso do que fora apresentado pelo Conselho Federal da OAB? Justifique.

II – o STF pode julgar a ADI procedente em relação também a outro dispositivo da mesma lei, mesmo não tendo este dispositivo sido objeto da ADI? Justifique.

► **Gabarito comentado**

Segundo a jurisprudência do STF, o Tribunal, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, está limitado em relação ao pedido, mas não à causa de pedir, que é aberta. É dizer, o STF pode considerar a lei impugnada inconstitucional por motivos diversos daqueles apresentados pelo proponente da ADI.

Entendimento diverso implicaria reconhecer que uma ADI mal formulada, com argumentos frágeis ou equivocados pela inconstitucionalidade da lei, levando à improcedência da ação e à consequente declaração de constitucionalidade da lei. Em relação ao pedido, este, a princípio, é limitado ao que foi questionado pelo proponente da ação. O STF, no entanto, admite em caráter excepcional que dispositivos legais não impugnados na ação sejam declarados inconstitucionais, mas somente se forem dependentes dos dispositivos impugnados. É dizer, nos casos em que a incons-

tutucionalidade de um dispositivo impugnado implica necessariamente a inconstitucionalidade de outro não impugnado. A este fenômeno dá-se o nome de inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração” ou “consequente”.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
I. O STF não está adstrito ao fundamento da ação	0 / 0,5
II. O STF pode julgar ADI também com fundamento em outro dispositivo, o que ocorre com a inconstitucionalidade por arrastamento	0 / 0,5

04. (OAB – Exame 2010.2) Em 2005, o STF julgou procedente ADC ajuizada pelo Procurador-Geral da República visando à declaração de constitucionalidade de uma lei federal que estava sendo questionada em diversos processos judiciais pelo país, gerando uma controvérsia judicial em torno da sua adequação ao texto constitucional. Nas eleições ocorridas em outubro de 2010, um determinado partido do político conseguiu, pela primeira vez em sua história, eleger um parlamentar, no caso um deputado federal, graças à coligação partidária firmada com um partido político de maior expressão e base eleitoral.

O diretório nacional do referido partido do político pretende, no próximo ano, após o início da sessão legislativa, ajuizar uma ADI contra a mencionada lei federal, a partir de argumentos que não foram enfrentados pelos ministros do STF em 2005.

Analise a pretensão do partido do político, considerando os seguintes tópicos:

- I. A legitimidade para a propositura da ação.
- II. A possibilidade de o STF declarar a inconstitucionalidade da lei (com ou sem modulação dos efeitos).

► Gabarito comentado

A Emenda Constitucional, nº 3/93, ao criar a ação declaratória de constitucionalidade, não atribuiu legitimidade ativa aos mesmos que poderiam ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, de modo que o partido político com representação no Congresso Nacional poderia ajuizar apenas esta, mas não aquela. A Emenda Constitucional nº 45/2004, relativa à Re-

forma do Poder Judiciário, alterou o art. 103, estabelecendo que todos aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) podem também ajuizar a ação declaratória de constitucionalidade (ADC). Embora o art. 103 não faça qualquer discriminação entre os legitimados para a propositura das ações, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que alguns dos legitimados só podem ajuizar ADI ou ADC se demonstrarem pertinência temática com a lei ou ato normativo objeto da ação. Estes são denominados legitimados especiais (art. 103, IV, V e IX), ao passo que aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática são chamados de legitimados universais (art. 103, I, II, III, VI, VII e VIII). O partido político, no entanto, é um dos legitimados universais, não sendo necessário demonstrar pertinência temática para poder ajuizar a ação. Quanto à representação no Congresso Nacional, embora se trate de órgão bicameral, abrangendo Câmara dos Deputados e Senado Federal, o STF tem antiga jurisprudência no sentido de que basta a representação em uma das Casas do Congresso para que se possa afirmar que o partido político tem representação no Congresso Nacional. Desse modo, não há dúvida de que o partido político em questão pode ajuizar a ADI.

Quanto à possibilidade de uma lei declarada constitucional em ADC ser objeto de ADI, a doutrina é pacífica no sentido de que isso é possível, uma vez que não reconhecer esta possibilidade implicaria afirmar que o STF, após haver declarado a constitucionalidade de uma lei, jamais poderia mudar seu entendimento, ainda que estivesse disso convencido. O STF poderá, por motivos de segurança jurídica, declarar a inconstitucionalidade com efeito não retroativo [*ex nunc*] ou determinar uma data a partir da qual a lei deveria ser considerada inconstitucional, mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, não havendo nada que impeça o STF de declarar a inconstitucionalidade com efeito retroativo (*ex tunc*).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
I. O partido possui legitimidade para impetrar a ação (dispositivo legal e fundamentação).	0 / 0,2 / 0,3 / 0,5.
II. É possível a modificação legal, haja vista que não pode haver engessamento de posicionamento do STF.	0 / 0,2 / 0,3 / 0,5.

05. (OAB – Exame 2010.2) A Constituição de determinado estado da federação, promulgada em 1989, ao dispor sobre a administração pública estadual, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público é assegurada aos cidadãos naturais daquele estado e depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Em 2009 foi promulgada pela Assembleia Legislativa daquele estado (após a derrubada de veto do Governador), uma lei que permite o ingresso em determinada carreira por meio de livre nomeação, assegurada a estabilidade do servidor nomeado após 3 (três) anos de efetivo exercício.

Considerando-se que a Constituição estadual arrola o Governador como um dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em âmbito estadual (art. 125, § 2º da CRFB), e considerando-se que o Governador pretende obter a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual, responda:

I. o que ocorreria se logo após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade de âmbito estadual, ajuizada pelo Governador do Estado junto ao Tribunal de Justiça (nos termos do art. 125, § 2º da CRFB) e antes do julgamento, fosse ajuizada pelo Conselho Federal da OAB uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, tendo por objeto esta mesma lei? Explique.

II. poderia o Presidente da República ajuizar ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF contra o dispositivo da Constituição estadual? Explique.

► Gabarito comentado

A Constituição estadual basicamente reproduziu o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, que dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. A reprodução do dispositivo, embora desnecessária, eis que o art. 37 da Constituição Federal refere-se expressamente à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, também não é estranha à experiência constitucional brasileira nem viola formalmente o texto constitucional, tornando-se assim norma constitucional estadual e federal. O dispositivo estadual, no entanto, limitou o direito de ingresso na carreira aos cidadãos naturais daquele Estado, incorrendo, desse modo, em inconstitucionalidade material, uma vez que, de acordo com o art. 25 da Constituição Federal, “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”. No caso em tela, a lei estadual viola a regra constitucional do concurso público, prevista tanto na Constituição Federal como na Constituição estadual, não fazendo diferença aqui o fato de a norma estadual limitar o acesso ao concurso público apenas aos naturais daquele Estado. Desse modo, sendo o Governador de Estado legitimado para ajuizar ação de inconstitucionalidade de âmbito estadual (de acordo com o enunciado da questão) e o Conselho Federal da OAB, legítimo para ajuizar a ADI de âmbito federal (de acordo com o art. 103, VII, da CRFB), e considerando-se que lei estadual pode ser objeto de ambas as ações (arts. 102, I, a, e 125, § 2º, da CRFB) é possível que as duas ações sejam ajuizadas concomitantemente. No entanto, de acordo com a firme jurisprudência do STF, neste caso a ação estadual ficaria suspensa, aguardando a decisão do STF. Em relação à segunda pergunta, considerando-se que a emenda à Constituição estadual é ato normativo estadual, considerando-se que deve estar de acordo com os princípios e regras estabelecidos pela Constituição Federal (art. 25, da CRFB), considerando-se que a referida emenda violou os arts. 5º, *caput*, e 37, II da CRFB, considerando-se, por fim, que o Presidente é um dos legitimados para a proposição da ADI, nos termos do art. 103, I da CRFB, é possível o ajuizamento da ação, valendo lembrar que o Presidente da República é legitimado universal, estando, assim, dispensado de demonstrar pertinência temática com o ato normativo impugnado.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
I. A ação estadual fica suspensa esperando decisão do STF (dispositivo legal e fundamentação).	0 / 0,2 / 0,3 / 0,5
II. O Presidente da República pode impetrar uma ação porque é legitimado universal.	0 / 0,2 / 0,3 / 0,5

► 2010.3

01. (OAB – Exame 2010.3) O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de determinado Estado-membro, ao disciplinar o processo de criação e instauração das Comissões Parlamentares de Inquérito, condiciona a criação de CPI à aprovação, pelo Plenário da Casa Legislativa, de requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos Deputados Estaduais. Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Analise, de maneira justificada, a constitucionalidade da referida previsão regimental. (Valor: 0,8)

b) O Diretório Regional de um Partido Político do Estado-membro em questão tem legitimidade para questionar a previsão regimental perante o Supremo Tribunal Federal por meio de ADI? (Valor: 0,2)

► Gabarito Comentado

A previsão regimental é inconstitucional, por introduzir requisito para instauração das CPIs que não encontra paralelo na Constituição da República. O artigo 58, § 3º, da CRFB contempla modelo de observância compulsória pelos Estados-membros e garante o direito das minorias legislativas ao estabelecer, como requisito objetivo para instauração de CPI, a subscrição do requerimento por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa, sem condicionar à aprovação pelo Plenário. De fato, de acordo com a jurisprudência do STF, a garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária.

Quanto ao item b, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou (artigo 103, § 1º, VIII, da CRFB).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) (I) A previsão regimental é inconstitucional, por violação à norma do artigo 58, § 3º, da CRFB. (II) Modelo de observância compulsória pelos Estados-membros. (III) Violação do direito das minorias legislativas. (IV) A garantia de instalação da CPI independe de deliberação plenária. (0,2 cada um)	0 / 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8
b) Não, o Partido Político deve estar representado por seu Diretório Nacional.	0 / 0,1 / 0,2

02. (OAB – Exame 2010.3) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso extraordinário, declarou a inconstitucionalidade, *incidentaliter tantum*, de uma lei estadual. Antônio Augusto, interessado em ser alcançado pelos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, impetrou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal objetivando a fixação de prazo para que o Senado Federal edite resolução para suspender a execução da mencionada lei estadual. Considerando a situação hipotética narrada, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Quais são os efeitos subjetivos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei em questão e qual é a função reservada ao Senado Federal pela norma do artigo 52, inciso X, da CRFB? (Valor: 0,5)

b) De acordo com a tradição constitucional brasileira, é cabível o pretendido controle jurisdicional da atuação do Senado Federal em tal hipótese? (Valor: 0,3)

c) O Senado Federal pode exercer a competência descrita no artigo 52, inciso X, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual? (Valor: 0,2)

► Gabarito Comentado

A questão aborda o tema relativo ao exame de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle difuso. Como de conhecimento convencional, a declaração de inconstitucionalidade, em tais hipóteses, configura-se questão prejudicial e como tal é apreciada pelo Tribunal. Subjetivamente, a decisão produz efeitos apenas *inter partes*. A função que a Constituição reserva ao Senado Federal, prevista no artigo 52, inciso X, da CRFB, é precisamente a de conferir efeitos *erga omnes* à decisão proferida na via difusa do controle de normas. De acordo com a tradição constitucional brasileira, a competência outorgada ao Senado Federal pela norma do artigo 52, X, retrata atuação política e discricionária, não cabendo controle jurisdicional a seu respeito.

Por fim, é cabível a suspensão da execução pelo Senado Federal mesmo em se tratando de declaração de inconstitucionalidade incidental de norma estadual ou municipal. Ver, a propósito, ADI 3929-MC.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

Item	Pontuação
a) (I) Efeitos <i>inter partes</i> . (II) Senado Federal pode conferir efeitos <i>erga omnes</i> à decisão de (III) inconstitucionalidade proferida na via difusa. (I = 0,1 / II e III = 0,2 cada um.)	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5
b) (I) Não é cabível, pois (II) o ato de suspensão é político e (III) discricionário.	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3

03. (OAB – Exame 2010.3) Considere uma lei federal que aumentou a alíquota de determinado tributo, mas sem dispor expressamente que a nova alíquota só poderia ser cobrada no exercício financeiro seguinte. Suponha que uma turma de determinado Tribunal Regional Federal esteja julgando, em grau de recurso, um mandado de segurança impetrado por um contribuinte que se insurgiu contra a cobrança do tributo no mesmo ano em que fora instituído. Diante desse quadro, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Pode a turma do TRF, ao julgar o caso, estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte? (Valor: 0,6)

b) Qual é o princípio que fundamenta a cláusula de reserva de plenário? (Valor: 0,4)

► Gabarito Comentado

a) Ao estabelecer que a nova alíquota só poderá ser cobrada no ano seguinte ao da sua majoração, a Turma estaria entendendo que a sua cobrança imediata seria inconstitucional, por violar o art. 150, III, “b”. Portanto, trata-se de declaração de inconstitucionalidade, o que impõe a observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB. Ademais, a Turma estaria obrigada a adotar esse procedimento, por estar vinculada ao enunciado da súmula vinculante nº 10, editada pelo STF.

b) O princípio que fundamenta a cláusula de reserva de plenário é o da presunção de constitucionalidade das leis. É por essa razão que a Constituição dispõe (o que vem desde o texto de 1934) que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo ór-

gão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. (art. 97, CRFB)

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

Item	Pontuação
a) Não, pois deve observar a cláusula de reserva de plenário. Súmula vinculante nº 10. (0,2 = fundamento correto e indicação da norma / 0,5 = indicou também o art. 97 / 0,6 = indicou, além dos demais, a súmula).	0 / 0,1 / 0,2 / 0,5 / 0,6
b) Presunção de constitucionalidade das leis.	0 / 0,2 / 0,4

04. (OAB – Exame 2010.3) No início de um ano eleitoral, o Congresso Nacional aprovou e promulgou uma emenda constitucional suprimindo a alínea “a” do inciso II do § 1º do art. 14 da Constituição e alterando o § 2º do mesmo dispositivo, que passaria a ter a seguinte redação: “Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, os analfabetos e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.” Ocorre que, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno de votação da proposta (PEC) no Senado Federal, o Presidente da República havia decretado intervenção federal num determinado Estado da federação. Diante da dúvida generalizada a respeito do direito de voto dos analfabetos na eleição que ocorreria naquele ano, o Procurador-Geral da República houve por bem ajuizar ADI contra a referida emenda constitucional.

A esse respeito, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Uma emenda constitucional pode ser objeto de ADI? (Valor: 0,5)

b) Há inconstitucionalidade formal ou material na emenda em questão? (Valor: 0,5)

► Gabarito Comentado

a) Sim. A emenda constitucional é um ato normativo e, embora vise justamente a alterar o texto constitucional, está sujeita a alguns limites impostos pelo poder constituinte originário: limites circunstanciais (art. 60, § 1º, CRFB) e limites materiais – expressos (art. 60, § 4º, CRFB) e implícitos (art. 1º, parágrafo único, e art. 60, §§ 2º e 3º, CRFB).

b) Há inconstitucionalidade material, por violação ao disposto no art. 60, § 4º, II, da CRFB e inconstitucionalidade formal, por violação ao disposto no art. 60, § 1º, da CRFB.

Em relação à correção, levou-se em conta o seguinte critério de pontuação:

Item	Pontuação
a) (I) Sim, pois a EC está sujeita à observância dos limites ao poder de reforma. Citação dos limites (II) ao poder de reforma. (0,3 = I / 0,2 = II; resposta incompleta = 0,1)	0 / 0,1 / 0,3 / 0,5
b) Inconstitucionalidade material – violação ao art. 60, § 4º, CRFB. Inconstitucionalidade formal – violação ao art. 60, § 1º, CRFB (completa ou incompleta = 0,5)	0 / 0,5

05. (OAB – Exame 2010.3) Em 31/12/2010, foi publicada a Lei ordinária federal 2.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e regulamentou o exercício da profissão de arquiteto e urbanista, estabelecendo, entre outros, as áreas de atuação privativa dos referidos profissionais. Suponha que, a partir da entrada em vigor da referida lei, tenha sido suscitada uma rica discussão sobre a sua constitucionalidade, com argumentos contrários e favoráveis à regulamentação legal daquelas atividades e que foram publicados nos diversos e mais importantes jornais do país, além de publicações em revistas especializadas das áreas de Direito, Urbanismo, Arquitetura e Engenharia.

Com base no exposto, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Seria cabível o ajuizamento de uma ADC pelo próprio Conselho criado pela norma? (Valor: 0,4)

b) Seria cabível o ajuizamento de uma ADI pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? (Valor: 0,3)

c) Assumindo que fosse cabível o ajuizamento da ADC, qual seria o efeito de uma decisão que julgasse improcedente, no mérito, a ação? (Valor: 0,3)

► Gabarito Comentado

a) Embora o CAU/BR tenha legitimidade para a propositura da ADC (art. 103, IX, CRFB), não seria cabível o ajuizamento da ação, pois esta ação demanda a existência de controvérsia judicial relevante acerca do ato nor-

mativo (art. 14, III, Lei 9.868/99), o que não ocorreu no caso, em que o debate se limitou aos jornais e revistas especializadas.

b) O Conselho Federal da OAB pode ajuizar ADI, pois é um dos legitimados para tanto (art. 103, CRFB) e não precisa demonstrar pertinência temática (por ser legitimado universal).

c) De acordo com os arts. 24 e 28, parágrafo único, da Lei 9868, a declaração de inconstitucionalidade pode decorrer tanto da propositura da ADI como da improcedência da ADC, e nos dois casos tem efeito vinculante e eficácia *erga omnes* em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) O CAU tem legitimidade. OU Não há controvérsia judicial relevante.	0 / 0,4
b) O Conselho Federal da OAB tem legitimidade ativa. O Conselho Federal da OAB é legitimado universal. (0,1 = legitimidade ativa / 0,2 = indicou o dispositivo / 0,3 = legitimado universal)	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3
c) Efeitos <i>erga omnes</i> e eficácia vinculante – em relação ao Poder Judiciário e Adm. Pub. (0,1 = só <i>erga omnes</i> / 0,2 = indicou também a eficácia vinculante / 0,3 = indicou o fundamento)	0 / 0,1 / 0,2 / 0,3

► IV Exame

01. (OAB – Exame IV) O Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual X e uma ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto a lei federal Y – ambas ajuizadas com pedido de medida cautelar.

Considerando-se o exposto, responda fundamentadamente:

a) Diante da ambivalência das ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, se o STF indeferir a cautelar na ADI, pode um juiz, no exame de um caso concreto (controle difuso), declarar a inconstitucionalidade da lei X? (Valor: 0,65)

b) Se o STF deferir a cautelar na ADC, pode um juiz, no exame de um caso concreto, declarar a inconstitucionalidade da lei Y, mas por outros fundamentos, que não aqueles que deram causa à ação? (Valor: 0,6)

► Gabarito Comentado

a) A medida cautelar nas ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade não tem caráter ambivalente, de modo que o indeferimento de medida cautelar em ADI não implica a declaração de constitucionalidade.

b) De acordo com a Lei 9.868/99, uma vez deferida a medida cautelar em ADC todos os processos em que a lei objeto da ação estiver sendo discutida devem ser suspensos, razão pela qual uma juíza não poderia, após deferida a cautelar em ADC, declarar a inconstitucionalidade da lei.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Sim, uma vez que a cautelar em ADI não tem caráter ambivalente.	0 / 0,65
B) Não, pois os processos ficam suspensos. (0,3) Art. 21 da Lei 9.868/99 (0,3).	0 / 0,3 / 0,6

02. (OAB – Exame IV) Determinado Partido Político com representação no Congresso Nacional ajuíza Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para questionar a íntegra de uma lei estadual. Em relação ao cenário acima, comente, justificadamente, as consequências jurídicas das seguintes hipóteses, considerando sua ocorrência antes do julgamento da ADI:

a) a lei estadual impugnada é revogada; (Valor: 0,5)

b) o Partido Político deixa de ter representação no Congresso Nacional. (Valor: 0,75)

► Gabarito Comentado

Em relação ao item “a”, a jurisprudência do STF é firme no sentido que a revogação superveniente da norma impugnada em ADI conduz à extinção anômala do processo, ficando o exame do mérito prejudicado, por perda superveniente do objeto da ação. Por sua vez, quanto às ADIs ajuizadas por Partidos Políticos, o STF, em sua jurisprudência inicial, considerava que a ADI deveria ser extinta, sem exame de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa. Porém, no julgamento do Agravo regimental interposto contra decisão monocrática adotada na ADI 2.618/PR, o STF reviu sua posição e atualmente entende que a perda superveniente de representação do Partido Político não repercute sobre o julgamento da

ADI. Em verdade, entende-se que a aferição da legitimidade ativa do Partido Político deve ser realizada à época do ajuizamento da ADI em razão da objetividade do processo e da indisponibilidade da ação.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
A) A ADI será prejudicada, extinta sem exame de mérito, por perda superveniente do objeto.	0 / 0,5
B) Perda superveniente de representação do Partido Político não repercute sobre o julgamento da ADI.	0 / 0,75

03. (OAB – Exame IV) Suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados (recursos extraordinários) a incompatibilidade de uma lei ordinária do Estado Y, em vigor desde 1999, com uma emenda constitucional promulgada no ano seguinte. À 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y foi distribuído um recurso de apelação cível em que a incompatibilidade da referida lei com a emenda constitucional é questão prejudicial. Diante desses fatos, responda:

a) As decisões proferidas pelo STF, reconhecendo a referida incompatibilidade entre lei e emenda constitucional, devem ser encaminhadas ao Senado? Explique. (Valor: 0,7)

b) A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y tem competência para deixar de aplicar a lei estadual incompatível com a emenda constitucional? Explique. (Valor: 0,55)

► **Gabarito Comentado [Comentários feitos quando ainda vigente o CPC/1973.]**

a) No caso, a lei (de 1999) é posterior à Constituição (de 1988), mas anterior à emenda constitucional (de 2000). De acordo com a jurisprudência do STF (ADI 2), a incompatibilidade entre uma lei e uma norma constitucional posterior a ela implica a revogação da lei e não a sua inconstitucionalidade. Tratando-se de revogação e não de inconstitucionalidade, e considerando-se que a competência do Senado restringe-se aos casos de declaração de inconstitucionalidade, a decisão não deveria ser encaminhada àquela Casa legislativa.

Art. 440, parágrafo único do CPC/2015
b) Embora o art. 481, parágrafo único, do CPC “dispense” o órgão fracionário de um Tribunal (no caso, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça

do Estado Y) de encaminhar a questão constitucional ao pleno (art. 97, CRFB) quando há decisão do STF sobre a constitucionalidade da lei, como o caso envolve revogação, e não inconstitucionalidade, a cláusula de reserva de plenário não se aplica, tampouco a exceção a ela, prevista no CPC.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Não se encaminha ao Senado quando é caso de revogação.	0 / 0,7
B) Sim, pois se trata de caso de revogação, em que não se aplica a cláusula de reserva de plenário.	0 / 0,55

04. (OAB – Exame IV) Mévio, advogado com longos anos de carreira, resolve concorrer a vaga de magistrado surgida no Tribunal de Justiça K, tendo apresentado o seu currículo para a Ordem dos Advogados do Brasil, que o incluiu na lista de advogados. Mesma situação ocorreu com a lista escolhida pelo Tribunal de Justiça.

À luz das normas constitucionais, responda aos itens a seguir:

A) Qual é o percentual de vagas destinada aos advogados nos Tribunais de Justiça? (Valor: 0,35)

B) Quais são os ritos de escolha realizados pela OAB e pelo Tribunal de Justiça? (Valor: 0,6)

C) De quem é a competência para nomeação? (Valor: 0,3)

► Gabarito Comentado

O ingresso do advogado na carreira da magistratura pode ocorrer através do denominado Quinto Constitucional, pois a norma do art. 94, da CRFB/88, reserva um quinto das vagas dos tribunais para ocupação dentre membros do Ministério Público e da Advocacia, com notório saber, reputação ilibada, com mais de dez anos de atividade profissional.

A OAB, no caso a seccional estadual, indicará os candidatos em lista sêxtupla, cabendo ao Tribunal de Justiça votar uma lista tríplice que será enviada ao Governador do Estado que escolherá, livremente, um dos indicados.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A – Com base no art. 94 da CRFB (Quinto Constitucional) (0,15), o percentual é de 10% para advogados	0,2
B – Escolha de lista sêxtupla pela OAB local, dentre advogados com mais de dez anos. (0,3). Escolha de lista tríplice pelo TJ	0,3
C – Governador do Estado	0 / 0,3

► V Exame

01. (OAB – Exame V) Com o objetivo de incrementar a arrecadação tributária, projeto de lei estadual, de iniciativa parlamentar, cria uma gratificação de produtividade em favor dos Fiscais de Rendas que, no exercício de suas atribuições, alcancem metas previamente estabelecidas. O projeto é aprovado pela Assembleia Legislativa e, em seguida, encaminhado ao Governador do Estado, que o sanciona. Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) Indique a inconstitucionalidade formal que a lei apresenta e informe se a sanção da Chefia do Poder Executivo teve o condão de saná-la. (Valor: 0,65)

b) Supondo que a lei seja questionada perante o STF por meio de ADI, de que forma poderia o Sindicato dos Fiscais de Rendas daquele Estado atuar no feito em defesa da lei? Teria legitimidade para interposição de embargos declaratórios contra a decisão final adotada na ADI? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

A inconstitucionalidade formal decorre da não observância das regras de processo legislativo revistas na Constituição da República, que são, consoante jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, de reprodução compulsória pelas Constituições Estaduais, uma vez que corolário do princípio da separação funcional de poderes. Na situação proposta, o projeto de lei de iniciativa parlamentar vulnera a norma do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da CRFB, aplicável, por simetria, aos Estados-membros. No que tange à sanção governamental, a jurisprudência do STF é pacífica em reconhecer que a sanção do Governador não tem o condão de convalidar o vício de iniciativa, estando superado Enunciado nº 05 daquele Tribunal.

O Sindicato dos Fiscais de Rendas do Estado poderia requerer a sua admissão no feito na qualidade de *amicus curiae*, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868/99. Em sendo deferido o pedido, poderia o Sindicato manifestar-se por escrito e realizar sustentação oral, mas não poderia interpor recurso, conforme precedentes do STF.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A1) Vício de iniciativa (0,15) – artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da CRFB (0,15) – princípio da simetria (0,15).	0 / 0,15 / 0,30 / 0,45
A2) A sanção não convalida o vício de iniciativa. (0,20)	0 / 0,20
B) Requerer admissão no feito na qualidade de <i>amicus curiae</i> (0,30) Artigo 7º, § 2º, Lei 9.868/99 (0,15) O STF não reconhece legitimidade recursal ao <i>amicus curiae</i> (0,15).	0 / 0,15 / 0,30 / 0,45 / 0,60

02. (OAB – Exame V) O Tribunal de Contas da União (TCU), acolhendo representação contendo fortes indícios de irregularidades em procedimento licitatório realizado por entidade submetida à sua fiscalização, determina, cautelarmente, a suspensão do certame e fixa prazo para que o gestor responsável apresente defesa. Após regular instrução do processo, o TCU rejeita as razões de defesa, confirma a medida acautelatória e aplica multa sancionatória ao administrador público responsável pelas irregularidades.

Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) É juridicamente possível a suspensão cautelar do procedimento licitatório por decisão do TCU? (Valor: 0,65)

b) Supondo que, contra a aplicação da multa sancionatória, não tenha sido interposto qualquer recurso administrativo, qual é a providência a ser adotada para sua execução? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

Quanto à adoção de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas da União, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a atribuição de índole cautelar às Cortes de Contas, com apoio na teoria dos poderes implícitos, permitindo a adoção das medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das com-

petências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República. O *leading case* na matéria foi o MS 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 19-11-2003, Plenário, DJ de 19-3-2004. Além disso, seria um poder implícito decorrente da competência expressa no artigo 71, IX, da CRFB.

Por sua vez, quanto ao item b, as decisões dos Tribunais de Contas de que resulte aplicação de multa ostentam eficácia de título executivo extrajudicial (artigo 71, § 3º, CRFB) e sua execução compete ao órgão de representação judicial do ente público beneficiário da condenação, no caso, a Advocacia-Geral da União.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a1) É juridicamente possível a suspensão cautelar do procedimento licitatório, conforme precedentes do STF (0,30). A jurisprudência do STF reconhece o poder geral de cautela aos Tribunais de Contas com fundamento na teoria dos poderes implícitos. (0,25)	0 / 0,25 / 0,30 / 0,55
a2) Artigo 71, IX, da CRFB. (0,10)	0 / 0,10
b) Compete à AGU / representante judicial promover a execução da multa (0,30). A decisão do Tribunal de Contas que aplica a multa tem natureza de título executivo extrajudicial (0,15) – artigo 71, § 3º, CRFB (0,15).	0 / 0,15 / 0,30 / 0,45 / 0,60

03. (OAB – Exame V) Um fazendeiro descobriu que sua mulher o havia traído com um cidadão de etnia indígena que morava numa reserva próxima à sua fazenda. No mesmo instante em que tomou ciência do fato, o fazendeiro dirigiu-se à reserva indígena e disparou três tiros contra o índio, que, no entanto, sobreviveu ao atentado.

Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) A quem compete julgar esse caso? (Valor: 0,45)

b) Qual é o fundamento do art. 109, IX, da Constituição da República? (Valor: 0,40)

c) Caso o juiz federal entendesse ser incompetente para julgar esse caso e encaminhasse os autos ao juiz de direito e este também entendesse ser incompetente, a quem caberia decidir qual o juízo competente? Por quê? (Valor: 0,40)

► Gabarito Comentado

a) Por se tratar de crime doloso contra a vida, o caso deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, da justiça estadual comum. Embora a vítima seja um índio, o caso não está relacionado a disputa de direitos indígenas, razão pela qual não seria competência da Justiça Federal (art. 109, XI).

b) A atribuição à Justiça Federal da competência para julgar disputas sobre direitos indígenas decorre da competência atribuída à União Federal para proteção da cultura indígena, seus bens e valores (art. 231, CRFB). É por esta razão que a competência, nestas hipóteses, será da Justiça Federal, independentemente do Estado onde o caso tenha ocorrido.

c) A competência, neste caso, será do STJ, pois se trata de conflito negativo de competência entre órgãos vinculados a tribunais diversos (art. 105, I, d, CRFB).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) Justiça estadual (0,15) – Tribunal do Júri (0,15). Não se trata de disputa de direitos indígenas (0,15).	0 / 0,15 / 0,30 / 0,45
b) Proteção dos direitos dos índios é competência da União, art. 109, XI (0,4) OU b) Referência ao fundamento contido no art. 109, IX. (0,4)	0 / 0,4
c) STJ (0,2), por ser conflito negativo de competência entre órgãos vinculados a tribunais diversos OU art. 105, I, d, da CRFB (0,2)	0 / 0,2 / 0,4

04. (OAB – Exame V) O Presidente da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 5º da lei federal X, de 2005. Essa lei tem sido declarada totalmente inconstitucional pelo STF em reiteradas decisões, todas em sede de controle difuso. Com base nesse cenário e à luz da jurisprudência do STF, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

a) O Advogado-Geral da União está obrigado a defender a constitucionalidade da lei X? Explique. (Valor: 0,8)

b) Ao julgar essa ADI, pode o STF declarar a inconstitucionalidade de outro(s) dispositivo(s) da lei X, além do art. 5º? Explique. (Valor: 0,45)

► Gabarito Comentado

a) Não. Embora a Constituição determine que o AGU deve defender a constitucionalidade das leis impugnadas através de ADI, de acordo com o que foi decidido pelo STF na ADI 1616, o AGU está dispensado desta obrigação se a lei em questão já tiver sido declarada inconstitucional pelo STF através de controle concreto-difuso.

b) Sim, caso haja interdependência do art. 5 com outro dispositivo legal. É a chamada inconstitucionalidade por arrastamento.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Pela Constituição, a AGU deve defender (0,2). Pelo STF, está dispensado se já houver decisão do tribunal pela inconstitucionalidade. (0,6)	0 / 0,2 / 0,6 / 0,8
B) Sim, inconstitucionalidade por arrastamento.	0 / 0,45

► VI Exame

01. (OAB – Exame VI) Suponha que tramite perante a Câmara dos Deputados Proposta de Emenda à Constituição da República estabelecendo a obrigatoriedade de Estados, Municípios e Distrito Federal indexarem a remuneração de seus servidores públicos de acordo com o salário mínimo. Considerando a situação hipotética, analise os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso:

a) a constitucionalidade da referida PEC; (Valor: 0,6)

b) a possibilidade de provimento jurisdicional que avalie a constitucionalidade da PEC ainda no curso do processo legislativo. (Valor: 0,65)

► Gabarito Comentado

A PEC não resiste ao confronto com as limitações materiais ao poder de reforma, estabelecidas no artigo 60, § 4º, da CRFB, mais especificamente ao enfraquecimento do pacto federativo. Isso porque a indexação da remuneração dos servidores estaduais, distritais e municipais pelo salário mínimo (fixado em lei da União Federal) importa em vulneração da autonomia dos entes federativos e, nesse sentido, em quebra do pacto federativo (ADPF 33/PA).

Quanto ao item 2, a jurisprudência do STF já se firmou no sentido de reconhecer a possibilidade de controle jurisdicional da PEC em tramitação, reconhecendo a legitimidade dos deputados e senadores para a impetração de mandado de segurança por violação ao direito líquido e certo de observância do devido processo legislativo (MS 24.642/DF).

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
a) Mencionar os limites materiais ao poder de reforma (0,3). Artigo 60, § 4º, I, da CRFB: violação à autonomia dos entes federativos – quebra do pacto federativo (0,3).	0 / 0,3 / 0,6
b) O STF admite o controle jurisdicional de PECs durante a tramitação legislativa para coibir violação ao devido processo legislativo (0,35). Legitimidade do parlamentar para impetração de mandado de segurança (0,3).	0 / 0,3 / 0,35 / 0,65

02. (OAB – Exame VI) Marco Antônio, titular, desde 2006, de mandato de Senador pelo Estado X, pretende se reeleger, em 2014, para o Senado, mas dessa vez como Senador pelo Estado Y, governado pela sua esposa, Maria, eleita em 2010 e que pretende a reeleição em 2014. Como Marco Antonio irá concorrer, em 2014, ao cargo de Senador pelo Estado Y, Paulo, filho de Marco Antonio e Maria, decidiu que naquele ano irá se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado X.

Diante desse quadro, responda:

a) Pode Marco Antonio se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado Y, em 2014? (Valor: 0,75)

b) Pode Paulo se candidatar ao cargo de Senador pelo Estado X, em 2014? (Valor: 0,5)

► **Gabarito Comentado**

a) Não, pois há impedimento em razão de parentesco. Marco Antonio se lançaria candidato a Senador pelo Estado em que sua esposa é Governadora. Neste caso, não ocorre a exceção da parte final do art. 14, par. 7, porque Marco Antonio não é “titular do cargo de Senador pelo Estado Y”.

b) Sim, porque o impedimento previsto no art. 14, par. 7, limita-se aos parentes dos chefes do Poder Executivo (Prefeito, Governador e Presidente).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Não. Inelegibilidade relativa (0,5) – art. 14, § 7º (0,25). Obs.: A mera resposta “não” não é pontuada..	0 / 0,25 / 0,5 / 0,75
B) Sim. A Inelegibilidade se aplica apenas a parentes do Poder Executivo (0,5). Obs.: A mera resposta “sim” não é pontuada.	0 / 0,5

03. (OAB – Exame VI) O Prefeito do Município WK apresenta projeto de lei que outorga reajustes a determinadas categorias de servidores públicos, que veio a sofrer emendas pelos parlamentares ampliando os benefícios para outras categorias não acolhidas no projeto do Chefe do Executivo, com aumento de despesas, em previsibilidade orçamentária. A Constituição Estadual prescreve que nessa matéria a iniciativa é exclusiva do Chefe do Executivo, repetindo normas da Constituição Federal. A lei foi votada por maioria e sancionada pelo Prefeito. A legitimidade prevista para o controle de constitucionalidade repete, no plano local, aquela inscrita na Constituição Federal.

Responda fundamentadamente:

a) A emenda parlamentar ao projeto de lei seria possível? (Valor: 0,65)

b) Existiria algum meio de controle de constitucionalidade da lei votada pela Câmara? (Valor: 0,4)

c) Teria o Prefeito legitimidade para propor a eventual ação direta de inconstitucionalidade, mesmo tendo sancionado o projeto? (Valor: 0,2)

► Gabarito Comentado

Nas leis de iniciativa exclusiva ou privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, “a”, da CRFB) não pode ocorrer emenda parlamentar que gere aumento de despesas. (art. 63, I, da CRFB). No caso de ofensa à Constituição Estadual, seria cabível a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal de competência do Tribunal de Justiça estadual, com a legitimidade conferida ao Chefe do Poder Executivo local, por simetria com a Constituição Federal. Adite-se que mesmo a sanção não seria passível de convalidar a norma, não impedindo, portanto, o controle de constitucionalidade. A jurisprudência do STF é uníssona nessa matéria.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) Não. Por ser lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (0,25). Princípio da simetria (0,2). Obs.: A mera resposta “não” não é pontuada.	0 / 0,2 / 0,25 / 0,45
Artigo 61, § 1º, II, “a”, da CRFB (0,1). Artigo 63, I, da CRFB (0,1).	0 / 0,1 / 0,2
b) Sim. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. (0,2) Artigo 125, § 2º, da CRFB. (0,2) Obs.: A mera resposta “sim” não é pontuada.	0 / 0,2 / 0,4
c) Sim, por simetria à Chefia do Executivo Federal. Obs.: A mera resposta “sim” não é pontuada.	0 / 0,2

04. (OAB – Exame VI) O Senador da República Valdecir foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis pela prisão comunicaram o fato ao Poder Judiciário, que manteve a prisão.

a) Diante do fato descrito, pode ser tomada alguma medida para que o Senador seja posto em liberdade? (Valor: 0,65)

b) Em caso positivo, que medida seria e com que fundamento? Em caso negativo, justifique sua resposta. (Valor: 0,6)

► Gabarito Comentado

É impossível a manutenção da prisão por decisão judicial, uma vez que, em função da imunidade formal prevista no art. 53, § 2º, da Constituição da República, cabe à Casa a que pertence o parlamentar deliberar sobre a manutenção da prisão nos casos de crimes inafiançáveis. Diante da ilegalidade da manutenção da prisão por autoridade incompetente para tanto, cabe a impetração de *habeas corpus* perante o Supremo Tribunal Federal, conforme disposição do art. 102, I, “b” e “d”, da CRFB.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) Sim, por violação da imunidade formal (0,35) nos termos do art. 53, § 2º, da CRFB (0,3). Obs.: A mera resposta “sim” não é pontuada.	0 / 0,3 / 0,35 / 0,65
b) A medida cabível é a impetração de <i>habeas corpus</i> perante o STF (0,3), nos termos do art. 102, I, “b” e “d”, da CRFB (0,3).	0 / 0,3 / 0,6

► VII Exame

01. (OAB – Exame VII) No mês de março, um projeto de emenda constitucional foi rejeitado logo no primeiro turno de votação, realizado na Câmara dos Deputados. Em agosto do mesmo ano, esse projeto de emenda foi novamente posto em votação na Câmara dos Deputados. Na sequência, determinado Deputado Federal, contrário ao projeto de emenda e decidido a impedir sua tramitação, afirmou que iria acessar o Poder Judiciário. Discorra sobre a possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle sobre a tramitação da emenda, bem como sobre a possível medida cabível no caso em tela. (Valor: 1,25)

► Gabarito Comentado

Há possibilidade de o Poder Judiciário controlar a constitucionalidade do processo legislativo do projeto de emenda constitucional. No caso em tela o controle mostra-se viável em função da violação da limitação procedimental constante no art. 60, parágrafo 5º da CRFB. A única medida cabível ao caso é a impetração do mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Identificação da violação do Art. 60, §. 5º da CRFB (0,30) e da possibilidade de controle da PEC pelo judiciário (0,35).	0,00 / 0,30 / 0,35 / 0,65
B) Identificação do mandado de segurança como medida cabível (0,30), bem como da competência do STF para a realização do julgamento (0,30).	0,00 / 0,30 / 0,60

02. (OAB – Exame VII) Em determinado Estado da federação, vieram a público denúncias de irregularidades praticadas em obra pública, com graves indícios de desvio de dinheiro do Erário. Tício, deputado estadual, pretende instalar Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração das denúncias, com base em previsão constante da Constituição estadual. Considerando a situação acima descrita, responda aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) É possível que a Constituição Estadual preveja a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito no plano estadual? (Valor: 0,45)

B) É possível o ajuizamento de ação em que se questione a constitucionalidade de norma de Constituição Estadual perante a Constituição da República, de modo a invalidar aquela? O Governador do Estado tem legitimidade para fazê-lo? (Valor: 0,80)

► **Gabarito Comentado**

A) Há possibilidade de previsão da CPI na Constituição Estadual, fundamentando a resposta na autonomia do Estado. Ou seja, ao conferir poder de auto-organização aos estados da Federação (art. 18, CRFB), permitiu que editassem constituições prevendo formas de investigação, como a CPI (STF, ACO 730-RJ), observado o princípio da simetria.

B) O Governador tem legitimidade para propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, devendo demonstrar pertinência temática. Além disso, deve ser tratada a possibilidade de questionar a constitucionalidade da norma da Constituição Estadual perante a Constituição Federal, conforme reiterada jurisprudência do STF.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
a) Possibilidade da criação da CPI na Constituição Estadual, com fundamento na autonomia (capacidade de auto-organização) dos Estados (art. 18, CRFB) (0,25). Observado o princípio da simetria (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,25 / 0,45
b) Possibilidade de a Constituição Estadual ser objeto de controle de constitucionalidade perante a Constituição Federal (0,40). Legitimidade do Governador para ajuizar a ADI, no caso (art. 103, V, CRFB) (0,20). Pertinência temática (0,20)	0,00 / 0,20 / 0,40 / 0,60 / 0,80

03. (OAB – Exame VII) Renata, servidora pública estadual, ingressou no serviço público antes da edição da Constituição da República de 1988, e é regida pela Lei X, estatuto dos servidores públicos do Estado-membro. Sobre a situação funcional de Renata, responda justificadamente:

A) O que ocorrerá com a Lei X caso ela não tenha sido editada conforme os trâmites do processo legislativo previstos pela atual Constituição? (Valor: 0,40)

B) É possível que Renata questione, em ação individual, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade formal da Lei X perante a constituição revogada? (Valor: 0,40)

C) Tendo em vista que Renata já estava inserida em um regime jurídico, é possível afirmar que a mesma tem direito adquirido a não ser atingida pela Constituição de 1988 no que tange à sua situação funcional? (Valor: 0,45)

► Gabarito Comentado

A) Renata continuará sendo regida pela lei X, que não é formalmente inconstitucional. Ademais, quando nova constituição é editada, somente são consideradas não recepcionadas as normas que contenham incompatibilidade material com a mesma. Ou seja, a incompatibilidade analisada é a de conteúdo e não de forma, que é regida pelo princípio do *tempus regit actum*.

B) É possível que se questione perante qualquer órgão jurisdicional, em um caso concreto, incidentalmente, a invalidade formal de ato legislativo que foi editado em desacordo com os requisitos exigidos para a sua formação, ato que é inválido *ab initio*.

C) Não é possível a oposição do direito adquirido em face de uma nova Constituição. A Constituição é o fundamento de validade de toda ordem jurídica. Nesse sentido, todas as normas (como é o caso da Lei X da questão) existentes no regime constitucional anterior, no que são materialmente incompatíveis com a nova Constituição, ficam revogadas, salvo disposição expressa da Constituição nova. Além disso, há reiterada jurisprudência do STF no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) A lei X não é afetada, pois somente são consideradas não recepcionadas as normas que contenham incompatibilidade material com a nova Constituição.	0,00 / 0,40
B) Possibilidade de se questionar, em controle difuso, a constitucionalidade da lei editada antes da nova Constituição, tendo a Constituição revogada como parâmetro.	0,00 / 0,40
C) Impossibilidade de invocar direito adquirido em face da nova Constituição, notadamente direito adquirido a regime jurídico.	0,00 / 0,45

04. (OAB – Exame VII) Erasmo, cidadão residente e eleitor do Estado “A”, viveu sua infância no Estado “B”, pelo qual possui grande apreço. Por entender que certo Deputado Federal, no exercício de sua função, e no âmbito territorial do Estado “B”, praticou ato lesivo ao patrimônio público do ente ao qual está vinculado, Erasmo propôs ação popular em vara federal da seção judiciária de “B”. O Deputado Federal, em sua contestação, alega a incompetência do juízo de 1º grau, com o fundamento de que possui foro privilegiado, e a ilegitimidade ativa de Erasmo.

Responda aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Qual o órgão competente para conhecer a ação popular ajuizada em face do Deputado Federal? (valor: 0,65)

B) Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, Erasmo teria legitimidade ativa para ajuizar a ação popular na seção judiciária de “Z”? (valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

A) A ação foi proposta no órgão competente, ou seja, em órgão de 1º grau da Justiça Federal, em virtude do disposto no art. 5º da Lei nº 4.717/65 e no art. 102 da Constituição da República (CRFB). O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu reiteradamente que o rol de competências originárias fixadas na CR (art. 102) é taxativo, e que a prerrogativa de foro, unicamente invocável em procedimentos de caráter penal, não se estende às causas de natureza civil (Ex.: Pet 3152 AgR/PA e 1738 AgR/MG). Logo, não são de sua competência originária as ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha foro por prerrogativa de função no STF.

B) A resposta deve ser positiva. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), – vide REsp 1242800/MS (julgamento em 14/06/2011) – o fato de o cidadão ser eleitor em Município diverso daquele onde ocorreram as irregularidades não o impede de ajuizar ação popular, o que poderá ser feito em qualquer seção judiciária (“A”, “B”, “D”, “Z”). Afinal, a legitimidade ativa da ação é deferida

ao cidadão. A condição de eleitor configura meio de prova documental da cidadania.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
A1. Órgão de 1º grau da Justiça Federal (0,20), em virtude de o rol de competências originárias fixadas no artigo 102 da CRFB ser taxativo / a prerrogativa de foro, unicamente invocável em procedimentos de caráter penal, não se estende às causas de natureza civil (0,25).	0,00 / 0,20 / 0,25 / 0,45
A2. Aplicação do artigo 5º da Lei nº 4.717/65 (0,20).	0,00/0,20
B. Sim. O fato de o cidadão ser eleitor em município diverso daquele em que ocorreram as irregularidades não o impede de ajuizar ação popular, pois a legitimidade ativa da ação é deferida ao “cidadão”, sendo a condição de eleitor mero meio de prova da cidadania.	0,00 / 0,60

► **VIII Exame**

01. (OAB – VIII Exame) Uma agência reguladora federal editou, recentemente, uma portaria proibindo aos médicos prescrever a utilização de medicamentos que não tenham similar nacional. A Associação Brasileira de Profissionais da Saúde, entidade de âmbito nacional constituída há mais de dois anos, propôs uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra aquela medida.

A respeito da situação acima, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) É possível a propositura da ADPF contra a portaria emitida pela agência reguladora federal? (Valor: 0,40)

B) A Associação tem legitimidade para a propositura daquela ADPF? (Valor: 0,40)

C) Pode um Estado instituir uma ADPF no plano estadual? Nesse caso, qual o instrumento jurídico apto à criação do instituto? (Valor: 0,45)

► Gabarito Comentado

A) A questão trata do tema da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), previsto no art. 102, § 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e disciplinado pela Lei nº 9.882/1999. O legislador determinou, no art. 4º, § 1º daquela lei, que “Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. O dispositivo consagra o chamado princípio da subsidiariedade, de modo que o cabimento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) para impugnar a validade de determinado ato do poder público exclui o cabimento da ADPF. Tendo em vista que a ADIn não é o mecanismo hábil à impugnação de atos normativos “secundários” (infralegais), abre-se espaço para o cabimento da ADPF para a impugnação de portaria editada por agência reguladora federal.

B) Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.882/1999, “podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental (....) os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade”. De seu turno, os legitimados para a propositura da ADIn são, nos termos do art. 103 da Constituição, “I – o Presidente da República; II – a Mesa do Senado Federal; III – a Mesa da Câmara dos Deputados; IV – a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI – o Procurador-Geral da República; VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII – partido político com representação no Congresso Nacional; IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.

Em relação à legitimidade das entidades de classe de âmbito nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal cunhou o conceito de pertinência temática, que significa a necessidade de demonstração, por alguns legitimada, de que o objeto da instituição guarda relação com o pedido da ação direta proposta por referida entidade. No caso, tal requisito encontra-se atendido, tendo em vista que a norma impugnada se dirige, exatamente, aos profissionais da saúde.

C) A Constituição Federal não previu a arguição no âmbito dos Estados-membros – como fez com ação direta de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º) – mas, a exemplo do que se passa com a ação direta de constitucionalidade, pode ser instituída pelo constituinte estadual, com base no princípio da simetria com o modelo federal.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Sim, a ADPF é medida judicial adequada a impugnar a validade de ato normativo infralegal (0,20), pois restou atendido o princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º da Lei nº 9.882/1999 (0,20) OBS.: A mera indicação do artigo não pontua.	0,00 / 0,20 / 0,40
B) Sim, pois os legitimados para a propositura da ADPF (art. 2º da Lei nº 9.882/1999) são os mesmos da ADIn (art. 103 da CRFB) (0,20), e foi observado o requisito da pertinência temática (0,20). OBS.: A mera indicação do artigo não pontua.	0,00 / 0,20 / 0,40
C) Sim, é possível a instituição de uma ADPF no plano estadual (0,10), desde que se o faça por meio de previsão na Constituição do Estado. (0,35)	0,00 / 0,10 / 0,35 / 0,45

02. (OAB – VIII Exame) Em 2010 foi aprovada emenda à Constituição do Estado “X”, acrescentando dispositivo que permite que o Governador do Estado edite medida provisória, com força de lei, com eficácia imediata, devendo ser convertida em até 30 dias. Com base neste dispositivo, em 15 de dezembro de 2011, o Governador do Estado editou medida provisória majorando as alíquotas mínima e máxima do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, visando à cobrança do imposto com as novas alíquotas em 2012. Não tendo sido apreciada nos primeiros vinte dias de vigência, a medida provisória entrou em regime de urgência, e foi finalmente aprovada pela Assembleia Legislativa. A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) O dispositivo da Constituição do Estado X que confere ao Governador competência para editar medida provisória viola a Constituição da República? (Valor: 0,40)

B) A alteração das alíquotas pela medida provisória editada pelo Governador é constitucional? (Valor: 0,40)

C) As novas alíquotas podem ser cobradas em 2012? (Valor: 0,45)

► Gabarito Comentado

A) Não. Os Estados, no exercício da capacidade de auto-organização (art. 25, *caput*, CRFB), decorrente da autonomia constitucional, podem autorizar os Governadores a editar medida provisória. Trata-se de uma faculdade conferida aos Estados e não de uma obrigação decorrente do princípio da simetria. A Constituição da República, ao proibir que os Estados regulem a exploração e a concessão dos serviços locais de gás canalizado "por medida provisória" (art. 25, § 2º, CRFB), permite, *contrario sensu*, a edição de medida provisória para regular outras matérias.

B) Sim. A alteração da alíquota mínima é constitucional. Já a alteração da alíquota máxima é de competência do Senado, de modo que a sua alteração por medida provisória estadual gera inconstitucionalidade formal parcial.

C) Não. Embora os Estados possam autorizar a edição de medida provisória pelo Governador, devem, por outro lado, observar a regulação deste ato normativo em âmbito federal, o que inclui a observância do princípio da anterioridade em matéria tributária, de modo que uma medida provisória que implique a instituição ou a majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia do ano em que foi editada.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Não. Autonomia ou auto-organização (0,30) conforme art. 25, § 2º. (0,10) OBS.: A mera indicação do artigo não pontua.	0,00 / 0,30 / 0,40
B) Alíquota mínima: sim. (0,20) 0,00/0,20. Alíquota máxima: não, conforme art. 155, § 1º, IV. (0,20).	0,00 / 0,20
C) Não. Observar a regulação do art. 62, § 2º OU observar o princípio da anterioridade (0,45).	0,00 / 0,45

03. (OAB – VIII Exame) Maria alugou um prédio comercial no centro da cidade "P", capital do estado "K", para que o Estado estrangeiro W ali instalasse sua representação consular. Foram estabelecidos aluguéis de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais. Passados dois anos de vigência do contrato, em razão de dificuldades financeiras no continente onde se localiza o Estado W, o mesmo deixa de pagar aluguéis para Maria,

que, inconformada, busca a orientação de um profissional da advocacia para melhor defender seus interesses. O advogado contratado explica que proporá a ação em Vara Cível do Município “P”, cabendo eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado K. Responda, justificadamente, se a orientação do advogado contratado por Maria está na direção correta ao apontar os órgãos jurisdicionais competentes para a matéria em primeiro e em segundo grau de jurisdição. (Valor: 1,25)

► **Gabarito Comentado**

As orientações fornecidas estão equivocadas, pois ações movidas contra Estado estrangeiro devem ser propostas em primeira instância perante um Juiz Federal, conforme art. 109, II da Constituição; em grau recursal é cabível um recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, II, “c” da Constituição.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
A) Não. A primeira instância deverá ser perante Juiz Federal (0,45), conforme art. 109, II da Constituição (0,10). OBS.: A mera citação do artigo não pontua.	0,00 / 0,45 / 0,55
B) Em segundo grau é cabível o recurso ordinário (0,30) perante o STJ (0,30), conforme art. 105, II, “c” da Constituição (0,10). OBS.: A mera citação do artigo não pontua.	0,00 / 0,30 / 0,40 / 0,60 / 0,70

04. (OAB – VIII Exame) Caio e Tício, servidores públicos federais, foram surpreendidos com o advento de uma Emenda Constitucional que alterou o sistema previdenciário dos servidores, aumentando a idade mínima para aposentadoria e a forma de cálculo dos proventos. Caio já havia completado todos os requisitos para a aposentadoria (idade e tempo de contribuição), mas optou por permanecer em atividade. Tício ainda não havia preenchido todos os requisitos: apesar de já possuir a idade mínima, faltava-lhe um ano de contribuição. Pergunta-se:

A) as novas normas são aplicáveis a Caio e Tício, no que diz respeito à idade para aposentadoria e à forma de cálculo dos proventos? (0,80)

B) Alguns anos depois, já aposentados, Caio e Tício recebem a notícia de que foi editada lei federal que, majorando seus proventos de aposentadoria, modificou a sua forma de composição. É válida a lei que altera a composição da remuneração dos aposentados, quanto ao seu valor e a fórmula de cálculo? (0,45)

► Gabarito Comentado

A) Em relação a Caio, as novas normas não lhe são aplicáveis, pois, no momento em que preencheu os requisitos, adquiriu direito à aposentadoria pelas normas então vigentes. E uma Emenda Constitucional não pode ferir direito adquirido (cláusula pétrea). Em relação a Tício, as novas normas são aplicáveis, pois o servidor possuía apenas expectativa de direito à aposentadoria com as regras anteriores. É possível que a Emenda Constitucional traga regra de transição para abarcar aqueles que já eram servidores ao tempo de sua edição, mas, caso não exista essa regra (ou caso o servidor não se enquadre nessa regra), a nova sistemática da aposentadoria é imediatamente aplicável.

B) O examinando deve indicar que é possível a alteração, pois não existe direito adquirido a regime jurídico no que diz respeito à forma de composição dos vencimentos. Deve-se respeitar a irredutibilidade dos proventos, mas não a forma de cálculo do benefício.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Em relação a Caio, as novas normas não lhe são aplicáveis, pois, no momento em que preencheu os requisitos, adquiriu direito à aposentadoria pelas normas então vigentes (0,40) Em relação a Tício, as novas normas são aplicáveis, pois possuía apenas expectativa de direito à aposentadoria com as regras anteriores (0,40).	0,00 / 0,40 / 0,80
B) Sim, a lei é válida, desde que respeitada a irredutibilidade dos proventos, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico em relação a composição de vencimentos (0,45).	0,00 / 0,45

► IX Exame

01. (OAB – IX Exame) A Lei Orgânica do Município “Y”, que integra o Estado “X”, ao dispor sobre ingresso na administração pública municipal, e em observância aos princípios da eficiência e da moralidade, estabeleceu que os cargos, empregos e funções públicas seriam acessíveis aos brasileiros naturais do Estado “X”, que tivessem residência no Município “Y”, e que seriam investidos nos cargos mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. Contra

esse dispositivo da Lei Orgânica foi ajuizada, junto ao Tribunal de Justiça, uma Ação Direta de inconstitucionalidade, nos termos do Art. 125, § 2º da CRFB, alegando violação a dispositivo da Constituição estadual que, basicamente, reproduz o Art. 37 da CRFB. O Tribunal de Justiça conheceu da ação, mas julgou improcedente o pedido, entendendo que, respeitados os limites constitucionais, o Município pode criar regras próprias, no exercício da sua capacidade de auto-organização.

A partir do caso apresentado, responda justificadamente aos itens a seguir.

A) O Município tem autonomia para criar a regra citada no enunciado, conforme entendeu o Tribunal de Justiça? (Valor: 0,40)

B) A ADI estadual pode ter por objeto dispositivo de Lei Orgânica? (Valor: 0,45)

C) Dessa decisão do Tribunal de Justiça, cabe Recurso Extraordinário ao STF? (Valor: 0,40)

► Gabarito Comentado

A) Não. O dispositivo da lei orgânica viola o princípio da isonomia (Art. 5º, da CRFB) ou mais especificamente o da isonomia federativa (Art. 19, III, da CRFB), também prevista no Art. 37, I da CRFB.

B) Sim. A ADI estadual pode ter por objeto atos normativos estaduais e municipais, incluindo a Lei Orgânica, que deve estar de acordo com a Constituição da República e com a Constituição do respectivo Estado, conforme dispõe o Art. 29, da CRFB.

C) Sim. O dispositivo da Constituição estadual violado é norma de reprodução, de modo que, nesses casos, entende o STF que é cabível Recurso Extraordinário.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Não. Isonomia (Art. 5º) ou isonomia federativa (Art. 19, III) ou Art. 37, I (0,40)	0,00 / 0,40
B) Sim. Objeto de ADI (0,25) (Art. 125, § 2º) (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,25 / 0,45
C) Sim. Norma de reprodução (0,40).	0,00 / 0,40

02. (OAB – IX Exame) Instituto destinado a dar maior eficiência aos comandos constitucionais, a medida provisória possibilita que, em situações excepcionais, o Presidente da República edite norma com força de Lei Ordinária. A avalanche de medidas provisórias, porém, vem atravancando o trâmite dos projetos de lei, o que motivou nova orientação do então presidente da Câmara dos Deputados: a pauta não fica travada em relação a matérias que não podem, em tese, ser objeto de medida provisória. Em relação ao tema medida provisória, responda, fundamentadamente, aos seguintes itens.

A) Quais os limites para sua edição? (Valor: 0,40)

B) É possível Constituição Estadual prever edição de medida provisória pelo Governador do Estado? Nesse caso, a norma constitucional estadual poderia estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil? (Valor: 0,45)

C) É possível o controle jurisdicional dos requisitos de relevância e urgência da medida provisória? (Valor: 0,40)

► Gabarito Comentado

A. A medida provisória encontra limites materiais, estampados no § 1º, do Art. 62, da Constituição Federal; limites temporais, encontrados nos §§ 2º e 7º do referido artigo e limites circunstanciais, encontrados no § 10 do aludido dispositivo.

B. A resposta é afirmativa quanto à criação, pois a Constituição Estadual poderá criar Medidas Provisórias. Por outro lado, a norma constitucional estadual deverá guardar os mesmos requisitos e limites da norma da Constituição Federal, face ao mandamento da simetria das normas.

C. São requisitos indispensáveis às medidas provisórias a relevância e urgência, conforme dispõe o Art. 62, *caput* da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, por longa data, entendeu não ser possível o controle de constitucionalidade dos requisitos relevância e urgência, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Todavia, houve parcial mudança no entendimento da Corte, admitindo o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionais, em que a ausência desses pressupostos seja evidente, como por exemplo, na abertura de crédito extraordinário para destinar verba para a saúde que já deveria estar inclusa na lei orçamentária anual.

► **Distribuição dos pontos**

Item	Pontuação
A) A medida provisória encontra limites materiais, estampados no § 1º, do Art. 62, da Constituição Federal (0,20); limites temporais, encontrados nos §§ 2º e 7º do referido artigo (0,10) e limites circunstanciais, encontrados no § 10 do aludido dispositivo (0,10).	0,00 / 0,10 / 0,20 / 0,30 / 0,40
B) Sim, é possível Constituição Estadual prever edição de medida provisória pelo Governador do Estado (0,25) A norma constitucional estadual não poderá estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, devendo guardar os mesmos requisitos e limites da norma da Constituição Federal, face ao mandamento da simetria das normas. (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,25 / 0,45
C) O Supremo Tribunal Federal admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionais. (0,40)	0,00 / 0,40

03. (OAB – IX Exame) José, em um evento de confraternização na empresa em que trabalha, ouviu de Roberto, alterado pela ingestão de bebida alcoólica, que este detinha um cargo em comissão no Tribunal de Contas da União, ao qual nunca comparecera, exceto para a retirada do contracheque, ao final de cada mês. José se dirige, no dia seguinte, ao Tribunal de Contas da União e solicita cópia dos assentamentos funcionais relativos a Roberto, a fim de instruir uma ação judicial. O pedido administrativo foi dirigido ao Ministro Presidente daquela Corte de Contas, que resolveu negá-lo. Consternado, José impetrou Habeas Data em face do Presidente do Tribunal de Contas da União. Considerando a situação acima descrita, responda justificadamente aos itens a seguir.

A) Qual o Juízo ou Tribunal competente para julgamento do Habeas Data impetrado por José? (Valor: 0,40)

B) O dispositivo de lei que exige, para impetração do Habeas Data, demonstração da recusa ao acesso às informações, à luz do princípio da inafastabilidade de jurisdição, é constitucional? (Valor: 0,40)

C) A pretensão de José, nesse caso, pode ser veiculada por Habeas Data? (Valor: 0,45)

► **Gabarito Comentado**

A questão trata do *Habeas Data*, remédio constitucional destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamen-

tais ou, de caráter público, nos termos do Art. 5º, LXXII, da Constituição da República.

A) O examinando deve destacar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa do Art. 102, I, “d” da Constituição da República.

B) A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no *Habeas Data*. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do *Habeas Data*. Esse é o entendimento de longa data consagrado pelo Supremo Tribunal Federal (RHD 22, Rel. p./o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 19-9-1991, Plenário, DJ de 1º-9-1995) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 2). Esse entendimento restou positivado no Art. 8º, § único, da Lei nº 9.507/1997 e vem sendo reafirmado, sempre, pelo STF. (Nesse sentido: HD 87-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento em 25-11-2009, Plenário, DJE de 5-2-2010).

C) A pretensão de José não é amparada por *Habeas Data*, pois o remédio não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, nos termos da alínea “a” do inciso LXXII, do Art. 5º, da CRFB. Sua impetração deve ter por objetivo “assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante.” (Nesse sentido, ainda, jurisprudência STF: HD 87-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgamento em 25-11-2009, Plenário, DJE de 5-2-2010).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) O STF, na forma do Art. 102, I, “d” da CRFB. (0,40)	0,0 / 0,40
B) Sim. O requisito configura concretização do interesse de agir para a propositura de uma demanda (0,20), conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (0,20).	0,0 / 0,20 / 0,40
C) Não. Previsão do Art. 5º, LXXII, “a”, da Constituição Federal de que o remédio se destina a assegurar o conhecimento de informações do próprio impetrante (0,45)	0,0 / 0,45

04. (OAB – IX Exame) O Brasil assinou tratado internacional, discutido e votado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que regulamentava novas formas de controle sobre o comércio exterior. Ao invés de a função ser exercida pelo Ministério da Fazenda, como preceitua o Art. 237 da Constituição Federal, o texto do tratado

veda qualquer possibilidade de controle interno do comércio internacional pelos países signatários. A partir do fato acima, responda aos itens a seguir.

A) De acordo com o ordenamento constitucional vigente, a que autoridade ou órgão compete promover a internalização do referido tratado internacional? (Valor: 0,50)

B) Uma vez internalizado o tratado em questão, com que hierarquia ele passa a integrar o ordenamento jurídico pátrio? (Valor: 0,25)

C) Qual (is) princípio(s) de Interpretação Constitucional deve(m) nortear a resolução do conflito entre o texto do tratado e o texto constitucional? (Valor: 0,50)

► Gabarito Comentado

A) Cabe ao Presidente da República tão somente assinar o documento internacional (Art. 84, VIII), que deve ser submetido ao Congresso Nacional, a quem compete resolver definitivamente sobre Tratados, promovendo a sua internalização, conforme dispõe o Art. 49, inciso I, da Constituição Federal.

B) Tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, como o referido na questão, depois de internalizados, ingressam no ordenamento jurídico com status de Lei Ordinária.

C) Pelo Princípio da Supremacia da Constituição, conflito entre norma constitucional e norma com hierarquia de Lei Ordinária deve ser resolvido atestando-se a primazia do dispositivo constitucional.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Cabe ao Presidente da República assinar o documento internacional (Art. 84, VIII), que deve ser submetido ao Congresso Nacional a quem compete resolver definitivamente sobre Tratados, promovendo a sua internalização, conforme dispõe o Art. 49, inciso I, da Constituição Federal. (0,50).	0,00 / 0,50
B) Tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, depois de internalizados, ingressam no ordenamento jurídico com status de Lei Ordinária. (0,25).	0,00 / 0,25
C) Pelo Princípio da Supremacia da Constituição (0,50).	0,00 / 0,50

► **X Exame**

01. (OAB – X Exame) Determinado Ministério apresentou desempenho considerado insuficiente pela imprensa e pela opinião pública, havendo sério questionamento quanto aos gastos públicos destinados para a sua manutenção. Dessa forma, um Senador pelo Estado Y apresentou um projeto de lei no sentido de extinguir este Ministério. Tal projeto foi votado em plenário em um dia em que 32 (trinta e dois) dos 81 (oitenta e um) senadores estavam presentes, sendo aprovado pelo voto da maioria dos presentes e encaminhado à Câmara dos Deputados. Contando com forte apoio popular, a proposta legislativa foi aprovada pela maioria absoluta dos deputados federais e encaminhada ao Presidente da República, que a sancionou doze dias úteis depois de tê-la recebido, determinando sua imediata publicação no Diário Oficial da União. Uma semana após a publicação da lei na imprensa oficial, a CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) ajuizou uma ação declaratória de constitucionalidade em que pleiteava a declaração de conformidade da nova norma legal com a Constituição.

Responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Há algum vício que fulmine a constitucionalidade da norma em questão? (Valor: 0,80)

B) A CONAMP poderia ter ajuizado a ação declaratória de constitucionalidade? (Valor: 0,45)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► **Gabarito Comentado**

A) A norma possui vícios a fulminar a sua constitucionalidade. Projeto de lei para extinguir Ministério é de iniciativa privativa do Presidente da República (Art. 61, § 1º, II, “e” da Constituição), havendo, portanto, vício de iniciativa, já que o mesmo não poderia ter sido apresentado por um senador. Houve ainda vício na votação do projeto no Senado Federal, eis que o Art. 47 da Constituição exige a presença de maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa para a votação de um projeto de lei, ou seja, no caso, seria necessária a presença de ao menos 41 senadores para realizar a votação.

B) Apesar de legitimada pelo Art. 103, IX da Constituição, a CONAMP não poderia ter apresentado a ação declaratória de constitucionalidade no caso em análise, pois ausente o requisito da pertinência temática que deve obedecer, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Além do mais, tendo proposta a ação apenas uma semana após a publicação da lei, não foi seguido o requisito da controvérsia judicial relevante, exigido pelo Art. 14, III da Lei nº 9.868/99.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) O projeto era de iniciativa privativa do Presidente da República (0,20). Aplicação do Art. 61, § 1º, II, “e” da Constituição (0,20). É necessária ao menos a presença da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa para a votação do projeto de lei (0,20), conforme Art. 47 da Constituição Federal (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,40 / 0,60 / 0,80
B) Há ausência de pertinência temática para ajuizar a ação (0,25). Não foi obedecido o requisito da controvérsia judicial relevante (0,10). Incidência do Art. 14, III da Lei nº 9.868/99 (0,10). Obs.: A simples citação da lei não pontua.	0,00 / 0,10 / 0,25 / 0,35 / 0,45

02. (OAB – X Exame) Lei do Estado “Y”, editada em abril de 2012, com base no Art. 215, § 1º da Constituição da República, regulamenta a chamada rinha de galo, prática popular em que dois galos se enfrentam em lutas e espectadores apostam no galo que acreditam ser o vencedor. Comumente, os dois galos saem com muitos ferimentos da contenda, e não raras vezes algum animal morre ou adquire sequelas permanentes que recomendam seu abate imediato. A Associação Comercial do Estado “Y” ajuíza ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da referida lei estadual.

Em defesa da norma, parlamentar que votou pela sua aprovação, diz, em entrevista a uma rádio local, que a prática da conhecida briga de galos é comum em várias localidades rurais do Estado “Y”, ocorrendo há várias gerações. Além do mais, animais, especialmente aves, são abatidos diariamente para servir de alimento, o que não ocorreria com as aves destinadas para as rinhas.

Responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Quanto ao mérito do pedido, é cabível a declaração de inconstitucionalidade da lei do Estado “Y”, que regulamenta a chamada rinha de galo? (Valor: 0,65)

B) Há regularidade na legitimidade ativa da ação? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

A. Sim. Em que pese a Constituição dispor que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, há norma expressa que proíbe práticas que submetam os animais a crueldade. O caso é de aplicação do Art. 225, § 1º, VII da Constituição da República. Pelo princípio da unidade da Constituição e/ou o princípio da especialidade, não é possível que o Estado proteja manifestações culturais que submetam animais à crueldade. Precedentes do STF: ADI 3776, ADI 1856 e ADI 2514.

B. Não. O Art. 103, IX, da Constituição (reproduzido no Art. 2º, IX, da Lei 9868/99) exige que a entidade de classe tenha âmbito nacional para ajuizar ADI, o que não se deu no presente caso, uma vez que a Associação Comercial do Estado “Y” é entidade de classe de âmbito estadual.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A) Sim. Incidência do Art. 225, § 1º, VII da Constituição (0,40). Pelos princípios da unidade da Constituição OU da especialidade não se pode ter uma manifestação cultural que submeta os animais à crueldade (0,25).	0,00 / 0,25 / 0,40
B) Não. A Associação Comercial do Estado “Y” não é entidade de classe de âmbito nacional (0,30), como exige o Art. 103, IX da CRFB OU Art. 2º, IX da Lei 9868/99 (0,30).	0,00 / 0,30 / 0,60

03. (OAB – X Exame) Proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10% (dez por cento) dos Deputados Federais, cujo teor é criar novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, no controle abstrato de normas, ao crivo do Congresso Nacional, de modo que a decisão do Tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria ab-

soluções dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. A proposta é discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional, onde recebe a aprovação da maioria absoluta dos Deputados e Senadores nos dois turnos de votação. Encaminhada para o Presidente da República, este resolve sancionar a proposta, publicando a nova emenda no Diário Oficial. Cinco dias após a publicação da emenda constitucional, a Mesa da Câmara dos Deputados apresenta perante o Supremo Tribunal Federal ação declaratória de constitucionalidade em que pede a declaração de constitucionalidade desta emenda com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão? (Valor: 1,00)

B) A ação declaratória de constitucionalidade poderia ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal? (Valor: 0,25)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

A) Há diversas inconstitucionalidades formais. Inicialmente a PEC não poderia ser apresentada por 10% (dez por cento) dos Deputados Federais, já que, segundo o Art. 60, I da Constituição, esta só pode ser emendada por proposta de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados. A proposta deveria ser aprovada por três quintos dos membros de cada casa do Congresso Nacional (Art. 60, § 2º da Constituição) e não pela maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Por fim, não cabe sanção ou veto de proposta de emenda à Constituição, pois, conforme Art. 60, § 3º da Constituição, as emendas deverão ser promulgadas pelas Mesas da Câmara e do Senado. Materialmente também há inconstitucionalidade, uma vez que o teor da proposta, ao submeter todas as decisões do STF, no controle abstrato, ao crivo do Congresso Nacional, é atentatório contra a cláusula pétrea da separação dos poderes (Art. 60, § 4º, III da Constituição), pois esta cláusula pressupõe um sistema de freios e contrapesos, com controle e vigilância dos poderes constituídos entre si, sendo a emenda tendente a abolir tal cláusula.

B) Não. A ação não poderia ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal por ausência do requisito legal da existência de controvérsia judicial relevante (Art. 14, III da Lei nº 9.868/1999), já que não houve tempo hábil para que o Judiciário questionasse a norma objeto da referida ação.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A.1. A PEC não foi apresentada por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados (0,15). Art. 60, I da Constituição (0,10)	0,00 / 0,10
A.2. A PEC não foi aprovada por, ao menos, três quintos dos membros de cada casa do Congresso (0,15). Art. 60, § 2º, da Constituição (0,10)	0,00 / 0,10
A.3. Não cabe ao Presidente da República sancionar ou vetar uma PEC (0,15). Art. 60, § 3º, da Constituição (0,10)	0,00 / 0,10
A.4. A PEC viola a separação dos poderes por sujeitar as decisões do Supremo ao crivo do Poder Legislativo (0,15). Art. 60, § 4º, III, da Constituição (0,10)	0,00 / 0,10
B. Não, já que não há o requisito da controvérsia judicial relevante (0,15). Art. 14, III, da Lei 9.868/1999 (0,10)	0,00 / 0,10

04. (OAB – X Exame) O Estado W, sem motivo de força maior, não repassa aos municípios receitas tributárias determinadas pela Constituição Federal, nos prazos nela determinados. O Município JJ necessita dos recursos para realizar os serviços básicos de atendimento à população.

Diante do narrado, responda aos itens a seguir.

A) Quais as consequências do não repasse das verbas referidas? (Valor: 0,50)

B) Quais os procedimentos exigidos pela Constituição nesse caso? (Valor: 0,75)

O examinando deve fundamentar corretamente sua resposta. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

A) Nos termos do Art. 34, V, "b", da CFRB/88. (Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: ... V – reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a) suspender o pagamento da

dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;). Trata-se de intervenção para defesa das finanças estaduais.

B) O ato de intervenção será formalizado por decreto do Poder Executivo (CFRB, Art. 36). No caso em tela dependerá apenas da constatação dos fatos, ou seja, do não repasse. Haverá a nomeação de um interventor, pois se trata de intervenção no Executivo. Será o decreto submetido ao Congresso Nacional que, se em recesso, sofrerá convocação extraordinária (CFRB, Art. 36, §§ 1º e 2º). O ato pode ser realizado *ex officio* pelo Presidente da República ou decorrer de comunicação do município. Deverão ser ouvidos o Conselho da República (Art. 90, I, da CRFB) e o Conselho de Defesa Nacional (Art.91, § 1º, II, da CRFB).

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A. Intervenção da União nos Estados (0,25). Art. 34, V, "b", da CRFB (0,25).	0,00 / 0,25 / 0,50
B1. Decreto do Presidente (CFRB, Art. 36) (0,15). Submissão ao Congresso (CFRB, Art. 36) (0,15). Convocação extraordinária (0,15)	0,00 / 0,15 / 0,30 / 0,45
B2. Conselho da República (Art. 90, I, da CRFB) (0,15) e o Conselho de Defesa Nacional (Art.91, § 1º, II, da CRFB) (0,15)	0,00 / 0,15 / 0,30

► XI Exame

01. (OAB – XI Exame) Determinado Estado-membro aprovou uma lei que incluiu a disciplina de formação para o trânsito nos currículos do 1º e do 2º graus de ensino da rede pública estadual.

A esse respeito, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Analise a constitucionalidade dessa lei estadual. (Valor: 0,65)

B) O Governador de outro Estado pode ajuizar ADI ou ADPF contra esta lei? Por qual (is) motivo (s)? (Valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

O candidato deverá, na essência, observar quanto às perguntas, o seguinte:

A) A lei é constitucional, pois o Art. 24, IX, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Esta lei trata de educação no trânsito e não sobre trânsito e transporte, que seria de competência privativa da União Federal (Art. 22, XI, CRFB). Neste sentido, já se pronunciou o STF, ao julgar a ADI 1991/DF (Rel. Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, unânime, j. 03.11.2004).

B) Não, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, o Governador do Estado é legitimado especial, o que significa que só pode ajuizar a ação se demonstrar a existência de pertinência temática entre o interesse do Estado e o objeto da ação, o que não ocorre no caso concreto.

02. (OAB – XI Exame) O partido político “X” move, perante o Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Estado “Y”, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito daquele Estado federado, para atender às suas peculiaridades, sem afrontar normas gerais preexistentes. O partido alega que a referida lei estadual é inconstitucional, uma vez que a competência privativa para legislar sobre a matéria é da União, conforme o Art. 22, XXVII da Constituição da República. Parecer da Procuradoria-Geral da República opina no sentido do não conhecimento da ação, uma vez que o partido político “X” possui em seus quadros apenas seis Deputados Federais, mas nenhum Senador, não sendo dessa maneira legitimado a mover a referida ação direta. Além disso, não estaria demonstrado na inicial o requisito da pertinência temática. A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) É caso de se acolher o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do não conhecimento da ação? (Valor: 0,65)

B) Quanto ao fundamento de mérito apresentado, tem razão o partido político ao questionar a constitucionalidade da norma impugnada? (Valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► **Gabarito Comentado**

O candidato deverá, na essência, observar quanto às perguntas, o seguinte:

A) Não. A ação deve ser conhecida, uma vez que o partido político possui representação no Congresso Nacional, conforme Art. 103, VIII, da Constituição Federal, já que basta possuir representante em apenas uma das casas do Congresso Nacional para que o partido político tenha representação no Congresso, não sendo necessário que possua representantes nas duas casas legislativas. Além do mais, o partido político é legitimado universal e não precisa cumprir o requisito da pertinência temática.

B) Não. Quanto ao mérito, não tem razão o partido político no seu pleito, sendo caso de improcedência da ação, uma vez que a competência privativa da União do Art. 22, XXVII, da Constituição Federal se refere a normas gerais, tendo os estados federados competência para legislar sobre o tema para atender às suas peculiaridades, desde que não haja afronta às normas gerais editadas pela União.

03. (OAB – XI Exame) Lei do Município YY, de iniciativa da Câmara de Vereadores, estipulou novo plano de carreira para a categoria de professores municipais, impondo remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local. Com base no caso proposto, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

A) Observadas as regras constitucionais, há vício na referida lei? (Valor: 0,65)

B) A vinculação de remunerações entre Poderes é acolhida no texto constitucional? (Valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► **Gabarito Comentado**

O candidato deverá, na essência, observar quanto às perguntas, o seguinte:

A) Sim, há vício de iniciativa. Consoante o Art. 61, § 1º, II, letras a) e c), da Constituição Federal, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa quanto ao tema servidores públicos, norma que, por simetria, deve ser observada pelos Estados e Municípios.

B) Não, pois do art. 37, XIII, da Constituição Federal veda a equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie.

04. (OAB – XI Exame) Morales, de nacionalidade cubana, participante de *reality show* produzido e divulgado por emissora de televisão brasileira, alega que teve o seu direito fundamental à intimidade violado, ao serem amplamente divulgadas imagens suas em ato de convulsão, decorrentes de disfunção epilética que possui. Assim, após sua saída do programa, ingressa com demanda em face da emissora de televisão.

Considerando o fato acima descrito, responda fundamentadamente:

A) É possível invocar um direito fundamental, previsto na Constituição, em uma demanda movida contra um particular? (Valor: 0,65)

B) Seria correto o argumento, posto em sede de defesa, que a norma constitucional que resguarda o direito à intimidade não pode ser invocada, tendo em vista a ausência de lei disciplinando o dispositivo constitucional? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

O objetivo da questão é verificar se o candidato tem conhecimento das características dos direitos fundamentais, bem como das teorias acerca de sua aplicação.

A) Deve ser respondido que é possível a demanda, explicando o que vem a ser eficácia horizontal dos direitos fundamentais, bem como esclarecendo que esta eficácia horizontal decorre da dimensão objetiva dos direitos fundamentais.

B) Não é correto o argumento da defesa. Os direitos individuais, nos termos do Art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, têm aplicabilidade imediata, prescindindo de edição de norma regulamentadora, salvo quando a própria Constituição assim o exigir expressamente.

► **XII Exame**

01. (OAB – XII Exame) Insatisfeito com a demora para a efetivação das desapropriações necessárias à construção de uma rodovia federal, o Presidente da República editou o Decreto nº 9.999, por meio do qual, expressamente, determinou a revogação do Decreto Lei nº 3.365/1941, que dispunha sobre a desapropriação por utilidade pública, e, ao mesmo tempo, institui novo regramento a respeito do tema.

Sobre a hipótese apresentada, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

A) Em nosso ordenamento jurídico constitucional, existe previsão para a edição de decreto autônomo? (Valor: 0,50)

B) É possível a revogação do Decreto Lei nº 3.365/1941 pelo decreto presidencial? (Valor: 0,75)

► **Gabarito Comentado**

A) A resposta é positiva. “A Emenda Constitucional nº 32/2001, que modificou a redação do Art. 84, VI da Constituição da República, permitiu, em nosso ordenamento pós-Constituição de 1988, o chamado ‘decreto autônomo’, isto é, aquele decreto de perfil não regulamentar, cujo fundamento de validade repousa diretamente na Constituição”. Contrapõe-se aos chamados decretos regulamentares, ou de execução, previstos no Art. 84, IV, da Constituição, que não criam, modificam ou extinguem direitos, mas apenas desenvolvem a lei já existente, de onde buscam fundamento de validade. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal admite o controle, por via de ação direta de inconstitucionalidade, do decreto autônomo, revestido de conteúdo normativo, mas não o admite quando se tratar de decreto de regulamentação da lei.

B) A resposta é negativa. Em primeiro lugar, a desapropriação é matéria que exige lei em sentido formal para a sua disciplina, conforme previsão constante do Art. 5º, XXIV, da Constituição. Desse modo, o Decreto Lei nº 3.365/1941, que se reveste de forma não mais existente em nosso ordenamento, foi recepcionado com status de lei ordinária, e somente por essa forma legislativa pode ser revogado ou alterado. A mesma conclusão pode ser extraída do princípio da legalidade, que condiciona restrição a direito à existência de lei em sentido formal.

Além disso, o decreto autônomo só encontra espaço, em nosso ordenamento, para as hipóteses do Art. 84, VI, da Constituição, cabendo-lhe, no mais, apenas a regulamentação das leis. Por essa razão, decreto que cria disciplina nova ou que revoga ato normativo hierarquicamente superior exorbita da disciplina constitucional. Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, reiteradas vezes, afirmando que “faíece competência ao chefe do Poder Executivo para expedir decreto destinado a paralisar a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior” e a possibilidade de “controle de constitucionalidade de decretos que determinam a suspensão de lei complementar e a introdução de inovações legislativas, em extrapolação da função regulamentar”.

02. (OAB – XII Exame) Com a aproximação do pleito eleitoral, o Prefeito do Município ABC, que concorrerá à reeleição, vem tentando resgatar a sua imagem, desgastada por conta de sucessivos escândalos. O Prefeito deu início a uma série de obras públicas de embelezamento da cidade e quadruplicou as receitas destinadas à publicidade. Para fazer face a essas despesas, o Município deixou de aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde e anunciou corte ainda maior nas verbas destinadas à educação e saúde para o exercício financeiro seguinte.

Considerando que a Constituição da República autoriza a intervenção nessa hipótese, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

A) A União pode intervir nos Municípios, caso o Estado deixe de fazê-lo? (Valor: 0,65)

B) Caso o Governador decrete a intervenção do Estado no Município, tal ato estará sujeito a alguma forma de controle político? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

A) A resposta é negativa. A intervenção é medida excepcional, que só poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente enumeradas no texto constitucional. E a Constituição somente autoriza a intervenção federal em Estados ou em Municípios situados em territórios federais (artigos 34 e 35, da CRFB), mas não a intervenção federal em municípios situados em Estados (ainda que haja omissão do Estado). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, de longa data, deixou assentada essa impossibilidade, registran-

do que os municípios situados no âmbito dos estados-membros não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção decretada pela União, eis que, relativamente a esses entes municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles intervir é o Estado-membro. Por isso mesmo, no sistema constitucional brasileiro, falece legitimidade ativa à União para intervir em quaisquer Municípios, ressalvados, unicamente, os Municípios localizados em Território Federal.

B) A resposta é positiva. A intervenção estadual no município, no caso descrito, é ato executado pelo Chefe do Poder Executivo (Governador). Nada obstante, a própria Constituição da República estabelece o controle político *a posteriori* da Assembleia Legislativa do Estado sobre o Decreto de intervenção expedido pelo Governador (Art. 36, § 1º, CRFB).

03. (OAB – XII Exame) O Estado “Z” editou lei que institui uma Taxa de Fiscalização de Estradas; impondo o pagamento de uma elevada quantia para o acesso ou para a saída do território daquele Estado por meio rodoviário.

Sobre a hipótese sugerida, responda, fundamentadamente, aos seguintes itens.

A) O Governador do Estado “Y” pode impugnar a lei editada pela Assembleia Legislativa do Estado “Z” por meio de ação direta de inconstitucionalidade? (Valor: 0,65)

B) Caso a lei do Estado “Z” seja impugnada por um partido político, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, pode prosseguir a ação em caso de perda superveniente da representação do partido no Congresso Nacional? (Valor: 0,60)

► Gabarito Comentado

A) O examinando deve identificar que, no caso de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Governador de um Estado tendo por objeto lei de outro Estado da Federação, impõe-se a demonstração do requisito da “pertinência temática”. Esse requisito se refere à comprovação, por alguns legitimados, de que o objeto da instituição guarda relação (pertinência) com o pedido da ação direta proposta por referida entidade, tendo em vista a repercussão do ato sobre os interesses do Estado. A pertinência temática é requisito construído, de longa data, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, seria necessário que o Governador de um Estado da Federação demonstrasse que o conteúdo debatido em tal ação de controle de constitucionalidade (isto é, a lei de outro Estado da Federação) tem ligação, no mínimo indireta, com o interesse do seu Estado e de sua população.

B) O examinando deve identificar que a perda superveniente de representação no Congresso Nacional não obsta o prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Isso porque a aferição da legitimidade há de ser feita no momento da propositura da ação, uma vez que se trata de processo objetivo e indisponível. O próprio Supremo Tribunal Federal superou antiga jurisprudência que apontava a descaracterização superveniente da legitimidade no caso de perda de bancada legislativa no Congresso Nacional após a propositura da demanda.

04. (OAB – XII Exame) Após intenso debate, a Assembleia Legislativa do Estado X editou a Lei nº 1.001, de iniciativa do Deputado “M”, que prevê a obrigatoriedade de instalação, em até 360 (trezentos e sessenta dias), de um sistema eletrônico de limitação da velocidade de veículos automotores, de baixo custo, a fim de reduzir o número de acidentes com vítimas nas estradas estaduais. Irritado, o Deputado “P”, da oposição, quando procurado por jornalistas, afirmou que estava envergonhado daquele dia, pois a lei aprovada era “uma piada, uma palhaçada, ridícula”, protegia os empresários, e não a população e só poderia ter, como origem, um Deputado associado a grupos interessados no mercado de peças automotivas.

Considerando o exposto, responda fundamentadamente, aos itens a seguir.

A) O Deputado “P” pode ser responsabilizado pelas ofensas proferidas durante a entrevista? (Valor: 0,85)

B) É válida a lei estadual que impôs a obrigatoriedade de instalação de sistema de controle de velocidade de veículos automotores? (Valor: 0,40)

► Gabarito Comentado

A) A resposta é negativa. A Constituição assegura aos Deputados e Senadores, em seu Art. 53, a inviolabilidade, civil e penal, por suas opiniões, palavras e votos. Trata-se da chamada imunidade material. Essa

inviolabilidade, ou imunidade material também abrange, sob seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas e as declarações feitas aos meios de comunicação social, uma vez que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – se qualificam como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, “P” não pode ser responsabilizado pelas ofensas proferidas a outro Deputado durante a entrevista.

B) A resposta é negativa. A Constituição estabelece um sistema de repartição de competências legislativas, atribuindo privativamente à União legislar sobre trânsito e transportes (Art. 22, XI). Nesse sentido, não se admite aos Estados a edição de lei que disponha sobre a adoção de mecanismos ou sistemas eletrônicos de controle da velocidade de veículos automotores, por constituir invasão de tema reservado à competência privativa da União. Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas ocasiões.

► XIII Exame

01. (OAB – XIII Exame) Em 2004, entrou em vigor a lei estadual “X”, de autoria de um deputado governista (partido A), sob protestos de alguns parlamentares da oposição (partido B), já que a lei era flagrantemente inconstitucional de acordo com a jurisprudência pacífica do STF. A oposição, contudo, venceu as eleições naquele ano e já em 2005, quando o partido B conquistou a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa, foi aprovada a lei Y que revogou a lei “X”, ao dispor de forma distinta sobre a mesma matéria (revogação tácita), embora mantido vício de inconstitucionalidade. A partir do caso descrito, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, responda aos itens a seguir.

A) Após a entrada em vigor da Lei “Y”, pode o partido B ajuizar ADI, junto ao STF, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei “X”? (Valor: 0,55)

B) O Procurador-Geral da República pode ajuizar ADI pedindo a declaração de inconstitucionalidade das leis “Y” e “X”, sucessivamente? (Valor: 0,70)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

A) Não, pois lei revogada não pode ser objeto de ADI. Faltaria objeto, pois uma vez revogada, não mais estaria no mundo.

B) Sim, pois se a lei Y fosse declarada inconstitucional, voltaria a vigorar a lei X, e o Procurador-Geral da República já poderia pedir a inconstitucionalidade na mesma ADI, conforme entendimento atual do STF. OU

Não, o Procurador-Geral da República pode pedir a inconstitucionalidade da lei Y e, declarada sua inconstitucionalidade, que não haja efeito repristinatório em relação à lei X, conforme entendimento atual do STF.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A. Não, pois lei revogada não pode ser objeto de ADI. (0,55)	0,00 \ 0,55
B. Sim. A lei "X" voltará a vigorar e, consequentemente, será passível de controle (0,35). Indicação da legitimação universal do Procurador Geral da República. (0,35) OU Não, o Procurador-Geral da República pode pedir a inconstitucionalidade da lei Y (0,35) e, declarada sua inconstitucionalidade, que não haja efeito repristinatório em relação à lei X (0,35), conforme entendimento atual do STF	0,00 \ 0,35 \ 0,70

02. (OAB – XIII Exame) Giácomo e Giovanna são turistas italianos que, apaixonados pelo Brasil, aqui fixam residência, obtêm emprego e constituem família. Seus dois filhos, Luigi e Filipa nasceram no Brasil, respectivamente em 1989 e 1991. Considerando que o ordenamento italiano atribui nacionalidade italiana aos filhos de seus cidadãos, ainda que nascidos no estrangeiro, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

A) Filipa pode ser extraditada para a Itália, pela prática de crime comum, caso o Brasil mantenha tratado de extradição com aquele País? (Valor: 0,80)

B) A legislação ordinária pode estabelecer nova hipótese de aquisição de nacionalidade brasileira? (Valor: 0,45)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

A) A resposta é negativa. A despeito da previsão constante da legislação italiana, Filipa é brasileira nata, conforme previsão constante do artigo 12, inciso I, da Constituição. Além disso, o artigo 12, § 4º, II, "a", dispõe que não perde a nacionalidade brasileira aquele que tiver reconhecida a sua nacionalidade originária pela lei estrangeira, caso de Filipa. E os brasileiros natos não podem ser extraditados, conforme artigo 5º, inciso LI, da Constituição.

B) A resposta também é negativa. As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade originária quer se trate de nacionalidade derivada, decorrem exclusivamente do texto constitucional.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A1. Não, pois Filipa é brasileira nata (0,30), na forma do artigo 12, I, da Constituição (0,10).	0,00 \ 0,30 \ 0,40
A2. Os brasileiros natos não podem ser extraditados (0,30), conforme artigo 5º, inciso LI, da Constituição (0,10).	0,00 \ 0,30 \ 0,40
B. Não. As hipóteses de outorga da nacionalidade brasileira, quer se trate de nacionalidade originária quer se trate de nacionalidade derivada, decorrem exclusivamente do texto constitucional. (0,45).	0,00 \ 0,45

03. (OAB – XIII Exame) O Deputado Federal "G", de matriz política conservadora, proferiu, em sessão realizada na Câmara dos Deputados, pesado discurso contra o reconhecimento legal do direito de diversas minorias. Sentindo-se lesados, representantes de diversas minorias vão a público para manifestar sua indignação. A partir da hipótese sugerida, pergunta-se:

A) O deputado "G" pode ser condenado, civil ou penalmente, pelo discurso ofensivo que proferiu no plenário? E se proferir tal discurso durante entrevista televisiva, fora do ambiente da Câmara dos Deputados? Responda fundamentadamente. (Valor: 0,65)

B) Os vereadores possuem a chamada imunidade material? Em que condições territoriais? (Valor: 0,60)

A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► Gabarito Comentado

A) O examinando deve indicar que, conforme previsão constante da Constituição, aos Deputados é garantida a imunidade material, civil e penal, pela qual os parlamentares federais são invioláveis e irresponsáveis pelas suas opiniões e votos quando o fazem na qualidade de agentes políticos. O dispositivo constitucional que assegura tal direito é o artigo 53, *caput*, da Constituição: “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.” Portanto, o deputado “G” não pode ser condenado pelo discurso proferido, ainda que ofensivo às minorias. Deve ser indicado que a imunidade material se estende para os discursos proferidos fora do ambiente do Congresso Federal, desde que proferidos em razão do exercício do mandato parlamentar (isto é, na qualidade de agentes políticos). Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

B) O examinando deve identificar que a garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material também alcança os vereadores, para excluir a responsabilidade civil e penal do membro do Poder Legislativo, por danos eventualmente resultantes de manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática *in officio*) ou externadas em razão deste (prática *propter officium*). Tratando-se de vereador, a inviolabilidade constitucional que o ampara no exercício da atividade legislativa estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos, mesmo fora do recinto da própria Câmara Municipal, desde que nos estritos limites territoriais do Município a que se acha funcionalmente vinculado, conforme previsão constante do artigo 29, VIII, da Constituição Federal.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A. Não, pois da Constituição Federal assegura aos Deputados a chamada imunidade material, pela qual os parlamentares federais são invioláveis, civil e penalmente, pelas suas opiniões, palavras e votos (0,20). A imunidade material se estende para fora do âmbito do Congresso, em qualquer ambiente que o parlamentar federal se encontre, desde que o discurso seja motivado pelo desempenho do mandato ou externado em razão deste (0,35), conforme o artigo 53 da CRFB (0,10).	0,00 / 0,20 / 0,30 / 0,35 / 0,45 / 0,55 / 0,65
B. Os vereadores possuem imunidade material (0,30), com base no artigo 29, Inciso VIII (0,10). A imunidade material fica restrita à circunscrição municipal em que ele exerce mandato (0,20).	0,00 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60

04. (OAB – XIII Exame) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pelo rito do artigo 5º, § 3º, da Constituição da República.

Maria Y, portadora de necessidades especiais, consulta-o como advogado, indagando:

A) Ao ser incorporada ao ordenamento pátrio com base no artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, qual o status hierárquico normativo da referida convenção internacional? (Valor: 0,40)

B) Os demais tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados sem a observância do procedimento disposto no artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, possuem o mesmo status hierárquico? Justifique. (Valor: 0,40)

C) A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, após seu processo de internalização, de acordo com o artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade? Justifique sua resposta. (Valor: 0,45)

► **Gabarito Comentado**

A) O examinando deve identificar que a referida convenção internacional possui status de norma constitucional (Emenda Constitucional), pois foi aprovada de acordo com o rito de incorporação do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal.

B) O examinando deve identificar que os tratados internacionais de direitos humanos não incorporados segundo o procedimento do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, possuem status hierárquico de norma supralegal, conforme restou consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

C) O examinando deve identificar que, após sua incorporação conforme o procedimento descrito pelo artigo 5º, § 3º, a convenção possui status de norma constitucional. Deste modo, pode vir a ser considerada como parâmetro para controle de constitucionalidade, assim como as demais normas da Constituição da República.

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
A. A convenção internacional possui status de norma constitucional (emenda constitucional), conforme a dicção do artigo 5º § 3º da CRFB (0,40)	0,00 / 0,40
B. Os tratados de direitos humanos não incorporados segundo o procedimento do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, possuem status hierárquico de norma supralegal (0,40)	0,00 / 0,40
C. Sim, pois a convenção internacional adquiriu status normativo constitucional, conforme previsão constante do artigo 5º, § 3º, da CRFB (0,45)	0,00 – 0,45

► XIV Exame

01. (OAB – XIV Exame) A Imprensa Oficial do Estado “X” publicou, em 23.10.2013, a Lei nº 1.234, de iniciativa do Governador, que veda a utilização de qualquer símbolo religioso nas repartições públicas estaduais. Pressionado por associações religiosas e pela opinião pública, o Governador ajuíza Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto aquela lei, alegando violação ao preâmbulo da Constituição da República, que afirma “a proteção de Deus sobre os representantes na Assembleia Constituinte”.

Diante do exposto, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

a) É possível o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por parâmetro preceito inscrito no preâmbulo da Constituição da República? (Valor: 0,65)

b) É possível o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo Governador do Estado, tendo por objeto lei de sua iniciativa? (Valor: 0,60)

► Gabarito comentado

a) Não é possível preceito inscrito no Preâmbulo da Constituição da República atuar como parâmetro ao controle concentrado de constitucionalidade (ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade), uma vez que o preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, apresentando-se desvestido de força cogente.

b) Por se tratar de processo objetivo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser proposta pelo Governador do Estado mesmo se o objeto da ação for uma lei de sua iniciativa. O objetivo da ADIn é a preservação da higidez do ordenamento jurídico, desvinculado, portanto, de interesses individuais

► Distribuição dos pontos

Item	Pontuação
a) Não, pois o preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, apresentando-se desvestido de força cogente	0,65
b) Sim, pois a Ação Direta de Inconstitucionalidade é um processo objetivo para preservação da higidez do ordenamento, desvinculado de interesses individuais	0,60

02. (OAB – XIV Exame) Sob forte influência de grandes produtores rurais, numerosos parlamentares do Congresso Nacional se mobilizam para a edição de uma Emenda à Constituição, a fim de retirar do texto constitucional a referência à função social da propriedade. Como resposta, a sociedade civil começou uma campanha de coleta de assinaturas para deflagrar a edição, por iniciativa popular, de uma Emenda para tornar crime a manutenção de propriedades improdutivas.

Com base no fragmento acima, responda aos itens a seguir.

a) Um parlamentar tem iniciativa no processo legislativo de Emenda à Constituição? E a sociedade civil? Responda fundamentadamente. (Valor: 0,60)

b) É possível a edição de Emenda com o conteúdo pretendido pelos produtores rurais? (Valor: 0,65)

► Gabarito comentado

a) A resposta é negativa. O Art. 60 da Constituição estabelece a iniciativa para a proposta de Emenda à Constituição: (I) um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; (II) o Presidente da República; e (III) mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação. Desse modo, um parlamentar, isoladamente, não pode deflagrar processo legislativo de Emenda Constitucional. Do mesmo modo, a sociedade também não pode deflagrar tal processo. Não se há de confundir a iniciativa popular para a edição de leis, prevista no Art. 61, § 2º, da Constituição Federal, com a iniciativa para a edição de Emendas à Constituição.

b) A resposta também é negativa. Trata-se do tema das cláusulas pétreas, limitações materiais à possibilidade de reforma à Constituição. O Art. 60, § 4º, da Constituição de 1988, em relação ao conteúdo das Emendas à Constituição, afasta a possibilidade de supressão dos direitos e garantias individuais. E a função social é positivada na Constituição como inerente ao próprio direito à propriedade (Art. 5º, XXIII, da CRFB). Isto é, ela faz

parte do próprio conteúdo do direito à propriedade, que deixa de ser considerado em uma lógica puramente individual. A função social incide sobre a estrutura e o conteúdo da propriedade, sobre a própria configuração do direito, e constitui elemento que qualifica sua situação jurídica. Desse modo, não pode ser alterada por Emenda à Constituição.

► **Distribuição dos pontos**

ITEM	PONTUAÇÃO
a) A iniciativa para a proposta de Emenda à Constituição não contempla a atuação isolada de um parlamentar (0,30) nem a iniciativa popular (0,20), nos termos do Art. 60, incisos I, II e III da Constituição (0,10).	0,00 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 0,60
b) É vedada a edição de Emendas que tenham por objeto a supressão de direitos e garantias individuais. Tanto a propriedade quanto a sua função social são elementos de um direito assegurado como cláusula pétrea pela Constituição em uma concepção que foge à dimensão puramente individual pretendida pelos produtores rurais (0,55), conforme o Art. 60, § 4º, da Constituição Federal (0,10).	0,00 / 0,55 / 0,65

03. (OAB – XIV Exame) Tício ajuizou demanda em face do Estado “X”, postulando determinada prestação estatal. A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, entretanto, julgou improcedente o pedido, apontando, no fundamento da decisão, os diferentes graus de eficácia das normas constitucionais, que impedem todos os efeitos pretendidos por Tício.

Com base no fragmento acima, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

a) Em que medida as normas constitucionais de eficácia plena se diferenciam das normas de eficácia contida? (Valor: 0,65)

b) As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático, antes da intermediação legislativa, geram algum efeito jurídico? (Valor: 0,60)

► **Gabarito comentado**

a) O examinando deve identificar que, apesar de ambas possuírem aplicabilidade imediata, se diferenciam pela possibilidade de futura restrição em seu âmbito de eficácia. As normas de eficácia plena são aquelas

que produzem a plenitude dos seus efeitos, independentemente de complementação por norma infraconstitucional. São revestidas de todos os elementos necessários à sua executoriedade, tornando possível sua aplicação de maneira direta, imediata e integral. De outro lado, as normas de eficácia contida são aquelas que, de início, produzem a plenitude dos seus efeitos, mas podem ter o seu alcance restringido pela legislação infraconstitucional. Tais normas também possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, mas o seu alcance poderá ser reduzido, em razão da existência, na própria norma, de uma cláusula expressa de redutibilidade.

b) O examinando deve identificar que as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático, apesar de dependerem da integração da lei para a produção da plenitude de seus efeitos, geram de imediato, efeitos jurídicos. Assim, apesar de não se poder extrair de imediato, da norma, a plenitude de seus efeitos, em especial a eficácia positiva, capaz de amparar a pretensão de produção da consequência jurídica prevista na norma, é possível extrair, da norma, uma eficácia interpretativa, capaz de reger a interpretação das normas de hierarquia inferior, bem como uma eficácia negativa, isto é, a capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior que vierem a lhe contrariar ou ao controle de constitucionalidade das omissões do Poder Público.

► Distribuição dos pontos

ITEM	PONTUAÇÃO
a) As normas de eficácia plena são as que receberam do constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata e independem de providência normativa ulterior para a sua aplicação (0,30), ao passo que as normas de eficácia contida, apesar de também terem recebido normatividade suficiente para reger os interesses de que cogitam, sofreram do próprio constituinte a inserção de um mecanismo ou fórmula que autoriza a futura restrição à sua incidência ou à sua aplicação em determinado caso (0,35).	0,00 – 0,30 – 0,35 – 0,65
b) Sim, as normas constitucionais de eficácia limitada, mesmo antes da intermediação legislativa, geram efeitos jurídicos. Apesar de não se poder extrair de imediato, da norma, a plenitude de seus efeitos, em especial a eficácia positiva, capaz de amparar eventual pretensão à produção da consequência jurídica prevista no texto, é possível extrair uma eficácia interpretativa, capaz de reger a interpretação das normas de hierarquia inferior, bem como uma eficácia negativa, isto é, a capacidade de servir de parâmetro ao controle de constitucionalidade das normas de hierarquia inferior que vierem a lhe contrariar ou ao controle de constitucionalidade das omissões do Poder Público. (0,60)	0,00 – 0,60

04. (OAB – XIV Exame) A circulação no Brasil do subtipo 4 do vírus da dengue e o retorno do subtipo 1 podem aumentar o número de casos graves da doença no período que, historicamente, já registra o maior contingente de infectados. Para tentar conter a epidemia, o Estado com maior índice de contágio elabora lei que obriga os médicos públicos e particulares que atuam em seu território a notificarem os casos de dengue à Secretaria de Saúde. A mesma lei, mediante outro dispositivo, imputou responsabilidade civil ao médico por falta de notificação.

Diante do caso, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

a) É constitucional a obrigatoriedade de notificação dos casos de dengue? (Valor: 0,60)

b) É constitucional a responsabilização dos médicos que não notificarem? (Valor: 0,65)

Obs.: a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua.

► **Gabarito comentado**

a) Sim. A necessidade de notificação dos casos de dengue é constitucional, pois a matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre defesa da saúde, conforme Art. 24, XII, da CF.

b) Não. O dispositivo da lei estadual que atribui responsabilização civil ao médico por falta de notificação é inconstitucional; cabe à União legislar sobre essa matéria conforme Art. 22, I, da CF. (ADI2875, 20/06/2008).

► **Distribuição dos pontos**

ITEM	PONTUAÇÃO
a) Sim. A necessidade de notificação dos casos de dengue é constitucional, pois a matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre defesa da saúde (0,50), conforme o Art. 24, XII, da CF (0,10).	0,00 / 0,50 / 0,60
b) Não. O dispositivo da lei estadual que atribui responsabilização civil ao médico por falta de notificação é inconstitucional; cabe à União legislar sobre essa matéria (0,55), conforme Art. 22, I, da CF (0,10).	0,00 / 0,55 / 0,65

► XV Exame

01. (OAB – XV Exame) O Governador do Estado X ajuizou Representação de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, apontando a violação, pela Lei Estadual nº 1.111, de dispositivos da Constituição do Estado, que se apresentam como normas de reprodução obrigatória.

Considerando o exposto, responda aos itens a seguir.

a) O que são normas de reprodução obrigatória? (Valor: 0,65)

b) Proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal arguindo violação dos mesmos dispositivos da Constituição Federal, cuja reprodução pela mesma lei estadual (Lei nº 1.111) era obrigatória na Constituição Estadual, sem que tenha ocorrido o julgamento da Representação de Inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça local, poderão as duas ações tramitar simultaneamente? (Valor: 0,60)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

a) As normas de reprodução obrigatória são aquelas que se inserem compulsoriamente no texto constitucional estadual, como consequência da subordinação à Constituição da República, que é a matriz do ordenamento jurídico parcial dos Estados-membros. A tarefa do constituinte em relação a tais normas, portanto, limita-se a inseri-las no ordenamento constitucional do Estado, por um processo de transplantação. Assim, as normas de reprodução decorrem do caráter compulsório da norma constitucional superior (Art. 25, caput, da CFRB).

b) Se a lei estadual for impugnada perante o Tribunal de Justiça local e perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento em norma constitucional de reprodução obrigatória, com base no princípio da simetria, suspende-se a ação direta proposta na Justiça estadual até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, que poderá ter efeitos erga omnes e eficácia vinculante para o Tribunal de Justiça, se julgada procedente. Aliás, essa é a solução adotada, de longa data, pelo Supremo Tribunal Federal, que indica, como fundamentos a esse entendimento, a primazia da Constituição da República (e, conseqüentemente, a primazia de sua guarda) e a prejudicialidade do julgamento daquela Corte com relação aos Tribunais de Justiça locais.

02. (OAB – XV Exame) O Estado X, integrante da República Federativa do Brasil, foi agraciado com o anúncio da descoberta de enormes jazidas de ouro, ferro, estanho e petróleo em seu território. As jazidas de minério estão todas localizadas no Município de Alegria e as de petróleo, no Município de Felicidade, ambos localizados no Estado X.

Tendo em vista o disposto no ordenamento jurídico nacional, responda aos itens a seguir.

a) A qual ente federativo pertencem os recursos naturais recentemente descobertos? Os demais entes, em cujos territórios se deu a descoberta, recebem alguma participação no resultado da exploração desses recursos? (Valor: 0,85)

b) Um dos entes federativos (Estado ou Município), insatisfeito com a destinação dos recursos naturais descobertos em seu território, pode, à luz do nosso ordenamento, propor a secessão, a fim de se constituir em ente soberano, único titular daqueles recursos? Caso positiva a resposta, qual o procedimento a ser seguido? (Valor: 0,40)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

a) O examinando deve identificar que, conforme previsão constante do Art. 20, IX, da Constituição, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. E o Art. 176, da Constituição, em idêntico sentido, dispõe que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União. Portanto, as jazidas de ouro, ferro, estanho e petróleo recentemente descobertas pertencem à União. Nada obstante, a própria Constituição, em seu art. 20, § 1º, assegura aos Estados e aos Municípios participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Dessa forma, o Estado “X” e os Municípios de Alegria e Felicidade têm participação assegurada no resultado ou compensação financeira pela exploração de recursos em seus territórios.

b) A resposta é negativa. Nos termos do Art. 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. O vínculo que os une, à égide de nossa Constituição, não pode ser rompido (vedação à secessão).

03. (OAB – XV Exame) Os jornais noticiaram violenta chacina ocorrida no Estado Y, onde foram torturadas e assassinadas dezenas de crianças e mulheres de uma comunidade rural de baixa renda, com suspeita de trabalho escravo. É aberto inquérito policial para a investigação dos fatos e, passado um mês do ocorrido, a polícia e as autoridades locais mantêm-se absolutamente inertes, configurando, de forma patente, omissão na apuração dos crimes. A imprensa nacional e a internacional dão destaque à omissão, afirmando que o Estado Y não é capaz de assegurar a proteção aos diversos direitos humanos contidos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Com base no caso apresentado, responda aos itens a seguir.

a) O que se entende por federalização dos crimes contra os direitos humanos? (Valor: 0,65)

b) O Presidente da República pode requerer a aplicação do instituto? Perante qual juízo ou tribunal brasileiro deve ser suscitado o instituto da federalização dos crimes contra os direitos humanos? (Valor: 0,60)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

a) O examinando deve indicar que a federalização dos crimes contra os direitos humanos é um instituto trazido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, consistente na possibilidade de deslocamento de competência da Justiça comum para a Justiça Federal, nas hipóteses em que ficar configurada grave violação de direitos humanos. Tem previsão no Art. 109, § 5º, da Constituição Federal. A finalidade do instituto é a de assegurar proteção efetiva aos direitos humanos e o cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais.

b) O examinando deve indicar que o Presidente da República não tem competência para suscitar a aplicação do instituto. Conforme previsão constante do Art. 109, § 5º, da Constituição Federal, apenas o Procurador-Geral da República pode suscitar a aplicação do instituto, e, nos termos

do mesmo dispositivo, o tribunal perante o qual deve ser suscitado o instituto é o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

04. (OAB – XV Exame) Denúncias de corrupção em determinada empresa pública federal foram publicadas na imprensa, o que motivou a instalação, na Câmara dos Deputados, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Em busca de esclarecimento dos fatos, a CPI decidiu convocar vários dirigentes da empresa pública para prestar depoimento. Em razão do interesse público envolvido, o jornalista que primeiro noticiou o caso na grande imprensa também foi convocado a prestar informações, sob pena de condução coercitiva, de modo a revelar a origem de suas fontes, permitindo, assim, a ampliação do rol dos investigados. Outra decisão da CPI foi a de quebrar o sigilo bancário dos dirigentes envolvidos nas denúncias de corrupção, objeto de apuração da comissão.

Com base nessas informações, responda aos itens a seguir.

a) A CPI tem poder para intimar alguém a prestar depoimento, sob pena de condução coercitiva caso não compareça espontaneamente? (Valor: 0,40)

b) O jornalista convocado pode ser obrigado a responder indagações sobre a origem de suas fontes jornalísticas, em razão do interesse público envolvido? (Valor: 0,40)

c) A CPI tem poder para determinar a quebra do sigilo bancário dos investigados? (Valor: 0,45)

O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

a) A CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (Art. 58, § 3º, da CRFB), podendo determinar a condução coercitiva de testemunha.

b) O jornalista não pode ser obrigado a responder indagações sobre a origem de suas fontes, pois o Art. 5º, XIV, resguarda esse sigilo para os jornalistas, garantindo, assim, a liberdade de imprensa.

c) Sim, o STF reconhece o poder da CPI para determinar a quebra do sigilo bancário dos investigados, observada a devida fundamentação para tanto, pois a competência decorre da atribuição de poderes de investiga-

ção próprios das autoridades judiciais, e a matéria não se insere na cláusula de reserva de jurisdição.

► XVI Exame

01. (OAB – XVI Exame) Uma entidade de classe de servidores públicos ajuizou mandado de segurança coletivo contra decisão do Diretor Geral de um dado órgão público federal. Alegou que a decisão administrativa por ele proferida deixou de considerar direitos consolidados de uma das categorias que representa. O Diretor Geral informou ao seu advogado reconhecer que a questão sobre a existência ou não do direito em discussão envolvia grande complexidade jurídica. Esclareceu, ainda, que, apesar de alguns órgãos públicos aplicarem o direito almejado pelo impetrante, a maior parte não o reconhecia. Diante do relato acima, responda aos itens a seguir.

A) No caso em questão, havendo dúvidas quanto à certeza em matéria de direito, é possível movimentar o Poder Judiciário pela via do mandado de segurança? Justifique. (Valor: 0,75)

B) A entidade de classe em questão possui legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo, ainda que a pretensão veiculada diga respeito a apenas uma parte da categoria que representa? Justifique. (Valor: 0,50)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

► Gabarito comentado

A) Sim. A existência de dúvida sobre matéria de direito não impede a movimentação do Judiciário pela via de mandado de segurança. Sobre o tema o STF manifestou-se por meio da Súmula nº 625. Nesse sentido, a exigência de direito líquido e certo para a impetração de mandado de segurança não se refere à inexistência de “controvérsia sobre matéria de direito”, mas à inexistência de controvérsia sobre fatos, que devem ser objeto de pronta comprovação.

B) Sim. A entidade de classe tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada diga respeito a apenas a uma parte da respectiva categoria. É o que dispõe a Súmula nº 630 do STF (“A entidade de classe tem legitimação para o mandado de

segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”).

02. (OAB – XVI Exame) Faltando um pouco mais de um ano para as eleições estaduais, Prudêncio Ferreira, governador de um dos Estados da Federação (Estado W), mesmo diante de grave crise política, decide que concorrerá a um segundo mandato, sem se afastar do exercício de sua função. No seu entender, a referida crise política decorre do fato de não possuir, na Assembleia Legislativa (do Estado W), além de seu filho Zacarias, um número maior de deputados aguerridos, que defendam o seu governo, de forma contundente, dos insistentes ataques desferidos pela oposição. Por essa razão, traça como estratégia política reforçar a sua base de apoio na Casa Legislativa, com pessoas que considera de sua inteira confiança. Assim, submete à cúpula do partido que o apoia uma lista de candidatos a Deputado Estadual que deveriam receber especial apoio no decorrer da campanha. Os seguintes nomes constaram da relação, todos com mais de 21 anos: – Marcos Ferreira, seu neto, bacharel em Direito, que jamais exerceu qualquer cargo político; – Robervaldo Soberbo, seu sogro, que se encontra aposentado do cargo de fiscal de rendas do Estado W; – Carlos Ferreira, seu sobrinho, que não exerce nenhum cargo político no momento; e – Zacarias Ferreira, seu filho adotivo, político de carreira, que concorrerá à reeleição como deputado estadual no Estado W. Segundo a Constituição Federal, responda aos itens a seguir.

A) Dentre os nomes citados, quais estariam habilitados a concorrer ao cargo de Deputado Estadual do Estado W e quais não estariam? Justifique. (Valor: 0,70)

B) Dentre os que não estariam habilitados a concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo Estado W, poderiam eles concorrer ao cargo de Deputado Estadual por outro Estado? Justifique sua resposta. (Valor: 0,55)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

► **Gabarito comentado**

A) Podem candidatar-se Carlos Ferreira e Zacarias Ferreira, na forma do Art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Afinal, Carlos, na condição de sobrinho do Governador, mantém com este parentesco consanguíneo de “terceiro grau”, pela linha colateral, sendo que a inelegibilidade atinge tão

somente parentes (consanguíneos ou afins) até o segundo grau. No que diz respeito a Zacarias, embora seja ele filho adotivo de Prudêncio (parentesco de 1º grau por adoção), o fato de já ser titular de mandato eletivo e estar concorrendo à reeleição para o cargo de Deputado Estadual do Estado W, seu direito de concorrer está assegurado em face da exceção prevista no mesmo dispositivo (“salvo se já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”). Não se adequam às condições para concorrer ao cargo em referência Marcos Ferreira e Roberval Soberbo. O primeiro por manter com X parentesco consanguíneo de segundo grau pela linha direta; o segundo por manter parentesco de 1º grau por afinidade com X, por força do que estabelece o citado Art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

B) Conforme acima referenciado, embora Marcos Ferreira e Roberval Soberbo não possam concorrer ao cargo de Deputado Estadual do Estado W, por força do que estabelece o Art. 14, § 7º, da Constituição Federal (“no território de jurisdição do titular”, no caso o Governador). Marcos por manter com o Prudêncio Ferreira laço de parentesco consanguíneo de segundo grau pela linha direta; Roberval, por manter com Prudêncio Ferreira laço de parentesco de 1º grau por afinidade. Ambos, porém poderiam concorrer ao cargo de Deputado Estadual em qualquer Estado que não fosse W. Isso porque, no caso de governador, a circunscrição eleitoral atingida pela norma da inelegibilidade será a do território do Estado “W”. Todavia, satisfeitas as condições de elegibilidade presentes constantes no art. 14 da Constituição Federal, poderiam disputar a eleição em outro Estado que não “W”, pois encontrar-se-iam fora da circunscrição territorial em que Prudêncio exerce o mandato de Governador (Estado W), não estando abrangidos pelos casos de inelegibilidade estabelecidos no âmbito do § 7º do citado Art. 14 da Constituição Federal.

03. (OAB – XVI Exame) Projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, contendo vício de iniciativa, foi encaminhado ao Senado Federal. Na Casa revisora, o texto foi aprovado com pequena modificação, sendo suprimida determinada expressão, sem, contudo, alterar o sentido normativo objetivado pelo texto aprovado na Câmara. O projeto foi, então, enviado ao Presidente da República, que, embora tenha protestado pelo fato de ser a matéria disciplinada pelo Parlamento, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, sancionou-o por concordar com os termos ali estabelecidos, originando a Lei L. Diante dos fatos narrados, responda aos itens a seguir.

A) A não devolução do processo à Casa Iniciadora sempre configurará violação ao devido processo legislativo? Justifique. (Valor: 0,75)

B) No caso em tela, a sanção presidencial possuiria o condão de suprir o vício de iniciativa ao projeto de Lei? Justifique. (Valor: 0,50)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

► Gabarito comentado

A) Não. A alteração de texto não implica, necessariamente, o retorno do projeto à Casa iniciadora, já que mudança dessa natureza somente assume relevância se houver alteração do significado normativo. Nesta linha: “Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. LC 101, de 4-5-2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). MP 1.980-22/2000. (...) LC 101/2000. Vício formal. Inexistência. O parágrafo único do Art. 65 da CF só determina o retorno do projeto de lei à Casa iniciadora se a emenda parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da proposição jurídica.”

B) Não. Confirmada a usurpação do poder de iniciativa, mesmo a sanção do projeto do projeto de lei não possui o condão de afastar o vício de inconstitucionalidade formal. Neste sentido, a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo, com a sanção, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade. Restou superada a Súmula nº 5 do STF. Nesta linha: “A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.”

04. (OAB – XVI Exame) Durante a campanha eleitoral, determinado candidato a Deputado Federal acusa o Governador do Estado de liderar atividades criminosas ligadas a bingos e cassinos clandestinos. Logo em seguida, o referido candidato é eleito. Após a posse, o Procurador-Geral da República oferece denúncia contra o referido Deputado Federal, perante o Supremo Tribunal Federal, pelo crime comum cometido. Em sua defesa, o parlamentar argumenta que se encontra amparado pela inviolabilidade (imunidade material) quanto às suas opiniões, palavras e votos, razão pela qual não poderia responder pelo crime que lhe é imputado. Diante de tais fatos, responda aos itens a seguir.

A) Poderia o Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra o Deputado Federal sem a prévia autorização da Câmara dos Deputados? (Valor: 0,50)

B) Na hipótese de um Deputado Federal responder por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, o término do mandato tem alguma consequência sobre a definição e manutenção da competência jurisdicional? (Valor: 0,75)

Responda justificadamente, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

► **Gabarito comentado**

A) Sim. Não há nenhuma necessidade de autorização prévia da Câmara dos Deputados a fim de dar início à ação penal, tal qual dispõe o Art. 53, § 3º, da Constituição de 1988. Antes da promulgação da EC 35/01, os Deputados e Senadores não podiam ser processados sem prévia licença da respectiva Casa Legislativa. Entretanto, atualmente, permite-se a abertura de processo penal no Supremo Tribunal Federal sem necessidade da licença prévia, sendo possível, apenas, pelo voto da maioria absoluta da respectiva Casa Legislativa, sustar o andamento da ação. Ou seja, “recebida a denúncia contra o Senador ou o Deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação”. Esse dispositivo (§ 3º, do Art. 53, da CRFB) aplica-se ao caso, mesmo o crime tendo sido praticado antes da diplomação, por força das regras principiológicas que informam as prerrogativas parlamentares.

B) Sim. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de não manter, após o término do mandato legislativo, o foro por prerrogativa de função previsto no Art. 53, § 1º, da Constituição Federal. Com efeito, até agosto de 1999 era aplicada a Súmula nº 394 do Supremo Tribunal Federal, que preservava o foro para os atos praticados no exercício do mandato, mesmo após o término deste. Porém, a súmula foi cancelada e a competência deixou de ser do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a atual jurisprudência do STF entende que o foro especial por prerrogativa de função não permanece após o término do exercício da função pública. Ou seja, no término do exercício da função pública expira o direito ao foro especial por prerrogativa de função, devendo o processo ser remetido à Justiça ordinária competente.

► XVII Exame

01. (OAB – XVII Exame) O Congresso Nacional autorizou o Presidente da República a normatizar, por via de lei delegada, na sua forma típica ou própria (sem necessidade de posterior aprovação pelo Congresso), matéria que trata de incentivo ao parque industrial brasileiro. Ocorre, porém, que o Chefe do Poder Executivo, ao elaborar o diploma normativo, exorbitou dos poderes a ele conferidos, deixando de respeitar os limites estabelecidos pelo Congresso Nacional, por via de Resolução. A partir dessa narrativa, responda aos itens a seguir.

A) No caso em tela, o aperfeiçoamento do ato de delegação, com a publicação da Resolução, retira do Congresso Nacional o direito de controlar, inclusive constitucionalmente, o conteúdo da Lei Delegada editada pelo Presidente da República? Justifique. (Valor: 0,75)

B) Caso a Resolução estabelecesse a necessidade de apreciação do projeto pelo Congresso Nacional (delegação atípica ou imprópria), poderia a Casa legislativa alterar o texto elaborado pelo Presidente da República? Justifique. (Valor: 0,50) Obs.: Sua resposta deve ser fundamentada.

A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► Gabarito comentado

A) Não. Com base no que dispõe o inciso V do Art. 49 da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Congresso Nacional (o poder delegante) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. Trata-se de verdadeiro controle político e de constitucionalidade, na modalidade repressiva, exercido pelo Poder Legislativo.

B) Não, nos termos do Art. 68, § 3º, da Constituição Federal. Ao deliberar sobre o projeto, ou o Congresso Nacional o aprova integralmente ou o rejeita em sua totalidade, sendo vedada qualquer emenda.

02. (OAB – XVII Exame) Leonardo, dirigente da tradicional Associação X, desconfiado de que o regulamento do campeonato estadual de remo do Estado E estaria beneficiando uma agremiação em detrimento das demais – em completa violação ao princípio da igualdade –, busca auxílio jurídico. Preocupado, porém, em reduzir o tempo de dis-

puta jurídica, Leonardo sugere ao Advogado da Agremiação X que ajuíze ação perante a Justiça comum, sem acionar as instâncias desportivas. Na condição de estudante de Direito, Leonardo fundamentou sua sugestão no princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do que indica o Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Diante do caso acima narrado, responda aos itens a seguir.

A) O encaminhamento sugerido por Leonardo deve ser seguido pelo Advogado da Agremiação X? (Valor: 0,65)

B) A denominada justiça desportiva profere decisões judiciais? Justifique. (Valor: 0,60) Obs.: Sua resposta deve ser fundamentada.

A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► Gabarito comentado

A) Não, pois, apesar do Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal ter previsto que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, no caso, a própria ordem constitucional exige do jurisdicionado a comprovação de exaurimento na esfera administrativa antes de se dirigir ao Poder Judiciário (Art. 217, § 1º, da Constituição Federal). Nesse sentido: “No inciso XXXV do Art. 5º, previu-se que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. (...) O próprio legislador constituinte de 1988 limitou a condição de ter-se o exaurimento da fase administrativa, para chegar-se à formalização de pleito no Judiciário. Fê-lo no tocante ao desporto, (...) no Art. 217, § 1º, (...). Vale dizer que, sob o ângulo constitucional, o livre acesso ao Judiciário sofre uma mitigação e, aí, consubstanciando o preceito respectivo de exceção, cabe tão só o empréstimo de interpretação estrita. Destarte, a necessidade de esgotamento da fase administrativa está jungida ao desporto e, mesmo assim, tratando-se de controvérsia a envolver disciplina e competições, sendo que a chamada justiça desportiva há de atuar dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da formalização do processo, proferindo, então, decisão final – § 2º do Art. 217 da CF”. (ADI 2.139-MC e ADI 2.160-MC, voto do Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13-5-2009, Plenário, DJE de 23-10-2009.)

B) Não. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro é aquela estabelecida na Constituição Federal, mais especificamente a partir do Art. 92. As decisões da Justiça desportiva possuem natureza meramente “administrativa”, não jurisdicional.

03. (OAB – XVII Exame) A Medida Provisória Z (MP Z), editada pelo Governador do Estado H com o propósito de diminuir o alto grau de evasão escolar, regulou a concessão de bolsas escolares a alunos carentes matriculados em escolas públicas estaduais. Em virtude de crise política que surgiu entre o Executivo e o Legislativo, a referida Medida Provisória não foi convertida em lei. Ultrapassado o prazo de 60 dias, a Casa Legislativa não disciplinou as relações jurídicas surgidas no período em que a MP Z vigorou. João, que se beneficiou por três meses da referida bolsa, apreensivo, relatou a Carlos, um amigo, servidor da Assembleia Legislativa, que teme ter de devolver a totalidade do valor recebido. Carlos tranquilizou-o e informou-lhe que a crise política fora debelada, de modo que a Assembleia apenas aguarda a reedição da Medida Provisória, a fim de convertê-la em lei, ainda no mesmo ano legislativo em que a MP Z perdeu a eficácia. Considerando que a Constituição do Estado H regulou o processo legislativo em absoluta simetria com o modelo usado pela Constituição Federal, responda aos itens a seguir.

A) João terá de devolver aos cofres públicos o dinheiro recebido a título da bolsa? Fundamente. (Valor: 0,75)

B) A informação passada por Carlos a João encontra-se em harmonia com a sistemática constitucional? Justifique. (Valor: 0,50)

Obs.: Sua resposta deve ser fundamentada. A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► **Gabarito comentado**

A) Não. João não precisará devolver o valor recebido a título de bolsa, já que, conforme informado na questão, a não edição de decreto legislativo que regulamentasse as relações jurídicas estabelecidas pela MP Z, no prazo de sessenta dias após a perda de sua eficácia, acabou por implicar o reconhecimento dos efeitos jurídicos produzidos no período em que a MP esteve vigente, nos termos do que informa o Art. 62, § 11, da CF.

B) Não, pois, no caso em referência, tendo a medida provisória perdido sua eficácia, vedada seria sua reedição na mesma sessão legislativa, nos termos do que informa o Art. 62, § 10, da Constituição Federal.

04. (OAB – XVII Exame) Aprovado apenas pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputa-

dos, assim como no âmbito da mesma Comissão em razão dessa matéria do Senado Federal, determinado projeto de lei, que versava sobre política externa brasileira, foi levado à apreciação do Presidente da República, que resolveu vetá-lo, ao argumento de que nenhum projeto de lei pode ser aprovado sem a respectiva votação do Plenário de cada uma das casas legislativas. Diante do relato acima, responda aos itens a seguir.

A) O veto apresentado pelo Chefe do Executivo encontra amparo constitucional? (Valor: 0,65)

B) É correto afirmar que, de acordo com o processo legislativo brasileiro, o veto do Presidente da República deve ser apreciado pela Casa Inicial e revisto pela Casa Revisora, dentro do prazo de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento? (Valor: 0,60) Obs.: Sua resposta deve ser fundamentada.

A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► Gabarito comentado

A) Não. De acordo com o Art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal, há projetos de lei que podem ser discutidos e votados apenas no âmbito das comissões constituídas, em razão da matéria de sua competência, na forma do Regimento Interno da Casa Legislativa, sem a necessidade de apreciação pelo Plenário, desde que não haja recurso de um décimo dos membros da respectiva Casa. Portanto, o veto do Presidente da República não encontra amparo constitucional. Nesse sentido, é constitucionalmente possível que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprove um projeto de lei que verse sobre a política externa brasileira (matéria da competência da referida Comissão) sem a necessidade de passar pelo Plenário da Casa, desde que não haja oposição de um décimo dos seus membros. Portanto, é o próprio texto constitucional que admite a possibilidade de se afastar a incidência do princípio da reserva de plenário, atribuindo às Comissões, em razão da matéria de sua competência, a prerrogativa de discutir, votar e decidir as proposições legislativas.

B) Não. De acordo com o Art. 66, § 4º, da Constituição Federal, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro do prazo de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. Esgotado o prazo de trinta dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final.

► XVIII Exame

01. (OAB – XVIII Exame) José, inconformado com decisão judicial proferida em primeiro grau, que o condenou ao pagamento de indenização, recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado M. Distribuído o recurso para a Segunda Câmara Cível do mencionado tribunal, os desembargadores desse órgão fracionário, ao analisarem a matéria, entenderam corretos os argumentos de José no que se referia à inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentou o pedido da parte autora, ora recorrida. Ao realizarem acurada pesquisa jurisprudencial, observaram que o Pleno e o Órgão Especial do próprio Tribunal de Justiça do Estado M, bem como o Supremo Tribunal Federal, nunca se manifestaram sobre a matéria. Diante da situação narrada, responda aos itens a seguir.

A) Qual a providência a ser tomada pela Segunda Câmara? Justifique. (Valor: 0,75)

B) A solução seria diversa se houvesse manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão? Justifique. (Valor: 0,50)

Obs.: sua resposta deve ser fundamentada. A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► Gabarito comentado

A) No caso em tela, não havendo posição do Pleno ou do órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado M, com base no Art. 97 da CRFB/88, a Segunda Câmara, entendendo que deva ser reconhecida a inconstitucionalidade, deverá encaminhar o exame da constitucionalidade do ato normativo em questão à apreciação do Órgão Especial do próprio Tribunal (o que, acrescente-se, não seria necessário se entendesse que o dispositivo não era possuidor de qualquer vício). Afinal, os órgãos fracionários dos Tribunais – Câmaras, Turmas, etc. – não podem declarar a inconstitucionalidade de norma arguida por uma das partes, sem que já tenha sido esta objeto de análise pelo Plenário do Tribunal de Justiça ou, como no caso, pelo seu Órgão Especial. No problema acima apresentado, a Segunda Câmara Cível somente poderia analisar o recurso tendo por pressuposto a manifestação do Órgão Especial acerca da constitucionalidade / inconstitucionalidade do dispositivo sob análise.

B) Sim, pois quando houver manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da inconstitucionalidade / inconstitucionalidade da matéria, dispensa-se o seu envio ao Plenário ou Órgão Especial. O Art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil (acrescentado pela Lei nº 9.756/98), nessa linha, afirma que “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao Plenário, ou ao Órgão Especial, a arguição de constitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

02. (OAB – XVIII Exame) O Estado X editou a Lei nº 1.234, de 5 de fevereiro de 2010, para criar o Município Z, desmembrando-o do então Município W. Para a criação do ente federativo foram devidamente realizados os estudos de viabilidade municipal, bem como a consulta prévia às populações dos entes federativos envolvidos nesse evento. O novo Município estava em pleno funcionamento até que, em final de 2015, o vereador Toninho do Bem, do Município W, aventa publicamente a intenção do diretório municipal de seu partido “Vamos Brasil”, com representação no Congresso Nacional, de propor uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), perante o Supremo Tribunal Federal, para questionar a criação do Município Z. Com base no fragmento acima, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir.

A) A partir das normas constitucionais sobre a criação de município, a lei do Estado X é constitucional? (Valor: 0,65)

B) O diretório municipal do partido “Vamos Brasil” possui legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade? (Valor: 0,60) Obs.: sua resposta deve ser fundamentada.

A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► **Gabarito comentado**

A) A lei do Estado X é inconstitucional, pois o Art. 18, § 4º, da CRFB/88, desde a EC nº 15/96, exige a edição de lei complementar federal para determinar o período de criação de municípios por meio de lei estadual, transformando o referido dispositivo constitucional em norma constitucional de eficácia limitada, dependente de integração do legislativo federal para que todos os seus efeitos jurídicos possam ser produzidos. Até o presente momento não existe lei complementar a que se refere o Art. 18, § 4º, da CRFB/88, e o período da lei estadual está fora do âmbito da EC 57 (Art. 96 do ADCT), evidenciando, portanto, flagrante inconstitucionalidade por omissão, já pronunciada pelo STF.

B) Partido político possui legitimidade para a propositura de ADI desde que possua representação no Congresso Nacional, conforme o disposto no Art. 103, VIII, da CRFB/88 (“Art. 103. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;”). A Lei nº 9.868/99, da mesma forma, prevê um rol de legitimados que inclui o partido político com representação no Congresso Nacional (“Art. 20. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade: VIII – partido político com representação no Congresso Nacional”). Porém, o STF já externou seu entendimento de que o diretório municipal dos partidos políticos não tem legitimidade para a propositura de ADI em razão de não possuir condições para atuação em âmbito nacional, pois somente os diretórios nacionais e a executiva nacional do partido político possuem esta atribuição.

03. (OAB – XVIII Exame) O governador do Estado M decidiu propor duas emendas à Constituição estadual. A primeira, com o objetivo de instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, acrescentando sanções mais severas que as vigentes. A segunda, por sua vez, com o propósito de alterar o critério de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, de forma que três, do total de sete membros, passem a ser escolhidos, dentre os candidatos habilitados, pelo voto popular. Sobre as propostas acima formuladas, de acordo com o sistema jurídico-constitucional brasileiro, responda aos itens a seguir.

A) É possível que o poder constituinte derivado do Estado-membro M altere a Constituição Estadual para instituir normas que disciplinem o rito procedimental e de julgamento dos crimes de responsabilidade, bem como para acrescentar sanções? Justifique. (Valor: 0,65)

B) A autonomia estadual é suficiente para fundamentar a proposta de eleição para Conselheiro do Tribunal de Contas, nos termos propostos pelo Governador? Justifique. (Valor: 0,60) Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas.

A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Não. O sistema jurídico-constitucional brasileiro estabelece que o Estado-membro não pode legislar sobre crime de responsabilidade, ainda

que por intermédio de sua Constituição (estadual). A competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União nos termos do Art. 22, I, (mais especificamente no que se refere ao direito penal e ao direito processual) e do Art. 85, parágrafo único, ambos da CRFB/88, reforçado pelo que dispõe a Súmula Vinculante nº 46.

B) Não. O Art. 75 da CRFB/88 impõe, explicitamente, a necessidade de se observar a simetria entre as regras constantes na Seção IX, do Capítulo I, do Título IV, da CRFB/88, estabelecidas para o Tribunal de Contas da União e as regras a que devem se submeter os Tribunais congêneres estaduais. Ora, sendo a Constituição Estadual obra do poder constituinte derivado decorrente, não pode afrontar mandamento imposto pelo constituinte originário. No caso de a proposta do Governador ser levada à frente, estariam sendo violadas, minimamente, as regras constantes do Art. 73, § 2º, e do Art. 75, parágrafo único, ambos dispositivos da CRFB/88.

04. (OAB – XVIII Exame) Os irmãos Guilherme e Flávio fazem parte de uma família de tradicionais políticos do Estado M, conhecida por suas práticas beligerantes. Em um curto espaço de tempo, os irmãos se viram envolvidos em duas situações policiais: Guilherme, vereador da capital, agrediu fisicamente um vizinho, em situação originada por uma discussão relacionada à vaga em um estacionamento; no dia seguinte, Flávio, eleito e diplomado para exercer o cargo de deputado estadual, embora ainda não empossado, em estado de embriaguez, atropelou duas pessoas. O advogado (a) da família é convocado e a ele (ela) são dirigidas as questões a seguir.

A) Pelas práticas das ações acima descritas, estariam os irmãos Guilherme e Flávio cobertos pela prerrogativa da imunidade material a que fazem jus os membros do Poder Legislativo? Justifique. (Valor: 0,60)

B) Estão ambos aptos a fruir o benefício da imunidade formal? Justifique (Valor: 0,65)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) A inviolabilidade, por opiniões, palavras e votos abrange os deputados estaduais (Art. 27, § 1º, da CRFB/88) e os vereadores, nos limites da cir-

cunscrição de seu Município (Art. 29, VIII, da CRFB/88), porém, sempre no exercício do mandato. No caso em tela, as transgressões cometidas não se relacionam com a emanção de quaisquer opiniões, palavras ou votos no âmbito da atuação parlamentar, não havendo que se cogitar, portanto, de incidência da imunidade material.

B) As chamadas imunidades formais ou processuais são prerrogativas aplicáveis aos deputados estaduais, mas não aos vereadores. Em consequência, Flávio, mesmo não tendo tomado posse, pelo só fato de já ter sido diplomado, fará jus às prerrogativas decorrentes da imunidade formal, previstas no Art. 53 da CRFB/88, principalmente no que tange à prisão (§ 2º), ao processo (§ 3º) e à prestação de testemunho (§ 6º). Guilherme, porém, não se beneficiará de regras afetas à imunidade formal, pois estas não se estendem aos vereadores, nos limites da interpretação do que dispõe o Art. 29, VIII, da Constituição Federal.

► XIX Exame

01. Durante a tramitação de determinado projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, seguindo-se a sanção, a promulgação e a publicação. Sabendo que a lei seria alvo de ataques perante o Poder Judiciário em sede de controle difuso de constitucionalidade, o Presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia de vigência, uma Ação Declaratória de Constitucionalidade. Diante da narrativa acima, responda aos itens a seguir.

A) É cabível a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nesse caso? (Valor: 0,65)

B) Em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), é cabível a propositura de medida cautelar perante o Supremo Tribunal Federal? Quais seriam os efeitos da decisão do STF no âmbito dessa medida cautelar? (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

A) Não. Não caberia a ADC por falta de comprovação de relevante controvérsia perante juízes e tribunais a respeito da constitucionalidade da lei. A controvérsia existente no âmbito da doutrina não torna possível o ajuizamento da ADC. Com efeito, é de se presumir que, no primeiro dia de vigência da lei, não houve ainda tempo hábil para a formação de relevante controvérsia judicial, isto é, não haveria decisões conflitantes de tribunais e juízos monocráticos espalhados pelo País. É a própria dicção do Art. 14, III, da Lei nº 9.868/99 que estabelece a necessidade de comprovação da relevante controvérsia judicial, não sendo, por conseguinte, o momento exato de se manejar a ADC.

B) Sim. Nos termos do Art. 21, caput, da Lei nº 9868/99, os efeitos da medida cautelar, em sede de ADC, serão decididos pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros. Tais efeitos, de natureza vinculante, serão erga omnes e ex nunc, consistindo na determinação de que juízes e Tribunais suspendam o julgamento dos processos pendentes que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo que, de qualquer maneira, há de se verificar no prazo de cento e oitenta dias, nos termos do Art. 21, parágrafo único, da referida lei. Ou seja, a concessão da medida liminar serviria para determinar que juízes e tribunais do país não pudessem afastar a incidência de qualquer dos preceitos da Lei nos casos concretos, evitando, desde logo, decisões conflitantes. Pode o STF, por maioria absoluta de seus membros, conceder a medida cautelar, com efeitos ex tunc.

02. A Associação Antíqua, formada por colecionadores de carros antigos, observando que Mário, um de seus membros, supostamente teria infringido regras do respectivo Estatuto, designou comissão especial para a apuração dos fatos, com estrita observância das regras estatutárias. A Comissão, composta por membros de reconhecida seriedade, ao concluir os trabalhos, resolveu propor a exclusão de Mário do quadro de sócios, o que foi referendado pela Direção da Associação Antíqua. Questionada por Mário sobre o fato de não ter tido a oportunidade de contraditar os fatos ou apresentar defesa, a Associação apresentou as seguintes alegações: em primeiro lugar, não seria possível a Mário contraditar os fatos ocorridos, já que as provas de sua ocorrência eram incontestáveis; em segundo lugar, os trâmites processuais previstos no Estatuto foram rigorosamente respeitados; em terceiro lugar,

tratando-se de uma instituição privada, a Associação Antíqua tinha plena autonomia para a elaboração de suas regras estatutárias, que, no caso, permitiam a exclusão sem oitiva do acusado. Por fim, a Associação ainda alegou que Mário, ao nela ingressar, assinara um documento em que reconhecia a impossibilidade de solucionar possíveis litígios com a referida Associação pela via judicial. Inconformado, Mário o procurou para, como advogado(a), orientá-lo sobre as questões a seguir.

A) O direito à ampla defesa e ao contraditório podem ser alegados quando regras convencionais não os preveem? (Valor: 0,80)

B) É possível que o Estatuto da Associação Antíqua possa estabelecer regra que afaste a apreciação da causa pelo Poder Judiciário? (Valor: 0,45)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) No caso em tela, o direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no Art. 5º, LV, da CRFB, consubstancia preceito de ordem pública e não poderia ser desobedecido, mesmo no âmbito das relações privadas, configurando verdadeiro direito subjetivo de Mário. Afinal, direitos fundamentais dessa natureza devem ser observados tanto pelo Poder Público como pelos particulares. Nessa linha, o sistema jurídico-constitucional brasileiro tem reconhecido a possibilidade de aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Em consequência, as violações aos direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o particular e o Estado, mas igualmente nas relações estabelecidas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, em casos análogos ao descrito, em que um ente submete uma pessoa ao seu poder decisório, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam, diretamente, não apenas os poderes públicos, como também estão direcionados à proteção dos particulares em face do poder privado.

B) Não. Se o inciso XXXV do Art. 5º da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, por muito maior razão, diploma normativo sublegal certamente também não poderá fazê-lo. Acrescente-se que o dispositivo em referência tem natureza de direito fundamental, o que aumenta ainda mais sua densidade normativa.

03. No âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), foi determinada a busca e apreensão de documentos e de computadores nos escritórios das empresas do grupo investigado, tendo sido decretada, em decisão fundamentada, a indisponibilidade de bens e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um dos empresários envolvidos. Com base no fragmento acima, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

A) A medida adotada pela CPI, em relação aos bens do empresário, é amparada pela ordem constitucional? (Valor: 0,65)

B) A CPI poderia determinar a quebra de sigilo narrada na questão, sem autorização judicial? (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

A) Não. Apesar de o poder de investigar constituir uma das funções institucionais do Poder Legislativo, os poderes parlamentares de investigação sofrem limitações de ordem jurídico-constitucional. A Constituição Federal, ao conferir às CPIs “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” (Art. 58, §3º), delimitou a natureza de suas competências, mas não permitiu o exercício daqueles atos privativos do Poder Judiciário, como a decretação de indisponibilidade de bens e a diligência de busca e apreensão de documentos em escritório. Trata-se de postulado de reserva constitucional de jurisdição, ou seja, tais atos somente podem ser praticados por magistrados.

B) Sim. A Comissão Parlamentar de Inquérito possui poderes próprios das autoridades judiciais para, em decisão fundamentada, determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário, pois o que está em jogo é o acesso a informações já existentes. O Supremo Tribunal Federal já proferiu inúmeras decisões nesse sentido.

04. O deputado federal João da Silva, impulsionado por solicitação do seu partido, quer propor a alteração de alguns dispositivos normativos constantes da Lei nº 1.234, produzida pela via ordinária, em momento anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Porém, a atual ordem constitucional dispõe que a matéria de que

trata a referida Lei nº 1.234 deve ser regulamentada via Lei Complementar. Não sabendo como proceder, o referido deputado procura auxílio de sua assessoria jurídica a fim de sanar as dúvidas a seguir.

A) É possível considerar que a Lei nº 1.234 tenha mantido a conformidade constitucional com o advento da nova Constituição? Justifique. (Valor: 0,75)

B) Para a alteração dos dispositivos normativos constantes da Lei nº 1.234, que espécie legislativa deve ser utilizada pelo Deputado João da Silva? Justifique. (Valor: 0,50)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Sim, pois, nesse caso, se opera o fenômeno da recepção, que corresponde a uma revalidação das normas que não contrariam, materialmente, a nova Constituição. O importante é que a lei antiga não destoe materialmente da nova Constituição, pouco importando qual a forma com que se revista. Não se deve conferir importância a eventual incompatibilidade de forma com a nova Constituição, pois a forma é regida pela lei da época do ato (*tempus regit actum*). Assim, mesmo que o ato normativo seja veiculado por instrumento diverso daquele que a nova Carta exige para a regulação de determinada matéria, permanecerá em vigor e válido se houver concordância material, ou seja, no seu conteúdo, com as novas normas constitucionais.

B) Lei complementar. A partir da promulgação da nova Constituição, a Lei nº 1.234 foi recepcionada como “Lei Complementar”; portanto, diante da reserva constitucional expressa, qualquer alteração no seu texto deverá ser realizada por intermédio desta espécie legislativa.

► XX Exame

.....

01. Um candidato a Presidente da República, em discurso durante a campanha eleitoral, fez as proposições a seguir para seus eleitores: i. que iria revogar imediatamente uma medida provisória nociva ao interesse público, que foi editada em 10 de setembro de 2001, antes, portanto, da promulgação da Emenda Constitucional nº 32/01 (que até hoje

não foi apreciada pelo Congresso Nacional); ii. que iria editar medida provisória para modificar alguns artigos da Lei nº 6.815/80, mais especificamente aqueles que tratam da naturalização do estrangeiro residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais da Lei nº 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A partir da hipótese apresentada, com base nas regras do processo legislativo brasileiro, responda aos itens a seguir.

A) É constitucionalmente possível revogar uma Medida Provisória que tenha sido editada há vários anos e que ainda não tenha sido objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, ou seja, não tenha sido rejeitada, nem convertida em lei, tal qual consta na primeira proposição feita pelo candidato? Justifique. (Valor: 0,65)

B) A segunda proposição feita pelo candidato no sentido de editar Medida Provisória com o intuito de regular a naturalização do estrangeiro residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais do Código de Defesa do Consumidor encontra amparo constitucional? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: sua resposta deve ser fundamentada. A simples menção ao dispositivo legal não será pontuada.

► Gabarito comentado

A) Sim. O examinando deve destacar que a proposição desta MP teria amparo constitucional nos termos do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que estabelece que as medidas provisórias antigas, editadas em data anterior à promulgação daquela EC, continuam em vigor até que venham a ser revogadas ou apreciadas pelo Congresso Nacional. Portanto, a proposição feita tem amparo constitucional. Com efeito, levando em consideração que a data da EC nº 32 é de 11 de setembro de 2001, é correto afirmar que a MP editada em 10 de setembro de 2001 ainda se encontra em vigor. É importante frisar que todas aquelas medidas provisórias editadas anteriormente à EC nº 32 de 11 de setembro de 2001 continuam em vigor até hoje, se não foram rejeitadas pelo Congresso Nacional ou revogadas por outra MP do Presidente da República.

B) Não. Tal medida provisória seria duplamente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque estaria regulando matéria vedada a medida provisória, nos termos do Art. 62, § 1º, inciso I, alínea a, ou seja, matéria relativa à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos (situação jurídica do

estrangeiro no Brasil). Em segundo lugar, tal medida provisória seria incompatível com a CRFB/88, nos termos do Art. 62, § 1º, inciso I, alínea b, isto é, estaria versando sobre matéria de Direito Processual Civil (Código de Defesa do Consumidor).

02. O Presidente da República edita medida provisória estabelecendo o novo projeto de ensino para a educação federal no País, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília, pois só fazia sentido que estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro enquanto ela era a capital federal. Muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando contido no Art. 242, § 2º, da CRFB/88. Em resposta, a Advocacia-Geral da União sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

A) Segundo a Teoria Constitucional, qual é a diferença entre as denominadas normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais? (Valor: 0,75)

B) O entendimento externado pela Advocacia-Geral da União à imprensa está correto, sendo possível a alteração de norma constitucional formal por medida provisória? (Valor: 0,50)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) O examinando deverá responder que as normas materiais possuem status constitucional em razão do seu conteúdo, pois estabelecem normas referentes à estrutura organizacional do Estado, à separação dos Poderes e aos direitos e as garantias fundamentais, enquanto as normas em sentido formal só possuem o caráter de constitucionais porque foram elaboradas com o uso do processo legislativo próprio das normas constitucionais.

B) O examinando deverá responder que o entendimento externado pela Advocacia Geral da União à imprensa está incorreto, pois, independentemente da essência da norma, todo dispositivo que estiver presente

no texto constitucional, em razão da rigidez constitucional, só poderá ser alterado pelo processo legislativo solene das emendas constitucionais, tal qual previsto no Art. 60 da CRFB/88.

.....
03. A Assembleia Legislativa do Estado X elaborou Lei Estadual que determina que os veículos apreendidos pelas polícias militar e civil, caso não sejam reclamados no período de três anos, serão levados a hasta pública, repartindo-se o produto do leilão entre o Estado e o Município. O Governador do Estado, preocupado com a constitucionalidade da lei, visto que ela atingirá patrimônio privado, consulta o Procurador Geral do Estado. Com base no caso apresentado, responda aos itens a seguir.

A) A Lei Estadual está de acordo com as normas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988? (Valor: 0,65)

B) O Governador do Estado X pode propor, perante órgão da União, alguma medida judicial visando à impugnação da Lei Estadual? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► **Gabarito comentado**

A) O examinando deverá responder que estamos diante de um vício formal de constitucionalidade, pois a Lei Estadual viola o Art. 22, inciso I, da CRFB/88, que dispõe ser da competência privativa da União legislar sobre Direito Civil, já que trata de perda da propriedade.

B) O examinando deverá responder que o Governador é um dos legitimados ativos à propositura de ADI, de acordo com o Art. 103 da CRFB. A pertinência temática está presente, sendo possível questionar esse ato normativo por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o Art. 102, inciso I, a, da CRFB/88 e a Lei nº 9.868/99.

.....
04. Após o pleito eleitoral, o Deputado Federal X, diplomado e empossado, resolveu trocar de legenda, alegando que as normas que disciplinam o instituto jurídico da fidelidade partidária ainda não foram editadas no Brasil. O Deputado Federal X também conseguiu convencer o Senador Y, diplomado e empossado, a trocar de legenda, usando os mesmos argumentos. Efetuada a mudança para outra legenda já exis-

tente, o partido que perdeu os seus políticos resolveu pleitear, junto ao Poder Judiciário, a perda dos respectivos mandatos. Com base na situação narrada, responda aos itens a seguir.

A) A iniciativa do partido político de reaver o mandato do Deputado Federal X tem fundamento na CRFB/88? Justifique. (Valor: 0,65)

B) A solução jurídica é a mesma para o caso do Senador Y? Justifique. (Valor: 0,60)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Sim. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, nos cargos sujeitos ao sistema proporcional (deputados federais, deputados estaduais e vereadores), previsto no Art. 45, caput, da CRFB/88, o mandato eletivo pertence ao partido político e não ao parlamentar. No caso em tela, o abandono de legenda pelo Deputado Federal X enseja a extinção do seu mandato parlamentar, porque não há a caracterização de justa causa, ou seja, mudanças na ideologia do partido ou criação de um novo partido político. Portanto, a iniciativa deve ser julgada procedente, em atenção às características do sistema proporcional, cuja ênfase é dada aos votos obtidos pelos partidos políticos e não pelos parlamentares.

B) Não. A solução jurídica não deve ser a mesma, porque, nos cargos sujeitos ao sistema majoritário (presidente da república, governador, prefeito e senador), o mandato eletivo pertence ao parlamentar e não ao partido político. Nesse caso, o abandono de legenda pelo Senador Y não enseja a extinção do seu mandato parlamentar, porque o sistema majoritário se caracteriza pela ênfase na figura do candidato, daí a jurisprudência do STF no sentido da inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária. Portanto, a iniciativa deve ser julgada improcedente, em atenção ao princípio da soberania popular. Ou seja, no caso em tela, a mudança de partido feita pelo Senador Y, sem qualquer justa causa, não frustra a vontade do eleitor e não vulnera o princípio da soberania popular (Art. 1º, parágrafo único, e Art. 14, caput, ambos da CRFB/88).

► (OAB/FGV – XX Exame de Ordem Reaplicação Porto Velho – 2016)

01. Sob o argumento de sub-representação das regiões mais populosas do país, bem como de desigualdade entre os Estados-mem-

bro da Federação e, até mesmo, discriminação ente eles, o governador de um determinado Estado propõe Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a expressão “para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados”, constante do Art. 45, § 1º, da CRFB/88, dispositivo nela inserido desde a sua promulgação. Além desse problema, o mesmo governador fez uma outra consulta ao seu corpo jurídico para saber sobre a possibilidade de não aplicar determinada emenda constitucional que, no seu entender, não era benéfica ao seu Estado, isso apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido a sua compatibilidade com a CRFB/88. Nesse particular, um de seus assessores sugeriu a adoção da tese de que a norma constitucional originária é hierarquicamente superior, ao menos no plano axiológico, à norma constitucional derivada. Diante de tais fatos, responda, justificadamente, aos itens a seguir.

A) Cabe ADI contra o Art. 45, § 1º, da CRFB/88, norma constitucional que existe desde a promulgação da Constituição da República, em 1988? (Valor: 0,70)

B) A emenda constitucional pode deixar de ser aplicada com base na tese sugerida pelo assessor do Governador? (Valor: 0,55)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Não, porque a jurisprudência do STF não admite o cabimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra norma constitucional originária, por impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que se trata de norma formulada pelo poder constituinte originário, que não tem nenhum tipo de limitação, sendo, portanto, incondicionado, ilimitado, inaugural e soberano. A Suprema Corte não pode exercer o papel de fiscal do poder constituinte originário, a fim de verificar se este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo.

B) Não. O sistema constitucional brasileiro não admite a hierarquia de normas constitucionais. Portanto, há que se reconhecer que as emendas constitucionais têm a mesma força normativa das normas constitucionais originárias. Portanto, as emendas constitucionais que modifiquem as normas constitucionais originárias, desde que observem os requisitos constitucionais, não ocupam um plano inferior na hierarquia constitucional.

02. Joaquim Silva, português equiparado em direitos civis e políticos, preocupado com a probidade na República, impetrou habeas data contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa de seu Estado, pois este não respondera a pedido de expedição de certidão que comprovaria a suposta participação de deputados estaduais em fraudes a licitações de obras públicas. Aduziu que o Presidente da Casa Legislativa já havia se negado a expedir a certidão e que ela seria fundamental para as investigações que vinham sendo realizadas pelo Ministério Público. Em resposta ao writ, o Presidente da Assembleia Legislativa requer que a ação não seja conhecida, sob a alegação de que todo e qualquer remédio constitucional é garantia concedida pela Constituição da República Federativa do Brasil apenas a brasileiros natos. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

A) Ser cidadão brasileiro nato é condição para a impetração do habeas data? (Valor: 0,60)

B) É cabível a impetração do habeas data na hipótese? (Valor: 0,65)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Não, conforme se depreende da Lei nº 9.507/97 e do disposto no Art. 5º, inciso LXXII, da CRFB/88. O status de cidadão brasileiro somente é exigido para o ajuizamento de Ação Popular.

B) Não é cabível a impetração de habeas data na hipótese, pois, de acordo com o Art. 5º, inciso LXXII, da CRFB/88, este remédio constitucional destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

03. Emenda à Constituição insere novo direito na Constituição da República. Trata-se de uma norma de eficácia limitada, que necessita da devida integração por via de lei. Produzido o diploma legal regulador (Lei Y), ainda assim, alguns dos destinatários não se encontram em condições de usufruir do direito a que fazem jus, por ausência de regulamentação da norma legal pelo órgão competente (o Ministério da Previdência Social), conforme exigido pela citada Lei Y. Passados dois anos

após a edição da Lei Y, Mário, indignado com a demora e impossibilitado de usufruir do direito constitucionalmente garantido, é aconselhado a impetrar um Mandado de Injunção. Não sabendo exatamente os efeitos que tal medida poderia acarretar, Mário consulta um(a) advogado(a). A orientação recebida foi a de que, no seu caso específico, a adoção, pelo órgão judicante, de uma solução concretista individual iria satisfazer plenamente suas necessidades. Diante dessa situação, responda fundamentadamente aos itens a seguir.

A) Assiste razão ao(à) advogado(a) de Mário quanto à utilidade do acolhimento do Mandado de Injunção com fundamento na posição concretista individual? (Valor: 0,70)

B) A que órgão do Poder Judiciário competiria decidir a matéria? (Valor: 0,55)

Obs.: O examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) A teoria concretista individual é uma das posições reconhecidas pelo STF como passível de ser adotada nas situações em que é dado provimento ao Mandado de Injunção. Segundo esse entendimento, diante da lacuna, o Poder Judiciário deve criar a regulamentação para o caso específico, ou seja, a decisão viabiliza o exercício do direito, ainda não regulamentado pelo órgão competente, somente pelo impetrado, vez que a decisão teria efeitos *inter partes*. Como se vê, o órgão judicante, ao dar provimento ao Mandado de Injunção, estabeleceria a regulamentação da lei para que Mário (e somente ele) pudesse usufruir do direito constitucional garantido.

B) Segundo o Art. 125, inciso I, alínea h, da CRFB/88, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o Mandado de Injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão federal, da administração direta ou indireta. No caso, o Ministério da Previdência é um órgão da administração pública federal, sendo, portanto, o Superior Tribunal de Justiça o órgão judicial competente para processar e julgar a ação de Mário.

04.

A Associação Civil "Tudo Pela Saúde", preocupada com as péssimas condições de trabalho dos servidores da área de saúde,

elaborou projeto de lei que concedia aumento remuneratório a essa categoria de servidores. Esse projeto foi subscrito por um por cento do eleitorado nacional, circunscrito somente aos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, sendo apresentado ao Senado Federal. A Associação, esperançosa pela aprovação do projeto, informou à imprensa que, caso o projeto seja rejeitado ou vetado, irá ingressar com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para que os anseios do movimento se tornem normas constitucionais. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, de forma fundamentada, aos itens a seguir.

A) Os procedimentos adotados para encaminhar o projeto de lei estão de acordo com o processo legislativo estabelecido pela ordem constitucional? Justifique. (Valor: 0,80)

B) É possível que a PEC cogitada pela referida Associação seja de iniciativa popular? (Valor: 0,45)

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação.

► Gabarito comentado

A) Os procedimentos não estão corretos. O projeto apresenta uma série de vícios formais. O primeiro refere-se aos subscritores, que deveriam estar distribuídos por, pelo menos, cinco estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, segundo o Art. 61, § 2º, da CRFB/88. O segundo refere-se ao desrespeito à iniciativa reservada do Presidente da República, prevista no Art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da CRFB/88, em relação aos projetos de lei que objetivem aumentar a remuneração de servidores públicos federais. Por fim, há um terceiro vício. Os projetos de iniciativa popular devem ser iniciados sempre na Câmara dos Deputados e não no Senado Federal (Art. 61, § 2º, da CRFB/88).

B) Não. O Art. 60, incisos I, II e III, da CRFB/88 estabelece um rol taxativo de legitimados à propositura de PEC, e a iniciativa popular não está elencada nesses incisos. Em consequência, não será possível a propositura pela Associação.

CAPÍTULO 25

JURISPRUDÊNCIA DO STF 2015 E 2016

Tendo em vista que o sucesso na prova da segunda fase está relacionado à elaboração de uma boa peça processual, mas também de respostas adequadas às questões discursivas, separamos, com base na jurisprudência atual do STF, decisões importantes relacionadas ao Direito Constitucional sobre os mais variados temas, dentre eles, controle de constitucionalidade, direitos fundamentais e processo legislativo, assuntos cobrados com muita frequência no Exame de Ordem.

Aproveite a leitura e não deixe de fazer anotações no caderno de estudo sobre os principais aspectos das decisões aqui separadas.

INFORMATIVOS 2015

► "Amicus curiae": recorribilidade e legitimidade

O Plenário negou provimento a agravo regimental em que discutida a admissibilidade da intervenção, na qualidade de "amicus curiae", de instituição financeira em ação direta de inconstitucionalidade. Preliminarmente, o Colegiado conheceu do recurso. No ponto, a jurisprudência da Corte reconheceria legitimidade recursal àquele que desejasse ingressar na relação processual como "amicus curiae" e tivesse sua pretensão recusada. Por outro lado, não se conheceria de recursos interpostos por "amicus curiae" já admitido, nos quais se intentasse impugnar acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade. No mérito, o Plenário entendeu que não se justificaria a intervenção de instituição financeira para discutir situações concretas e individuais, no caso, a situação particular que desaguará na decretação de liquidação extrajudicial da instituição. Sob esse aspecto, a tutela jurisdicional de situações individuais deveria ser obtida pela via do controle difuso, por qualquer pessoa com interesse e legitimidade. O propósito do "amicus curiae" seria o de pluralizar o debate constitucional e conferir maior legitimidade ao julgamento do STF, tendo em conta a colaboração emprestada pelo terceiro interveniente. Este deveria possuir interesse de índole institucional, bem assim a legítima representação de um grupo de pessoas, sem qualquer interesse particular. Na espécie, a instituição agravante careceria de legitimidade, uma vez não possuir representatividade adequada.

AD! 5022 AgR/RO, rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2014. (ADI-5022)

(Informativo 772)

► **Vinculação a salário mínimo e criação de órgão**

O Plenário concedeu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 5º, c, 9º, e, 14 e 17 da Lei 1.598/2011 do Estado do Amapá, que institui o programa “Renda para Viver Melhor” no âmbito da Administração direta do Executivo estadual. A referida norma prevê o pagamento de metade do valor de um salário mínimo às famílias que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza, consoante critérios de enquadramento nela definidos. A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, também cria o “Conselho Gestor” do programa. A Corte, no tocante à interpretação conforme, assentou que as alusões ao salário mínimo deveriam ser entendidas como a revelarem o valor vigente na data da publicação da lei questionada, vedada qualquer vinculação futura por força do inciso IV do art. 7º da CF. Nesse ponto, a referência ao salário mínimo contida na norma de regência do benefício haveria de ser considerada como a fixar, na data da edição da lei, certo valor. A partir desse montante referencial, passaria a ser corrigido segundo fator diverso do mencionado salário. Asseverou ainda que, ao criar o Conselho Gestor, vinculado à Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social, a disciplinar-lhe as atribuições, a composição e o posicionamento na estrutura administrativa estadual, teria afrontado, à primeira vista, a competência do Poder Executivo, a incorrer em inconstitucionalidade formal.

ADI 4726 MC/AP, rel. Min. Marco Aurélio, 11.2.2015. (ADI-4726)

(Informativo 774)

► **Energia elétrica e competência para legislar**

As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União (CF, artigos 21, XII, b; 22, IV e 175). Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 12.635/2005 do Estado de São Paulo (“Art. 2º Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos, serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior”). A Corte, em questão de ordem, por entender não haver necessidade de acréscimos instrutórios mais aprofundados, converteu o exame da cautelar em julgamento de mérito. Apontou que a norma questionada, ao criar para as empresas obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”), para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, teria se imiscuído nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado-membro.

ADI 4925/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 12.2.2015. (ADI-4925)

(Informativo 774)

► **Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União – 1**

Por reputar usurpada a competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior (CF, art. 22, VIII), o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.427/2006 do Estado do Rio Grande do Sul (“Art. 1º – Fica proibida a comercialização, a estocagem e o trânsito de arroz, trigo, feijão, cebola, cevada e aveia e seus derivados importados de outros países, para consumo e comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, que não tenham sido submetidos à análise de resíduos químicos de agrotóxicos ou de princípios ativos usados, também, na industrialização dos referidos produtos. § 1º – Compreende-se como agrotóxicos o definido conforme a legislação federal. § 2º – O certificado ou laudo técnico será o documento hábil para atestar a realização da inspeção de que trata o ‘caput’, de forma a evitar a presença de toxinas prejudiciais à saúde humana. Art. 2º – Fica obrigatória a pesagem de veículo que ingresse ou trafegue no âmbito do território do Estado, transportando os produtos, aos quais se refere o art. 1º desta Lei, destinados à comercialização em estabelecimento ou ao consumidor final, no Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. Quando da pesagem, será obrigatória a apresentação da documentação fiscal exigida, bem como do documento de que trata o § 2º do art. 1º desta Lei”).

ADI 3813/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 12.2.2015. (ADI-3813)

(Informativo 774)

► **Agrotóxico: lei estadual e competência privativa da União – 2**

O Colegiado consignou que competiria à União a definição dos requisitos para o ingresso de produtos estrangeiros no País, visto se tratar de típica questão de comércio exterior (CF, art. 22, VIII). Recordou que, de acordo com a exposição de motivos da mencionada lei, a proibição em questão teria objetivo claro de evitar que a população gaúcha consumisse produtos contaminados por agrotóxicos que, pela legislação federal, seriam de uso proibido no País, por serem nocivos à saúde, mas que teriam uso regular na Argentina e no Uruguai. Entretanto, em que pese a relevância das preocupações do Poder Legislativo gaúcho, a lei não esconderia o propósito de criar requisitos especiais ao ingresso naquele Estado-membro de produtos agrícolas providos do exterior. Ao fazê-lo, a lei, por consequência lógica, restringiria a entrada desses produtos não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o País. Frisou que não seria possível compreender a matéria como pertencente ao âmbito legislativo concorrente dos Estados-membros, sob o argumento de tratar-se de legislação concernente à proteção da saúde dos consumidores (CF, art. 24, V e XII, §§ 1º e 2º). Ainda que se tratasse de questão, sob certo ponto de vista, de competência concorrente (consumo e proteção à saúde), predominariam, na hipótese, os limites da competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual. No caso, a norma impugnada, ao criar um certificado estadual para os produtos agrícolas, de modo a permitir que as próprias autoridades estaduais fiscalizassem a existência de resíduos de agrotóxicos, teria invadido competência que seria própria das autoridades federais.

ADI 3813/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 12.2.2015. (ADI-3813)

(Informativo 774)

► **Revisão de remuneração de servidores públicos e iniciativa legislativa**

É inconstitucional o dispositivo de Constituição estadual que disponha sobre a revisão concomitante e automática de valores incorporados à remuneração de servidores públicos em razão do exercício de função ou mandato quando reajustada a remuneração atinente à função ou ao cargo paradigma, matéria cuja iniciativa de projeto é reservada ao Governador. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 89, § 6º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (“O valor incorporado a qualquer título pelo servidor ativo ou inativo, como direito pessoal, pelo exercício de funções de confiança ou de mandato, será revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do cargo que lhe deu causa”).

ADI 3848/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 11.2.2015. (ADI-3848)

(Informativo 774)

► **Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 1**

Por violar a competência privativa da União, o Estado-membro não pode dispor sobre crime de responsabilidade. No entanto, durante a fase inicial de tramitação de processo por crime de responsabilidade instaurado contra governador, a Constituição estadual deve obedecer à sistemática disposta na legislação federal. Assim, é constitucional norma prevista em Constituição estadual que preveja a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que sejam iniciadas ações por crimes comuns e de responsabilidade eventualmente dirigidas contra o governador de Estado. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ações diretas para declarar a Inconstitucionalidade das expressões “processar e julgar o Governador ... nos crimes de responsabilidade” e “ou perante a própria Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade” previstas, respectivamente, nos artigos 54 e 89 da Constituição do Estado do Paraná. Declarou também a inconstitucionalidade do inciso XVI do art. 29, e da expressão “ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade”, contida no art. 67, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, bem como a inconstitucionalidade do inciso XXI do art. 56, e da segunda parte do art. 93, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo. A Corte rememorou que a Constituição Estadual deveria seguir rigorosamente os termos da legislação federal sobre crimes de responsabilidade, por imposição das normas dos artigos 22, I, e 85, da CF, que reservariam a competência para dispor sobre matéria penal e processual penal à União. Ademais, não seria possível interpretar literalmente os dispositivos atacados de modo a concluir que o julgamento de mérito das imputações por crimes de responsabilidade dirigidas contra o governador de Estado teria sido atribuído ao discernimento da Assembleia Legislativa local, e não do Tribunal Especial previsto no art. 78, § 3º, da Lei 1.079/1950. Esse tipo de exegese ofenderia os artigos 22, I, e 85, da CF.

ADI 4791/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 12.2.2015. (ADI-4791)

ADI 4800/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4800)

ADI 4792/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4792)

(Informativo 774)

► **Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 2**

Por outro lado, o Colegiado reconheceu a constitucionalidade das normas das Constituições estaduais que exigiriam a aprovação de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa como requisito indispensável — a denominada licença prévia — para se admitir a acusação nas ações por crimes comuns e de responsabilidade, eventualmente dirigidas contra o governador do Estado. Consignou que o condicionamento da abertura de processo acusatório ao beneplácito da Assembleia Legislativa, antes de constituir uma regalia antirrepublicana deferida em favor da pessoa do governador, serviria à preservação da normalidade institucional das funções do Executivo e à salvaguarda da autonomia política do Estado-membro, que haveria de sancionar, pelo voto de seus representantes, medida de drásticas consequências para a vida pública local. Salientou que a exigência de licença para o processamento de governador não traria prejuízo para o exercício da jurisdição, porque, enquanto não autorizado o prosseguimento da ação punitiva, ficaria suspenso o transcurso do prazo prescricional contra a autoridade investigada cujo marco interruptivo contaria da data do despacho que solicitasse a anuência do Poder Legislativo para a instauração do processo, e não da data da efetiva manifestação. O controle político exercido pelas Assembleias Legislativas sobre a admissibilidade das acusações endereçadas contra governadores não conferiria aos parlamentos locais a autoridade para decidir sobre atos constitutivos acessórios à investigação penal, entre eles as prisões cautelares. Todavia, a supressão da exigência de autorização das respectivas Casas parlamentares para a formalização de processos contra deputados e senadores (CF, art. 51, I), materializada pela EC 35/2001, não alterara o regime de responsabilização dos governadores de Estado. Isso encontraria justificativa no fato de que — diferentemente do que ocorreria com o afastamento de um governador de Estado, que tem valor crucial para a continuidade de programas de governo locais — a suspensão funcional de um parlamentar seria uma ocorrência absolutamente menos expressiva para o pleno funcionamento do Poder Legislativo.

ADI 4791/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 12.2.2015. (ADI-4791)

ADI 4800/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4800)

ADI 4792/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4792)

(Informativo 774)

► **Licença prévia para julgamento de governador em crime de responsabilidade e crime comum – 3**

Vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido formulado em relação à atribuição da Assembleia quanto aos crimes de responsabilidade, e procedente para afastar a necessidade de licença para fins de persecução criminal contra governador nos crimes comuns. Pontuava que a Constituição estadual poderia reger

a matéria pertinente a crime de responsabilidade. Afastava a possibilidade de se cogitar do Tribunal Especial, previsto no art. 78, § 3º, da Lei 1.079/1950, que seria tribunal de exceção, porque não fora criado em norma jurídica, mas estaria apenas previsto sem se ter, inclusive, indicação da composição. Esse Tribunal Especial seria incompatível com o inciso XXXVI do art. 5º da CF, que vedaria juízo ou tribunal de exceção. No que se refere aos crimes comuns, reputava que os artigos 51, I, e 86, da CF, deveriam ser interpretados restritivamente, especialmente porque o texto seria expresso ao tratar do Presidente da República, de modo que não se poderia estender a governador e muito menos a prefeito. Destacava que a competência do STJ para julgar governador de Estado não estaria condicionada a aprovação de licença prévia como se poderia observar do art. 105 da CF. Sublinhava, ademais, que, mantida essa licença, haveria transgressão à Constituição Federal e estaria colocado, em segundo plano, o primado do Judiciário, pois somente haveria persecução criminal por crime comum de governador se ele não tivesse bancada na Casa Legislativa.

ADI 4791/PR, rel. Min. Teori Zavascki, 12.2.2015. (ADI-4791)

ADI 4800/RO, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4800)

ADI 4792/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, 12.2.2015. (ADI-4792)

(Informativo 774)

► Competência concorrente para legislar sobre educação

Lei editada por Estado-membro, que disponha sobre número máximo de alunos em sala de aula na educação infantil, fundamental e média, não usurpa a competência da União para legislar sobre normas gerais de educação (CF, art. 24, IX, e § 3º). Com base nessa orientação, o Plenário julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face das alíneas a, b e c do inciso VII do art. 82 da LC 170/1998 do Estado de Santa Catarina. A Corte destacou a necessidade de rever sua postura “prima facie” em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, de forma a prestigiar as iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca da Constituição. Pontuou que essa diretriz se ajustaria à noção de federalismo como sistema que visaria a promover o pluralismo nas formas de organização política. Asseverou que, em matéria de educação, a competência da União e dos Estados-membros seria concorrente. Aduziu que, com relação às normas gerais, os Estados-membros e o Distrito Federal possuiriam competência complementar (CF, art. 24, § 2º) e a eles caberia suprir lacunas. Frisou a necessidade de não se ampliar a compreensão das denominadas normas gerais, sob pena de se afastar a autoridade normativa dos entes regionais e locais para tratar do tema. Enfatizou que o limite máximo de alunos em sala de aula seria questão específica relativa à educação e ao ensino e, sem dúvida, matéria de interesse de todos os entes da federação, por envolver circunstâncias peculiares de cada região. Ademais, a sistemática normativa estadual também seria compatível com a disciplina federal sobre o assunto, hoje fixada pela Lei 9.394/1996, que estabelece “as diretrizes e bases da educação nacional”. Em seu art. 25, a lei federal deixaria nítido espaço para atuação estadual e distrital na determinação da proporção professor e aluno dos sistemas de ensino. Possibilitaria, assim, que o sistema estadual detalhasse de que maneira a proporção entre

alunos e professores se verificaria no âmbito local. Sob o prisma formal, portanto, a Lei 9.394/1996 habilitaria a edição de comandos estaduais como os previstos nas alíneas a, b, e c do inciso VII do art. 82 da LC 170/1998 do Estado de Santa Catarina. Sob o ângulo material, a lei catarinense ainda apresentaria evidente diretriz de prudência ao criar uma proporção aluno-professor que se elevaria à medida que aumentasse a idade dos alunos.

ADI 4060/SC, rel. Min. Luiz Fux, 25.2.2015. (ADI-4060)

(Informativo 775)

► Repercussão geral

Imunidade parlamentar de vereador e exercício do mandato

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade prevista no art. 29, VIII, da CF aos vereadores ("Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: ... VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município"). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que se discutia o alcance da imunidade material de vereador em discurso, supostamente ofensivo à honra, proferido da tribuna da Casa Legislativa municipal. O Colegiado reputou que, embora as manifestações fossem ofensivas, teriam sido proferidas durante a sessão da Câmara dos Vereadores — portanto na circunscrição do Município — e teriam como motivação questão de cunho político, tendo em conta a existência de representação contra o prefeito formulada junto ao Ministério Público — portanto no exercício do mandato. O Ministro Teori Zavascki enfatizou ser necessário presumir que a fala dos parlamentares, em circunstâncias como a do caso, teria relação com a atividade parlamentar. Do contrário, seria difícil preservar a imunidade constitucional. O Ministro Gilmar Mendes sublinhou que, se o vereador tivesse de atuar com bons modos e linguagem esportiva, não haveria necessidade de a Constituição garantir a imunidade parlamentar. O Ministro Celso de Mello destacou que se o vereador, não obstante amparado pela imunidade material, incidisse em abuso, seria passível de censura, mas da própria Casa Legislativa a que pertencesse. Vencido o Ministro Marco Aurélio (relator), que desprovia o recurso. Considerava que a inviolabilidade dos vereadores exigiria a correlação entre as manifestações e o desempenho do mandato, o que não teria havido na espécie.

RE 600063/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 25.2.2015. (RE-600063)

(Informativo 775)

► Poder Executivo e quinto constitucional

A exigência de submissão do nome escolhido pelo governador à Casa Legislativa, para preenchimento de vaga destinada ao quinto constitucional, invade a atuação

do Poder Executivo. Com base nessa orientação, o Plenário acolheu preliminar de conhecimento parcial da ação e julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da EC estadual 25/2008, que altera “nova redação ao artigo 63 da Constituição do Estado de São Paulo – Capítulo IV – Do Poder Judiciário” (medida cautelar noticiada no Informativo 523). O Tribunal assentou a declaração de inconstitucionalidade da expressão “depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa”, incluída no parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado de São Paulo. Esclareceu que, embora o autor tivesse buscado a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da EC paulista 25/2008, restringira-se a discorrer sobre os motivos para a invalidade da expressão acrescentada à parte final do parágrafo único do artigo 63 da Constituição estadual. A Corte asseverou que o art. 94 da CF regula de maneira exaustiva o procedimento destinado à escolha dos membros dos tribunais de justiça oriundos do quinto constitucional. Precedente citado: ADI 202/BA (DJU de 7.3.1997).

ADI 4150/SP, rel. Min. Marco Aurélio, 25.2.2015. (ADI-4150)

(Informativo 775)

► Lei municipal e vício de iniciativa

Por vício de iniciativa, o Plenário deu provimento a recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III, VIII, bem como dos §§ 1º e 2º do art. 55 da Lei Orgânica de Cambuí/MG, que concede benefícios a servidores públicos daquela municipalidade. Na espécie, a norma questionada decorria de iniciativa de câmara legislativa municipal. A Corte asseverou que lei orgânica de município não poderia normatizar direitos de servidores, porquanto a prática afrontaria a iniciativa do chefe do Poder Executivo.

RE 590829/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 5.3.2015. (RE-590829)

(Informativo 776)

► TCU: medida cautelar de indisponibilidade de bens e tomada de contas especial

A 2ª Turma denegou mandado de segurança impetrado em face de acórdão do TCU, que, em procedimento de tomada de contas especial, decretara a indisponibilidade de bens dos ora impetrantes. Estes apontavam a violação ao contraditório e à ampla defesa, ao direito de propriedade, bem como a nulidade da decisão impugnada, em razão da inexistência de fundamentação, da ausência de individualização das condutas supostamente irregulares e da falta de demonstração dos requisitos legais autorizadores da medida constritiva. O Colegiado asseverou que não haveria que se falar em ilegalidade ou abuso de poder em relação à atuação do TCU, que, ao determinar a indisponibilidade dos bens, teria agido em consonância com suas atribuições constitucionais, com as disposições legais e com a jurisprudência do STF. Com efeito, o ato impugnado estaria inserido no campo das atribuições constitucionais de controle externo exercido por aquela corte de contas (CF, art. 71). A jurisprudência do STF reconheceria assistir ao TCU um poder geral de cautela, que se consubstanciaria em prerrogativa institucional decorrente das próprias atribuições que a Constituição

expressamente lhe outorgara para seu adequado funcionamento e alcance de suas finalidades. Seria possível, inclusive, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação fundamentada daquela Corte, sempre que necessárias à neutralização imediata de situações de lesividade ao interesse público ou à garantia da utilidade prática de suas deliberações finais. Ademais, o TCU disporia de autorização legal expressa (Lei 8.443/1992, art. 44, § 2º) para decretação cautelar de indisponibilidade de bens, o que também encontraria previsão em seu regimento interno (artigos 273, 274 e 276). Destacou, outrossim, que o relatório da decisão atacada seria integrado por diversidade de elementos e análises decorrentes de aprofundados relatórios de fiscalização elaborados pela equipe de auditoria do TCU, o que afastaria a alegação de nulidade da decisão atacada no ponto em que supostamente ausente a individualização de condutas comissivas ou omissivas a ensejar possível responsabilização. Além disso, dever-se-ia ressaltar que, de fato, estariam presentes os requisitos legais para a decretação cautelar da medida de indisponibilidade de bens, na medida em que o ato impugnado teria acentuado a robustez dos elementos de convicção colhidos, a vislumbrar alta reprovabilidade das condutas identificadas e elevado prejuízo causado. A referida determinação de indisponibilidade guardaria pertinência com os requisitos legais para que se evitasse a ocorrência de danos ao erário ou a inviabilidade de ressarcimento (Lei 8.443/1992, art. 44, “caput”). Essa medida também se coadunaria com a exigência legal de promover a indisponibilidade de bens dos responsáveis para garantir o ressarcimento dos danos em apuração (Lei 8.443/1992, art. 44, § 2º). Por fim, a mera cogitação de que o valor dos bens eventualmente tornados indisponíveis por meio da medida constritiva fosse muito inferior ao valor supostamente devido a título de ressarcimento, como alegado, não seria justificativa apta a impedir a adoção da medida cautelar pelo TCU.

MS 33092/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 24.3.2015. (MS-33092)

(Informativo 779)

► Art. 27 da Lei 9.868/1999 e suspensão de julgamento – 4

Em ação direta de inconstitucionalidade, com a proclamação do resultado final, se tem por concluído e encerrado o julgamento e, por isso, inviável a sua reabertura para fins de modulação. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de afirmar que o exame da presente ação direta fora concluído e que não seria admissível reabrir discussão após o resultado ter sido proclamado. Na espécie, na data do julgamento estavam presentes dez Ministros da Corte, porém, não se teria obtido a maioria de dois terços (oito votos) para se modular os efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 (“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”) e o julgamento fora encerrado Na sessão subsequente, tendo em conta o comparecimento do Ministro ausente da sessão anterior, cogitou-se prosseguir no julgamento quanto à modulação — v. Informativos 481 e 776. A Corte destacou que a análise da ação direta de inconstitucionalidade seria realizada de maneira bifásica: a) primeiro se discutiria a questão da constitucionalidade da norma,

do ponto de vista material; e, b) declarada a inconstitucionalidade, seria discutida a aplicabilidade da modulação dos efeitos temporários, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999. Assim, se a proposta de modulação tivesse ocorrido na data do julgamento de mérito, seria possível admiti-la. Ressaltou que não teria havido erro material e, uma vez que a apreciação do feito fora concluída e proclamado o resultado, não se poderia reabrir o que decidido. Por conseguinte, estaria preclusa, à luz do postulado do devido processo legal, a possibilidade de nova deliberação. Vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Menezes Direito e Teori Zavascki, que admitiam a retomada do julgamento quanto à modulação dos efeitos. Para o Ministro Teori Zavascki, teria havido “error in procedendo”. Apontava que, em caso de modulação, se não fosse alcançado o quórum e houvesse magistrado para votar, o julgamento deveria ser adiado.

ADI 2949 QO/MC, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 8.4.2015. (ADI-2949)

(Informativo 780)

► Publicidade de bebidas alcoólicas e omissão legislativa – 1

O Plenário, por maioria, conheceu de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e, no mérito, julgou improcedente pedido formulado em face de alegada omissão legislativa parcial do Congresso Nacional, tendo em vista ausência de regulamentação acerca da propaganda de bebidas de teor alcoólico inferior a 13 graus Gay Lussac (13° GL), em desacordo com o comando constitucional previsto no art. 220, § 4º, da CF (“§ 4º – A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso”). O Tribunal, de início, asseverou que estaria assentada na jurisprudência do STF, com fundamento na interpretação dos princípios da harmonia e independência entre os Poderes, a impossibilidade de, em sede jurisdicional, criar-se norma geral e abstrata em substituição ao legislador, reiterado o quanto decidido na ADI 1.755/DF (DJU de 18.5.2001). No entanto, no caso em comento, o primeiro item a ser considerado deveria ser a real existência da alegada omissão inconstitucional em matéria de propaganda de bebidas alcoólicas. O legislador federal, no exercício da atribuição a ele conferida pelo poder constituinte originário, aprovava a Lei 9.294/1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumíferos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da CF. Da análise do trâmite do projeto que dera origem à referida lei constatar-se-ia que a matéria teria sido amplamente debatida durante sete anos nas casas do Congresso Nacional. A elaboração da lei em análise teria sido, inclusive, seguida de: a) aprovação do Decreto 2.018/1996, que a regulamentava; b) instituição da Política Nacional sobre o Alcool — que dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool e respectiva associação com a violência e criminalidade —, aprovada pelo Decreto 6.117/2007; e c) regulamentação e fiscalização implementadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – Conar. Não se demonstraria, pois, omissão inconstitucional na espécie.

ADO 22/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.4.2015. (ADO-22)

(Informativo 782)

► Publicidade de bebidas alcoólicas e omissão legislativa – 2

A Corte destacou que a análise dos dados constantes da norma vigente e mesmo do elemento histórico — o qual não seria o melhor critério de interpretação, mas fator demonstrativo da ação legislativa, a deitar por terra, no caso, a afirmativa de omissão do legislador —, comprovariam que a questão estaria afeita ao exercício de competência legítima e prioritária do Poder Legislativo. Ademais, a irrisignação quanto ao critério fixado no parágrafo único do art. 1º da Lei 9.294/1996 — bebidas alcoólicas, para efeitos da lei, seriam as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13º GL — não seria suficiente para evidenciar a alegada omissão inconstitucional, dado que, como dito, estaria demonstrado nos autos ter sido a matéria relativa à propaganda de bebidas alcoólicas objeto de amplos debates em ambas as Casas do Poder Legislativo. Ainda que se pudessem considerar relevantes as razões sociais motivadoras da ação direta em apreciação, o pedido não poderia prosperar. Isso porque, tão importante quanto a preservação da saúde daqueles que se excedem no uso de bebidas alcoólicas, e que poderiam consumi-las em níveis menores, seria a observância de princípios fundamentais do direito constitucional, como o da separação dos Poderes. Assim, para afirmar a omissão inconstitucional na espécie, o STF teria de analisar a conveniência política de normas legitimamente elaboradas pelos representantes eleitos pelo povo. Portanto, não se estaria diante de uma omissão, mas diante de uma opção, ou seja, o que teria havido seria uma opção do legislador na escolha das propagandas que seriam viáveis, ou não. Outrossim, a Lei 9.294/1996 não contraditaria a Lei 11.705/2008, pela qual instituída a chamada “Lei Seca”, estabelecendo-se restrições ao uso de álcool por motoristas. No caso, estaria em discussão a questão da liberdade de expressão com relação à propaganda. Não se estaria a julgar teor alcoólico de bebida, e, sim, até que limite poderia ir sua publicidade. Vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia da ação direta, dado que seu autor seria carecedor de ação.

ADO 22/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 22.4.2015. (ADO-22)

(Informativo 782)

► STF e competência em decisões negativas do CNMP

O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar ações decorrentes de decisões negativas do CNMP e do CNJ. Com base nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, não conheceu de mandado de segurança impetrado para fins de anular decisão do CNMP proferida em Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público – RPA, que mantivera avocação de inquérito civil público instaurado para investigar atos praticados no âmbito da administração superior de Ministério Público estadual. Na espécie, promotoras de justiça instauraram procedimento para apurar o encaminhamento, à Assembleia Legislativa, de projeto de lei que criara cargos em comissão e concedera aumento aos servidores comissionados do Ministério Público estadual, a afrontar o art. 37, II e V, da CF. Na sequência, o Colégio de Procuradores de Justiça reconheceu, em razão do disposto no § 1º do art. 8º da LC estadual 25/1998, a competência do decano para a condução do inquérito, ante a existência de investigação a respeito de possível prática de atos de improbidade por parte do Procurador-Geral de Justiça e dos demais membros da administração superior. Com base nessa decisão, o Procurador de Justiça decano avocou o inquérito

civil público, que foi arquivado por ausência de ilegalidade, decisão homologada pelo CNMP estadual. Seguiu-se o ajuizamento de RPA em que pretendida a nulidade do ato de avocação, julgada improcedente. A Turma asseverou que não se trataria de negativa de acesso à jurisdição, mas as impetrantes não teriam acesso à jurisdição do STF. Reiterou o quanto decidido no MS 31453 AgR/DF (DJe de 10.2.2015), sentido de que o pronunciamento do CNJ — aqui, o CNMP, órgão similar — que consubstanciase recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolvesse mero reconhecimento de sua incompetência, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do STF. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que deferia a ordem para restaurar a investigação interrompida na origem e cujo processo fora avocado pela administração superior de Ministério Público Estadual. Esclarecia que a situação concreta em que o Conselho não adentrasse a controvérsia seria distinta daquela em que apreciasse e referendasse o pronunciamento de origem. Aduzia que, por analogia, estaria configurado o disposto no art. 512 do CPC (“O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”), a revelar que a decisão subsequente a confirmar ou a reformar a anterior, por ela seria substituída.

MS 33163/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão: Min. Roberto Barroso, 5.5.2015. (MS-33163)

(Informativo 784)

► EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 1

O Plenário, por maioria, deferiu pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para: a) suspender a aplicação da expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” contida no art. 100 do ADCT, introduzido pela EC 88/2015, por vulnerar as condições materiais necessárias ao exercício imparcial e independente da função jurisdicional, ultrajando a separação dos Poderes, cláusula pétrea inscrita no art. 60, § 4º, III, da CF; b) fixar a interpretação, quanto à parte remanescente da EC 88/2015, de que o art. 100 do ADCT não pudesse ser estendido a outros agentes públicos até que fosse editada a lei complementar a que alude o art. 40, § 1º, II, da CF, a qual, quanto à magistratura, é a lei complementar de iniciativa do STF, nos termos do art. 93 da CF; c) suspender a tramitação de todos os processos que envolvessem a aplicação a magistrados do art. 40, § 1º, II, da CF e do art. 100 do ADCT, até o julgamento definitivo da ação direta em comento; e d) declarar sem efeito todo e qualquer pronunciamento judicial ou administrativo que afastasse, ampliasse ou reduzisse a literalidade do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com base neste fundamento, assegurasse a qualquer outro agente público o exercício das funções relativas a cargo efetivo após ter completado 70 anos de idade. A norma impugnada — introduzida no ADCT pela EC 88/2015 — dispõe que, “até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal”. Alegava-se, na espécie, que a expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” incorreria em vício material por ofensa à garantia da vitaliciedade (CF, art. 93, “caput”)

e à separação dos Poderes (CF, art. 2º), exorbitando dos limites substantivos ao poder de reforma da Constituição (CF, art. 60, §4º, III e IV).

ADI 5316 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.5.2015. (ADI-5316)

(Informativo 786)

► EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 2

A Corte, inicialmente, assentou a regularidade processual na cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC em uma única demanda de controle concentrado, o que se daria na espécie, vencido o Ministro Marco Aurélio. Asseverou que a cumulação de ações seria não só compatível como também adequada à promoção dos fins a que destinado o processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, destinado à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional, reiterado o que decidido na ADI 1.434 MC/SP (DJU de 22.11.1996). Além disso, a cumulação objetiva de demandas consubstanciaria categoria própria à teoria geral do processo. Como instrumento, o processo existiria para viabilizar finalidades materiais que lhes seriam externas. A cumulação objetiva apenas fortaleceria essa aptidão na medida em que permitiria o enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente de questões minimamente relacionadas entre elas. Não seria legítimo que o processo de controle abstrato fosse diferente. Outrossim, rejeitar a possibilidade de cumulação de ações — além de carecer de fundamento expresso na Lei 9.868/1999 — apenas ensejaria a propositura de nova demanda com pedido e fundamentação idênticos, a ser distribuída por prevenção, como ocorreria em hipóteses de ajuizamento de ADI e ADC em face de um mesmo diploma. Ademais, os pedidos articulados na inicial não seriam incompatíveis jurídica ou logicamente, sendo provenientes de origem comum. Por outro lado, o requisito relativo à existência de controvérsia judicial relevante, necessário ao processamento e julgamento da ADC (Lei 9.868/1999, art. 14, III), seria qualitativo e não quantitativo, isto é, não diria respeito unicamente ao número de decisões judiciais num ou noutro sentido. Dois aspectos tornariam a controvérsia em comento juridicamente relevante. O primeiro diria respeito à estatura constitucional do diploma que estaria sendo invalidado nas instâncias inferiores — a EC 88/2015, que introduzira o art. 100 ao ADCT —, ou seja, uma emenda à Constituição, expressão mais elevada da vontade do parlamento brasileiro. Em segundo lugar, decisões similares poderiam vir a se proliferar pelos Estados-Membros, a configurar real ameaça à presunção de constitucionalidade da referida emenda constitucional.

ADI 5316 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.5.2015. (ADI-5316)

(Informativo 786)

► EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 3

Com relação ao mérito, o Plenário asseverou que a EC 88/2015 alterara o corpo permanente da Constituição para possibilitar, na forma a ser definida por lei complementar, a aposentadoria compulsória de servidores públicos aos 75 anos (CF, art. 40, §1º, II). Até que viesse a lume a referida lei complementar, a emenda constitucional em questão estabeleceria regra transitória para alguns servidores públicos, permitindo que os ministros do STF, dos tribunais superiores e do TCU se aposentassem com-

pulsoriamente apenas aos 75 anos de idade, nas condições do art. 52 da CF. Nessa senda, tornar-se-ia necessário delimitar o preciso sentido da expressão impugnada, qual seja, “nas condições do art. 52 da Constituição Federal”. Em uma primeira leitura, a referência poderia parecer sem sentido, afinal a única previsão do art. 52 pertinente ao caso cuidaria do ingresso de cidadãos nos cargos de ministros de tribunais superiores e do TCU (CF, art. 52, III, a e b). Não haveria regras no art. 52 da CF que tratassem da aposentadoria de magistrados e membros do TCU. Daí ser curioso que o art. 100 do ADCT determinasse que a aposentadoria fosse processada com base em dispositivo que não trataria de aposentadoria. Essa perplexidade inicial, porém, seria dissipada tanto pela leitura sistemática da EC 88/2015 quanto pela análise dos debates legislativos que lhe deram origem. Assim, pelo ângulo sistemático, seria evidente que o art. 100 do ADCT cumpriria provisoriamente o papel da lei complementar indicada na nova redação do art. 40 da CF. Esse papel seria exatamente o de fixar as condições para aposentadoria aos 75 anos. Isso porque, pela redação atual do artigo 40, §1º, II, da CF, a aposentadoria do servidor público ocorreria, em regra, aos 70 anos, embora fosse possível a extensão desse limite para os 75 anos segundo critérios a serem fixados em lei complementar. O art. 100 do ADCT simplesmente teria esclarecido que, provisoriamente e quanto aos agentes públicos ali mencionados, as condições de permanência até os 75 anos seriam idênticas àquelas de ingresso. Mais especificamente, a condição seria a sabatina perante o Senado Federal. Essa interpretação seria confirmada pelo ângulo histórico, na análise de documentos que integraram o processo legislativo resultante na EC 88/2015. Não haveria dúvidas, portanto, de que a expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” fixaria, inequivocamente, nova sabatina perante o Senado Federal como requisito para a permanência no cargo, para além dos 70 anos, de ministros do STF, dos tribunais superiores e do TCU. Assim, a presente controvérsia jurídica diria respeito à validade material da condição imposta pelo constituinte derivado.

ADI 5316 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.5.2015. (ADI-5316)

(Informativo 786)

► EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 4

A Corte ressaltou que o controle judicial de emendas constitucionais colocaria em evidência a tensão latente que existiria entre soberania popular e Estado de Direito. De um lado, seria certo que as cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º), ao consubstanciarem limites materiais ao poder de reforma da Constituição, consagrariam um núcleo mínimo de identidade constitucional, a afastar da esfera de atuação dos agentes políticos determinados valores considerados mais elevados. Por outro lado, as cláusulas pétreas não deveriam ser interpretadas como se incorporassem um sufocamento absoluto das tentativas de o próprio povo brasileiro redesenhar as instituições do Estado na busca do seu contínuo aperfeiçoamento. A sutileza que se colocaria perante o STF seria, portanto, a de encontrar o ponto ótimo de equilíbrio entre a deferência em relação às decisões do constituinte derivado e a salvaguarda dos princípios e valores mais fundamentais do Estado Democrático de Direito. Nesse quadro, o controle de constitucionalidade das emendas deveria ser reservado às hipóteses de inequívoca violação ao núcleo das cláusulas pétreas, o que ocorreria no caso em análise. A CF/1988

teria conferido algum grau de densidade semântica ao postulado da separação dos Poderes, a afirmar serem-lhe atributos próprios a independência e a harmonia (CF, art. 2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”). Na situação dos autos, interessaria, em particular, a independência entre os Poderes. Embora fosse saudável que houvesse, em certa medida, influências recíprocas entre os Poderes da República, mecanismos de “checks and balances” não poderiam jamais comprometer a independência funcional de cada braço da autoridade do Estado. A harmonia a que alude o art. 2º da CF não poderia significar complicitade entre os Poderes, particularmente em relação do Poder Judiciário, cuja independência seria pressuposto indispensável à imparcialidade necessária a qualquer ato de julgamento. Não seria o caso, porém, de, com isso, interditar toda e qualquer iniciativa do legislador em reformar as instituições existentes, inclusive o Poder Judiciário. Não se poderia jamais transigir, no entanto, com a imparcialidade da função jurisdicional, cuja mitigação vulneraria o núcleo essencial da separação dos Poderes (CF, art. 60, § 4º, III). Na espécie, portanto, haveria verossimilhança nas alegações de que a nova sabatina, introduzida pela EC 88/2015, degradaria ou estreitaria a imparcialidade jurisdicional. Seria tormentoso imaginar que o exercício da jurisdição pudesse ser desempenhado com isenção quando o julgador, para permanecer no cargo, carecesse da confiança política do Poder Legislativo, cujos atos, seriam muitas vezes questionados perante aquele mesmo julgador. Por outro lado, estaria configurado o “periculum in mora”. No âmbito do TCU e dos tribunais da cúpula do Poder Judiciário, haveria ao menos 20 ministros em vias de se aposentar compulsoriamente nos próximos três anos. Considerando que a sabatina seria designada para período anterior àquele em que o agente público completasse os setenta anos de idade, seria de se imaginar que o preceito impugnado produziria efeitos no curto lapso de tempo, o que caracterizaria o perigo na demora.

ADI 5316 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.5.2015. (ADI-5316)

(Informativo 786)

► EC 88/2015 e aposentadoria compulsória – 5

O Plenário destacou que haveria uma segunda questão colocada na hipótese em exame, que se desdobraria em outras duas. De um lado, estaria em discussão o sentido da expressão “lei complementar” na nova redação do art. 40, §1º, II, da CF. No contexto específico da magistratura, restaria definir se a aludida lei complementar seria de caráter nacional ou de caráter estadual. No ponto, porém, e em relação à magistratura, não haveria dúvidas de que se trataria da lei complementar nacional, de iniciativa do STF, indicada no art. 93 da CF. De outro lado, seria debatida a validade, à luz da noção de unidade do Poder Judiciário, da regra transitória contida no artigo 100 do ADCT, que limitara a eficácia imediata da aposentadoria compulsória aos 75 anos apenas aos integrantes da cúpula do Poder Judiciário e do TCU. Nesse diapasão, constatar-se-ia que o princípio da igualdade não proibiria de modo absoluto as diferenciações de tratamento. Vedaria apenas distinções arbitrárias. Nesse sentido, a carreira da magistratura seria nacional. Independentemente da instância em que atuassem, os magistrados estariam submetidos a um mesmo regime jurídico, na medida em que integrantes de uma única carreira. Não obstante isso, seria constitucionalmente pos-

sível que houvesse distinções pontuais entre os cargos da magistratura, especialmente quanto às condições para o seu provimento e vacância. Assim, o ingresso no cargo de ministro de tribunal superior ou do TCU decorreria da aprovação em sabatina e seria exaurida em evidente processo político com notória peculiaridade. Igualmente, as funções desempenhadas pelos destinatários atingidos pelo art. 100 do ADCT seriam técnicas, mas de resplandecente repercussão política, social e econômica, o que legitimaria o estabelecimento de critérios distintos daqueles dispensados aos demais agentes públicos. Então, a referida distinção consubstanciaria fundamento razoável para a existência de regra de transição exclusiva para os magistrados do STF e tribunais superiores bem como para os membros do TCU sabatinados em relação à futura vacância do cargo oriunda da aposentadoria compulsória. O referido discrimen não alcançaria o cerne fundamental do regime jurídico da magistratura, mas apenas o momento a partir do qual haveria compulsoriedade da aposentadoria. Assim, a distinção de tratamento dispensada pelo art. 100 do ADCT seria legítima, materialmente constitucional e, por não ofensiva à isonomia, deveria ser observada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, caracterizado, portanto, o “*fumus boni iuris*”. O “*periculum in mora*” também estaria configurado na medida em que haveria o elevado risco de que magistrados não integrantes da cúpula do Poder Judiciário e do TCU obtivessem decisões liminares favoráveis que afastassem a regra veiculada pelo art. 40 § 1º, II, da CF, introduzida pela EC 88/2015. O afastamento da referida exigência, mediante uma vulgarização indevida alicerçada em errônea aplicação do princípio da isonomia e da unicidade da magistratura, poderia comprometer a legítima vontade do parlamento, que apenas teria reconhecido a eficácia imediata da majoração da idade da aposentadoria compulsória para um grupo muito específico de agentes públicos. Vencidos, em parte, os Ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio, que davam interpretação conforme à parte final do art. 100 do ADCT, introduzido pela EC 88/2015, para excluir enfoque que fosse conducente a concluir-se pela segunda sabatina, considerado o mesmo cargo em relação ao qual ocorrida a primeira sabatina. Vencido, ainda, o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia do pedido com conteúdo de ação declaratória de constitucionalidade, por entender incabível a cumulação de ações procedida por meio de aditamento à inicial, e, superada a questão, indeferia a concessão de cautelar, porquanto esta medida seria prevista pela Constituição unicamente quanto à ação direta de inconstitucionalidade. Não caberia, assim, a suspensão de processos em curso nas diversas instâncias do Judiciário, que deveriam tramitar, considerado o devido processo legal. O exame de ameaça ou lesão a direito pelo Poder Judiciário configura cláusula pétrea que não poderia ser afastado sequer por lei.

ADI 5316 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, 21.5.2015. (ADI-5316)

(Informativo 786)

► Norma estadual e princípio da simetria

Por reputar inexistir ofensa ao princípio da simetria, o Plenário julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a expressão “e ao Vice-Governador”, constante do art. 65 da Constituição do Estado do Mato Grosso (“Aplicam-se ao Governador e ao Vice-Governador, no que couber, as proibições e impedimentos estabelecidos para os Deputados Estaduais”). A Corte asse-

tou que a determinação de observância aos princípios constitucionais não significaria caber ao constituinte estadual apenas copiar as normas federais. A inexistência da vedação no plano federal não obstaculizaria o constituinte de o fazer com relação ao vice-governador. Asseverou que o estabelecimento de restrições a certas atividades ao vice-governador, visando a preservar a sua incolumidade política, seria matéria que o Estado-Membro poderia desenvolver no exercício da sua autonomia constitucional. Precedentes citados: ADI 4.298 MC/TO (DJe de 27.11.2009) e ADI 331/PB (DJe de 2.5.2014).

ADI 253/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, 28.5.2015. (ADI-253)

(Informativo 787)

► Sistema majoritário e fidelidade partidária – 1

A perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Essa a conclusão do Plenário, que julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar inconstitucional o termo “ou vice”, constante do art. 10, e a expressão “e, após 16 (dezesesseis) de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário”, constante do art. 13, ambos da Resolução 22.610/2007 do TSE [“Art. 10. Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que emplesse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias. ... Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se apenas às desfilições consumadas após 27 (vinte e sete) de março deste ano, quanto a mandatários eleitos pelo sistema proporcional, e, após 16 (dezesesseis) de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário”]. Ademais, conferiu interpretação conforme à Constituição ao termo “suplente”, constante do citado art. 10, com a finalidade de excluir do seu alcance os cargos do sistema majoritário. Preliminarmente, o Colegiado assentou o cabimento da ação direta. No ponto, assinalou que, embora a Resolução 22.610/2007 do TSE, já tivesse sido objeto de controle concentrado perante o STF [ADI 3.999/DF (DJe de 17.4.2009) e ADI 4.086/DF (DJe de 17.4.2009)], a Corte apenas se pronunciara sobre a constitucionalidade formal da norma. Além disso, a questão da legitimidade constitucional da perda de mandato nas hipóteses de cargos eletivos do sistema majoritário não teria sido suscitada anteriormente, e não houvera decisão a respeito, muito embora a causa de pedir, na hipótese, fosse aberta. No mérito, o Plenário comparou os sistemas eleitorais praticados no Brasil: majoritário e proporcional. O majoritário, utilizado para eleição de prefeito, governador, senador e do presidente da República, contemplaria o candidato que obtivesse o maior número de votos, e os demais demais candidatos seriam desconsiderados. O proporcional, por sua vez, adotado para eleição de vereador, deputado estadual e deputado federal, contemplaria os partidos políticos. O número de cadeiras que cada um deles teria na Casa Legislativa estaria relacionado à votação obtida na circunscrição. No sistema aqui adotado, de lista aberta, o eleitor escolheria um candidato da lista apresentada pelo partido, sem ordem predeterminada. A ordem de obtenção das cadeiras seria ditada pela votação que os candidatos, individualmente, obtivessem. Porém, o sucesso individual dependeria impreterivelmente da quantidade de votos recebida pelo

partido ao qual filiados (quociente partidário). Esse sistema apresentaria várias disfunções: o custo elevado de campanha, o fato de cerca de 7% dos candidatos, apenas, serem eleitos com votação própria, e a criação de disputa direta e personalista entre candidatos de um mesmo partido.

ADI 5081/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 27.5.2015. (ADI-5081)

(Informativo 787)

► Sistema majoritário e fidelidade partidária – 2

O Colegiado analisou que a Constituição atual optara por desenho institucional que fortalecesse os partidos políticos, inclusive mediante a criação do fundo partidário e da garantia do acesso gratuito ao rádio e à televisão (CF, art. 17, § 3º). Esse cenário, somado com a possibilidade de criação de coligações nas eleições proporcionais, permitiria que partidos sem densidade mínima para atingir o quociente eleitoral conseguissem representatividade. Assim, haveria multiplicidade de partidos, a destacar as chamadas “legendas de aluguel”, existentes somente para obter dinheiro do fundo partidário e acesso aos meios de comunicação. A política ficaria afastada do interesse público e se tornaria negócio privado. Nesse cenário, surgiria a tradição de infidelidade partidária, a culminar em posicionamento do STF sobre o tema [MS 26.602/DF (DJe de 17.10.2008), MS 26.603/DF (DJe de 19.12.2008) e MS 26.604/DF (DJe de 3.10.2008)]. A Corte, à época, chancelara entendimento no sentido do dever constitucional de observância da regra de fidelidade partidária, possuindo como pano de fundo o sistema proporcional. Posteriormente, o TSE editara a resolução ora em debate, para aduzir que a mesma linha de entendimento seria aplicável quanto ao sistema majoritário, aos fundamentos de centralidade dos partidos políticos no regime democrático e de os candidatos do sistema majoritário também se beneficiarem da estrutura partidária para se elegerem. O Plenário reputou, entretanto, que haveria fundamento constitucional consistente apenas para vincular a regra da fidelidade partidária ao sistema proporcional. Sucede que, no sistema majoritário, como a regra seria da maioria de votos e não do quociente eleitoral, o candidato eleito seria o mais bem votado. Portanto, não seria necessário impor a fidelidade partidária como medida para preservar a vontade do eleitor. Não se trataria de corolário natural do princípio da soberania popular (CF, artigos 1º, parágrafo único; e 14). Ao contrário, no sistema majoritário, a imposição da perda do mandato por infidelidade partidária seria antagônica à soberania popular. Nos pleitos dessa natureza, os eleitores votariam em candidatos e não em partidos (CF, art. 77, § 2º). Embora fosse relevante o papel dos partidos, não se poderia invocar seu fortalecimento como fundamento para violar a soberania popular, ao retirar mandatos de candidatos escolhidos legitimamente por votação majoritária. Em suma, a Resolução 22.610/2007 do TSE, ao igualar os sistemas proporcional e majoritário para fins de fidelidade partidária, violaria as características essenciais dos sistemas eleitorais, extrapolaria a jurisprudência da Corte sobre o tema e, sobretudo, violaria a soberania popular.

ADI 5081/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 27.5.2015. (ADI-5081)

(Informativo 787)

► Efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ação rescisória

A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Com base nessa orientação, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em que discutida a eficácia temporal de decisão transitada em julgado fundada em norma superveniente declarada inconstitucional pelo STF. À época do trânsito em julgado da sentença havia preceito normativo segundo o qual, nos casos relativos a eventuais diferenças nos saldos do FGTS, não caberiam honorários advocatícios. Dois anos mais tarde, o STF declarou a inconstitucionalidade da verba que vedava honorários. Por isso, o autor da ação voltara a requerer a fixação dos honorários. Examinava-se, assim, se a declaração de inconstitucionalidade posterior teria reflexos automáticos sobre a sentença anterior transitada em julgado. A Corte asseverou que não se poderia confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade — que retira do plano jurídico a norma com efeito “ex tunc” — com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. O efeito vinculante não nasceria da inconstitucionalidade, mas do julgado que assim a declarasse. Desse modo, o efeito vinculante seria “pro futuro”, isto é, da decisão do Supremo para frente, não atingindo os atos passados, sobretudo a coisa julgada. Apontou que, quanto ao passado, seria indispensável a ação rescisória. Destacou que, em algumas hipóteses, ao declarar a inconstitucionalidade de norma, o STF modularia os efeitos para não atingir os processos julgados, em nome da segurança jurídica.

RE 730462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 28.5.2015. (RE-730462)

(Informativo 787)

► Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão – 1

É inexistente o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes. Essa a conclusão do Plenário, que julgou procedente pedido formulado em ação direta para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21 do CC (“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”), sem redução de texto, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, de produção científica, de liberdade de infor-

mação e de proibição de censura (CF, artigos 5º, IV, V, IX, X e XIV; e 220). O Colegiado asseverou que, desde as Ordenações Filipinas, haveria normas a proteger a guarda de segredos. A partir do advento do CC/1916, entretanto, o quadro sofrera mudanças. Ademais, atualmente, o nível de exposição pública das pessoas seria exacerbado, de modo a ser inviável reter informações, a não ser que não fossem produzidas. Nesse diapasão, haveria de se compatibilizar a inviolabilidade da vida privada e a liberdade de pensamento e de sua expressão. No caso, não se poderia admitir, nos termos da Constituição, que o direito de outrem de se expressar, de pensar, de criar obras biográficas — que dizem respeito não apenas ao biografado, mas a toda a coletividade, pelo seu valor histórico — fosse tolhido pelo desejo do biografado de não ter a obra publicada. Os preceitos constitucionais em aparente conflito conjugar-se-iam em perfeita harmonia, de modo que o direito de criação de obras biográficas seria compatível com a inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem. Assim, em suma, o Plenário considerou: a) que a Constituição asseguraria como direitos fundamentais a liberdade de pensamento e de sua expressão, a liberdade de atividade intelectual, artística, literária, científica e cultural; b) que a Constituição garantiria o direito de acesso à informação e de pesquisa acadêmica, para o que a biografia seria fonte fecunda; c) que a Constituição proibiria a censura de qualquer natureza, não se podendo concebê-la de forma subliminar pelo Estado ou por particular sobre o direito de outrem; d) que a Constituição garantiria a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa; e e) que a legislação infraconstitucional não poderia amesquinhar ou restringir direitos fundamentais constitucionais, ainda que sob pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo condições ao exercício de liberdades de forma diversa da constitucionalmente fixada.

ADI 4815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 10.6.2015. (ADI-4815)

(Informativo 789)

► **Biografias: autorização prévia e liberdade de expressão – 2**

O Ministro Roberto Barroso ponderou que, embora os artigos 20 e 21 do CC produzissem legítima ponderação em favor dos direitos da personalidade e em desfavor da liberdade de expressão, esta deveria prevalecer, por algumas razões. Em primeiro lugar, o país teria histórico de graves episódios de censura, de modo que, para que não se repetissem, a liberdade de expressão deveria ser sempre reafirmada. Em segundo lugar, a liberdade de expressão não seria apenas um pressuposto democrático, mas também um pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais. Por último, a liberdade de expressão seria essencial para o conhecimento histórico, o avanço social e a conservação da memória nacional. Como consequências de se estabelecer a prevalência da liberdade de expressão, haveria o ônus argumentativo de aquele que pretendesse cerceá-la demonstrar o seu direito. Além disso, quaisquer manifestações de cerceamento de liberdade de expressão deveriam sofrer forte suspeição e escrutínio rigoroso. Por fim, seria vedada a censura prévia ou a licença. Apontou que, se a informação sobre determinado fato tivesse sido obtida por meios ilícitos, isso poderia comprometer a possibilidade de vir a ser divulgada legitimamente. Ademais, a mentira dolosa, com o intuito de fazer mal a alguém, poderia também ser fundamento para considerar-se ilegítima a divulgação de um fato, e que essas transgressões seriam

reparáveis por meio de indenização. De toda forma, qualquer intervenção jurisdicional haveria de processar-se sempre “a posteriori”. Assinalou que a liberdade de expressão não necessariamente significaria a prevalência da verdade ou da justiça, mas seria um valor em si relevante para as democracias. A Ministra Rosa Weber salientou a possibilidade de existirem várias versões sobre um mesmo fato histórico, de modo que controlar biografias significaria tentar controlar a história. O Ministro Luiz Fux lembrou que apenas pessoas notórias seriam biografadas, e que, na medida do crescimento da notoriedade, diminuir-se-ia a reserva de privacidade. O Ministro Dias Toffoli sublinhou que o autor de biografia não estaria impedido de requerer autorização para que sua obra fosse publicada, no intuito de evitar eventual controle jurisdicional. Entretanto, essa seria uma mera faculdade. O Ministro Gilmar Mendes ressaltou que a indenização não seria o único meio capaz de reparar eventual dano sofrido, tendo em vista a possibilidade de, por exemplo, exigir-se a publicação de nova obra, com correção, a funcionar como exercício do direito de resposta. O Ministro Marco Aurélio considerou que escrever biografia mediante autorização prévia não seria biografar, mas criar publicidade. A pessoa com visibilidade social geraria interesse por parte do cidadão comum, e caberia a terceiro revelar o respectivo perfil. O Ministro Celso de Mello frisou o pluralismo de pensamento como um dos fundamentos estruturantes do Estado de Direito, e a garantia do dissenso seria condição essencial à formação de opinião pública livre, em face do caráter contramajoritário dos direitos fundamentais. O Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) apontou a existência das publicações em meio digital, o que facilitaria a disseminação de conteúdo apócrifo e com alcance mundial. Portanto, a problemática seria complexa, e haveria de existir meios para coibir abusos dessa natureza.

ADI 4815/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 10.6.2015. (ADI-4815)

(Informativo 789)

► Concurso público e limite de idade

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição no certame. Com base nessa orientação e, em face da peculiaridade do caso, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Na espécie, candidato preenchia o requisito etário previsto no edital quando da inscrição para o certame. Ocorre que houvera atrasos no andamento do concurso, fazendo com que o candidato não mais preenchesse esse requisito. A Turma destacou a jurisprudência da Corte no sentido de que a regra quanto ao limite de idade, por ocasião da inscrição, se justificaria ante a impossibilidade de se antever a data em que seria realizada a fase final do concurso, caso fosse fixada como parâmetro para aferição do requisito etário. Os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber entenderam que a idade limite seria aquela da data da posse no cargo, porém, em razão do destaque dado pelo tribunal local quanto à demora e à desídia da Administração Pública para prosseguir no certame, acompanharam o relator.

ARE 840.592/CE, Min. Roberto Barroso, 23.6.2015. (ARE-840.592)

(Informativo 791)

► Constituição estadual e separação de poderes – 1

O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta e declarou a constitucionalidade do art. 77, XXIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (“XXIII – ressalvada a legislação federal aplicável, ao servidor público estadual é proibido substituir, sobre qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve”). O Colegiado asseverou, quanto à regularidade formal da norma, que o STF consolidara entendimento de que as regras básicas do processo legislativo presentes na CF/1988 incorporariam noções elementares do modelo de separação dos poderes, o que as torna de observância inafastável no âmbito local (CF, art. 25). As regras de iniciativa reservada, por demarcarem as competências privativas assinaladas a cada uma das instâncias políticas do País, estariam entre as disposições mais representativas da Federação, razão pela qual a jurisprudência da Corte assevera que à força normativa dessas regras corresponderia não apenas um encargo positivo a ser cumprido pelas assembleias legislativas, mas também uma eficácia negativa, que as impede de abordar temas de iniciativa de outras autoridades públicas. Em casos nos quais o STF rechaçara a existência de regras, em Constituição local, que deveriam constar de legislação ordinária, ficara consignado que esses conteúdos deveriam contar com a avaliação do Chefe do Executivo local, investido da conveniência e oportunidade de propor o debate a respeito de temas que estariam tipicamente submetidos à sua alçada política, como remuneração de cargos, regime jurídico de servidores, organização da administração local, entre outros. Permitir o tratamento dessa temática diretamente na Constituição estadual equivaleria, portanto, a esvaziar as competências do Chefe do Executivo.

ADI 232/RJ, rel. Min. Teori Zavascki, 5.8.2015. (ADI-232)

(Informativo 793)

► Constituição estadual e separação de poderes – 2

O Plenário afirmou que, contudo, isso não significaria que as assembleias constituintes estaduais seriam submetidas a uma completa interdição na disciplina das regras gerais de funcionamento da Administração local, devendo se ater à estrita reprodução do texto federal. Somente as normas de cunho substantivo deveriam ser necessariamente adotadas pelo Constituinte local. Assim, desde que: a) as linhas básicas que regem a relação entre os poderes federados (no que se incluem as regras de reserva de iniciativa) fossem respeitadas; e b) o parlamento local não suprimisse do governador a possibilidade de exercício de uma opção política legítima dentre aquelas contidas na sua faixa de competências típicas, a Constituição estadual poderia dispor de modo singular a respeito do funcionamento da Administração, sobretudo quando essa disciplina peculiar traduzisse a concretização de princípios também contemplados no texto federal. No caso, ressalvada a legislação federal aplicável, o texto impugnado proíbe que servidor público estadual seja designado para substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Embora o preceito esteja relacionado ao funcionamento da Administração local, ele não se sobrepusera ao campo de discricionariedade política que a Constituição Federal reserva, com exclusividade, à iniciativa do governador. Tampouco a regra dera à Administração local configuração definitiva em desacordo com o texto federal. A norma em exame não teria deficiência

formal. Seu conteúdo, basicamente expletivo, veda a substituição de trabalhadores grevistas por servidores públicos, a coibir a institucionalização do desvio de função como prática a frustrar o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. A Constituição local apenas textualizara um comportamento administrativo já condenável pela ordem constitucional federal. Este texto contém hipóteses de excepcionalidade, em que envolvidas necessidades inadiáveis da comunidade (CF, art. 9º, § 1º) que poderiam justificar o deslocamento de servidores para o exercício temporário de funções alheias aos correspondentes cargos. Presentes situações emergenciais, a Constituição Federal relativiza até mesmo a exigência de concurso público (CF, art. 37, IX). A norma adversada contempla uma ressalva de emergencialidade, tanto que remete à legislação federal a respeito de greve. O preceito não retira do governador uma alternativa viável de aproveitamento dos servidores a ele submetidos para o benefício da Administração. O que se proíbe é que a substituição dos grevistas viesse a ser implementada para servir a pretextos outros que não o da própria emergencialidade. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente), que julgavam procedente o pedido. Entendiam que o constituinte local antecipara-se ao disciplinar a matéria, de iniciativa do governador. O Ministro Marco Aurélio acrescia que a lei também padeceria de vício material, pois estaria indevidamente acrescida no texto constitucional local.

ADI 232/RJ, rel. Min. Teori Zavascki, 5.8.2015. (ADI-232)

(Informativo 793)

► **Emenda parlamentar e pertinência temática**

O Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da LC 376/2007 do Estado de Santa Catarina. Na espécie, em projeto de iniciativa do governador do referido Estado-Membro (CF, art. 61, § 1º, II, a), a assembleia legislativa aprovava emenda aditiva sem pertinência com a proposição inicial do chefe do Poder Executivo. Assim, a referida emenda aditiva — formalizada no curso da tramitação de projeto de lei complementar que visava a criação de funções comissionadas no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, Ciência e Tecnologia — impusera ao governador o reequilíbrio de servidores do Instituto de Previdência estadual. A Corte afirmou que a ausência de pertinência temática de emenda da Casa Legislativa a projeto de lei de iniciativa exclusiva do Executivo levaria a concluir-se pela sua inconstitucionalidade formal. Ademais, aplicar-se-ia ao caso o teor do Enunciado 685 da Súmula do STF, no sentido de ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propiciasse ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integrasse a carreira na qual anteriormente investido.

ADI 3926/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 5.8.2015. (ADI-3926)

(Informativo 793)

► **Modificação de decisão judicial pelo TCU e coisa julgada – 3**

Não atenta contra a coisa julgada o entendimento de que, em face de efetiva alteração do estado de direito superveniente, a sentença anterior, a partir de então, deixa

de ter eficácia. Assim, modificadas as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, via de regra, é imediata e automática, sem depender de novo pronunciamento judicial. Com base nessa orientação, a Segunda Turma, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a agravo regimental para denegar a segurança. Na espécie, o TCU determinara a supressão do percentual de 28,86% dos proventos da impetrante, servidora de universidade federal. Aduzira-se, na impetração, que aquela Corte de Contas, ao assim decidir, teria desrespeitado decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos de ação ordinária, no sentido de estender aos professores daquela universidade o mesmo índice de reajuste salarial (28,86%) anteriormente concedido aos militares pela Lei 8.622/1993 — v. Informativo 749. A Turma apontou que o ato atacado apenas emitira juízo sobre a eficácia temporal da decisão, tendo em vista que, com o advento da Medida Provisória 1.704/1998 e de leis posteriores reestruturadoras da carreira do magistério superior, houvera significativa mudança no estado de direito, não mais subsistindo o quadro fático-normativo que dera suporte à diferença de vencimentos reconhecida em ação judicial transitada em julgado. Asseverou que a coisa julgada atuaria “*rebus sic stantibus*” e, no caso, restringira-se a garantir o referido reajuste aos vencimentos dos professores, sem mencionar sua necessária incidência também para efeito de proventos de aposentadoria. A coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, sem significar que, para o cálculo dos proventos, essa proteção jurídica se estendesse desde logo. Nesse sentido, o cômputo seria feito caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto jurídico diverso: o instituto dos proventos. Vencido o Ministro Celso de Mello (relator), que negava provimento ao recurso de agravo. Observava que, após proferir seu voto no presente recurso, fizera consignar, em decisões supervenientes, as mesmas razões da tese ora vencedora, porém, mantinha seu voto original nos presentes autos. Precedentes citados: RE 596.663/RJ (DJe de 26.11.2014); MS 26.980 AgR/DF (DJe de 8.5.2014); MS 32.416/DF (DJe de 19.12.2013); MS 30.725/DF (DJe de 22.12.2011).

MS 32435 AgR/DF, rel. orig. Min. Celso de Mello, red. p/ o acórdão, Min. Teori Zavascki, 4.8.2015. (MS-32435)

(Informativo 793)

► **Obras emergenciais em presídios: reserva do possível e separação de poderes – 1**

É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. Essa a conclusão do Plenário, que proveu recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo estadual obrigação de fazer consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, a fim de garantir a observância dos direitos fundamentais dos presos. O Colegiado assentou tratar-se, na espécie, de estabelecimento

prisonal cujas condições estruturais seriam efetivamente atentatórias à integridade física e moral dos detentos. Pontuou que a pena deveria ter caráter de ressocialização, e que impor ao condenado condições sub-humanas atentaria contra esse objetivo. Entretanto, o panorama nacional indicaria que o sistema carcerário como um todo estaria em quadro de total falência, tendo em vista a grande precariedade das instalações, bem assim episódios recorrentes de sevícias, torturas, execuções sumárias, revoltas, superlotação, condições precárias de higiene, entre outros problemas crônicos. Esse evidente caos institucional comprometeria a efetividade do sistema como instrumento de reabilitação social. Além disso, a questão afetaria também estabelecimentos destinados à internação de menores. O quadro revelaria desrespeito total ao postulado da dignidade da pessoa humana, em que haveria um processo de “coisificação” de presos, a indicar retrocesso relativamente à lógica jurídica atual. A sujeição de presos a penas a ultrapassar mera privação de liberdade prevista na lei e na sentença seria um ato ilegal do Estado, e retiraria da sanção qualquer potencial de ressocialização. A temática envolveria a violação de normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais. Dessa forma, caberia ao Judiciário intervir para que o conteúdo do sistema constitucional fosse assegurado a qualquer jurisdicionado, de acordo com o postulado da inafastabilidade da jurisdição. Os juízes seriam assegurados do poder geral de cautela mediante o qual lhes seria permitido conceder medidas atípicas, sempre que se mostrassem necessárias para assegurar a efetividade do direito buscado. No caso, os direitos fundamentais em discussão não seriam normas meramente programáticas, sequer se trataria de hipótese em que o Judiciário estaria ingressando indevidamente em campo reservado à Administração. Não haveria falar em indevida implementação de políticas públicas na seara carcerária, à luz da separação dos poderes. Ressaltou que não seria dado ao Judiciário intervir, de ofício, em todas as situações em que direitos fundamentais fossem ameaçados. Outrossim, não caberia ao magistrado agir sem que fosse provocado, transmutando-se em administrador público. O juiz só poderia intervir nas situações em que se evidenciasse um “não fazer” comissivo ou omissivo por parte das autoridades estatais que colocasse em risco, de maneira grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados.

RE 592581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13.8.2015. (RE-592581)

(Informativo 794)

► **Obras emergenciais em presídios: reserva do possível e separação de poderes – 2**

O Ministro Edson Fachin ponderou que a cláusula da reserva do possível somente seria oponível se objetivamente verificado o justo motivo que tivesse sido suscitado pelo poder público para não realizar o mandamento constitucional. Seria preciso ponderar que o magistrado não deveria substituir o gestor público, mas poderia compeli-lo a cumprir o programa constitucional vinculante, mormente quando se tratasse de preservar a dignidade da pessoa humana. O Ministro Roberto Barroso aduziu que a judicialização não substituiria a política, mas haveria exceções, como no caso, em que se trataria de proteger os direitos de uma minoria sem direitos políticos, sem capacidade de vocalizar as próprias pretensões. Além disso, se cuidaria de um problema historicamente crônico de omissão do Executivo, e se o Estado se arrogasse do poder de privar essas pessoas de liberdade, deveria exercer o dever de proteção dessas pessoas. O Ministro Luiz Fux reforçou a ideia

de que a intervenção judicial seria legítima se relacionada a obras de caráter emergencial, para proteger a integridade física e psíquica do preso. A Ministra Cármen Lúcia lembrou que determinadas políticas, como de melhoria do sistema penitenciário, seriam impopulares com o eleitorado, mas isso não justificaria o descumprimento reiterado de um mandamento constitucional. Ademais, não caberia falar em falta de recursos, tendo em vista a criação do Fundo Penitenciário, para suprir essa demanda específica. O Ministro Gilmar Mendes salientou que a questão não envolveria apenas direitos humanos, mas segurança pública. Presídios com condições adequadas permitiriam melhor policiamento, melhor monitoramento e dificultariam o crescimento de organizações criminosas nesses locais. Frisou que a lei contemplaria hipótese de o juiz da execução poder interditar estabelecimento penal que funcionasse em condições inadequadas ou ilegais, bem assim que caberia às corregedorias e ao Ministério Público zelar pelo correto funcionamento desses estabelecimentos. O Ministro Celso de Mello afirmou que a hipótese seria de excesso de execução — em que o Estado imporia ao condenado pena mais gravosa do que a prevista em lei —, portanto de comportamento estatal ao arrepio da lei.

RE 592581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 13.8.2015. (RE-592581)

(Informativo 794)

► **Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 6**

O Plenário concluiu o julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental em que discutida a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Nessa mesma ação também se debate a adoção de providências estruturais com objetivo de sanar as lesões a preceitos fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações e omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal. No caso, alegava-se estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, “estado de coisas inconstitucional”, diante da seguinte situação: violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades. Postulava-se o deferimento de liminar para que fosse determinado aos juízes e tribunais: a) que lançassem, em casos de decretação ou manutenção de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não se aplicam medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no art. 319 do CPP; b) que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Cívicos e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizassem, em até 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas do momento da prisão; c) que considerassem, fundamentadamente, o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de implemento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal; d) que estabelecessem, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo; e) que viessem a abrandar os requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando revela-

das as condições de cumprimento da pena mais severas do que as previstas na ordem jurídica em razão do quadro do sistema carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção; e f) que se abatesse da pena o tempo de prisão, se constatado que as condições de efetivo cumprimento são significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal. Requeria-se, finalmente, que fosse determinado: g) ao CNJ que coordenasse mutirão carcerário a fim de revisar todos os processos de execução penal, em curso no País, que envolvessem a aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às medidas pleiteadas nas alíneas “e” e “f”; e h) à União que liberasse as verbas do Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos — v. Informativos 796 e 797.

ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF-347)

(Informativo 798)

► **Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 6**

O Plenário concluiu o julgamento de medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental em que discutida a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro. Nessa mesma ação também se debate a adoção de providências estruturais com objetivo de sanar as lesões a preceitos fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações e omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal. No caso, alegava-se estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, “estado de coisas inconstitucional”, diante da seguinte situação: violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades. Postulava-se o deferimento de liminar para que fosse determinado aos juízes e tribunais: a) que lançassem, em casos de decretação ou manutenção de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não se aplicam medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no art. 319 do CPP; b) que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Cívicos e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizassem, em até 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas do momento da prisão; c) que considerassem, fundamentadamente, o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de implemento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal; d) que estabelecessem, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo; e) que viessem a abrandar os requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as condições de cumprimento da pena mais severas do que as previstas na ordem jurídica em razão do quadro do sistema carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção; e f) que se abatesse da pena o tempo de prisão, se constatado

que as condições de efetivo cumprimento são significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal. Requeria-se, finalmente, que fosse determinado: g) ao CNJ que coordenasse mutirão carcerário a fim de revisar todos os processos de execução penal, em curso no País, que envolvessem a aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às medidas pleiteadas nas alíneas “e” e “f”; e h) à União que liberasse as verbas do Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos — v. Informativos 796 e 797.

ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF-347)

(Informativo 798)

► **Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 7**

O Colegiado deliberou, por decisão majoritária, deferir a medida cautelar em relação ao item “b”. A Ministra Rosa Weber acompanhou essa orientação, com a ressalva de que fossem observados os prazos fixados pelo CNJ. Vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso e Teori Zavascki, que delegavam ao CNJ a regulamentação sobre o prazo para se realizar as audiências de custódia. O Tribunal decidiu, também por maioria, deferir a cautelar no tocante à alínea “h”. Vencidos, em parte, os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, que fixavam o prazo de até 60 dias, a contar da publicação da decisão, para que a União procedesse à adequação para o cumprimento do que determinado. O Plenário, também por maioria, indeferiu a medida cautelar em relação às alíneas “a”, “c” e “d”. Vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski (Presidente), que a deferiam nessa parte. De igual modo indeferiu, por decisão majoritária, a medida acatadora em relação à alínea “e”. Vencido o Ministro Gilmar Mendes. O Tribunal, ademais, rejeitou o pedido no tocante ao item “f”. Por fim, no que se refere à alínea “g”, o Plenário, por maioria, julgou o pleito prejudicado. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que deferiam a cautelar no ponto. Por fim, o Colegiado, por maioria, acolheu proposta formulada pelo Ministro Roberto Barroso, no sentido de que se determine à União e aos Estados-Membros, especificamente ao Estado de São Paulo, que encaminhem à Corte informações sobre a situação prisional. Vencidos, quanto à proposta, os Ministros relator, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Presidente.

ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF-347)

(Informativo 798)

► **Sistema carcerário: estado de coisas inconstitucional e violação a direito fundamental – 8**

O Plenário anotou que no sistema prisional brasileiro ocorreria violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica. As penas privativas de liberdade aplicadas nos presídios converter-se-iam em penas cruéis e desumanas. Nesse contexto, diversos dispositivos constitucionais (artigos 1º, III, 5º, III, XLVII, e, XLVIII, XLIX, LXXIV, e 6º), normas internacionais reconhe-

cedoras dos direitos dos presos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos Humanos) e normas infraconstitucionais como a LEP e a LC 79/1994, que criara o Funpen, teriam sido transgredidas. Em relação ao Funpen, os recursos estariam sendo contingenciados pela União, o que impediria a formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuiria para o agravamento do quadro. Destacou que a forte violação dos direitos fundamentais dos presos repercutiria além das respectivas situações subjetivas e produziria mais violência contra a própria sociedade. Os cárceres brasileiros, além de não servirem à ressocialização dos presos, fomentariam o aumento da criminalidade, pois transformariam pequenos delinquentes em “monstros do crime”. A prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública estaria nas altas taxas de reincidência. E o reincidente passaria a cometer crimes ainda mais graves. Consignou que a situação seria assustadora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de direitos humanos; fora deles, aumento da criminalidade e da insegurança social. Registrou que a responsabilidade por essa situação não poderia ser atribuída a um único e exclusivo poder, mas aos três — Legislativo, Executivo e Judiciário —, e não só os da União, como também os dos Estados-Membros e do Distrito Federal. Ponderou que haveria problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal. Além disso, faltaria coordenação institucional. A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representaria falha estrutural a gerar tanto a ofensa reiterada dos direitos, quanto a perpetuação e o agravamento da situação. O Poder Judiciário também seria responsável, já que aproximadamente 41% dos presos estariam sob custódia provisória e pesquisas demonstrariam que, quando julgados, a maioria alcançaria a absolvição ou a condenação a penas alternativas. Ademais, a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena fixado evidenciaria a inadequada assistência judiciária. A violação de direitos fundamentais alcançaria a transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial e justificaria a atuação mais assertiva do STF. Assim, caberia à Corte o papel de retirar os demais poderes da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. A intervenção judicial seria reclamada ante a incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas. Todavia, não se autorizaria o STF a substituir-se ao Legislativo e ao Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deveria superar bloqueios políticos e institucionais sem afastar esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deveria agir em diálogo com os outros poderes e com a sociedade. Não lhe incumbiria, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Em vez de desprezar as capacidades institucionais dos outros poderes, deveria coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e deficiência estatal permanente. Não se trataria de substituição aos demais poderes, e sim de oferecimento de incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o estabelecimento das minúcias para se alcançar o equilíbrio entre respostas efetivas às violações de direitos e as limitações institucionais reveladas. O Tribunal, no que se refere às alíneas “a”, “c” e “d”, ponderou se tratar de pedidos que traduziriam mandamentos legais já impostos aos juízes. As medidas poderiam ser positivas como reforço ou incentivo, mas, no caso da alínea “a”, por exemplo, a inserção desse ca-

pítulo nas decisões representaria medida genérica e não necessariamente capaz de permitir a análise do caso concreto. Como resultado, aumentaria o número de reclamações dirigidas ao STF. Seria mais recomendável atuar na formação do magistrado, para reduzir a cultura do encarceramento. No tocante à cautelar de ofício proposta pelo Ministro Roberto Barroso, o Colegiado frisou que o Estado de São Paulo, apesar de conter o maior número de presos atualmente, não teria fornecido informações a respeito da situação carcerária na unidade federada. De toda forma, seria imprescindível um panorama nacional sobre o assunto, para que a Corte tivesse elementos para construir uma solução para o problema.

ADPF 347 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF-347)

(Informativo 798)

► ADI e financiamento de campanha eleitoral – 18

São inconstitucionais as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. No que se refere às contribuições de pessoas físicas, regulam-se de acordo com a lei em vigor. Esse o entendimento do Plenário, que, em conclusão de julgamento e por maioria, acolheu, em parte, pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 23, §1º, I e II; 24; e 81, “caput” e § 1º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), que tratam de doações a campanhas eleitorais por pessoas físicas e jurídicas, no ponto em que cuidam de doações por pessoas jurídicas. Declarou, ainda, a inconstitucionalidade dos artigos 31; 38, III; 39, “caput” e § 5º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que regulam a forma e os limites em que serão efetivadas as doações aos partidos políticos, também exclusivamente no que diz respeito às doações feitas por pessoas jurídicas — v. Informativos 732 e 741. O Colegiado reputou que o modelo de autorização de doações em campanhas eleitorais por pessoa jurídica não se mostraria adequado ao regime democrático em geral e à cidadania, em particular. Ressalvou que o exercício de cidadania, em sentido estrito, pressuporia três modalidades de atuação física: o “jus sufragius”, que seria o direito de votar; o “jus honorum”, que seria o direito de ser votado; e o direito de influir na formação da vontade política por meio de instrumentos de democracia direta como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Destacou que essas modalidades seriam inerentes às pessoas naturais e, por isso, o desarrazoado de sua extensão às pessoas jurídicas. A participação de pessoas jurídicas apenas encareceria o processo eleitoral sem oferecer, como contrapartida, a melhora e o aperfeiçoamento do debate. O aumento dos custos de campanhas não corresponderia ao aprimoramento do processo político, com a pretendida veiculação de ideias e de projetos pelos candidatos. Ao contrário, os candidatos que tivessem despendido maiores recursos em suas campanhas possuiriam maior êxito nas eleições. Ademais, a exclusão das doações por pessoas jurídicas não teria efeito adverso sobre a arrecadação dos fundos por parte dos candidatos aos cargos políticos. Todos os partidos políticos teriam acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral gratuita nos veículos de comunicação, a proporcionar aos candidatos e as suas legendas, meios suficientes para promover suas campanhas. O princípio da liberdade de expressão, no aspecto político, teria como finalidade estimular a ampliação do debate público, a permitir que os indivíduos conhecessem diferentes plataformas e projetos políticos. A excessiva participação

do poder econômico no processo político desequilibraria a competição eleitoral, a igualdade política entre candidatos, de modo a repercutir na formação do quadro representativo. Assim, em um ambiente cujo êxito dependesse mais dos recursos despendidos em campanhas do que das plataformas políticas, seria de se presumir que considerável parcela da população ficasse desestimulada a disputar os pleitos eleitorais.

ADI 4650/DF, rel. Min. Luiz Fux, 16 e 17.9.2015. (ADI-4650)

(Informativo 799)

► ADI e financiamento de campanha eleitoral – 19

O Tribunal, com relação aos mecanismos de controle dos financiamentos de campanha, rechaçou a afirmação no sentido de que a discussão acerca da doação por pessoa jurídica deveria se restringir aos instrumentos de fiscalização. Defender que a questão da doação por pessoa jurídica se restrinja aos mecanismos de controle e transparência dos gastos seria insuficiente para amainar o cenário em que o poder político mostrar-se-ia atraído pelo poder econômico. A possibilidade de que as empresas continuassem a investir elevadas quantias — não contabilizadas (caixa dois) — nas campanhas eleitorais não constituiria empecilho para que o STF declarasse ser disfuncional o corrente modelo. Assinalou a inconstitucionalidade dos critérios de doação a campanhas por pessoas jurídicas, sob o enfoque da isonomia entre elas, haja vista que o art. 24 da Lei das Eleições não estende essa faculdade a toda espécie de pessoa jurídica. O aludido preceito estabelece rol de entidades que não poderiam realizar doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro a candidatos ou a partidos políticos, a exemplo das associações de classe e sindicais, bem como entidades integrantes do terceiro setor. Como resultado desse impedimento, as empresas privadas — cuja maioria se destina à atividade lucrativa — seriam as protagonistas em doações entre as pessoas jurídicas, em detrimento das entidades sem fins lucrativos e dos sindicatos, a desaguar em ausência de equiparação entre elas. Vencidos os Ministros Teori Zavascki, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que julgavam parcialmente procedente o pleito, para dar interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas e vedar as seguintes formas de contribuição a partidos políticos e a campanhas eleitorais: a) de pessoas jurídicas ou de suas controladas e coligadas que mantivessem contratos onerosos celebrados com a Administração Pública, independente de sua forma e objeto; b) de pessoas jurídicas a partidos (ou seus candidatos) diferentes, que competem entre eles. De igual forma, proibiam que pessoas jurídicas que tivessem efetuado contribuições a partidos ou campanhas, desde então e até o término da gestão subsequente, celebrassem qualquer contrato oneroso com entidades da Administração. Por fim, o Colegiado deliberou não modular os efeitos da decisão, tendo em vista não haver sido atingido o número necessário de votos para tanto. Assim, a decisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2016, inclusive, independentemente da publicação do acórdão.

ADI 4650/DF, rel. Min. Luiz Fux, 16 e 17.9.2015. (ADI-4650)

(Informativo 799)

► **Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 1**

O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 12.875/2013, que, ao promoverem alterações nas Leis 9.096/1995 e 9.504/1997, restringem, aos novos partidos políticos, criados após a realização das eleições para a Câmara dos Deputados, qualquer acesso aos recursos do Fundo Partidário, bem como qualquer tempo destinado a propaganda eleitoral. De início, o Colegiado destacou que as disposições ora impugnadas decorreriam de superação legislativa da interpretação conferida pelo STF ao art. 47, § 2º, II, da Lei 9.504/1997 (ADI 4.430/DF, DJe de 19.9.2013 e ADI 4.795/DF, DJe de 30.10.2013). Na oportunidade, o Tribunal dera interpretação conforme ao preceito questionado, para salvaguardar aos partidos novos, criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos dois terços do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Poucos meses após o julgamento dos casos supracitados, o Congresso editara a Lei 12.875/2013 que, em sentido oposto ao pronunciamento da Corte, subtraía dessas novas legendas o acesso aos recursos do Fundo e ao direito de antena. Caberia perquirir, portanto, quais os limites de reações legislativas a decisões proferidas pelo STF, tendo em vista o impacto na esfera de liberdade de conformação do legislador. Nesse sentido, o Tribunal daria a última palavra no que se refere à interpretação da Constituição, imune a qualquer controle democrático. Não se ignoraria, entretanto, a legitimidade, em algumas hipóteses, do ativismo congressional, ou seja, de reversão legislativa a decisões da Corte, desde que observadas algumas balizas constitucionais. Nesses casos, o Legislativo buscaria reverter situações de autoritarismo judicial ou de comportamento antidialógico, incompatível com a separação de poderes. Ao legislador seria, assim, franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF. Seria possível extrair as seguintes conclusões a respeito do tema: a) o Tribunal não subtrai “ex ante” a faculdade de correção legislativa pelo constituinte reformador ou pelo legislador ordinário; b) no caso de reversão jurisprudencial via emenda constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas hipóteses estritas de ultraje aos limites do art. 60 da CF; e c) no caso de reversão jurisprudencial por lei ordinária, excetuadas as situações de ofensa evidente ao texto constitucional, a Corte tem adotado comportamento de autorrestrição e de maior deferência às opções políticas do legislador.

ADI 5105/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1º.10.2015. (ADI-5105)

(Informativo 801)

► **Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 2**

O Tribunal assinalou que seria prudente não se atribuir a qualquer órgão, fosse do Judiciário, fosse do Legislativo, a faculdade de pronunciar, em solução de definitividade, a última palavra sobre o sentido da Constituição. O próprio texto constitucional desafiaria esse entendimento. Em primeiro lugar, os efeitos vinculantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato não atingem o Legislativo (CF, artigos 102, § 2º; e 103-A), de modo a ser perfeitamente possível a edição de emendas constitucionais

ou leis ordinárias acerca do assunto objeto de pronunciamento judicial. Em segundo lugar, o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), impõe que o STF, mesmo nas hipóteses de correção legislativa de sua jurisprudência, enfrente a controvérsia à luz dos novos argumentos expendidos pelo legislador para reverter o precedente. Além disso, desconsiderar que as demais instituições sejam intérpretes autorizados da Constituição poderia propiciar certa acomodação ou desinteresse nos demais atores em interpretar o texto constitucional. Ademais, a perspectiva juriscêntrica de hermenêutica constitucional também estimula comportamentos irresponsáveis na conformação da Constituição pelo legislador. Assim, o STF deveria proceder como catalisador deliberativo, promovendo a interação e o diálogo institucional, de modo a maximizar a qualidade democrática na obtenção dos melhores resultados em termos de apreensão do significado constitucional. Portanto, o legislador poderia, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar a jurisprudência, reclamando posturas distintas da Corte. Se veiculada por emenda, altera-se o próprio parâmetro amparador da jurisprudência. Nessas situações, a invalidade da emenda somente poderá ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CF. Se, porém, introduzida por legislação ordinária, a norma que frontalmente colidir com a jurisprudência do Tribunal nasce com presunção de inconstitucionalidade, de sorte que caberia ao legislador o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente se afigura legítima, e que o posicionamento jurisprudencial deve ser superado, tendo em conta novas premissas fáticas e jurídicas. Assim, a novel legislação que frontalmente colidisse com a jurisprudência se submeteria a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso.

ADI 5105/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1º.10.2015. (ADI-5105)

(Informativo 801)

► **Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressional – 3**

O Colegiado apontou que, no caso em debate, a análise da justificação do projeto de lei que desaguara na norma supracitada revelaria a inaptidão dos fundamentos ali expendidos para legitimar a reversão da interpretação fixada pelo STF na matéria. Os fundamentos seriam: a) as migrações que ocorrem durante a legislatura vulneram a previsibilidade institucional na distribuição dos recursos dos fundos partidários e do horário de propaganda; b) essas alterações geram um cenário de insegurança jurídica; c) a medida legislativa visa a valorizar os partidos políticos, de modo a evitar disfunções no sistema partidário; d) perenidade do partido enquanto instrumento do pluralismo político; e e) o art. 17, § 3º, da CF seria observado com a distribuição equitativa dos 5% dos recursos do Fundo Partidário e do 1/3 do horário de propaganda eleitoral. Não haveria, no projeto, enfrentamento aos fundamentos das ações diretas de inconstitucionalidade referidas, e os argumentos não seriam capazes de infirmar a tese então exarada pela Corte. Na oportunidade, o Plenário asseverara que o art. 17 da CF, que consagra o direito político fundamental da liberdade de criação de partidos, tutela, igualmente, as agremiações que tenham representação no Congresso, sendo irrelevante perquirir se essa representatividade resulta da criação de nova legenda no curso da legislatura. Além disso, também ficara consignado que erigir a cria-

ção de novos partidos como hipótese caracterizadora de justa causa para as migrações partidárias, somada ao direito constitucional de livre criação de novas legendas, impõe a conclusão inescapável de que é defeso privar as prerrogativas inerentes à representatividade política do parlamentar. Por sua vez, a justificação do projeto de lei se limitara a afirmar, genericamente, que a regulamentação da matéria, excluindo dos partidos criados o direito de antena e o Fundo Partidário, fortaleceria as agremiações, sem enfrentar os fundamentos das ações diretas. Portanto, a inconstitucionalidade das normas em questão se agrava, porquanto a decisão do STF fora ancorada em sólida construção argumentativa calcada em cláusulas pétreas. Em tese, a nova legislação que afrontasse decisões do Tribunal nasceria com presunção relativa de inconstitucionalidade, mas, na espécie, a inconstitucionalidade da lei seria evidente.

ADI 5105/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1º.10.2015. (ADI-5105)

(Informativo 801)

► **Partidos políticos: direito de antena, acesso ao Fundo Partidário e ativismo congressual – 4**

O Plenário reputou, também, que as normas em debate seriam inconstitucionais por afrontarem as condições de funcionamento das instituições democráticas. A restrição imposta pela nova lei às novas legendas justificaria a intervenção do STF, pois se cuidaria de tentativa de inviabilizar os canais de acesso e de participação daqueles que estão fora do jogo democrático. Seria dever da Corte otimizar e aperfeiçoar o processo democrático, de sorte a: a) corrigir as patologias que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de expressão e os canais de participação política; e b) proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas dificilmente encontram eco nas deliberações majoritárias. A discussão acerca dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do horário de propaganda eleitoral encerram importantes ferramentas de viabilização e desenvolvimento dessa engenharia democrática, impactando decisivamente no pleito eleitoral. Com a imposição de severas limitações ao Fundo Partidário e ao direito de antena, as novas agremiações seriam aliadas do processo político. Por esses motivos, a reação jurisprudencial materializada na Lei 12.875/2013, ao subtrair dos partidos novos, criados no curso da legislatura, o direito de antena e o acesso a recursos do Fundo Partidário remanesceria eivada de inconstitucionalidade, na medida em que, além de o legislador não ter logrado trazer novos e consistentes fundamentos para infirmar o pronunciamento da Corte, o diploma inviabiliza, no curto prazo, o funcionamento e o desenvolvimento de minorias político-partidárias, em ofensa aos postulados do pluralismo político e da liberdade partidária (CF, art. 17, § 3º). Vencidos os Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski (Presidente), que julgavam o pedido improcedente.

ADI 5105/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1º.10.2015. (ADI-5105)

(Informativo 801)

► **Medida provisória: emenda parlamentar e "contrabando legislativo" - 1**

É incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medida provisória submetida a sua apreciação. Essa a conclusão do Plenário — com efeitos “ex nunc” e imediata identificação do Poder Legislativo — que, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face do art. 76 da Lei 12.249/2010, inserido mediante emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei, a versar sobre objeto distinto daquele originalmente veiculado no texto apresentado à conversão. O dispositivo impugnado regula o exercício e a fiscalização da profissão contábil, ao passo que a Medida Provisória 472/2009, convertida na lei em comento, contemplava, originalmente, matérias educacionais, fiscais, tributárias e outras. O Colegiado assinalou que as regras formais do processo legislativo seriam construídas mediante escolhas fundamentais da comunidade nos momentos constituintes, de modo a canalizar os futuros julgamentos políticos e tomadas de decisão. Equacionou que a questão constitucional em foco daria respeito a dois aspectos relevantes: a) necessidade de lei específica para restringir o exercício de profissão; e b) possibilidade de, em processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, ser apresentada emenda parlamentar com conteúdo temático distinto daquele objeto da medida provisória. No que se refere à suposta exigência de lei específica (CF, art. 5º, XIII), o texto constitucional seria claro ao estabelecer o direito fundamental ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, trazendo a possibilidade de que lei estabeleça qualificações e exigências para o exercício desse direito fundamental. Assim, a liberdade profissional, em que pese seja direito individual de liberdade, impondo ao Estado um dever, em princípio, de abstenção, não fora outorgada sem limites. Não obstante, qualquer limitação legal somente poderia fixar exigências e limitações que guardassem nexo lógico com as funções e atividades a serem desempenhadas, sob pena de vício de inconstitucionalidade por violação ao princípio da igualdade. Destacou que essa restrição ao direito fundamental ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão consistiria em restrição legal qualificada. Nesse sentido, a Constituição não se limitaria a exigir que eventual restrição ao âmbito de proteção de determinado direito fosse apenas prevista em lei, mas também estabeleceria as condições especiais, os fins a serem perseguidos pela limitação. No caso, a reserva legal qualificada fora satisfeita pela Lei 12.249/2010, tendo em vista que a matéria de seu art. 76 tem por finalidade não a mera restrição ao direito fundamental de livre exercício da profissão de contador, mas a imposição de qualificações para que o exercício desse direito, no âmbito da profissão contábil, seja mais adequadamente realizado. A necessidade de lei formal para o estabelecimento de qualificações para o exercício profissional deveria, portanto, observar as regras de competência legislativa e não poderia impedir o exercício da profissão. Ao contrário, deveria antes servir para assegurar à sociedade que determinados profissionais, em especial os liberais, fossem efetiva e adequadamente qualificados para exercer uma específica atividade. No ponto, a Lei 12.249/2010 estabelece, em seu art. 76, a exigência de determinadas qualificações a serem cumpridas para o regular exercício da profissão de contador. Inova ao fixar essas exigências e ainda estabelece uma regra de transição àqueles que exerçam o ofício de técnicos em contabilidade. O Tribunal assentou que estariam cumpridos os requisitos formais e materiais impostos constitucionalmente. Destacou, por outro lado, que o processo legislativo de conversão de medida provisória, não obstante ser peculiar e de tramitação mais célere, consistiria

em espécie constitucionalmente prevista, sem restrição quanto à matéria versada na lei impugnada. Assim, não implicaria inconstitucionalidade o simples fato de a lei haver resultado de projeto de conversão de medida provisória.

ADI 5127/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 15.10.2015. (ADI-5127)

(Informativo 803)

► **Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo” - 2**

O Plenário, no que concerne à possibilidade de, em processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, ser apresentada emenda parlamentar com conteúdo temático distinto daquele objeto da medida provisória, consignou que esta seria espécie normativa primária, de caráter excepcional, sujeita a condição resolutiva e de competência exclusiva do Presidente da República (CF, artigos 59, V; e 62, § 3º). Como espécie normativa de competência exclusiva do Presidente da República e excepcional, não seria possível tratar de temas diversos daqueles fixados como relevantes e urgentes. Uma vez estabelecido o tema relevante e urgente, toda e qualquer emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei se limitaria e circunscreveria ao tema definido como urgente e relevante. Assim, seria possível emenda parlamentar ao projeto de conversão, desde que observada a devida pertinência lógico-temática. De outro lado, editada a medida provisória, competiria ao Legislativo realizar o seu controle. Esse controle seria político e jurídico, pois daria respeito à urgência e relevância exigidas constitucionalmente. O Colegiado frisou que o uso hipertrofiado da medida provisória, instrumento excepcional, deturparia o processo legislativo, gerando distorções ilegítimas. Nessa quadra, a prática das emendas parlamentares no processo de conversão de medida provisória em lei com conteúdo temático distinto apresentaria fortes complexidades democráticas. O Legislativo, no procedimento de conversão, poderia aprovar emendas aditivas, modificativas ou supressivas. Por outro lado, o fato de a Constituição não ter expressamente disposto no art. 62 a impossibilidade de se transbordar a temática da medida provisória não significaria que o exercício da faculdade de emendar pelo Congresso fosse incondicionado.

ADI 5127/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 15.10.2015. (ADI-5127)

(Informativo 803)

► **Medida provisória: emenda parlamentar e “contrabando legislativo” - 3**

O Tribunal reputou que, quando uma medida provisória, ao ser convertida em lei, passa a tratar de diversos temas inicialmente não previstos, o seu papel de regulação da vida comum estaria enfraquecido do ponto de vista da legitimidade democrática. Com essa prática, se geraria insegurança. Um processo legislativo democrático, público e transparente deveria primar por uma uniformidade temática que o tornasse sempre mais acessível, pelos outros poderes e pelo povo. Esse entendimento não significaria fortalecimento do Executivo, tendo em vista a importante função de controle do Legislativo no que diz respeito aos pressupostos autorizadores de medida provisória. Ademais, também não implicaria, necessariamente, o reconhecimento da

inconstitucionalidade de todas as leis de conversão promulgadas até o presente julgamento, inclusive a lei objeto desta ação. Isso se daria por duas razões: em primeiro lugar, seria a primeira oportunidade de a Corte enfrentar o tema, e compreensão diversa subtrairia a possibilidade de diálogo entre os diversos ramos do Estado sobre a matéria. Em segundo lugar, essa prática alusiva à conversão de medidas provisórias estaria arraigada, a resultar em diversas normas produzidas de acordo com o procedimento. Assim, a decisão da Corte não poderia provocar insegurança jurídica, de modo que estariam preservadas as leis fruto de conversão de medida provisória, no que diz respeito à inconstitucionalidade formal. O Ministro Roberto Barroso acrescentou que o entendimento pela inconstitucionalidade das emendas parlamentares sem pertinência temática com a medida provisória decorreria de nova interpretação da Constituição quanto a esse costume, à luz do fato de que a prática seria reiterada há muito tempo. O Ministro Teori Zavascki frisou a LC 95/1998, a tratar da técnica de formulação das leis, segundo a qual a necessidade de pertinência temática estaria prevista. O Ministro Gilmar Mendes enfatizou a necessidade de se sinalizar ao Congresso Nacional que essa prática, muito embora mantidos os atos praticados até o momento, não poderia se repetir doravante. Vencidos os Ministros Rosa Weber (relatora), Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente), que julgavam o pedido procedente; e o Ministro Dias Toffoli, que julgava o pleito improcedente em maior extensão, por considerar que não caberia ao STF avaliar a pertinência temática entre a medida provisória e a emenda, o que seria de competência do Congresso Nacional.

ADI 5127/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/o acórdão Min. Edson Fachin, 15.10.2015. (ADI-5127)

(Informativo 803)

► Parlamentar e imunidade

A imunidade parlamentar é uma proteção adicional ao direito fundamental de todas as pessoas à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da Constituição. Assim, mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que guardem alguma pertinência com suas funções parlamentares, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, “caput”, da Constituição (“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”). Com base nessa orientação, a Primeira Turma, em julgamento conjunto e por maioria, rejeitou a queixa-crime oferecida em face de senador a quem fora imputado a prática dos delitos de calúnia, injúria e difamação. Na espécie, parlamentar teria postado na rede social “Facebook” que ex-Presidente da República teria cometido crimes e, ainda, teria impetrado “habeas corpus” preventivo relativo a atos de corrupção ocorrido no âmbito da Petrobrás. De início, a Turma assentou o caráter reprovável e lamentável com o qual as críticas à suposta condutas de um ex-Presidente da República teriam sido feitas. Na sequência, ressaltou que a imunidade material conferida aos parlamentares não seria uma prerrogativa absoluta. Restringir-se-ia a opiniões e palavras externadas, dentro ou fora do recinto do Congresso Nacional, mas no exercício do mandato ou em razão dele. Prevaleceria, portanto, a compreensão de que a imunidade parlamentar não se estenderia para opiniões ou palavras que pudessem malferir a honra de alguém quando essa manifestação estivesse dissociada do

exercício do mandato. Para o Colegiado, a Constituição teria garantido uma tolerância com o uso — que normalmente fosse considerado abusivo — do direito de expressar livremente suas opiniões, quando proveniente de parlamentar no exercício de seus respectivos mandatos. Essa condescendência se justificaria para assegurar um bem maior — a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor as suspeitas que pairassem sobre outros homens públicos, mesmo que de forma que pudesse ser considerada abusiva e, portanto, criminosa, o caminho trilhado pela Constituição seria o de conferir liberdade ao congressista. Assim, a regra da imunidade deveria prevalecer nas situações limítrofes em que não fosse delineada a conexão entre a atividade parlamentar e as ofensas irrogadas a pretexto de exercê-la, mas que, igualmente, não se pudesse, de plano, dizer que exorbitassem do exercício do mandato.

Inq 4088/DF, rel. Min. Edson Fachin, 1º.12.2015. (Inq-4088)

Inq 4097/DF, rel. Min. Edson Fachin, 1º.12.2015. (Inq-4097)

(Informativo 810)

► **Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 1**

O Plenário julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face de diversos dispositivos da Lei 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo e julgamento. O arguente pleiteava: a) a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 19 da Lei 1.079/1950, para que se fixasse, com efeitos “ex tunc” — abrangendo os processos em andamento —, a orientação segundo a qual o recebimento da denúncia, referido no dispositivo legal, deveria ser precedido de audiência prévia do acusado, no prazo de 15 dias; b) a declaração de não recepção das expressões “regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”, constantes do art. 38; c) a declaração de recepção dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23, “caput”, afastando-se a interpretação segundo a qual o art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados substituiria o procedimento previsto nos referidos preceitos legais; d) a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 19, afastando-se a interpretação de que a formação da comissão especial deveria se dar com representantes dos blocos parlamentares no lugar de representantes dos partidos políticos; e) a realização de interpretação conforme a Constituição dos artigos 18, § 1º, 22, 27, 28 e 29, para se fixar a interpretação no sentido de que toda a atividade probatória fosse desenvolvida em primeiro lugar pela acusação e por último pela defesa; f) a realização de interpretação conforme a Constituição do § 1º do art. 22 e dos artigos 28 e 29, para se fixar a interpretação de que, em cada fase processual — perante a Câmara dos Deputados e perante o Senado Federal —, a manifestação do acusado, pessoalmente ou por seus representantes legais, fosse o último ato de instrução; g) a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 24 para se fixar a interpretação segundo a qual o processo de “impeachment”, autorizado pela Câmara, poderá ou não ser instaurado no Senado, cabendo a decisão de instaurá-lo ou não à respectiva Mesa, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 44 da própria Lei 1.079/1950, não sendo essa decisão passível de recurso; h) a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 24 para se fixar a interpretação no

sentido de que a decisão da Mesa do Senado pela instauração do processo deverá ser submetida ao Plenário da Casa, aplicando-se, por analogia, os artigos 45, 46, 48 e 49 da própria lei impugnada, exigindo-se, para se confirmar a instauração do processo, a decisão de 2/3 dos Senadores; i) a declaração da não recepção dos §§ 1º e 5º do art. 23, e dos artigos 80 e 81; j) a realização de interpretação conforme a Constituição dos artigos 25, 26, 27, 28, 29 e 30, para se fixar a interpretação segundo a qual os Senadores só deveriam realizar diligências ou a produção de provas de modo residual e complementar às partes, sem assumir, para si, a função acusatória; e, por fim, k) a realização de interpretação conforme a Constituição do art. 19, com efeitos “*ex tunc*” — alcançando processos em andamento —, para fixar a interpretação de que o Presidente da Câmara dos Deputados apenas poderia praticar o ato de recebimento da acusação contra o Presidente da República se não incidisse em qualquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, esta última objetivamente aferível pela presença de conflito concreto de interesses.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 2

O Plenário, inicialmente, deliberou conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Destacou que as alegações contrárias ao seu conhecimento não seriam procedentes pelas seguintes razões: a) a jurisprudência do STF seria pacífica sobre competir ao próprio STF o juízo sobre o que se deveria compreender por preceito fundamental, mediante esforço hermenêutico que identificasse “as disposições essenciais para a preservação dos princípios basilares dos preceitos fundamentais de um determinado sistema” (ADPF 33 MC/PA, DJU 27.10.2006); b) a ofensa na presente hipótese, notadamente, ao sistema de governo, à separação de poderes, à soberania popular, ao direito ao devido processo legislativo e às garantias procedimentais no curso da apuração de crime de responsabilidade poderia ser inferida potencialmente; c) ainda, o requisito da subsidiariedade estaria presente, pois “a existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, “*a priori*”, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação” (ADPF 33 MC/PA, DJU 27.10.2006); d) o objeto da arguição seria a Lei 1.079/1950, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, e foi promulgada sob a égide da Constituição da República de 1946. Tratar-se-ia, portanto, de um juízo de recepção sobre diploma legislativo anterior à ordem constitucional atual e não da suposta tentativa de julgamento de inconstitucionalidade dos regimentos internos das Casas do Congresso Nacional; e) as medidas cautelares incidentais a tratar da eleição da comissão especial guardariam pertinência com a potencial recepção do art. 19 da referida lei pela CF/1988, sobretudo no tocante à expressão “comissão especial eleita”; f) as noções de instrumentalidade das formas e de economia processual recomendariam considerar as Petições/STF 64.212 e 64.216, ambas de 2015, como aditamento à peça inicial, tendo em vista a viabilidade do ajuizamento de uma nova arguição incidental ante a relevância da controvérsia constitucional em discussão; por fim, g) o tema referente ao “impeachment” presidencial seria da mais alta magnitude jurídico-política, de maneira a revelar a imperatividade de um diálogo institucional

entre o STF, na qualidade de guardião das regras da democracia constitucional, e os demais Poderes da República, aqui, por intermédio da prestação da jurisdição constitucional em processo objetivo.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 3

No mérito, a Corte, asseverou que, visto que o impeachment, nos estritos limites da controvérsia e desde que observadas as regras constitucionais, seria um dos mecanismos capazes de corrigir distorções não republicanas. Dessa maneira, o STF deveria zelar para que as regras de delimitação do exercício de controle do Poder Executivo não acabassem por impedi-lo de realizar sua missão constitucional. processual do instituto, conforme decidido no MS 20.941/DF (DJU de 31.8.1992). Além disso, o instituto Assim, a natureza política do “impeachment” não retiraria do Poder Judiciário o controle sobre a regularidade seria compatível com a Constituição e concretizaria o princípio republicano, exigindo dos agentes políticos responsabilidade civil e política pelos atos que praticassem no exercício do poder. Outrossim, não haveria dúvida quanto à recepção, pela CF/1988, dos aspectos materiais da Lei 1.079/1950. Quanto aos seus aspectos processuais, no entanto, tendo em vista as modificações em relação ao papel da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no processo de “impeachment” em relação às ordens jurídicas anteriores, seria preciso realizar a sua leitura à luz dos mandamentos constitucionais. O sistema processual do “impeachment”, portanto, estaria hoje previsto na imbricação entre a Constituição e a citada lei, que dariam as linhas mestras e estruturantes a serem seguidas. Então, no cenário jurídico-político, a Constituição consagraria na matéria a necessidade da existência de um processo ao conferir essa atribuição ao Senado Federal quanto aos crimes de responsabilidade imputados ao Presidente da República (CF, art. 52, I). Essa exigência deveria ser lida à luz da vedação do abuso de poder e das garantias processuais constitucionais, assinalando-se que o processo funcionaria como instrumento a subtrair a possibilidade de que o Chefe do Poder Executivo fosse submetido a julgamento arbitrário, garantia constitucional atinente à cláusula do “due process of law”, a ser assegurada aos acusados em geral.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 4

A Corte, então, relativamente ao item “a”, indeferiu o pedido para afirmar que não há direito à defesa prévia ao ato do Presidente da Câmara, ante a ausência de violação ao devido processo legal. afirmou que a Lei 1.079/1950 seria silente quanto à competência para o recebimento da denúncia, mas esclareceria se tratar de providência a ser tomada antes da formação da comissão especial. Nessa matéria, afeta de forma preponderante à auto-organização da Câmara dos Deputados, embora com efeitos processuais reflexos, seria lícito que se socorresse ao Regimento Interno da Casa, que atribuiria essa tarefa ao Presidente da Câmara dos Deputados. Esse ato do

Presidente da Câmara, mesmo que acarretasse o recebimento da denúncia no contexto do processo instaurado no âmbito daquela Casa Legislativa, não encerraria de forma definitiva o juízo de admissibilidade da denúncia. Sendo a denúncia recebida pelo Presidente da Câmara, incumbiria ao Plenário o juízo conclusivo acerca da viabilidade da denúncia. No processo instaurado na Câmara, a avaliação da Presidência deveria ocorrer à luz da denúncia e das provas que a acompanhassem. Em razão da natureza e gravidade do processo, também seria razoável que esse juízo fosse renovado pelo Plenário. Assim, o traço distintivo entre o juízo de admissibilidade e o de mérito seria simples. No caso do processo instaurado pela Câmara, se o juízo positivo não importasse autorização de processamento do Presidente da República, tratar-se-ia de juízo de admissibilidade interno. Havendo autorização, a decisão resolveria o mérito do processo instaurado na Câmara, com admissão da denúncia para fins de processamento no âmbito do Senado Federal. Nesse contexto, como meio inerente ao contraditório, deveria ser assegurado ao acusado a oportunidade de manifestação prévia à aprovação do parecer da comissão especial, oportunidade em que se julgará, para os fins do processo instaurado na Câmara, a admissão definitiva da denúncia. Nessa linha, considerando que o recebimento operado pelo Presidente da Câmara configuraria juízo sumário da admissibilidade da denúncia para fins de deliberação colegiada, não haveria obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão. Desse modo, a exigência de defesa prévia ao recebimento da denúncia não constituiria derivação necessária da cláusula do devido processo legal, na medida em que, reconhecido o direito de manifestação anterior à aprovação do primeiro parecer proferido pela comissão especial, haveria contraditório prévio à admissibilidade conclusiva. O devido processo legal, nessa ótica, seria respeitado.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► **Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 5**

Quanto ao item “b”, o Tribunal deferiu parcialmente o pedido para estabelecer, em interpretação conforme a Constituição do art. 38 da Lei 1.079/1950, que seria possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de “impeachment”, desde que fossem compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. Asseverou que os referidos regimentos internos possuiriam aplicação ao rito do “impeachment” naquilo que dissessem respeito à auto-organização interna dos referidos órgãos legislativos, mas não para a autorização, processamento e julgamento do “impeachment”. Não haveria, assim, violação à reserva de lei exigida pelo art. 85 da CF. Em relação ao item “c”, o Pleno, por maioria, deferiu parcialmente o pleito para (1) declarar recepcionados pela CF/1988 os artigos 19, 20 e 21 da Lei 1.079/1950, interpretados conforme a Constituição para que se entendesse que as “diligências” e atividades ali previstas não se destinariam a provar a improcedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia; e (2) para declarar não recepcionados pela CF/1988 o art. 22, “caput”, 2ª parte — que se inicia com a expressão “No caso contrário...” —, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da lei em questão, que determinam dilação probatória e segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Prevaleceu, no ponto, o

voto do Ministro Roberto Barroso. Assinalou que a lei em questão regulamentaria a Constituição de 1946. Portanto, referido ato normativo disciplinaria a participação da Câmara dos Deputados em dois momentos: o de recebimento da denúncia e o momento seguinte, em que, por 2/3 dos votos, ela julgaria procedente, ou não, a denúncia. Porém, pela nova sistemática que decorreria da CF/1988 a Câmara se manifestaria uma única vez sobre a autorização, ou não, para a instauração do processo. Vencidos os Ministros Edson Fachin (relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que (1) declaravam a recepção do art. 20, “caput” e §1º; (2) davam interpretação conforme ao art. 20, § 2º, a fim de firmar o entendimento de que antes da discussão única em plenário fosse lida a manifestação do Presidente da República sobre o parecer preliminar elaborado pela comissão especial; (3) declaravam a recepção do art. 21, 22, “caput”, §1º, §2º, bem assim do art. 23, “caput”; e (4) davam interpretação conforme ao art. 22, §3º, a fim de firmar o entendimento de que o Presidente da República dovesse ser notificado para apresentar alegações finais sobre o parecer definitivo da comissão especial.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 6

O Plenário, no que diz com o item “d”, indeferiu o pedido, por reconhecer que a proporcionalidade na formação da comissão especial poderia ser aferida em relação aos partidos e blocos partidários. Ressaltou que não haveria, relativamente ao art. 19 da Lei 1.079/1950 qualquer incompatibilidade material em relação à Constituição Federal, logo se teria o dispositivo como válido e eficaz à formação da comissão. No concernente ao item “e”, por maioria, deferiu o pleito para estabelecer que a defesa tem o direito de se manifestar após a acusação, vencido, nesse item, o Ministro Marco Aurélio, que assentava a necessidade de se ouvir o Presidente da República antes da acusação, no âmbito do Senado Federal. Quanto ao item “f”, a Corte deferiu o pedido para estabelecer que o interrogatório seja o ato final da instrução probatória. Já quanto ao item “g”, por maioria, deferiu parcialmente a pretensão para (1) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 24 da Lei 1.079/1950, a fim de declarar que, com o advento da CF/1988, o recebimento da denúncia no processo de “impeachment” ocorre apenas após a decisão do Plenário do Senado Federal, e (2) declarar que a votação nominal deverá ser tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de seus membros. Prevaleceu, no ponto sob enfoque, o voto do Ministro Roberto Barroso. Asseverou que, em relação ao papel da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no procedimento, caberia à Câmara autorizar a instauração do processo, e ao Senado processar e julgar o acusado. Significaria, conseqüentemente, que o Senado faria um juízo inicial de instauração, ou não, do processo, correspondente ao recebimento, ou não, da denúncia. Isso se daria em razão do advento da CF/1988 que passara a prever, para a Câmara dos Deputados, apenas o papel de autorizar a instauração do processo, como condição de procedibilidade da ação perante o Senado. Diferentemente da CF/1946 na qual se previa, como papel da Câmara dos Deputados, a declaração da procedência ou da improcedência da acusação, sendo o Presidente da República imediatamente suspenso das suas funções no primeiro caso. Vencidos, quanto ao subitem “1”, os Ministros Edson Fachin (relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que fixavam o entendimento de que não competiria ao Senado rejei-

tar a autorização expedida pela Câmara dos Deputados; e quanto ao subitem “2”, os Ministros Edson Fachin (relator), Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que assentavam a necessidade de observância do quórum de 2/3.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► Lei 1.079/1950: procedimento de “impeachment” e recepção - 7

Quanto ao item “h”, o colegiado por maioria, deferiu parcialmente o pedido para declarar constitucionalmente legítima a aplicação analógica dos artigos 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei 1.079/1950 — os quais determinam o rito do processo de “impeachment” contra Ministros do STF e o PGR — ao processamento no Senado Federal de crime de responsabilidade contra o Presidente da República. Prevaleceu, na matéria, o voto do Ministro Roberto Barroso. Destacou que deveria ser observado o procedimento adotado durante o “impeachment” realizado no ano de 1992, do então Presidente da República, Fernando Collor. Assim, o Senado Federal se pronunciaria, no momento inicial, pelo recebimento, ou não, da denúncia, por maioria simples. Recebida esta, o processo deveria prosseguir. Não recebida a denúncia, o processo deveria ser extinto. Depois, haveria uma deliberação por maioria simples, quanto à pronúncia, e uma deliberação por 2/3, quanto à procedência, ou não, da acusação. Vencidos, nesse tópico, os Ministros Edson Fachin (relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Em relação ao item “i”, a Corte, por maioria, deferiu integralmente a pretensão para declarar que não foram recepcionados pela CF/1988 os artigos 23, §§ 1º, 4º e 5º; 80, 1ª parte; e 81, porque estabeleceriam os papéis da Câmara e do Senado Federal de modo incompatível com os artigos 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, da CF. Prevaleceu, também nesse ponto, o voto do Ministro Roberto Barroso. Vencidos, em menor extensão, os Ministros Edson Fachin (relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que (1) declaravam a não recepção do § 5º do art. 23, e dos artigos 80, “ab initio”, e 81; e (2) davam interpretação conforme ao art. 23, § 1º, para consignar que o efeito da procedência da denúncia na Câmara dos Deputados seria a autorização para processar e julgar o Presidente da República. Com relação aos itens “j” e “k”, o Tribunal indeferiu os pleitos para, respectivamente: i) afirmar que os senadores não precisam se apartar da função acusatória e ii) reconhecer a impossibilidade de aplicação subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição do CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos Deputados. Destacou que em processos norteados pelo convencimento jurídico, a imparcialidade do juiz constituiria desdobramento lógico da cláusula do devido processo legal. Outrossim, por opção constitucional, determinadas infrações sujeitar-se-iam a processamento e a julgamento em território político, em que os atores ocupariam seus postos com supedâneo em prévias agendas e escolhas dessa natureza. Sendo assim, soaria natural que a maioria dos agentes políticos ou figurassem como adversários do Presidente da República ou comungassem de suas compreensões ideológico-políticas. Esses entraves de ordem política seriam da essência de um julgamento de jaez jurídico-político. Com efeito, o nível de imparcialidade aduzido nos referidos pedidos não se coadunariam com a extensão pública das discussões valorativas e deliberações dos parlamentares. Seria preciso que se reconhecesse que, embora guardassem algumas semelhanças, processos jurídicos e político-jurídicos resolver-se-iam em palcos distintos e seguiriam lógicas próprias. Destarte, exigir aplicação fria das regras de julgamento significaria,

em verdade, converter o julgamento jurídico-político em exclusivamente jurídico, o que não observaria a intenção constitucional. A Constituição teria pretendido que o julgador estivesse sujeito à lei e a interesses políticos, de modo que a subtração dessa perspectiva implicaria violação ao princípio democrático.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

► **Lei 1.079/1950: procedimento de "impeachment" e recepção - 8**

Em seguida, o Plenário, ao apreciar cautelar incidental relativa à alegada impossibilidade de candidaturas avulsas, por maioria, deferiu integralmente o pedido para declarar que não é possível a formação de comissão especial a partir de candidaturas avulsas. Prevaleceu, ainda nessa matéria, o voto do Ministro Roberto Barroso. Afirmou que haveria duas razões que infirmariam a legitimidade da candidatura avulsa: uma textual e a outra lógica. A justificativa textual seria que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com a autoridade da delegação recebida pelo art. 58 da CF, estatuiria que a indicação dos representantes partidários ou dos blocos parlamentares competiria aos líderes. Já a razão lógica se sustentaria no fato de que, por força da Constituição, a representação proporcional seria do partido ou do bloco parlamentar. Assim, os nomes dos partidos não poderiam ser escolhidos heteronomamente, o que se daria caso os adversários escolhessem o representante do partido. Vencidos, no ponto, os Ministros Edson Fachin (relator), Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que entendiam não caber ao Poder Judiciário, mesmo em sede de jurisdição constitucional, tolher uma opção legitimamente feita pela Câmara dos Deputados no pleno exercício de uma liberdade política que lhe seria conferida pela ordem constitucional, na forma do art. 58, §1º, da CF. Quanto à cautelar incidental relativa à forma de votação para formação da comissão especial, por maioria, deferiu o pedido para reconhecer que a eleição da comissão especial somente poderia se dar por voto aberto. Prevaleceu, na matéria, o voto do Ministro Roberto Barroso. Ressaltou a incidência, na questão em comento, dos princípios republicano, democrático, representativo, e o que eles importariam em transparência. Ademais, dever-se-ia preservar o procedimento seguido no "impeachment" instaurado em 1992, no qual fora aberta a votação para a constituição da comissão especial. Vencidos, quanto ao ponto em comento, os Ministros Edson Fachin (relator), Teori Zavascki, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que afirmavam não competir ao Poder Judiciário sindicat atos administrativos do Parlamento, quando as soluções fossem múltiplas e constitucionalmente adequadas. Isso em consideração à noção de autocontenção do Estado-Juiz perante o Parlamento e em homenagem à tripartição dos poderes. Finalmente, a Corte, por maioria, resolveu questão de ordem suscitada da tribuna para reafirmar o "quorum" de maioria simples para deliberação do Senado relativamente ao juízo de instauração do processo, prevalecendo o voto do Ministro Roberto Barroso. Vencidos, quanto à questão de ordem, os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que estabeleciam o "quorum" de 2/3. Ao final, o Pleno converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito.

ADPF 378/DF, rel. Min. Edson Fachin, 16, 17 e 18.12.2015. (ADPF-378)

(Informativo 812)

INFORMATIVOS 2016

► Sigilo e fiscalização tributária - 4

O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, reputou improcedentes os pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face de normas federais que possibilitam a utilização, por parte da fiscalização tributária, de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo constitucional, sem a intermediação do Poder Judiciário (LC 104/2001, art. 1º; LC 105/2001, artigos 1º, § 3º e 4º, 3º, § 3º, 5º e 6º; Decreto 3.724/2001; Decreto 4.489/2002; e Decreto 4.545/2002) — v. Informativo 814. A Corte afirmou que, relativamente à alegação de inconstitucionalidade da expressão “do inquérito ou”, contida no § 4º do art. 1º da LC 105/2001, a norma impugnada não cuidaria da transferência de informações bancárias ao Fisco, questão que estaria no cerne das ações diretas. Tratar-se-ia de norma referente à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito há muito se admitiria a quebra de sigilo bancário, quando presentes indícios de prática crimínosa (AC 3.872 AgR/DF, DJe de 13.11.2015; HC 125.585 AgR/PE, DJe de 19.12.2014; Inq 897 AgR/DF, DJU de 24.3.1995). No que tange à impugnação dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, ponto central das ações diretas de inconstitucionalidade, haveria que se consignar a inexistência, nos dispositivos combatidos, de violação a direito fundamental, notadamente de ofensa à intimidade. Não haveria “quebra de sigilo bancário”, mas, ao contrário, a afirmação desse direito. Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres do contribuinte — o dever fundamental de pagar tributos — e os deveres do Fisco — o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com fundamento, inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nesse sentido, para se falar em “quebra de sigilo bancário” pelos preceitos impugnados, necessário seria vislumbrar, em seus comandos, autorização para a exposição das informações bancárias obtidas pelo Fisco. A previsão de circulação dos dados bancários, todavia, inexistiria nos dispositivos questionados, que consagrariam, de modo expresso, a permanência no sigilo das informações obtidas com base em seus comandos. O que ocorreria não seria propriamente a quebra de sigilo, mas a “transferência de sigilo” dos bancos ao Fisco. Nessa transmutação, inexistiria qualquer distinção entre uma e outra espécie de sigilo que pudesse apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do bancário. Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras — muitas das quais de natureza privada — se manteria, com ainda mais razão, com relação aos órgãos fiscais integrantes da Administração Pública, submetidos à mais estrita legalidade.

ADI 2390/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2390)

ADI 2386/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2386)

ADI 2397/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2397)

ADI 2859/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2859)

(Informativo 815)

► Sigilo e fiscalização tributária - 5

O Plenário destacou que, em síntese, a LC 105/2001 possibilitara o acesso de dados bancários pelo Fisco, para identificação, com maior precisão, por meio de legítima

atividade fiscalizatória, do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte. Não permitiria, contudo, a divulgação dessas informações, resguardando-se a intimidade e a vida íntima do correntista. E esse resguardo se tornaria evidente com a leitura sistemática da lei em questão. Essa seria, em verdade, bastante protetiva na ponderação entre o acesso aos dados bancários do contribuinte e o exercício da atividade fiscalizatória pelo Fisco. Além de consistir em medida fiscalizatória sigilosa e pontual, o acesso amplo a dados bancários pelo Fisco exigiria a existência de processo administrativo — ou procedimento fiscal. Isso por si, já atrairia para o contribuinte todas as garantias da Lei 9.784/1999 — dentre elas, a observância dos princípios da finalidade, da motivação, da proporcionalidade e do interesse público —, a permitir extensa possibilidade de controle sobre os atos da Administração Fiscal. De todo modo, por se tratar de mero compartilhamento de informações sigilosas, seria mais adequado situar as previsões legais combatidas na categoria de elementos concretizadores dos deveres dos cidadãos e do Fisco na implementação da justiça social, a qual teria, como um de seus mais poderosos instrumentos, a tributação. Nessa senda, o dever fundamental de pagar tributos estaria alicerçado na ideia de solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de tributos, no Brasil, seria um dever fundamental — por representar o contributo de cada cidadão para a manutenção e o desenvolvimento de um Estado que promove direitos fundamentais —, seria preciso que se adotassem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal. No entanto, a Corte ressaltou que os Estados-Membros e os Municípios somente poderiam obter as informações previstas no art. 6º da LC 105/2001, uma vez regulamentada a matéria de forma análoga ao Decreto 3.724/2001, observados os seguintes parâmetros: a) pertinência temática entre a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento administrativo instaurado; b) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os demais atos, garantido o mais amplo acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de documentos, mas também de decisões; c) sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico; d) existência de sistemas eletrônicos de segurança que fossem certificados e com o registro de acesso; e, finalmente, e) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios. Já quanto à impugnação ao art. 1º da LC 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, o Tribunal asseverou que os dispositivos seriam referentes ao sigilo imposto à Receita Federal quando essa detivesse informações sobre a situação econômica e financeira do contribuinte. Os preceitos atacados autorizariam o compartilhamento de tais informações com autoridades administrativas, no interesse da Administração Pública, desde que comprovada a instauração de processo administrativo, no órgão ou entidade a que pertencesse a autoridade solicitante, destinado a investigar, pela prática de infração administrativa, o sujeito passivo a que se referisse a informação.

ADI 2390/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2390)

ADI 2386/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2386)

ADI 2397/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2397)

ADI 2859/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2859)

(Informativo 815)

► Sigilo e fiscalização tributária - 6

A Corte asseverou que, no ponto, mais uma vez o legislador teria se preocupado em criar mecanismos que impeçissem a circulação ou o extravasamento das informações relativas ao contribuinte. Diante das cautelas fixadas na lei, não haveria propriamente quebra de sigilo, mas sim transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Em relação ao art. 3º, § 3º, da LC 105/2001 — a determinar que o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) forneçam à Advocacia-Geral da União (AGU) “as informações e documentos necessários à defesa da União nas ações em que seja parte” —, ressaltou que essa previsão seria prática corrente. Isso se daria porque, de fato, os órgãos de defesa da União solicitariam aos órgãos federais envolvidos em determinada lide informações destinadas a subsidiar a elaboração de contestações, recursos e outros atos processuais. E de nada adiantaria a possibilidade de acesso dos dados bancários pelo Fisco se não fosse possível que essa utilização legítima fosse objeto de defesa em juízo por meio do órgão por isso responsável, a AGU. Por fim, julgou parcialmente prejudicada uma das ações, relativamente ao Decreto 4.545/2002. O Ministro Roberto Barroso reajustou seu voto para acompanhar o relator. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que conferiam interpretação conforme aos dispositivos legais atacados, de modo a afastar a possibilidade de acesso direto aos dados bancários pelos órgãos públicos, vedado inclusive o compartilhamento de informações. Este só seria possível, consideradas as finalidades previstas na cláusula final do inciso XII do art. 5º da CF, para fins de investigação criminal ou instrução criminal. Nesse sentido, a decretação da quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária das CPIs (CF, art. 58, § 3º), pressuporia, sempre, a existência de ordem judicial, sem o que não se imporá à instituição financeira o dever de fornecer à Administração Tributária, ao Ministério Público, à Polícia Judiciária ou, ainda, ao TCU, as informações que lhe tivessem sido solicitadas.

ADI 2390/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2390)

ADI 2386/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2386)

ADI 2397/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2397)

ADI 2859/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 24.2.2016. (ADI-2859)

(Informativo 815)

► Fornecimento de informações financeiras ao fisco sem autorização judicial - 5

O art. 6º da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Por sua vez, a Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN. Esse o entendimento do Plenário, que em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade — frente ao parâmetro do sigilo bancário — do acesso aos dados bancários por parte de autoridades e agentes fiscais tributários da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem autorização judicial, nos termos dispostos pela LC 105/2001. Debatia-se, ainda, se haveria afronta ao princípio da irretroatividade das leis, quando esses mecanismos são empregados para a apuração de créditos relativos a tributos distintos da CPMF, cujos fatos geradores tenham ocorrido em período anterior à vigência deste diploma legislativo — v. Informativo 814. O Colegiado afirmou não haver dúvidas de que o direito à privacidade ou mesmo à intimidade seriam direitos que teriam base fática e forte conteúdo jurídico. Significa dizer que seriam direitos passíveis de conformação. Não se trataria de pura condição restritiva, mas a própria lei poderia estabelecer determinadas delimitações. Esclareceu que a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, visando à Administração Tributária, não padeceria de nenhuma ilegalidade. Por outro lado, o art. 144, § 1º, do CTN imporia que qualquer método de apuração tributária entre em vigor imediatamente, o que afastaria a alegação de retroatividade. Na verdade, o tema ora em debate não seria quebra de sigilo, mas transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A legislação aplicável garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros, estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente praticassem essa infração. Assim, dados sigilosos de interesse fiscal somente poderiam ser acessados depois da instauração de competente processo administrativo, por ato devidamente motivado, nos moldes hoje preconizados pelo Decreto 3.724/2002, compreendidos os três níveis político-administrativos da Federação. Garante-se, ainda, a imediata notificação do contribuinte, a ele assegurado o acesso aos autos e o direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, para que possa exercer, a todo o tempo, o controle jurisdicional dos atos da Administração, nos termos da Lei 9.784/1999. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que davam provimento ao recurso. Para o Ministro Celso de Mello, a decretação da quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária das CPIs (CF, art. 58, § 3º), pressuporia, sempre, a existência de ordem judicial, sem o que não se poderia impor à instituição financeira o dever de fornecer à Administração Tributária, ao Ministério Público ou, ainda, à Polícia Judiciária as informações que lhe tenham sido solicitadas. RE 601314/SP, rel. Min. Edson Fachin, 24.2.2016. (RE-601314)

(Informativo 815)

► **Inquérito: corrupção passiva e lavagem de dinheiro - 1**

O Plenário recebeu, parcialmente, denúncia oferecida contra deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (CP, art. 317, “caput” e § 1º, c/c art. 327, §§ 1º e 2º) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998, art. 1º, V, VI e VII, com redação anterior à Lei 12.683/2012). Ainda, na mesma assentada, a Corte, por maioria, recebeu denúncia oferecida contra ex-deputada, hoje prefeita municipal, pelo suposto delito de corrupção passiva. Por fim, julgou prejudicados os agravos regimentais. Inicialmente, o Tribunal, por maioria, rejeitou as preliminares suscitadas. Afirmou não prosperar a alegação de nulidade do depoimento prestado pela denunciada perante o Ministério Público, ao argumento de que teria sido ouvida como testemunha e não como investigada, o que comprometeria o direito de não autoincriminação. Isso porque, embora ela tivesse sido ouvida na condição de testemunha e assumido o compromisso de dizer a verdade, constaria do termo de

depoimento que ela teria sido informada de que estariam ressalvadas daquele compromisso “as garantias constitucionais aplicáveis”. Afastou também a pretensão do denunciado de ver suspenso o processo, por aplicação analógica do art. 86, § 4º, da CF, já que essa previsão constitucional se destinaria expressamente ao chefe do Poder Executivo da União. Desse modo, não estaria autorizado, por sua natureza restritiva, qualquer interpretação que ampliase a incidência a outras autoridades, notadamente do Poder Legislativo. Rechaçou o alegado cerceamento de defesa, arguido em agravos regimentais, por meio dos quais se buscava acessar o inteiro teor do acordo de colaboração premiada e respectivos termos de depoimento de réu já condenado pela justiça federal por crimes apurados na denominada “Operação Lava Jato”. Resaltou que o Procurador-Geral da República juntara aos autos todos os depoimentos de colaboradores que se referiam ao acusado e aos fatos referidos na denúncia. Inq 3983/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 2 e 3.2016. (Inq-3983)

(Informativo 816)

► CNJ: férias de 60 dias e justiça estadual - 1

A Segunda Turma denegou a ordem em mandado de segurança impetrado em face de ato do CNJ, consistente na declaração de ilegalidade da fixação de férias de 60 dias para os servidores de tribunal de justiça estadual. A Turma, inicialmente, assentou a competência do CNJ para apreciar a matéria em questão. Isso porque a disciplina das férias de serventuários da Justiça de qualquer dos estados-membros, entre outras matérias, constituiria função a ele cominada pela CF, em seu artigo 103-B, § 4º, II. Outrossim, não haveria nessa atuação do Conselho hipótese de usurpação da competência do STF, mas sim de exercício direto da competência constitucional que lhe fora atribuída. O Colegiado afastou também alegação segundo a qual teria havido violação à ampla defesa e ao contraditório na decisão atacada porque proferida sem que tivesse sido publicado edital para que fossem ouvidos os servidores do tribunal local. Afirmou que a baliza que se poderia identificar nos julgados do STF, no sentido de assegurar a oitiva de terceiros nos feitos administrativos de controle de atos de tribunais ou órgãos de ministérios públicos locais pelos respectivos Conselhos constitucionais — CNJ e CNMP —, tem sido a existência de situação jurídica constituída com base no ato controlado. Assim, inexistindo a consolidação de situação jurídica, o tribunal não reconheceria o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por outro lado, a par de observar a existência de situação jurídica consolidada, seria necessário avaliar a natureza do ato objeto de controle — se ato geral ou individual — e, por consequência, a natureza da deliberação a ser proferida pelo Conselho constitucional — objetiva ou subjetiva —, a fim de se definir a necessidade de oitiva dos possíveis atingidos pela decisão. Nesse sentido, os atos elaborados a partir da consideração de situação individual do beneficiário, ou seja, com componente subjetivo, demandariam, nos feitos voltados a sua desconstituição, a necessária participação do interessado, que deveria, desse modo, ser notificado à apresentação de sua defesa. No caso dos autos, todavia, seria discutida deliberação do CNJ, que, controlando atos normativos de tribunal local, considerara ilegal a concessão de 60 dias de férias aos serventuários da justiça estadual. Ao apreciar a legalidade de um decreto-lei de tribunal local e sua conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, o CNJ não

consideraria a situação particular dos beneficiários da norma, projetando, isto sim, sua apreciação, sob o enfoque objetivo.

MS 26739/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.3.2016. (MS-26739)

(Informativo 816)

► CNJ: férias de 60 dias e justiça estadual - 2

No mérito, a Turma asseverou que as normas estaduais infirmadas na decisão do CNJ assegurariam 60 dias de férias aos servidores da Justiça estadual como decorrência da associação entre esse direito e o período de férias coletivas concedidas nos tribunais. Todavia, essa forma de usufruto do direito às férias já teria a sua inconstitucionalidade declarada pelo STF. De fato, a jurisprudência da Corte se pacificara no sentido de ser inconstitucional a concessão de férias coletivas aos magistrados, diante da previsão inserta pela EC 45/2004 ao art. 93, XII, da CF. Tal preceito dispõe que “a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”. Ademais, “EC 45/2004, ao vedar as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam” (ADI 3.085/CE, DJU de 28.4.2006). Assim, se a Constituição veda a concessão de férias coletivas aos magistrados, com vista a garantir que a atividade jurisdicional seja ininterrupta, seria também inadmissível o gozo coletivo de férias pelos servidores de tribunal de justiça local. MS 26739/DF, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.3.2016. (MS-26739)

(Informativo 816)

► Licença-maternidade e discriminação entre gestação e adoção - 1

Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de lei instituir prazos diferenciados para a concessão de licença-maternidade às servidoras gestantes e às adotantes. Reconheceu o direito da recorrente, servidora pública, ao prazo remanescente da licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, seja de 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença, previstos no art. 7º, XVIII, da CF, acrescidos dos 60 dias de prorrogação, nos termos da lei. De início, o Colegiado afirmou que a Constituição trouxera inovações a respeito do tema. Uma delas, a superação da ideia de família tradicional, hierarquizada, liderada pelo homem, chefe da sociedade conjugal. Fora criada uma noção de família mais igualitária, que não apenas resulta do casamento. Além disso, ela não é mais voltada para proteger o patrimônio, mas para cultivar e manter laços afetivos. Outra mudança diz respeito à igualdade entre os filhos, que tinham regime jurídico diferenciado, a depender de suas origens. Por fim, fora estabelecido, no art. 7º, XVIII, da CF, a licença à gestante como um direito social. No que se refere à legislação infraconstitucional, o Tribunal explicou sua evolução até o quadro atual, em

que há duas situações distintas: para servidoras públicas, regidas de acordo com a Lei 8.112/1990, a licença-maternidade, para gestantes, é de 120 dias. Para adotantes, a licença-maternidade é de 90 dias, para crianças menores de 1 ano, e de 30 dias, para maiores de 1 ano. Por outro lado, para trabalhadoras da iniciativa privada, regidas de acordo com a CLT, a licença-gestante é equiparada à licença-adotante, e não há diferenciação em virtude da idade da criança adotada. Com o advento da Lei 11.770/2008, passara a ser previsto o direito de prorrogação da licença-maternidade em até 50%, tanto para servidoras públicas quanto para trabalhadoras do setor privado. RE 778889/PE, rel. Min. Roberto Barroso, 10.3.2016. (RE-778889)

(Informativo 817)

► **Licença-maternidade e discriminação entre gestação e adoção - 2**

O Plenário analisou que essa diferenciação existente no setor público, tanto em razão de a mãe ser adotante quanto em virtude da idade da criança adotada, seria ilegítima. Isso porque as crianças adotadas apresentam dificuldades inexistentes para filhos biológicos: histórico de cuidados inadequados, carência, abuso físico, moral e sexual, traumas, entre outros. Além disso, quanto maior a idade da criança, maior o tempo em que submetida a esse quadro, e maior a dificuldade de adaptação à família adotiva. Por isso, quanto mais a mãe pudesse estar disponível para a criança adotiva, mormente nesse período inicial, maior a probabilidade de recuperação emocional da criança em adaptação. Além disso, crianças adotadas apresentam mais problemas de saúde, se comparadas com filhos biológicos, e quanto mais avançada a idade da criança, menor a probabilidade de ser escolhida para adoção. Assim, nada indica que crianças mais velhas demandam menos cuidados se comparadas a bebês. A situação revela justamente o contrário. Ademais, é necessário criar estímulos para a adoção de crianças mais velhas. Portanto, o tratamento mais gravoso dado ao adotado de mais idade viola o princípio da proporcionalidade, e implica proteção deficiente. O Colegiado observou o tema, ainda, à luz da autonomia da mulher. Por causa de razões culturais, o membro da família mais onerado na experiência da adoção é a mãe. Também por esse motivo, não há justificativa plausível para conferir licença inferior à mãe adotiva, se comparada à gestante. Não existe fundamento constitucional para a desequiparação da mãe gestante e da mãe adotante, sequer do adotado mais velho e mais novo. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que desprovia o recurso. Considerava que a diferenciação quanto a gestantes e adotivas teria fundamento constitucional. RE 778889/PE, rel. Min. Roberto Barroso, 10.3.2016. (RE-778889)

(Informativo 817)

► **ADI e revalidação de diplomas obtidos no exterior**

A previsão em lei estadual, acerca da revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL, afronta o pacto federativo (CF, art. 60, §4º, I), na medida em que usurpa a competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional. Essa a conclusão do Plenário ao referendar medida cautelar para suspender a eficácia da Lei 2.973/2014 do Estado do Acre. Tal norma trata da admissão de diploma estrangeiro sem necessidade de revalidação. O Colegiado acrescentou que a lei impugnada estabelece um conjunto de

circunstâncias que afastam exigências de revalidação de diploma de curso superior oriundo de instituições estrangeiras, o que vai de encontro ao sentido do Decreto 5.518/2005, que promulgara o acordo de admissão de títulos e graus universitários para exercício de atividades acadêmicas nos Estados-Partes do MERCOSUL. Verificou, também, a possibilidade de dano ao erário, tendo em vista eventual concessão de promoções funcionais e gratificações a servidores a quem a lei estadual beneficia. ADI 5341 MC-Referendo/AC, rel. Min. Edson Fachin, 10.3.2016. (ADI-5341)

(Informativo 817)

► **ADI: despesas com pessoal e Lei de Diretrizes Orçamentárias**

Em virtude da ocorrência de episódio de usurpação da competência da União para dispor em tema de limite de despesas com gasto de pessoal (CF, art. 169, “caput”), o Plenário referendou em parte medida cautelar para suspender, com efeitos “ex nunc”, até o julgamento final da ação, a eficácia da expressão “Poder Legislativo 4,5%”, contida no art. 50 da Lei 1.005/2015 do Estado de Rondônia (Lei de Diretrizes Orçamentárias). No caso, a lei impugnada não respeitara os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal referentes ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. ADI 5449 MC-Referendo/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 10.3.2016. (ADI-5449)

(Informativo 817)

► **Exercício do cargo de Ministro de Estado por membro do Ministério Público e vedações constitucionais - 1**

Membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos, fora do âmbito da instituição, salvo cargo de professor e funções de magistério. Com base nesse entendimento, o Plenário julgou parcialmente procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade da Resolução 72/2011, do CNMP, e determinar a exoneração dos ocupantes de cargos em desconformidade com a interpretação fixada, no prazo de até 20 dias após a publicação da ata do julgamento. No caso, o descumprimento de preceitos fundamentais teria ocorrido por atos normativos e atos concretos. No plano normativo, por ato do CNMP, que derogara resolução que tratava das vedações ao exercício de cargo ou função pública por membro do Ministério Público. No plano concreto, por atos de nomeação de membros do Ministério Público para ocupar cargos fora da instituição e, em especial, a nomeação de procurador de justiça para o cargo de Ministro de Estado da Justiça. Inicialmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da arguição. O pedido estaria ancorado em suposta violação a preceitos fundamentais da independência dos Poderes (CF, art. 2º e art. 60, § 4º, III) e da independência funcional do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º) consubstanciados na vedação aos promotores e procuradores de exercerem “qualquer outra função pública, salvo uma de magistério” (CF, art. 128, § 5º, II, “d”). Além disso, tendo em vista o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o juízo de subsidiariedade levaria em conta, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Assim, ante a inexistência de processo de índole objetiva apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia constitucional, não haveria como deixar de reconhecer a admissibilidade da arguição de descumprimento.

mento de preceito fundamental. Isso porque as ações originárias e o recurso extraordinário não seriam capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma geral, definitiva e imediata. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia da ação e indeferia a medida cautelar. Assinalava que haveria meio próprio para afastar do cenário jurídico a designação de procurador de justiça para figurar como Ministro de Estado. Na espécie, já se teria ajuizado ação popular para esse fim. Da mesma forma, seria cabível ação direta de inconstitucionalidade para atacar a resolução do CNMP. Vencido, em menor extensão, o Ministro Edson Fachin, que não conhecia da arguição de preceito fundamental quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da mencionada resolução, diante do não atendimento do princípio da subsidiariedade. ADPF 388/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 9.3.2016. (ADPF-388)

(Informativo 817)

► **Exercício do cargo de Ministro de Estado por membro do Ministério Público e vedações constitucionais - 2**

Em seguida, a Corte resolveu superar a análise do pedido de medida liminar e apreciou diretamente o mérito da ação. Entendeu que a autorização criada pela Resolução 72/2011 seria flagrantemente inconstitucional. A Constituição vedara aos promotores e procuradores o exercício de “qualquer outra função pública, salvo uma de magistério” (art. 128, § 5º, II, “d”). Observou que o constituinte enfatizara que a vedação não seria simplesmente ao exercício de “outra função pública”, mas ao exercício de “qualquer outra função pública”, regra cuja única exceção seria a de magistério. Sublinhou que o art. 129, IX, da CF não deveria ser lido como uma espécie de cláusula de exceção. Esse dispositivo seria o inciso final da lista de funções institucionais do “parquet” enumerada no texto constitucional. De acordo com sua redação, competiria ao Ministério Público “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. Essa disposição seria relativa às funções da instituição Ministério Público e não aos seus membros. Norma com dupla função. Uma primeira, de abertura do rol das atribuições ministeriais, que explicitaria que a lista do art. 129 seria “*numerus apertus*”, de modo que poderia ser ampliada. Uma segunda, reforçaria a completa separação, inaugurada pela Constituição de 1988, do Ministério Público com a advocacia pública, ao afastar o “parquet” de realizar “a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. O entendimento de que a vedação seria quanto ao exercício concomitante de funções de promotor e outras funções fora da instituição não passaria pela leitura do texto constitucional. A vedação ao exercício de outra função pública vigeria “ainda que em disponibilidade”. Ou seja, enquanto não rompido o vínculo com a instituição. Ao exercer cargo no Poder Executivo, o membro do Ministério Público passaria a atuar como subordinado ao chefe da Administração. Isso fragilizaria a instituição Ministério Público, que poderia ser potencial alvo de captação por interesses políticos e de submissão dos interesses institucionais a projetos pessoais de seus próprios membros. Por outro lado, a independência em relação aos demais ramos da Administração Pública seria uma garantia dos membros do Ministério Público, que poderiam exercer suas funções de fiscalização do exercício do Poder Público sem receio de reverses. O CNMP adotara orientação afrontosa à Constituição e à jurisprudência do STF. Criara uma exceção à vedação

constitucional, que textualmente não admitiria exceções. O Conselho não agira em conformidade com sua missão de interpretar a Constituição. Pelo contrário, se propôs a mudá-la, com base em seus próprios atos. Ressaltou, no entanto, que a forma federativa de Estado (CF, art. 60, § 4º, I) não fora violada pela nomeação de membro de poder de unidade da Federação para ocupar cargo no governo federal. Se fosse viável a ocupação do cargo na Administração Federal, seria ela mediante afastamento do cargo na origem. Assim, esse argumento seria de todo improcedente. Por fim, não se acolheu o pleito de anulação imediata da nomeação do Ministro da Justiça. ADPF 388/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 9.3.2016. (ADPF-388)

(Informativo 817)

► **ADI: Tribunal de Contas estadual e vício de iniciativa**

O Plenário, em julgamento conjunto, deferiu medidas acauteladoras para suspender a eficácia dos artigos 1º a 9º e 11 a 20 da LC 666/2015 do Estado de Santa Catarina. A norma dispõe sobre competência e organização do Tribunal de Contas estadual, bem assim sobre a estrutura do Ministério Público atuante junto àquele órgão. O Colegiado assinau que o projeto de lei, apresentado pelo Tribunal de Contas, fora submetido à Assembleia Legislativa estadual, que incluía 19 artigos a versar sobre objetos distintos do veiculado no único dispositivo constante do texto original. Não se tratara de simples emenda, mas de inclusão e de supressão de preceitos relacionados a questões estranhas à contida na proposição inicial, a configurar aparente vício de iniciativa.

ADI 5442 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 17.3.2016. (ADI-5442)

ADI 5453 MC/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 17.3.2016. (ADI-5453)

(Informativo 818)

► **Auditoria do TCU e participação de servidor indiretamente afetado**

Tratando-se de auditoria do TCU, considerada a gestão administrativa do Poder Legislativo, não há como concluir pelo direito dos servidores indiretamente afetados de serem ouvidos no processo fiscalizatório. Com esse entendimento, a Primeira Turma indeferiu ordem em mandado de segurança no qual se questionava decisão da referida Corte de Contas a respeito de auditoria realizada com o objetivo de averiguar a regularidade de valores constantes na folha de pagamentos dos servidores da Câmara dos Deputados. O Colegiado consignou a desnecessidade de o impetrante — servidor daquela Casa Legislativa — ser convocado para integrar o processo referente à auditoria. MS 32540/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 29.3.2016. (MS-32540)

(Informativo 819)

► **ADI: “Impeachment” e ordem de votação - 1**

O Plenário, por maioria, indeferiu pedido formulado em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra os artigos 218, § 8º, e 187, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) [“Art. 218. É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara dos Deputados o Presidente da República, o Vice-

-Presidente da República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade. (...) § 8º Encerrada a discussão do parecer, será o mesmo submetido à votação nominal, pelo processo de chamada dos Deputados. (...) Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas às instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização. (...) § 4º Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os arts. 217, IV, e 218, §8º, a votação nominal será feita pela chamada dos Deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa, observando-se que: I - os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos Secretários; II - os Deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação; III - as abstenções serão também anotadas pelo Secretário”]. Preliminarmente, o Tribunal, por maioria conheceu da ação, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, que dela não conheciam por considerarem que a questão discutida configuraria matéria “inter-na corporis”, insuscetível de controle abstrato de constitucionalidade.

ADI 5498 MC/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-5498)

(Informativo 821)

► ADI: “Impeachment” e ordem de votação - 2

Em seguida, o Colegiado afirmou que o autor da petição inicial não teria demonstrado de que modo os dispositivos atacados teriam ofendido os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da impessoalidade, da moralidade e da República. A mera invocação genérica de transgressão a um postulado constitucional não seria suficiente para legitimar o ajuizamento de ação direta. Não bastaria, portanto, deduzir-se a pretensão de inconstitucionalidade. Seria preciso não apenas indicar os valores, os princípios, mas também estabelecer as razões jurídicas que pudessem legitimar a pretendida ocorrência de violação às normas de parâmetro invocadas no processo de controle objetivo de constitucionalidade. Avaliou que o requerente teria articulado minimamente a alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal, ao aduzir que a votação poderia gerar efeito cascata, de modo que os primeiros votos pudessem influenciar os últimos, o que comprometeria o princípio da imparcialidade. Entretanto, qualquer tipo de votação nominal, independentemente do critério adotado, jamais afastaria o efeito cascata. Logo, a única forma de acabar com tal efeito seria eliminar a votação nominal, o que seria absurdo. Assim, inexistindo incompatibilidade entre o dispositivo regimental com qualquer preceito constitucional, não se vislumbrou a relevância do direito, o que seria razão para indeferir a medida liminar. Ademais, o Tribunal sublinhou que não se poderia exigir isenção e imparcialidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na realidade, o “impeachment” seria uma questão política que haveria de ser resolvida com critérios políticos. A garantia da imparcialidade estaria no alto quórum exigido para a votação.

ADI 5498 MC/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-5498)

(Informativo 821)

► **ADI: “Impeachment” e ordem de votação - 3**

Vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Ricardo Lewandowski (Presidente) e, em menor extensão, o Ministro Roberto Barroso. O Ministro Marco Aurélio deferia a liminar para suspender a eficácia do art. 187, § 4º, do RICD, no tocante ao alcance do critério para julgamento do Presidente da República. Assentava que a votação deveria ocorrer de forma nominal e por ordem alfabética dos parlamentares, nos termos adotados no processo de impedimento de Presidente Fernando Collor, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. Os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski concediam a liminar para emprestar interpretação conforme e declarar como única interpretação constitucional compatível com o devido processo legislativo aquela que respeitasse a literalidade do § 4º do art. 187 do RICD. Ou seja, aquela que estabelecesse que a chamada fosse feita pelos deputados, de forma alternada e individualizada, considerada a ordem geográfica das capitais com suas respectivas latitudes. O Ministro Roberto Barroso concedia parcialmente a liminar para fixar interpretação conforme de modo que a votação fosse nominal, por bancada, alternadamente, de norte para sul e vice-versa, observada a exata latitude da capital de cada Estado-Membro. ADI 5498 MC/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-5498)

(Informativo 821)

► **“Impeachment” e ordem de votação - 1**

Ante o empate na votação, o Plenário indeferiu pedidos de medida cautelar formulados em mandados de segurança impetrados em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados, no qual fora formalizada interpretação conferida ao art. 187, § 4º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (“Art. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrônico de votos, obedecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização. ... § 4º Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e nas hipóteses de que tratam os arts. 217, IV, e 218, §8º, a votação nominal será feita pela chamada dos Deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa, observando-se que: I - os nomes serão enunciados, em voz alta, por um dos Secretários; II - os Deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria em votação; III - as abstenções serão também anotadas pelo Secretário”). Manteve-se, em razão disso, o ato impugnado, segundo o qual a autoridade coatora assentara, em síntese, que: “a) (...) a chamada terá início por um Estado da região norte e, em alternância, será chamado um Estado da região sul. Em seguida, em razão do ‘vice-versa’, será chamado um Estado da região sul e, depois, um Estado da região norte, e assim sucessivamente, passando pelas demais regiões; b) a ordem dos Estados seguirá a tradição da Casa, a disposição constante no painel de votação e, por analogia, a ordem geográfica das capitais prevista no art. 3º, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (...)”. De início, a Corte deliberou não caber sustentação oral em apreciação de liminar em mandado de segurança, porquanto: a) o art. 937, § 3º, do novo CPC, prevê o cabimento de sustentação oral em julgamento de mandado de segurança unicamente no “agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga”; e b) o art. 16 da Lei 12.016/2009 prevê a sustentação oral em mandado de segurança na sessão de julgamento de mé-

rito, e não em liminar. Em seguida, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, ao fundamento de que o “writ” adentrava em matérias “interna corporis” da Câmara dos Deputados. Além disso, não se teria, no caso, questão a envolver direito subjetivo.

MS 34127 MC/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-34127)

MS 34128 MC/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-34128)

(Informativo 821)

► “Impeachment” e ordem de votação - 2

No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, que indeferiu a medida cautelar. Considerou o ato atacado compatível com uma interpretação possível do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Além disso, não haveria, na espécie, matéria constitucional relevante. Os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram tal entendimento. Por sua vez, o Ministro Roberto Barroso (relator) também reputou a interpretação do Presidente da Câmara dos Deputados compatível com o citado dispositivo regimental. No entanto, deferiu apenas parcialmente a medida cautelar para determinar que a autoridade impetrada observasse, na chamada dos deputados para votação nominal em Plenário — referente à denúncia por crime de responsabilidade supostamente praticado pela Presidente da República —, a alternância entre norte e sul, considerando-se, para tanto, a latitude das capitais dos Estados-Membros. A Ministra Rosa Weber perfilhou essa orientação. O Ministro Edson Fachin, ao reportar-se ao voto proferido no julgamento da ADI 5.498 MC/DF (acima noticiada), deferiu a cautelar, em maior extensão, no que foi acompanhado pelos Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente). Asseverou que deveria haver a votação nominal pela chamada dos deputados, alternadamente, do norte para o sul e vice-versa.

MS 34127 MC/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-34127)

MS 34128 MC/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, 14.4.2016. (ADI-34128)

(informativo 821)

► Magistratura: triênio para ingresso na carreira e momento de comprovação

A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público. Essa a conclusão do Plenário, tomada por maioria de votos, em recurso extraordinário no qual se discutia o momento de comprovação de tal exigência: se no ato da inscrição definitiva ou na data da posse. Pretendia-se que a ausência de especificação de data certa no edital para o início da inscrição definitiva transferiria para a data da nomeação a comprovação de tempo de prática

forense. O Tribunal assinalou que a controvérsia fora dirimida na ADI 3.460/DF (DJe de 12.3.2015), oportunidade em que definido como termo final para comprovação de atividade jurídica, nos termos da reforma empreendida pela EC 45/2004, a data de inscrição definitiva no concurso público. Isso porque é importante que todos os candidatos que adentrem na disputa tenham condições para o exercício do cargo naquele momento, inclusive para se evitar o óbice do certame em razão de medidas judiciais precárias, voltadas a tratar de excepcionalidades, ou mesmo para se prevenir a existência de cargos vagos “sub judice” por período indeterminado. Além disso, impende observar o princípio da isonomia. Nesse sentido, o edital serve para orientar os potenciais candidatos sobre a possibilidade de serem aprovados, tendo em vista o preenchimento dos requisitos exigidos. Não se pode estimular, assim, aqueles que não atendem às exigências a adentrar no certame, com a esperança de logrem êxito judicialmente, tendo em vista que houvera outros que, nas mesmas condições, optaram por obedecer à regra prescrita e não efetuaram inscrição. Ademais, definir a data da posse como termo apresenta outro revés, pois privilegia aqueles com pior classificação no concurso, que teriam mais tempo para completar o triênio. No caso concreto, entretanto, o Colegiado negou provimento ao recurso extraordinário da União. Na situação dos autos, o requerimento de inscrição definitiva da candidata no certame fora indeferido por ausência de comprovação do triênio até aquela data. A Corte entendeu que se deveria assegurar a posse da recorrida porque, no edital do concurso, não houvera especificidade quanto à data para comprovação do período de atividade jurídica. Além disso, a fase de inscrição definitiva, em relação à candidata, estava sendo discutida judicialmente e, nesse ínterim, o triênio transcorreria. Vencidos, quanto à tese fixada em repercussão geral, os Ministros Luiz Fux (relator), Roberto Barroso e Marco Aurélio, que entendiam que a exigência trazida pela EC 45/2004 tem relação com o ingresso na carreira — que se dá com a posse — e não com a inscrição em concurso público. Por fim, o Plenário decidiu que a redação para o acórdão deve incumbir ao Ministro que encampa a tese firmada. RE 655265/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 13.4.2016. (RE-655265)

(Informativo 821)

► MS e perda de nacionalidade brasileira

A Primeira Turma, por maioria, denegou mandado de segurança em que se questionava ato do ministro da Justiça que declarara a perda da nacionalidade brasileira da impetrante (CF, art. 12, § 4º, II), por ter adquirido outra nacionalidade (Lei 818/1949, art. 23). No caso, a impetrante, brasileira nata, obtivera a nacionalidade norte-americana de forma livre e espontânea e, posteriormente, fora acusada, nos Estados Unidos da América, da prática de homicídio contra seu marido, nacional daquele país. Diante disso, o governo norte-americano indiciara a impetrante e requereu às autoridades brasileiras a prisão para fins de extradição. O Colegiado entendeu que o ato do ministro da Justiça de cassação da nacionalidade brasileira é legítimo, pois a impetrante perdera a nacionalidade brasileira ao adquirir outra em situação que não se enquadraria em qualquer das duas exceções constitucionalmente previstas: (i) tratar-se de mero reconhecimento de outra nacionalidade originária, considerada a natureza declaratória desse reconhecimento (art. 12, § 4º, II, “a”); e (ii) ter sido a

outra nacionalidade imposta pelo Estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis (art. 12, § 4º, II, “b”). Por fim, a Turma revogou a liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu provisoriamente a eficácia da portaria ministerial de cassação da nacionalidade. Vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, que concediam a segurança. O Ministro Edson Fachin assentava que o brasileiro nato não poderia ser extraditado pelo Brasil a pedido de governo estrangeiro, porque se cuidaria de garantia fundamental que não comporta exceção. Salientava ainda que se a extradição não for concedida, legitimar-se-á ao Estado Brasileiro, mediante a aplicação extraterritorial de sua própria lei penal, fazer instaurar a persecução criminal. O Ministro Marco Aurélio reputava que, em se tratando de mandado de segurança contra ato de ministro da Justiça, o órgão competente para julgamento é o Superior Tribunal de Justiça. Além disso, concluía que o direito à condição de brasileiro nato seria indisponível. MS 33864/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 19.4.2016. (MS-33864)

(Informativo 822)

► Competência da União em telefonia

Compete à União explorar os serviços de telecomunicações, bem como legislar privativamente sobre essa matéria (CF, artigos 21, XI e 22, IV). Com base nessa orientação, o Plenário reafirmou sua reiterada jurisprudência sobre o tema e julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei 12.239/2006 do Estado de São Paulo. A norma estadual declarada inconstitucional dispõe sobre a instituição de cadastro com os números das linhas telefônicas dos assinantes do serviço de telefonia interessados no sistema de venda por via telefônica. ADI 3959/SP, rel. Min. Roberto Barroso, 20.4.2016. (ADI-3959)

(Informativo 822)

► Emenda parlamentar e aumento de despesa

É inconstitucional norma resultante de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, na hipótese em que a emenda apresentada acarrete aumento de despesa (CF, art. 61, § 1º, II, “a” e art. 63, I). Esse o entendimento do Plenário, que, ao reafirmar a jurisprudência assentada na matéria, confirmou medida cautelar (noticiada no Informativo 299) e julgou procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 3º, “caput” e parágrafo único, da Lei 11.753/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Tais preceitos, de iniciativa parlamentar, dispõem sobre o realinhamento dos vencimentos de servidores do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS). ADI 2810/RS, rel. Min. Roberto Barroso, 20.4.2016. (ADI-2810)

(Informativo 822)

► Fazenda Pública e atuação em juízo - 1

O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada em face dos artigos 4º e 10 da Medida Provisória 2.102-27/2001. O art. 4º acrescentara os artigos 1º-B e 1º-C à Lei 9.494/1997 (“Art. 1º-B. O prazo a que se refere o “caput”

dos arts. 730 do Código de Processo Civil, e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a ser de trinta dias. Art. 1º-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”). Já o art. 10, também impugnado na ação, inserira parágrafo único ao art. 741 do CPC/1973 (“Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”). A Corte destacou, de início, que não teria havido a perda de objeto da ação, relativamente ao parágrafo único do art. 741 do CPC/1973, revogado pela Lei 13.105/2015, que estatui um novo Código. A matéria disciplinada no referido dispositivo teria recebido tratamento normativo semelhante, embora não igual, nos §§ 5º a 8º do art. 535 e nos §§ 12 a 15 do art. 525 do novo CPC. As alterações sofridas pela norma em questão — que cuidaram apenas de adjetivar o instituto da inexigibilidade por atentado às decisões do STF — não teriam comprometido aquilo que ela teria de mais substancial, ou seja, a capacidade de interferir na coercitividade de títulos judiciais. Este seria, de fato, o aspecto objeto de impugnação pelo autor da ação direta, para quem o instituto frustraria a garantia constitucional da coisa julgada. Portanto, não havendo desatualização significativa no conteúdo do instituto, não haveria obstáculo para o reconhecimento da ação (ADI 2.501/MG, DJe de 19.12.2008). No mérito, o Plenário afirmou que a ampliação de prazo para a oposição de embargos do devedor pela Fazenda Pública, inserida no art. 1º-B da Lei 9.494/1997, não violaria os princípios da isonomia e do devido processo legal. Isso porque o estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, inclusive em relação a prazos diferenciados, quando razoáveis, não constituiria propriamente restrição a direito ou prerrogativa da parte adversa, mas buscaria atender ao princípio da supremacia do interesse público. Por outro lado, a fixação do prazo de trinta dias para a Fazenda apresentar embargos à execução não poderia ser tido como irrazoável. Afinal, tratar-se-ia de prazo idêntico ao que tem o particular para apresentar esses mesmos embargos nas execuções fiscais contra ele movidas pela Fazenda Pública, conforme estatuído pelo art. 16 da Lei 6.830/1980. A rigor, portanto, sequer haveria diferença de tratamento normativo entre as pessoas privadas e as de direito público.

ADI 2418/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 4.5.2016. (ADI-2418)

(Informativo 824)

► Fazenda Pública e atuação em juízo - 2

A Corte asseverou também que a fixação do prazo prescricional de 5 anos para os pedidos de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, constante do art. 1º-C da Lei 9.494/1997, igualmente não violaria dispositivo constitucional. Esse preceito teria simplesmente reproduzido o que já dispunha o art. 1º do Decreto 20.910/1932. A única novidade teria sido incluir, entre os destinatários da norma, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, atribuindo-lhes o mesmo regime prescricional das pessoas jurídicas de direito público. A equiparação

se justificaria em razão do que disposto no § 6º do art. 37 da CF, que expressamente equipara essas entidades às pessoas de direito público relativamente ao regime de responsabilidade civil pelos atos praticados por seus agentes. Outrossim, o CC/2002 estabelecerá prazo prescricional de apenas 3 anos para “a pretensão de reparação civil” (art. 206, § 3º, V). Portanto, considerando o atual estágio normativo civil, a norma atacada, antes de beneficiar, seria, na verdade, desvantajosa para a Fazenda Pública e as empresas concessionárias de serviço público. Por fim, não haveria igualmente como negar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973, bem como dos correspondentes dispositivos do CPC/2015 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º). Seriam dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, apenas agregariam ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de certas sentenças inconstitucionais, em tudo semelhante às hipóteses de ação rescisória (CPC/1973, art. 485, V; CPC/2015, art. 966, V). O instituto da coisa julgada, embora de matriz constitucional, teria sua conformação delineada pelo legislador ordinário, ao qual seria conferida a faculdade de estabelecer seus limites objetivos e subjetivos, podendo, portanto, indicar as situações em que o instituto cedesse passo a postulados, princípios ou bens de mesma hierarquia, porque também juridicamente protegidos pela Constituição. A interpretação literal do dispositivo em comento apontaria a existência de três vícios de inconstitucionalidade, na sentença exequenda, a permitir a utilização do mecanismo nele previsto: a) a aplicação de lei inconstitucional; b) a aplicação da lei a situação considerada inconstitucional; ou, ainda, c) a aplicação da lei com um sentido — uma interpretação — inconstitucional. Haveria um elemento comum às três hipóteses: o da inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. Entretanto, considerado o atual sistema de controle de constitucionalidade e os efeitos das sentenças do STF dele decorrentes, constatar-se-ia a existência de outra situação, implícita, que autorizaria a invocação da inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial: quando a sentença exequenda reconhecesse a inconstitucionalidade de norma que o STF tiver declarado constitucional.

ADI 2418/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 4.5.2016. (ADI-2418)

(Informativo 824)

► Fazenda Pública e atuação em juízo - 3

O Plenário ressaltou que, por outro lado, seria indispensável à aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC — ou dos correspondentes dispositivos do novo CPC/2015 — que a sentença exequenda tivesse dirimido a questão constitucional em sentido contrário ao que decidido pelo STF. No regime do CPC/1973 não haveria distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente à sentença exequenda, apesar de que, na hipótese de precedência da decisão do STF, ficaria evidenciado o desrespeito à autoridade da Suprema Corte. No atual regime — CPC/2015 —, sendo a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, caberia ação rescisória, com prazo contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Desse modo, a inexigibilidade do título executivo a que se refere o referido dispositivo se caracterizaria exclusivamente nas hipóteses em que: a) a sentença exequenda estivesse fundada em norma reconhecidamente inconstitu-

cional, fosse por aplicar norma inconstitucional, fosse por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; b) a sentença exequenda tivesse deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tivesse decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido em relação ao vício de inconstitucionalidade formal. Isso se daria porque a medida provisória em questão portaria defeitos alusivos aos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Ademais, julgava o pedido procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade material das mudanças procedidas pela medida provisória relativamente: a) ao prazo dos embargos à execução; e b) à inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. ADI 2418/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 4.5.2016. (ADI-2418)

(Informativo 824)

► **Parlamentar e afastamento do cargo - 1**

Por reputar que os elementos fáticos e jurídicos teriam demonstrado que a presença de parlamentar na função de Presidente da Câmara dos Deputados representaria risco para as investigações penais sediadas no Supremo Tribunal Federal, o Plenário referendou medida cautelar deferida em ação cautelar ajuizada pelo Procurador-Geral da República, no âmbito de inquéritos já instaurados na Corte. A decisão referendada decretara a suspensão do exercício do mandato de deputado federal e, em decorrência, da função de Presidente da Câmara dos Deputados. O Tribunal também determinou que fosse notificado o Primeiro-Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, ou, na sua ausência, o Segundo-Vice-Presidente (Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art. 18), do inteiro teor da presente decisão, a fim de dar-lhe cumprimento, nos termos regimentais próprios. Na espécie, embora se tratasse de providência inserida no rol das competências originárias do relator das ações penais (Lei 8.038/1990, art. 2º, “caput” e parágrafo único), a decisão fora levada a referendo do Plenário pela relevância institucional de suas consequências. O Colegiado reputou que de forma minuciosa o Ministério Público Federal descrevera diversos fatos supostamente criminosos e praticados com desvio de finalidade, sob a atuação direta do referido parlamentar que estaria a utilizar o cargo de deputado federal e a função de Presidente da Câmara dos Deputados para fins ilícitos e, em especial, para obtenção de vantagens indevidas. Apontou que a reforma positivada pela Lei 12.403/2011 no CPP trouxe alterações quanto à decretação de medidas de cautela, entre as quais o estabelecimento da preferencialidade do uso de meios alternativos à prisão preventiva. É o que dispõe o art. 282, § 6º da referida norma [“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: ... § 6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”]. Entretanto, o cabimento da medida suspensiva reclama inevitável leitura a respeito da existência de riscos que possam transcender a própria instância processual penal, sobretudo quando se tratar do exercício de funções públicas relevantes. Nestes casos, a decretação da medida servirá a dois interesses públicos indivisíveis: a) a preservação da utilidade do processo (pela neutralização de uma posição de poder que possa tornar o trabalho de persecução mais acidentado); e b) a preservação da

finalidade pública do cargo (pela eliminação da possibilidade de captura de suas competências em favor de conveniências particulares sob suspeita).

AC 4070/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 5.5.2016. (AC-4070)

(Informativo 824)

► Parlamentar e afastamento do cargo - 2

O relator lembrou que o CPP tutela igualmente e a um só tempo o risco tanto da prática da delinquência no poder quanto do uso do poder para delinquir (“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: ... VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”). Esclareceu que compete a cada uma das Casas Parlamentares a grave missão institucional de decidir sobre a cassação do título que investe deputados e senadores nos poderes inerentes à representação popular. Isso implica admitir por mais excêntrico que possa parecer à consciência cívica em geral que um mandato parlamentar pode vir a subsistir ainda quando o seu titular tenha tido seus direitos políticos suspensos pela justiça, por decisão transitada em julgado (“Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; ... VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. ... § 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”). O preceito trabalha com uma lógica de harmonia entre Poderes, que não interdita o funcionamento de qualquer um deles. Pelo contrário, permite que cada um funcione dentro de suas respectivas competências. O Poder Judiciário se pronuncia quanto à formação da culpa, enquanto o Poder Legislativo se manifesta sobre a cessação do mandato, cabendo a esta última instância justificar o seu entendimento sobre a subsistência de vínculo de representatividade já debilitado no seu substrato de legitimidade diante dos apelos da opinião pública. Segundo o Plenário, a ascensão política do investigado à posição de Presidente da Câmara, além de não imunizá-lo de eventuais medidas penais de caráter cautelar, concorre para que o escrutínio a respeito do cabimento dessas medidas seja ainda mais aprofundado. Afinal, de acordo com o art. 282, II, do CPP, o exame deve considerar as condições pessoais do agente, o que remete, quando a medida postulada for aquela do art. 319, VI, do mesmo Código, a investigação sobre a realidade de Poder em que ele está inserido (“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: ... II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”). Por óbvio, quando se trata de responsabilidades da liderança de uma das duas Casas Legislativas mais importantes da Nação, que exige escrúpulos compatíveis com a sua altíssima honorabilidade, mais intensa deve ser a crítica judiciária a respeito da presença de riscos para o bom desenvolvimento da jurisdição penal. Depoimentos de testemunhas, documentos e mensagens em telefones celulares demonstraram a atuação do parlamentar que, de forma reiterada, agiria com aparente desvio de finalidade e para o alcance de fins ilícitos, entre eles o recebimento ilícito de valores

expressivos. Ainda, teria o parlamentar colocado seus aliados em cargos chaves de importante CPI para fins de constranger colaboradores, bem como para evitar que ele próprio fosse investigado, além de desqualificar pessoas, empresas e políticos que se disponibilizaram a colaborar com a elucidação dos crimes.

AC 4070/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 5.5.2016. (AC-4070)

(Informativo 824)

► **Parlamentar e afastamento do cargo - 3**

O Colegiado considerou que os episódios narrados configurariam caso típico de abuso de poder que merece a intervenção do Judiciário, sob pena de comprometer o resultado final da investigação e, portanto, da aplicação da lei penal. Destacou o fato de que o cumprimento de qualquer diligência investigatória na Câmara dos Deputados deve ser precedido de autorização de sua Mesa Diretora, que é presidida pelo parlamentar em questão. Ou seja, a produção de provas em relação a eventuais ilícitos praticados pelo Presidente da Câmara dependeria de prévia autorização do próprio investigado. Ainda que a perfeita interação entre os Poderes seja a situação idealizada como padrão pela Constituição, que deles exige harmonia, isso se manifesta claramente impossível quando o investigado é, como no caso, o próprio Presidente da Mesa Diretora. Portanto, embora não seja a prévia autorização do Parlamento um pressuposto de validade do ato investigatório, porque ausente previsão constitucional que malfira a jurisdição do STF, não há dúvida de que a condição de investigado do Presidente da Câmara compromete a harmonia entre os Poderes da República. Ainda que não seja o momento de se formular juízo definitivo acerca dos fatos narrados, há indícios de que o requerido, na condição de parlamentar e, mais ainda, na de Presidente da Câmara dos Deputados, tem meios e é capaz de efetivamente obstruir a investigação e a colheita de provas, intimidar testemunhas e impedir, ainda que, indiretamente, o regular trâmite da ação penal em curso no STF, assim como das diversas investigações existentes nos inquéritos regularmente instaurados. Frisou haver fato superveniente ao pedido ora analisado consistente no fato de o Conselho de Ética daquela Casa Legislativa haver admitido a representação formulada em desfavor do requerido. Além disso, o estado de suspeição que paira sobre a figura do atual ocupante da presidência da Casa Legislativa — formalmente acusado por infrações penais e disciplinares — contracena negativamente com todas suas responsabilidades, principalmente quando há ponderáveis elementos indiciários a indicar que ele articulou uma rede de obstrução contra as instâncias de apuração dos pretensos desvios de conduta que lhe são imputados.

AC 4070/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 5.5.2016. (AC-4070)

(Informativo 824)

► **Parlamentar e afastamento do cargo - 4**

A presença do requerido na função por ele ora ocupada além representar risco para as investigações penais sediadas no Supremo Tribunal Federal, é um pejorativo que conspira contra a própria dignidade da instituição por ele liderada. O exercício do cargo, nas circunstâncias indicadas, compromete a vontade da Constituição, sobre-

tudo a que está manifestada nos princípios de probidade e moralidade que devem governar o comportamento dos agentes políticos. A Corte asseverou que todo ocupante de mandato tem ao menos dois compromissos a respeitar: um deles é com os seus representados; o outro é com o do projeto de país que ele se obriga a cumprir ao assumir sua função pública. A atividade parlamentar só poderá ser exercida, com legitimidade, se for capaz de reverenciar essas duas balizas. Se os interesses populares vierem a se revelar contrários às garantias, às liberdades e ao projeto de justiça da Constituição, lá estará o STF para declará-los nulos, pelo controle de constitucionalidade. No entanto, não são apenas os produtos legislativos que estão submetidos ao controle judicial. Também o veículo da vontade popular — o mandato — está sujeito a controle. A forma preferencial para que isso ocorra é pelas mãos dos próprios parlamentares. Mas, em situações de excepcionalidade, em que existam indícios concretos a demonstrar riscos de quebra da respeitabilidade das instituições, é papel do STF atuar para cessá-los, garantindo uma república para os comuns, e não uma comuna de intocáveis. O Tribunal concluiu que, em razão dos fatos descritos, a medida postulada mostra-se necessária, adequada e suficiente. AC 4070/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 5.5.2016. (AC-4070)

(Informativo 824)

► **Magistratura e limites de despesas médicas e odontológicas conferidas por lei estadual**

A Primeira Turma, por maioria, concedeu mandado de segurança para assentar a insubsistência de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinara a cessação do ressarcimento de despesas médicas, cirúrgicas e odontológicas de magistrados, benefício previsto em lei estadual (Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso). O Ministro Marco Aurélio (relator), de início, reconheceu a legitimidade ativa do ente federado, tendo em conta o afastamento da lei estadual pelo CNJ. Em seguida, afastou eventual alegação de decadência do “mandamus”, porque ausente a cientificação do Estado-Membro do ato impugnado, haja vista não ter sido parte no procedimento administrativo realizado pelo CNJ. Quanto ao mérito, assentou que a Lei Complementar 35/1979 (Loman), ao vedar a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias nela não previstas, não atinge as verbas de natureza indenizatória consagradas em legislação estadual, no caso, o Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. Assim, nos termos perquiridos no mandado de segurança, a lei estadual não conflita com a Loman e com a Constituição Federal. O Ministro Edson Fachin, ao acompanhar a conclusão do relator, ressaltou o entendimento de que a decisão do CNJ de declaração de inconstitucionalidade de lei estadual desborda da finalidade e da competência específica do órgão. Vencidos os Ministros Roberto Barroso e Rosa Weber, que denegavam a segurança. O Ministro Roberto Barroso reputava que a possibilidade de ressarcimento irrestrito de despesas médicas e o pagamento de passagens aéreas para a realização de tratamentos médicos contrariariam não só o art. 65, §2º, da Loman, que veda a concessão de vantagem nela não prevista, mas também o art. 195, §5º, da CF, que não permite a criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade social (saúde, previdência e assistência social) sem a respectiva fonte de custeio. Acrescentava que o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas funções, tem legiti-

midade para deixar de aplicar uma norma em face da supremacia da Constituição. MS 27463/MT, rel. Min. Marco Aurélio, 10.5.2016. (MS-27463)

(Informativo 825)

► **EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 6**

O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, indeferiu pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade em que se pretendia a suspensão da eficácia do § 3º do art. 134 da CF, introduzido pela EC 74/2013, segundo o qual se aplica às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal o disposto no § 2º do mesmo artigo, este introduzido pela EC 45/2004, a assegurar às Defensorias Públicas estaduais autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º, da CF — v. Informativos 802 e 804. O Colegiado equacionou que a controvérsia diria respeito à aplicabilidade, às propostas de emenda constitucional, da cláusula de iniciativa legislativa reservada à Presidência da República (CF, art. 61, § 1º). Além disso, discutia-se eventual ofensa ao postulado da separação de Poderes (CF, art. 60, § 4º, III) em decorrência da edição de emenda constitucional sobre matéria disposta no art. 61, § 1º, II, da CF, sem que o processo constituinte reformador tenha sido deflagrado pelo titular da iniciativa fixada nesse dispositivo para as leis complementares e ordinárias. A respeito, o direito constitucional pátrio inscreve a emenda constitucional entre os atos elaborados por meio de processo legislativo (CF, art. 59). A jurisprudência da Corte reconhece, com apoio no princípio da simetria, a inconstitucionalidade de emendas a Constituições estaduais, por inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Não há, por outro lado, precedente do Colegiado a assentar, no plano federal, a sujeição do poder constituinte derivado à cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Executivo prevista de modo expresso no art. 61, § 1º, da CF, para o Poder Legislativo complementar e ordinário (poderes constituídos). A orientação de que o poder das assembleias legislativas de emendar constituições estaduais está sujeito à reserva de iniciativa do Executivo local existe desde antes do advento da CF/1988. O poder constituinte, originário ou derivado, delimita as matérias alçadas ao nível constitucional, e também aquelas expressamente atribuídas aos legisladores ordinário e complementar. Assim, norma de constituição estadual dotada de rigidez não imposta pela Constituição Federal é contrária à vontade desta. Portanto, não se reveste de validade constitucional a emenda a Constituição estadual que, subtraindo o regramento de determinada matéria do titular da reserva de iniciativa legislativa, eleva-a à condição de norma constitucional. Desse modo, emana da jurisprudência do STF a visão de que o poder constituinte estadual jamais é originário. É poder constituído, cercado por limites mais rígidos do que o poder constituinte federal. A regra da simetria é exemplo disso. Por essa razão, as assembleias legislativas se submetem a limites rígidos quanto ao poder de emenda às constituições estaduais. Entretanto, não há precedentes no sentido de que as regras de reserva de iniciativa contempladas no art. 61 da CF alcançam o processo de emenda à Constituição disciplinado em seu art. 60. ADI 5296 MC/DF, rel. Min. Rosa Weber, 18.5.2016. (ADI-5296)

(Informativo 826)

► **EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 7**

O Tribunal consignou que os limites formais ao poder constituinte derivado são os inscritos no art. 60 da CF, segundo o qual a Constituição poderá ser emendada mediante proposta: a) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; b) do Presidente da República; ou c) de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Já a iniciativa privativa de leis sobre determinadas matérias é assegurada, no plano federal, ao Presidente da República, ao STF, aos tribunais superiores e ao Procurador-Geral da República. Não existe, portanto, identidade entre o rol dos legitimados para a propositura de emenda à Constituição e o dos atores aos quais reservada a iniciativa legislativa sobre determinada matéria. É, pois, insubsistente condicionar a legitimação para propor emenda à Constituição, nos moldes do art. 60 da CF, à leitura conjunta desse dispositivo com o art. 61, § 1º, que prevê as hipóteses em que a iniciativa de leis ordinárias e complementares é privativa da Presidência da República. Do contrário, as matérias cuja iniciativa legislativa é reservada ao STF, aos tribunais superiores ou ao Procurador-Geral da República não poderiam ser objeto de emenda constitucional. De um lado, nenhum daqueles legitimados figura no rol do art. 60 da CF e, de outro, nenhum dos relacionados no mesmo dispositivo pode propor emenda sobre essas matérias. Além disso, existem diversas emendas constitucionais em vigor, cuja constitucionalidade poderia ser legitimamente desafiada, se prevalecesse a tese da aplicação, às propostas de emenda, das cláusulas que reservam ao Executivo e ao Judiciário a iniciativa legislativa sobre certos temas. No caso da EC 74/2013, o preceito por ela introduzido diz respeito à Defensoria Pública como instituição, e não ao regime jurídico de seus integrantes. Ainda que, indiretamente, em momento posterior, alteração dessa natureza pudesse refletir no regime jurídico citado, a EC 74/2013 não tem como objeto o reconhecimento de vantagens funcionais, sequer equivale a norma dessa natureza. Nesse contexto, está ausente o “*fumus boni iuris*” necessário à concessão da cautelar. ADI 5296 MC/DF, rel. Min. Rosa Weber, 18.5.2016. (ADI-5296)

(informativo 826)

► **EC: vício de iniciativa e autonomia da Defensoria Pública - 8**

O Plenário acrescentou que, a se entender incidente a cláusula da reserva de iniciativa do Presidente da República sobre as propostas de emenda à Constituição, sua inobservância traduziria, também, afronta à separação de Poderes, independentemente do conteúdo material da emenda. O desequilíbrio se caracteriza pela ingerência de um poder constituído no terreno exclusivo de outro — o Executivo. Por outro lado, afastada a emenda constitucional do âmbito de incidência da cláusula de reserva de iniciativa legislativa, ainda se lhe impõem os limites materiais do art. 60, § 4º, da CF. Assim, é necessário analisar a EC 74/2013 à luz desse postulado. A respeito, o § 2º do art. 134 da CF, introduzido pela EC 45/2004, deve ser também verificado sob esse aspecto. No ponto, a legitimidade da EC 45/2004, no que assegura autonomia às Defensorias Públicas estaduais, está respaldada pela jurisprudência do STF, embora ainda não tenha sido objeto de análise específica. Entretanto, o art. 60, § 4º, da CF, não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de

entes com sede na Constituição. Esta, ressalvada a imutabilidade das cláusulas pétreas, consagra, mormente por meio das emendas constitucionais, abertura dinâmica ao redesenho das instituições, com vista a seu aperfeiçoamento, desde que observadas, no processo, as garantias constitucionais voltadas a impedir a deturpação do próprio mecanismo e a preservar a essência constitucional. No caso, sob esse enfoque, a concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, do Distrito Federal e dos Estados-Membros não parece incompatível com a ordem constitucional. Pelo contrário, essa medida é tendente ao aperfeiçoamento do próprio sistema democrático. Nesse contexto, a assistência jurídica aos hipossuficientes é direito fundamental, na linha do amplo acesso à justiça. Além disso, essa arquitetura institucional encontra respaldo em práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional, a exemplo do estabelecido na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Ademais, o art. 127, § 2º, da CF assegura ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa. Todavia, nem sempre são legítimas alterações de outra ordem ou em outros segmentos. É indispensável o exame de cada caso, em face do art. 60, § 4º, III, da CF. Ademais, as atribuições da Defensoria Pública não têm vinculação direta com a essência da atividade executiva. Por fim, o Colegiado apontou a ausência de “periculum in mora”, tendo em vista o ajuizamento da ação decorrido mais de um ano da promulgação da EC 74/2013. Além disso, o apontado risco de lesão aos cofres públicos não teria relação direta com a emenda, isso porque a Constituição, ao atribuir autonomia, não trata de autonomia financeira, mas sim administrativa e funcional. Nesse sentido, iniciativa de proposta orçamentária — a ser submetida a posterior controle do Legislativo — não implica autonomia orçamentária. Vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que deferiram a medida acauteladora. ADI 5296 MC/DF, rel. Min. Rosa Weber, 18.5.2016. (ADI-5296)

(Informativo 826)

► **Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária**
- 4

O Plenário concluiu o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade e de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discutia a autonomia de Defensorias Públicas estaduais — v. Informativo 802. Na ADI 5.286/AP, debatia-se a constitucionalidade de dispositivos da LC 86/2014 do Estado do Amapá, que atribuem ao chefe do Executivo estadual competências administrativas, como as de prover cargos e de aplicar penalidades no âmbito da Defensoria Pública local. O Colegiado, por maioria, conheceu parcialmente da ação e julgou o pedido procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade de expressões que submetem a Defensoria Pública a atos do governador, por ofensa aos artigos 24, XIII e § 1º, e 134, ambos da CF. Reputou que o conhecimento parcial da ação se impõe pelo fato de a via eleita se prestar, no caso, somente à apreciação da referida lei complementar, mas não à análise de atos normativos secundários, atos de efeitos concretos ou, ainda, atos administrativos. No mérito, assinalou que a garantia constitucional do acesso à justiça exige a disponibilidade de instrumentos processuais idôneos à tutela dos bens jurídicos protegidos pelo direito positivo. Nesse sentido, a Constituição atribui ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral aos necessitados. Assim, a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, representa

verdadeira essencialidade do Estado de Direito. Quanto às Defensorias Públicas estaduais, a EC 45/2004 conferiu-lhes autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa própria para a elaboração de suas propostas orçamentárias. Além disso, o art. 24 da CF estabelece competências concorrentes entre União e Estados-Membros para legislar sobre certos temas, determinando a edição de norma de caráter genérico na primeira e de caráter específico na segunda hipótese. Consequentemente, as leis estaduais que, no exercício da competência legislativa concorrente, disponham sobre as Defensorias Públicas estaduais devem atender às disposições já constantes das definições de regras gerais realizadas pela LC 80/1994. Na situação dos autos, atribuiu-se ao governador a incumbência de nomear membros da carreira para diversos cargos elevados dentro da instituição, o que é incompatível com a referida lei complementar e com o texto constitucional. No que se refere à autonomia financeira, as Defensorias Públicas estaduais têm a prerrogativa de formular sua própria proposta orçamentária. Assim, a elas deve ser assegurada a iniciativa de lei para a fixação do subsídio de seus membros (CF, art. 96, II). Vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido improcedente.

ADI 5286/AP, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5286)

ADI 5287/PB, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5287)

ADPF 339/PI, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADPF-339)

(Informativo 826)

► **Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária - 5**

Por sua vez, na ADI 5.287/PB, discutia-se a constitucionalidade de ato mediante o qual o governador, por meio da Lei 10.437/2015 do Estado da Paraíba, reduziu unilateralmente valores previstos na LOA destinados à Defensoria Pública, em relação ao que inicialmente proposto pela instituição quando da consolidação da proposta orçamentária enviada ao Legislativo. Nesse caso, o Plenário conheceu parcialmente do pleito e, por maioria, julgou-o procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei, sem pronúncia de nulidade, apenas quanto à parte em que fixada a dotação orçamentária à Defensoria Pública estadual, em razão da prévia redução unilateral. Ademais, assentou o entendimento de que é inconstitucional a redução unilateral pelo Poder Executivo dos orçamentos propostos pelos outros Poderes e por órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, na fase de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, quando tenham sido elaborados em obediência às leis de diretrizes orçamentárias e enviados conforme o art. 99, § 2º, da CF, cabendo-lhe apenas pleitear ao Poder Legislativo a redução pretendida, visto que a fase de apreciação legislativa é o momento constitucionalmente correto para o debate de possíveis alterações no projeto de lei orçamentária. Preliminarmente, por decisão majoritária, o Tribunal afastou questão atinente à eventual prejudicialidade do pedido, tendo em conta o esgotamento da eficácia da LOA para o exercício financeiro de 2015. Entendeu que a impugnação fora feita em tempo adequado, a ação fora incluída em pauta e o julgamento fora iniciado antes do aludido esgotamento de eficácia. Além disso, é necessário pacificar a controvérsia para fins de fixação de precedente, mesmo porque toda LOA possui eficácia exígua. Portanto, condicionar

o enfrentamento do tema à eficácia da norma, nessas hipóteses, pode implicar o esvaziamento da possibilidade de controle de constitucionalidade. Vencidos, no tocante à preliminar, os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski (Presidente), que julgavam o pedido prejudicado, tendo em conta a perda superveniente de objeto. No mérito, o Colegiado, inicialmente, reportou-se aos fundamentos do caso anterior. Acrescentou que as Defensorias Públicas têm a prerrogativa de elaborar e apresentar suas propostas orçamentárias, as quais devem, posteriormente, ser encaminhadas ao Executivo. Há apenas dois requisitos para tanto: a) a proposta orçamentária deve ser elaborada em consonância com o que previsto na respectiva LDO; e b) a proposta deve ser encaminhada em conformidade com a previsão do art. 99, § 2º, da CF. A apreciação das leis orçamentárias deve se dar perante o órgão legislativo correspondente, ao qual cabe deliberar sobre a proposta apresentada, fazendo-lhe as modificações que julgue necessárias. Ressaltou, no ponto, o art. 166 da CF. Na espécie, assinalou que, no momento da consolidação da proposta orçamentária a ser encaminhada à assembleia estadual, o governador reduzira unilateralmente os valores das propostas apresentadas pelo Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, apesar de as propostas estarem em conformidade com a LDO, o que afronta a Constituição. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido.

ADI 5286/AP, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5286)

ADI 5287/PB, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5287)

ADPF 339/PI, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADPF-339)

(Informativo 826)

► **Defensoria Pública: autonomia funcional, administrativa e orçamentária**
- 6

No que se refere à ADPF 339/PI, fora ajuizada em face de suposta omissão do governador do Estado do Piauí, consistente na ausência de repasse de duodécimos orçamentários à Defensoria Pública estadual, na forma da proposta originária. O Colegiado, por maioria, julgou procedente o pedido para, diante de lesão aos artigos 134, § 2º; e 168, ambos da CF, determinar ao governador que proceda ao repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública estadual pela LOA para o exercício financeiro de 2015, inclusive quanto às parcelas já vencidas, assim também em relação a eventuais créditos adicionais destinados à instituição. Sublinhou serem asseguradas às Defensorias Públicas a autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua proposta orçamentária, por força da Constituição. O repasse de recursos correspondentes, destinados à Defensoria Pública, ao Judiciário, ao Legislativo e ao Ministério Público, sob a forma de duodécimos, é imposição constitucional. O repasse de duodécimos destinados ao Poder Público, quando retidos pelo governo, constitui prática indevida de flagrante violação aos preceitos fundamentais da Constituição. Ademais, o princípio da subsidiariedade, ínsito ao cabimento da arguição, é atendido diante da inexistência, para a autora, de outro instrumento igualmente eficaz ao atendimento célere da tutela constitucional pretendida. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava o pedido improcedente.

ADI 5286/AP, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5286)

ADI 5287/PB, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADI-5287)

ADPF 339/PI, rel. Min. Luiz Fux, 18.5.2016. (ADPF-339)

(Informativo 826)

► Distribuição de medicamento e necessidade de registro sanitário - 1

O Plenário, por decisão majoritária, deferiu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia da Lei 13.269/2016, que autoriza o uso do medicamento fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, a despeito da inexistência de estudos conclusivos no tocante aos efeitos colaterais em seres humanos, bem assim de ausência de registro sanitário da substância perante o órgão competente. O Colegiado entendeu que, ao suspender a exigibilidade de registro sanitário do medicamento, a lei impugnada discrepa da Constituição (art. 196) no tocante ao dever estatal de reduzir o risco de doença e outros agravos à saúde dos cidadãos. O STF, em atendimento ao preceito constitucional, tem proferido decisões a garantir o acesso a medicamentos e tratamentos médicos, cabendo aos entes federados, em responsabilidade solidária, fornecê-los. O caso, entretanto, não se amolda a esses parâmetros. Sucede que, ao dever de fornecer medicamento à população contrapõe-se a responsabilidade constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em circulação no território nacional, ou seja, a atuação proibitiva do Poder Público, no sentido de impedir o acesso a determinadas substâncias. Isso porque a busca pela cura de enfermidades não pode se desvincular do correspondente cuidado com a qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos mediante rigoroso crivo científico. Na elaboração do ato impugnado, fora permitida a distribuição do remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária. Entretanto, a aprovação do produto no órgão do Ministério da Saúde é condição para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais (Lei 6.360/1976, art. 12). O registro é condição para o monitoramento da segurança, eficácia e qualidade terapêutica do produto, sem o qual a inadequação é presumida. A lei em debate é casuística ao dispensar o registro do medicamento como requisito para sua comercialização, e esvazia, por via transversa, o conteúdo do direito fundamental à saúde. ADI 5501 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 19.5.2016. (ADI-5501)

(Informativo 826)

► Distribuição de medicamento e necessidade de registro sanitário - 2

O Tribunal vislumbrou, na publicação do diploma impugnado, ofensa à separação de Poderes. Ocorre que incumbe ao Estado, de modo geral, o dever de zelar pela saúde da população. Entretanto, fora criado órgão técnico, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde (Anvisa), à qual incumbe o dever de autorizar e controlar a distribuição de substâncias químicas segundo protocolos cientificamente validados. A atividade fiscalizatória (CF, art. 174) é realizada mediante atos administrativos concretos devidamente precedidos de estudos técnicos. Não cabe ao Congresso, portanto, viabilizar, por ato abstrato e genérico, a distribuição de qualquer medicamento. Assim, é temerária a liberação da substância em discussão sem os

estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da viabilidade do medicamento para o bem-estar do organismo humano. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que concediam a medida liminar para dar interpretação conforme à Constituição ao preceito impugnado. Reputavam que o uso do medicamento, nos termos da lei, deveria ser autorizado a pacientes em estágio terminal. ADI 5501 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 19.5.2016. (ADI-5501)

(Informativo 826)

CAPÍTULO 26
SIMULADOS

SIMULADO 1

► Peça Processual – Valor 5,0

Um relatório da CGU (Controladoria Geral da União) a que Caio teve acesso apontou um superfaturamento de nove milhões em um contrato do Ministério do Esporte com a Fundação Econômica X para apoio à Olimpíada do Rio-2016. Um dos objetivos da contratação da Fundação, que foi realizada sem licitação, desrespeitando a Constituição e a Lei 8.666/93, era justamente obter economia nos gastos com as obras dos jogos.

Em consulta a advogado especialista, e após meses de análise do contrato e até mesmo de alguns aditivos, o mesmo esclareceu a Caio que não houve nenhum evento imprevisível que justificasse o montante a ser pago pelo Dr. Paulo, Ministro do Esporte, e destacou que restou comprovado o superfaturamento apontado no relatório, o que gerou dano aos cofres públicos.

Caio lhe procura afirmando que, na qualidade de cidadão, se sente no dever de tomar as devidas providências a fim de invalidar o contrato celebrado pelo Ministério do Esporte.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a) contratado(a) por Caio, redija a petição inicial da ação cabível, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos: a) competência do órgão julgador; b) legitimidade ativa e passiva; c) argumentos de mérito; d) requisitos formais da peça judicial proposta; e) tutela de urgência.

► Questão 1

Em um município paulista está em vigor determinada lei, de iniciativa parlamentar, que estendeu a gratuidade no transporte público municipal aos idosos a partir dos sessenta anos de idade.

Essa lei é material e formalmente constitucional? Explique e fundamente. (Valor: 1,25)

► Questão 2

O Conselho Federal da OAB ajuizou perante o STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo por objeto um artigo de uma lei federal em vigor desde 2014, sendo manifesta a pertinência temática do dispositivo impugnado com o exercício da advocacia. A Corte entende que o referido dispositivo legal é inconstitucional, mas por fundamento distinto do que fora apresentado na inicial, tendo o STF inclusive de-

clarado a inconstitucionalidade desse mesmo dispositivo no julgamento de um caso concreto, em sede de Recurso Extraordinário.

Com base nas informações acima, responda:

- A Corte pode julgar a ADI procedente a partir de fundamento diverso do que fora apresentado pelo Conselho Federal da OAB? Justifique. (Valor: 0,65)
- A Corte pode julgar a ADI procedente em relação também a outro dispositivo da mesma lei, mesmo não tendo este dispositivo sido objeto da ADI? Justifique. (Valor: 0,60)

► Questão 3

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso extraordinário, declarou a inconstitucionalidade, em sede de controle incidental, de uma lei estadual. Rafael, interessado em ser alcançado pelos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, impetrou mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal objetivando a fixação de prazo para que o Senado Federal edite resolução para suspender a execução da mencionada lei estadual.

Com base no relato, responda aos itens a seguir:

- Quais são os efeitos subjetivos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade da lei em questão e qual é a função reservada ao Senado Federal pela norma do artigo 52, inciso X, da CRFB? Explique. (Valor: 0,65)
- De acordo com a tradição constitucional brasileira, é cabível o pretendido controle jurisdicional da atuação do Senado Federal em tal hipótese? (Valor: 0,60)

► Questão 4

Marcelo, necessitando obter certidão de tempo de serviço trabalhado como médico no Hospital Municipal TTT, a ser utilizada para subsequente averbação junto à Secretaria de Saúde Pública JJJ, protocolou o seu pedido administrativo tendo o mesmo sido negado por escrito sem qualquer justificativa da autoridade.

Passados trinta dias da negativa, Marcelo lhe contrata. Na qualidade de advogado (a) do mesmo, responda aos seguintes questionamentos:

- Qual ação será cabível para garantir a Marcelo o direito de obter a certidão? Justifique e fundamente. (Valor: 0,65)
- Há prazo específico para propositura da referida ação? Explique e fundamente. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da ... Vara Federal da Seção Judiciária do Estado...	0 a 0,50	
Identificação da peça: Ação Popular – art. 5º, LXXIII da CRFB/88 e Lei 4.717/65.	0 a 0,50	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Legitimidade ativa: Caio (0,20) Legitimidade Passiva: Paulo (Ministro do Esporte), União Federal e Fundação Econômica X (0,30)	0 a 0,50	
Fundamentação: – Art. 5º, LXXIII, da CRFB/88; – Art. 37, caput da CRFB/88 (princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade); – Art. 37, XXI – Art. 2º, “b”, “c” e “e” da Lei 4.717/65. – Lei 8.666/3	0 a 1,50	
Tutela de Urgência: Concessão de medida cautelar/liminar – Art. 5º, § 4º da Lei 4.717/65 e art. 300 do CPC; Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.	0 a 0,50	
Pedidos: Concessão de medida cautelar/liminar para suspender o contrato; Procedência do pedido para invalidar o contrato celebrado pelo Ministro do Esporte; Citação dos Réus; Intimação do Representante do Ministério Público; Condenação dos Réus em custas e em honorários advocatícios; Produção de todos os meios de provas em direito admitidas; Juntada de documentos. – Em cumprimento ao art. 319, VII do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação.	0 a 1,00	
Valor da causa: R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).	0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Sim. Não há qualquer inconstitucionalidade na referida lei. A autonomia constitucional inerente aos Municípios (CRFB/88, art. 30, I), justifica a constitucionalidade da mesma. Não há óbice, na Constituição Federal, para o exercício, pelo Município, da típica atribuição institucional que lhe pertence, para legislar, por autoridade própria, sobre tal matéria, pois se trata de competência material reservada pela própria Constituição, cuja prática autoriza a dispor, em sede legal, sobre tema que reflete assunto de interesse eminente perante local.	0 a 1,25	
	Valor Total: ____	

Questão 2

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Segundo a jurisprudência do STF, o Tribunal, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, está limitado em relação ao pedido, mas não à causa de pedir, que é aberta. Ou seja, o STF pode considerar a lei impugnada inconstitucional por motivos diversos daqueles apresentados pelo proponente da ADI.	0 a 0,65	
b) O pedido, a princípio, é limitado ao que foi questionado pelo proponente da ação. O STF, no entanto, admite em caráter excepcional que dispositivos legais não impugnados na ação sejam declarados inconstitucionais, mas somente se forem dependentes dos dispositivos impugnados. A este fenômeno dá-se o nome de inconstitucionalidade por “arrastamento” ou “atração” ou “consequente”.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A declaração de inconstitucionalidade, em tal hipótese, configura-se questão prejudicial e como tal é apreciada pelo Tribunal. Subjetivamente, a decisão produz efeitos apenas inter partes. A função que a	0 a 0,65	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Constituição reserva ao Senado Federal, prevista no artigo 52, inciso X, da CRFB, é a de conferir efeitos <i>erga omnes</i> à decisão proferida na via difusa do controle de normas.	0 a 0,65	
b) Não, pois de acordo com a tradição constitucional brasileira, a competência outorgada ao Senado Federal pela norma do artigo 52, X, retrata atuação política e discricionária, não cabendo controle jurisdicional.	0 a 0,60	
Valor Total: ____		

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Caberá Mandado de Segurança, de acordo com o art. 5º, LXIX da CRFB/88 e da Lei 12.016/09, para defender o direito líquido e certo de obtenção da certidão. (art. 5º, XXXIV)	0 a 0,65	
b) Em se tratando de MS repressivo, como é o caso, o mesmo deve ser impetrado no prazo de cento e vinte dias, contados da ciência do ato, de acordo com o art. 23 da Lei 12.016/09.	0 a 0,60	
Valor Total: ____		

SIMULADO 2

► Peça Processual – Valor 5,0 (cinco pontos)

Catarina Bastos é portadora de "hiperinsulinismo congênito", rara patologia que gera a liberação exacerbada de insulina pelas células beta do pâncreas, cujo tratamento necessita da utilização do medicamento Diazóxido, fabricado no Canadá, conforme comprovado por laudos médicos. Como o produto não é produzido no Brasil e não possui recursos para adquiri-lo, Catarina solicitou à Secretaria de Saúde do Estado M o referido medicamento e o Secretário de Saúde se manifestou por escrito acerca da ausência do mesmo por não fazer parte do Programa de Medicamentos Excepcionais do SUS. Ademais, nesse documento, a referida autoridade alegou que o ente federativo em referência tem envidado esforços no sentido de prover a população dos serviços de saúde de forma ampla e eficiente, inclusive o fornecimento de medicamentos em geral; todavia, os recursos públicos são limitados, o que impele o gestor público a adotar uma política que atente aos princípios da economicidade das ações e do custo-benefício dos tratamentos. Catarina, que depende desse medicamento para manter a taxa de glicemia em níveis controlados e levar uma vida sadia, procura o seu escritório de advocacia, objetivando ingressar com ação para obter com urgência o referido medicamento. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado, redija a petição inicial da ação cabível, de procedimento célere, para a defesa dos interesses de sua cliente, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos: a) pedido de assistência judiciária gratuita; b) competência do órgão julgador; c) legitimidade ativa e passiva; d) argumentos de mérito; e) tutela de urgência.

► Questão 1

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental promovida contra veto, que, emanado do Senhor Presidente da República, incidiu sobre o § 2º do art. 55 de proposição legislativa que se converteu na Lei nº. 20457/2009 (LDO), destinada a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da lei orçamentária de 2010. O dispositivo vetado possui o seguinte conteúdo material:

"§ 2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, consideram-se ações e serviços públicos de saúde a totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza."

O autor da presente ação constitucional sustenta que o veto presidencial importou em desrespeito a preceito fundamental decorrente da EC 29/2000, que foi promulgada para garantir recursos financeiros mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde. Diante do caso exposto, responda:

- A) Segundo a orientação atual do STF, o veto do Presidente da República pode ser objeto de ADPF? E as súmulas da Corte, vinculantes ou não, podem ser objeto de ADPF? Explique. (0,65)
- B) Admite-se desistência em sede de ADPF? E a participação do *amicus curiae* é permitida? Explique. (0,60).

► **Questão 2**

O Partido Político JKLM, com representação no Congresso Nacional, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para questionar a íntegra de uma lei estadual.

Responda aos questionamentos a seguir, levando em conta o relatado acima:

- a) O que ocorrerá caso a lei estadual impugnada seja revogada? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Se Partido Político JKLM deixar de ter representação no Congresso Nacional, o que acontecerá com a ADI? (Valor: 0,60)

► **Questão 3**

Em sede de apelação penal, órgão fracionário do Tribunal de Justiça constatou de ofício uma inconstitucionalidade sobre a qual não havia qualquer precedente dos plenários do Tribunal ou do STF. Defensor e Ministério Público não haviam suscitado esta questão. O feito foi julgado pelo referido órgão fracionário, que em face da inconstitucionalidade absolveu o réu. Questiona-se:

- a) Poderia o órgão fracionário ter suscitado a inconstitucionalidade de ofício e julgado o mérito da apelação? Explique. (0,45)
- b) Caso houvesse precedente dos plenários do Tribunal ou do STF sobre a inconstitucionalidade, poderia o órgão fracionário levá-lo em consideração para o julgamento do mérito? Explique e fundamente. (0,40)
- c) Turmas Recursais de Juizados Especiais devem respeitar o Princípio da Reserva de Plenário do art. 97, da CRFB/88? Explique. (0,40)

► **Questão 4**

João (brasileiro) e Joana (canadense) são casados e estão na Bulgária em razão de João ter sido convocado para trabalhar em tal país a serviço oficial da Marinha do Brasil. Durante a viagem nasceu Luli, filha do casal, que foi registrada em Consulado brasileiro competente. Pergunta-se:

- a) Luli será reconhecida brasileira? Em caso positivo, será considerada nata ou naturalizada? Justifique e fundamente. (0,65)
- b) Qual o critério adotado pela República Federativa do Brasil quanto à atribuição de nacionalidade originária? Poderia uma lei estadual ampliar as hipóteses de aquisição de tal nacionalidade? Explique e fundamente. (0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado M	0 a 0,50	
Identificação da peça: Mandado de Segurança – art. 5º, LXIX e Lei 12.016/09	0 a 0,50	
Impetrante: Catarina Bastos Impetrados: Secretário de Saúde do Estado M e Estado M	0 a 0,50	
Tempestividade – art. 23, da Lei 12.016/09	0 a 0,30	
Pedido de gratuidade de justiça – preenchimento dos requisitos contidos – no art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CRFB/88.	0 a 0,40	
Tutela de Urgência (cautelar/liminar) – art. 7º, III, da Lei 12.016/09 e art. 300 do CPC. <i>Fumus boni iuris</i> e <i>Periculum in mora</i> ou probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.	0 a 0,30	
Fundamentação: – Existência de prova pré-constituída (art. 6º, da Lei 12.016/09); – Direito ao mandado de segurança – art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09; – Direito líquido e certo ao medicamento; – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CRFB/88); – Direito à vida; – Direito à saúde (arts. 6º e 196 da CRFB/88).	0 a 1,30	
Pedidos: – Concessão da cautelar/liminar; – Notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender pertinentes ao caso; – Que seja dada ciência à pessoa jurídica; – A intimação do Representante do Ministério Público; – A condenação do impetrado em custas processuais; – A juntada dos documentos; – Que ao final seja julgado procedente o pedido para que a impetrante receba o medicamento necessário ao seu tratamento.	0 a 0,80	
Valor da causa: R\$ 1.000,00.	0 a 0,40	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com a atual orientação do STF, o veto do Presidente da República não pode ser objeto de ADPF em nome do princípio da separação dos poderes (ADPF 73). – Segundo jurisprudência da Corte, as súmulas, vinculantes ou não vinculantes, também não podem ser objeto de ADPF (ADPFs 80 e 147).	0 a 0,65	
b) Não poderá haver desistência, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública e interesse não disponível, conforme dispõe a Lei 9.868/99, em seu art. 5º, que deve ser observada em conjunto com a Lei 9.882/99, em defesa da supremacia da Constituição Federal. – A participação do <i>amicus curiae</i> é permitida, de acordo com o art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei 9.882/99 e art. 138 do CPC, pois é um importante instrumento de democratização da Jurisdição Constitucional.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A jurisprudência do STF é firme no sentido que a revogação superveniente da norma impugnada em ADI conduz à extinção anômala do processo, ficando o exame do mérito prejudicado, por perda superveniente do objeto da ação.	0 a 0,65	
b) O STF entende que a perda superveniente de representação do Partido Político não repercute sobre o julgamento da ADI, pois a aferição da legitimidade ativa do Partido Político deve ser realizada à época do ajuizamento da ADI em razão da objetividade do processo e da indisponibilidade da ação.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) O órgão fracionário poderia ter suscitado a inconstitucionalidade de ofício. – O órgão fracionário não poderia ter julgado o mérito da apelação tendo em vista o Princípio da reserva de plenário estabelecido no art. 97 da CRFB/88. – O órgão fracionário deveria ter promovido uma “cisão funcional” de competência, submetendo ao pleno, ou órgão especial, a análise da inconstitucionalidade da norma (arts. 948 a 950 do CPC).	0 a 0,45	
b) Sim. O órgão fracionário poderia aplicar um dos precedentes e resolver, de plano, o mérito. Trata-se de exceção ao princípio da reserva de plenário, estabelecida no art. 949, parágrafo único do CPC.	0 a 0,40	
c) As turmas recursais não são consideradas Tribunais, portanto, não precisam observar o princípio da reserva de plenário.	0 a 0,40	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim. Luli será considerada brasileira nata, de acordo com o art. 12, I, “b” da CRFB/88. – Trata-se de concessão de nacionalidade originária que leva em conta os critérios sanguíneo e funcional.	0 a 0,65	
b) O Brasil adotou o critério misto (ou territorial/<i>ius soli</i> relativo), numa combinação entre o territorial e o sanguíneo, apesar de o critério territorial predominar. Art. 12, I, alíneas a, b e c, da CRFB/88. – Não, pois a CRFB/88 traz as únicas formas de aquisição de nacionalidade originária brasileira, não podendo a legislação infraconstitucional ampliá-las.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 3

► Peça Processual – Valor: 5,0

Máximo de Oliveira, Governador do Estado X e no segundo mandato consecutivo é casado com Maria das Graças há 10 anos. Na iminência de ocorrer as eleições do Município Y, situado no referido Estado, sua esposa tenta realizar o registro da candidatura para Prefeita, entretanto a Justiça Eleitoral não permite tendo em vista o disposto no art. 14, § 7º, da CRFB/88. Sabendo da intenção de Maria das Graças de se candidatar e da possibilidade de manutenção do poder familiar depois de findo o seu mandato, Máximo propõe a ela que se divorciem para afastar o vínculo conjugal, permitindo assim a sua candidatura. Com o novo pedido de candidatura, recém-divorciada, a Justiça Eleitoral concede o registro requerido por Maria. João da Silva, também candidato ao cargo de Prefeito do Município Y apresenta uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, mas não obtém êxito, nem na instância inferior, nem perante o Tribunal Superior Eleitoral. Sabendo da existência da Súmula Vinculante 18 e que a decisão ainda não transitou em julgado, na qualidade de advogado de João redija a peça judicial cabível diretamente ao STF para fins de manutenção dos efeitos vinculantes da referida súmula, com pedido imediato de tutela de urgência.

► Questão 1

Suponha que o Procurador-Geral da República tenha ajuizado uma ADI contra a Lei Estadual 2.222/16 e uma ADC tendo por objeto a Lei Federal 4.444/15, ambas com pedido de medida cautelar. Responda:

- Diante da ambivalência das ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade, se o STF indeferir a cautelar na ADI, pode um juiz, ao julgar um caso concreto, em controle difuso, declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 2.222/16? (Valor: 0,65)
- Se o STF deferir a cautelar na ADC pode um juiz, no exame de um caso concreto, declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal 4.444/15, mas por outros fundamentos, que não aqueles que deram causa à ação? (Valor: 0,60)

► Questão 2

Determinado Prefeito, cumprindo promessas eleitorais, apresentou projeto de lei outorgando reajustes a determinadas categorias de servidores públicos. Tal projeto sofreu diversas emendas pelos parlamentares ampliando os benefícios para outras categorias não acolhidas no projeto inicialmente apresentado pelo Prefeito, inclusive com aumento de despesas. A Constituição Estadual estabelece que nessa matéria a

iniciativa é exclusiva do Chefe do Executivo, repetindo normas da Constituição Federal. A lei foi votada por maioria e sancionada pelo Prefeito. Responda fundamentadamente:

- A emenda parlamentar ao projeto de lei seria possível? (Valor: 0,65)
- Existiria algum meio de controle de constitucionalidade da lei votada pela Câmara? (Valor: 0,60)

► Questão 3

Ashanti, africana de nascimento, reside no Brasil há (26) vinte e seis anos e decide fazer um concurso público para auditora da Receita Federal, função reservada a brasileiros. Como já possui tempo suficiente no país para adquirir a nacionalidade derivada e não sofreu nenhuma condenação penal na vida, apresenta toda a documentação necessária ao Ministério da Justiça e pleiteia a naturalização brasileira. Ashanti estuda muito para o concurso, abdicando durante alguns meses da vida social e é aprovada em primeiro lugar no critério de classificação da banca. Entretanto, é impedida de tomar posse, pois o procedimento administrativo de naturalização ainda não está concluído. Em face do exposto, responda:

- A estrangeira residente no Brasil, neste caso específico, pode tomar posse no cargo? Explique. (Valor: 0,65)
- Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Se afirmativo, em qual situação? (Valor: 0,60).

► Questão 4

O Deputado Federal Florisberto Silva foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis por sua prisão comunicaram regularmente o fato ao Poder Judiciário, que manteve a prisão.

- Diante do fato descrito, pode ser tomada alguma medida para que Florisberto seja posto em liberdade? Fundamente. (Valor: 0,65)
- Se Florisberto exercesse cargo de Vereador, como seria o tratamento jurídico? (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.	0 a 0,50	
Identificação da peça: Reclamação Constitucional – art. 103-A, § 3º, da CRFB/88; art. 988, III do CPC e art. 7º da Lei 11.417/06.	0 a 1,00	
Pedido de Tutela de Urgência – Art. 989, II e art. 300 do CPC.	0 a 0,50	

Questão avaliada	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Fundamentação: – Decisão do Tribunal Superior Eleitoral que contrariou o enunciado da súmula vinculante 18 do STF; – Efeitos vinculantes da súmula em relação ao Poder Judiciário, de acordo com o art. 103-A, <i>caput</i> , da CRFB/88; – Art. 988, III do CPC; – Inelegibilidade reflexa, art. 14, § 7º da CRFB/88; – Princípio Democrático.	0 a 1,50	
Pedidos: – Concessão da tutela de urgência para suspender a decisão impugnada; – Citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação; – Oitiva/requisição da autoridade Reclamada; – Oitiva do Procurador-Geral da República; – Juntada de documentos; – Procedência do pedido para que seja cassada a decisão judicial e proferida nova decisão.	0 a 1,00	
Valor da Causa: R\$ 1.000,00 ,	0 a 0,50	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, pois a medida cautelar nas ações de constitucionalidade e inconstitucionalidade não tem caráter ambivalente, de modo que o indeferimento de medida cautelar em ADI não implica a declaração de constitucionalidade.	0 a 0,65	
b) Não, pois de acordo com o art. 21 da Lei 9.868/99, uma vez deferida a medida cautelar em ADC todos os processos em que a lei objeto da ação estiver sendo discutida devem ser suspensos, razão pela qual a juíza não poderia, após deferida a cautelar em ADC, declarar a inconstitucionalidade da lei.	0 a 0,60	
Valor Total: ____		

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois nas leis de iniciativa exclusiva ou privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, "a", da CRFB) não pode ocorrer emenda parlamentar que gere aumento de despesas (art. 63, I, da CRFB).	0 a 0,65	
b) Sim, no caso de ofensa à Constituição Estadual, é cabível a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal de competência do Tribunal de Justiça estadual. A norma também pode ser impugnada no controle difuso e, no plano federal, por meio de uma ADPF.	0 a 0,60	
Valor Total: ____		

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, pois como há o direito público subjetivo do estrangeiro de se naturalizar brasileiro, conforme prevê o art. 12, II, "b" da CRFB/88, o simples pedido de naturalização já é instrumento suficiente para que seja dada a posse no concurso. Vale ressaltar que, sendo um ato vinculado do Ministério da Justiça, nem mesmo se poderia negar a nacionalidade pretendida, desde que cumpridos os requisitos exigidos.	0 a 0,65	
b) Sim. De acordo com o art. 12, § 4º, inciso II da CRFB/88, haverá a perda da nacionalidade se o brasileiro nato optar pela aquisição voluntária de outra nacionalidade. Entretanto, não haverá perda de nacionalidade nos casos previstos nas alíneas "a" e "b" do citado dispositivo, caso em que se consagra a possibilidade de dupla-nacionalidade.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim. É impossível a manutenção da prisão por decisão judicial, uma vez que, em função da imunidade formal prevista no art. 53, § 2º, da CRFB/88, cabe à Casa a que pertence o parlamentar deliberar sobre a manutenção da prisão nos casos de crimes inafiançáveis. Poderia ser impetrado uma <i>Habeas Corpus</i> .	0 a 0,65	
b) Seria possível manter a prisão, pois vereadores não gozam de imunidade formal quanto a prisão e nem mesmo quanto ao processo.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 4

► Peça Processual – Valor 5,0

O Governador do Estado U, Sr. Márcio Marcelo, pressionado pela oposição, sancionou a Lei Estadual 171/16, que promoveu a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público. O Presidente do partido político "Zero Corrupção", com representação no Congresso Nacional, indignado, destacou que na atual ordem constitucional, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso e que as exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição Federal – e não se justificam no caso da Lei em questão –, como ocorre nas nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração ou no recrutamento de servidores temporários. Dessa forma, o Partido sustenta que a Lei Estadual 171/16 violou dispositivos constitucionais basilares e, então, já anunciou na imprensa nacional que questionará a qualidade da Lei Estadual em questão.

Na qualidade de advogado(a) do partido político, elabore a peça cabível, observando: a) competência do juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) requisitos formais da peça; e) tutela de urgência.

► Questão 1

O controle de constitucionalidade no Brasil ganhou inegável reforço na CRFB/88. O sistema difuso foi associado a um sistema de controle concentrado de constitucionalidade que recebeu nesse texto constitucional mais três importantes ações: ADO, ADC e ADPF, que, em conjunto com a ADI, presente no ordenamento jurídico desde a EC 16/1965, formam o arcabouço principal de proteção constitucional no controle abstrato das leis e asseguram a supremacia da Constituição. Sobre o tema, responda aos seguintes questionamentos:

- Explique o que vem a ser a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição. Há necessidade de se respeitar o princípio da reserva de plenário nas duas hipóteses? (0,65)
- O que significa a modulação temporal dos efeitos da decisão? Essa técnica pode ser adotada em todas as ações do controle concentrado? Explique. (0,60)

► Questão 2

Ana, advogada com longos anos de carreira, resolveu concorrer a vaga de magistrado surgida no Tribunal de Justiça ABC, tendo apresentado o seu currículo para a Or-

dem dos Advogados do Brasil, que a incluiu na lista de advogados. Mesma situação ocorreu com a lista escolhida pelo Tribunal de Justiça.

Com base no acima relatado, responda aos itens a seguir:

- A) Qual é o percentual de vagas destinada aos advogados nos Tribunais de Justiça? Fundamente. (Valor: 0,65)
- B) Quais são os ritos de escolha realizados pela OAB e pelo Tribunal de Justiça? De quem é a competência para nomeação? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Questão 3

O Conselho Federal da OAB ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 125 da lei federal H, de 2015. Essa lei tem sido declarada totalmente inconstitucional pelo STF em reiteradas decisões, todas em sede de controle difuso.

Com base nesse cenário e à luz da jurisprudência do STF, responda aos itens a seguir:

- a) O Advogado-Geral da União está obrigado a defender a constitucionalidade da lei federal H? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Ao julgar essa ADI, pode o STF declarar a inconstitucionalidade de outro(s) dispositivo(s) da lei H, além do art. 125? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 4

No mês de abril de 2016, uma proposta de emenda constitucional foi rejeitada logo no primeiro turno de votação, realizado na Câmara dos Deputados. Em setembro do mesmo ano, essa proposta foi novamente posta em votação na Câmara dos Deputados. Na sequência, determinado Deputado Federal, contrário à referida proposta e decidido a impedir sua tramitação, afirmou que iria acessar o Poder Judiciário.

Pergunta-se: há possibilidade de o Poder Judiciário exercer controle sobre a tramitação da emenda? Em caso positivo, qual a possível medida cabível no caso em tela? (Valor: 1,25)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal	0 a 0,50	
Identificação da peça: Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 102, I, “a”, da CRFB/88 e Lei 9.868/99	0 a 0,50	
Legitimidade ativa: Partido Político Zero Corrupção – legitimado universal (0,25) Demonstração da representação do Partido no Congresso Nacional (0,25)	0 a 0,50	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Representação do Partido Político por seu Diretório Nacional	0 a 0,50	
Medida Cautelar – arts. 10 a 12 da Lei 9.868/99. <i>Fumus boni iuris</i> e <i>Periculum in mora</i> .	0 a 0,50	
Fundamentação: – Art. 102, I, “a”, da CRFB/88; – Lei 9.868/99; – Violação ao art. 37, II da CRFB/88; – Violação aos princípios da impessoalidade e moralidade (art. 37, <i>caput</i> , da CRFB/88).	0 a 1,50	
Pedidos: – Concessão da medida cautelar para suspender a norma impugnada e, ao final, a procedência do pedido, para que seja declarada a sua inconstitucionalidade; – Juntada de documentos; – Que sejam solicitadas informações ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa Estadual; – Citação do Advogado Geral da União; – Oitiva do Procurador-Geral da República.	0 a 0,70	
Valor da causa: R\$ 1.000,00	0 a 0,30	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é uma modalidade de declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 28, p. único, da Lei 9.868/99 que tem como consequência a declaração de inconstitucionalidade de uma determinada interpretação, sem afetar o texto da norma. É dizer, o texto da norma permanece inalterado, mas determinada interpretação que a princípio poderia ser feita da norma é considerada inconstitucional. Como há uma declaração de inconstitucionalidade, ainda que sem redução de texto, deve haver observância ao princípio. Na interpretação conforme, se o texto comportar plúrimas interpretações, e dentre elas houver pelo menos uma que esteja em conformidade com a CRFB/88, o STF afastará as interpretações que não se compatibilizam com a Constituição e declarará qual a correta interpretação da norma. A decisão da Corte aproveita a lei e o seu texto não é afetado, sendo a interpretação do texto vinculado ao entendimento dos ministros, por isso não precisa observar o princípio da reserva de plenário.	0 a 0,65	
b) A modulação temporal é a possibilidade, de acordo com o art. 27 da Lei 9.868/99, da Corte decidir que a norma deixará de produzir efeitos jurídicos a partir do trânsito em julgado da decisão (<i>ex nunc</i>) ou posteriormente ao acórdão (eficácia pro futuro ou prospectivos), em nome do interesse público e segurança jurídica. Essa técnica pode ser adotada em todas as ações do controle concentrado.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com o art. 94 da CRFB/88, que trata do denominado "quinto constitucional", o percentual é de dez por cento para advogados.	0 a 0,65	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
b) A escolha da lista sêxtupla pela OAB local, dentre advogados com mais de dez anos. Cabe ao Governador do Estado.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois embora a Constituição determine que o AGU deva defender a constitucionalidade das leis impugnadas através de ADI, de acordo com o que já foi decidido pelo STF, o AGU está dispensado desta obrigação se a lei em questão já tiver sido declarada inconstitucional pelo STF através de controle difuso.	0 a 0,65	
b) Sim, caso haja interdependência do art. 125 com outro dispositivo legal. É a chamada inconstitucionalidade por arrastamento.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Sim, há possibilidade de o Poder Judiciário controlar a constitucionalidade do processo legislativo do projeto de emenda constitucional. No caso em tela o controle mostra-se viável em função da violação da limitação procedimental constante no art. 60, parágrafo 5º da CRFB/88. A única medida cabível ao caso é a impetração do mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal.	0 a 1,25	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 5

► Peça Processual – VALOR 5,0

Roberto Vieira foi aprovado no concurso público que prestou no Estado PPP para ocupar o cargo de enfermeiro no Hospital Estadual X. Em razão de sua aprovação dentro do número de vagas estabelecidas no edital, começou a se preparar para assumir o cargo que tanto almejou, tendo comparecido ao local indicado para levar documentação exigida no edital do concurso.

Algumas semanas após ter levado pessoalmente os documentos indicados, recebeu telegrama do Governo do Estado PPP que comunicava a sua desclassificação no concurso em razão de uma tatuagem classificada como "de pequeno tamanho", mas incompatível com o cargo pretendido.

Diante disso, Roberto contratou um advogado que ajuizou uma ação de procedimento comum contra o Estado, pretendendo a sua nomeação bem como indenização por danos morais. Em sentença, o juiz de primeiro grau sustentou que não havia, no caso, direito à nomeação em razão da tatuagem.

Na qualidade de advogado (a) de Roberto, prepare o recurso cabível da decisão de mérito que julgou improcedente a ação, abordando toda a matéria de direito processual e substancial pertinente ao caso apresentado.

► Questão 1

O Poder Reformador é o responsável pelas alterações formais que a Constituição poderá sofrer ao longo de sua existência. Para substituir, revogar, adicionar ou reenumerar dispositivo no texto constitucional será necessária a atuação dessa manifestação derivada de poder.

Sobre o tema, responda aos seguintes questionamentos:

- Há alguma limitação de ordem temporal e/ou circunstancial enfrentada pela Constituição de 1988, em seu processo de alteração em nome da proteção da rigidez constitucional? Em caso positivo, explique. (Valor: 0,65)
- Explique o que seria a mutação constitucional e aponte eventuais limitações ao fenômeno. (Valor: 0,60)

► Questão 2

O Governador do Estado K sancionou a Lei Estadual nº 888/16 que estabelece a gratuidade em estacionamentos de veículos automotores no Estado-Membro, em

estabelecimentos privados como shoppings, farmácias, supermercados, dentre outros. Pergunta-se:

- a) A Lei Estadual nº 888/16 é constitucional? Explique fundamentadamente. (Valor: 0,65)
- b) Qual seria o instrumento jurídico adequado para questionar a constitucionalidade da referida lei? O Governador do Estado W teria legitimidade ativa para a sua propositura? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 3

Sabemos que com a EC 45/04 houve a constitucionalização formal dos tratados internacionais sobre Direitos Humanos, de acordo com o art. 5º, § 3º, da CRFB/88 que assim estabelece:

“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”

Responda aos seguintes questionamentos sobre o tema:

- a) Os tratados internacionais sobre Direitos Humanos que não passarem pelo procedimento estabelecido no art. 5º, § 3º, da CRFB/88, terão status de norma federal? E os tratados que versam sobre direito comercial, ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com que status? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Explique a Teoria do Bloco de Constitucionalidade na seara dos Direitos Humanos e aponte a posição do STF em relação ao tema. (Valor: 0,60)

► Questão 4

Com a chegada de uma nova Constituição, inaugura-se um momento também novo na vida de um país. No Brasil, entre um ordenamento constitucional novo e as normas constitucionais anteriores sempre se operou o fenômeno da revogação global, que significa dizer que a Constituição nova revoga a Constituição que a antecedeu, deixando esta última de produzir seus efeitos jurídicos.

Sobre a nova Constituição e o direito anterior, responda:

- a) O que seria a Teoria da repristinação? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Apesar de a CRFB/88 ter revogado toda a Constituição que a precedeu, não poderia jamais ter revogado todas as normas infraconstitucionais elaboradas antes da sua existência. O que ocorre com as normas ordinárias preexistentes com a chegada da nova Constituição? Explique. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ... Vara de Fazenda Pública da Comarca... (0,30) Endereçamento da petição de razões: Ao Tribunal de Justiça do Estado PPP (0,20)	0 a 0,50	
Identificação da peça: Recurso de Apelação – art. 1.009, do CPC.	0 a 0,50	
Recorrente: Roberto Vieira (0,20) Recorrido: Governador e Estado PPP (0,30)	0 a 0,50	
Tempestividade – art. 1.003, § 5º, do CPC (0,30). Cabimento do Recurso: art. 1.009 do CPC. (0,40). Preparo: art. 1.007, do CPC (0,30)	0 a 1,00	
Fundamentação: – Direito à nomeação, art. 37, IV, da CRFB/88 – Princípio do concurso público, art. 37, II, da CRFB/88; – Princípio da igualdade, Art. 5º, I; – Princípio da legalidade, art. 37, caput da CRFB/88; – Direito à indenização. Art. 37, §6º	0 a 1,50	
Pedidos: Postulação de reforma da sentença para garantir o direito à nomeação, bem como à indenização; Condenação nos ônus sucumbenciais.	0 a 1,00	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Inexiste limitação de ordem temporal ao Poder Reformador, o que permite a alteração do atual texto constitucional desde a sua promulgação. De acordo com o art. 60, § 1º, da CRFB/88, não pode haver emenda ao texto na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, que configuram a proteção constitucional às situações de crise. Como nessas circunstâncias o Estado está vivendo um momento de exceção, protege-se a Carta Constitucional de eventuais golpes que poderiam ser a ela deflagrados com reformas constitucionais descabidas.	0 a 0,65	
b) Ao lado do processo formal de mudança da Constituição, que hoje consiste na elaboração das emendas constitucionais, a mutação constitucional vai dar oxigênio ao texto constitucional, permitindo a sua releitura à luz da sociedade atual, dos fatos econômicos, históricos e políticos, existentes no momento da interpretação da Constituição. A mutação não realiza mudanças formais na Constituição, por isso se diz que seria uma reanálise do sentido e alcance das normas constitucionais, sem mudança de texto. Além de respeitar a própria essência da Constituição, a mutação não poderá contrariar as cláusulas pétreas do art. 60, § 4º, da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A lei é inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, de acordo com o art. 22, I da CRFB/88. Trata-se de inconstitucionalidade formal subjetiva (ou orgânica). Também podemos destacar a inconstitucionalidade material por violação ao princípio da livre iniciativa. Art. 1º, IV da CRFB/88.	0 a 0,65	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
b) A ADI seria o instrumento jurídico adequado para questionar a constitucionalidade da referida lei no controle concentrado de constitucionalidade. De acordo com o art. 103, V da CRFB/88, e com a jurisprudência do STF, os Governadores de Estado são legitimados especiais, ou seja, devem demonstrar a pertinência temática quando da propositura da referida ação. Logo, para que o Governador do Estado W tivesse legitimidade para propositura da ADI, teria que comprovar que a norma impugnada interfere de alguma forma nos interesses do seu Estado, sob pena de a ação não ser conhecida.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Os tratados internacionais sobre direitos humanos que ingressarem no ordenamento jurídico brasileiro sem observar o citado dispositivo terão status de norma supra legal, pois estarão abaixo da Constituição, mas acima das normas infraconstitucionais. Os demais tratados, que não versam sobre direitos humanos, ingressam no ordenamento jurídico brasileiro como lei ordinária federal.	0 a 0,65	
b) A teoria do bloco de constitucionalidade parte de uma visão monista, ou seja, a de que o ordenamento jurídico é um só. Dessa forma, sustenta que quando o Brasil assina qualquer tratado sobre direitos humanos, independentemente do seu processo de incorporação, o mesmo já teria status de Constituição, em razão da matéria nele tratada. O STF adota o dualismo moderado, fazendo a separação entre o direito nacional e o internacional e só reconhece como constitucional o Tratado que passa pelo crivo do art. 5º, § 3º, da CRFB/88.	0 a 0,60	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com o art. 2º, § 3º, da Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro, uma lei validamente revogada não volta a produzir efeitos jurídicos com a revogação da lei que a revogou. Esse é um fenômeno salutar de sucessão legislativa no país. Entretanto, conforme a parte inicial do dispositivo, é possível que mediante disposição expressa, a lei nova, revogadora de outra, que revogou a que a antecedeu, restaure os efeitos jurídicos de uma norma já revogada, realizando o fenômeno da repristinação.	0 a 0,65	
b) Segundo teoria dominante no Brasil, se houver compatibilidade de conteúdo, assunto, com a nova Constituição, as normas do direito ordinário anterior serão bem-vindas e recebidas perante a nova ordem constitucional e continuarão a produzir completamente seus efeitos jurídicos. Se, por sua vez, não existir harmonia de matéria, as normas não serão recebidas e, em consequência, revogadas. É o que tratam os fenômenos da recepção e não repristinação.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

SIMULADO 6

► Peça Processual – Valor 5,0

A Sociedade Empresária TTT, do ramo de suprimentos de materiais de escritório, participou de licitação pública realizada pelo Estado da Esperança e foi declarada como vencedora por ter apresentado o melhor preço e a melhor proposta. Mesmo com toda documentação devidamente apresentada e tendo sido cumpridas todas as exigências do instrumento editalício, o Sr. Décio TTT, sócio-diretor da empresa, recebeu notificação assinada pelo Governador do Estado, informando a exclusão de sua empresa do procedimento licitatório já concluído – sem especificar as razões para tanto – com a notícia de que a empresa que havia ficado em segundo lugar na ordem de classificação fora declarada vencedora.

Indignado, então, Décio procurou um escritório de advocacia para que fosse apresentada ação adequada na defesa do direito da sociedade empresária TTT de permanecer como primeira classificada e vencedora do procedimento licitatório, tendo o advogado impetrado um Mandado de Segurança, de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Esperança.

O remédio fora denegado, no mérito, sob o argumento da inexistência do referido direito líquido e certo mencionado pela impetrante. Na qualidade de advogado (a), elabore a peça cabível, contra a decisão que denegou a segurança, observando: a) competência do Juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) os requisitos formais da peça; e) adequação do recurso.

► Questão 1

As mudanças ocorridas no controle de constitucionalidade brasileiro com o advento da nova Constituição não conseguiram suprir algumas lacunas ainda existentes quanto à análise do direito pré-constitucional, da controvérsia constitucional sobre as normas revogadas e ainda, sobre o controle de constitucionalidade do direito municipal em face à Constituição Federal. Foi nesse panorama que nasceu a arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF –, prevista na Constituição Federal. Sobre o tema, responda aos questionamentos abaixo:

- a) Explique o que seria o caráter subsidiário da ação. Caso uma lei municipal X viole ao mesmo tempo norma da Constituição Federal e da Constituição do Estado – norma de observância obrigatória –, tal lei deverá ser objeto de ADPF? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Quais seriam os preceitos fundamentais protegidos pela ação? O rol de tais preceitos seria exaustivo? (Valor: 0,60)

► Questão 2

O Estado é uma grande organização política da modernidade, surgido da evolução das primitivas *polis*, *imperium*, *civitas*, *landers* e não se confunde com o governo, que é um de seus elementos. Governos passam e o Estado se mantém firme no propósito de singularizar a forma peculiar de divisão política de um país.

Sobre a organização do Estado brasileiro, responda:

- a) Sabendo-se que uma das características da Federação é a repartição de competências que exterioriza justamente qual é a parcela de poder interno que possui cada ente para tomada das decisões políticas, explique o princípio da predominância de interesses. (Valor: 0,65)
- b) Pode-se afirmar que os Territórios federais são entes federativos? Explique. Os mesmos podem ser divididos em municípios? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Questão 3

O Poder Legislativo realiza como uma de suas atividades típicas a função de fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, mediante controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Sobre o tema, responda aos seguintes questionamentos:

- a) É obrigatória a criação da Corte de Contas nos Estados? Explique. Poderia uma Constituição de Estado outorgar competência para que a Assembleia Legislativa julgue as próprias contas sem o auxílio da Corte de Contas Estadual? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Qual o órgão judicial competente para processar e julgar os conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais quando cometem crimes comuns e de responsabilidade? (Valor: 0,60)

► Questão 4

O art. 5º da CRFB/88 ressalta o núcleo principal dos direitos fundamentais e os seus destinatários. O direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade são desdobrados nos setenta e oito incisos e nos quatro parágrafos que com ele se relacionam e ainda em uma série de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que reforçam a proteção ao núcleo.

- a) No que tange ao direito à liberdade, explique a liberdade interna/subjetiva e a liberdade externa/objetiva. (Valor: 0,65)
- b) Em relação ao direito à igualdade, explique a isonomia formal e a isonomia material. Explique. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição ao Tribunal de Justiça do Estado da Esperança	0 a 0,50	
Identificação da peça: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança – art. 105, II, “b” da CRFB/88 e arts. 1.027 e 1.028 do CPC. Competência do STJ	0 a 0,50	
Recorrente: Sociedade Empresária TTT (0,20) Recorrido: Governador do Estado (0,30)	0 a 0,50	
Tempestividade: 15 dias (art. 1.003, parágrafo 5º do CPC). Preparo: art. 1.007 do CPC.	0 a 0,50	
Fundamentação: – Cabimento do Recurso: art. 105, II, “b”, da CRFB/88; – Direito líquido e certo; – Direito ao mandado de segurança: art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09. – Princípio da licitação, art. 37, XXI da CRFB/88; – Princípio da vinculação ao edital; – Princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.	0 a 1,50	
Pedidos: Postulação de reforma da decisão para garantir o direito líquido de ser declarada vencedora; Condenação do Recorrido nos ônus de sucumbência.	0 a 1,50	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com o art. 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882/99, que trata do caráter residual da ação, a mesma só será admitida quando inexistir outro meio eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental. Logo, quando couber alguma das ações do controle concentrado federal para afastar a lesividade, não caberá ADPF. O STF já decidiu que no caso de lei municipal violar ao mesmo tempo norma da CRFB/88 e de Constituição Estadual, a mesma deverá ser objeto de uma Representação de Inconstitucionalidade, com base no art. 125, parágrafo 2º da CRFB/88, e não da ADPF, em razão do princípio da subsidiariedade.	0 a 0,65	
b) Embora a Constituição Federal e a Lei 9.882/99 não tenham definido exatamente o conceito de preceito fundamental, de acordo com a jurisprudência do STF, configuraria rol não exaustivo de preceitos fundamentais os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, as cláusulas pétreas, os princípios que regem a Administração Pública e os princípios constitucionais sensíveis.	0 a 0,60	
	Valor Total:	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Tal princípio quer dizer que as matérias que sejam de interesse nacional, ou geral, devem ser tratadas pela União Federal, os assuntos relativos às regiões, aos Estados e, de predominância local, aos Municípios.	0 a 0,65	
b) Não, pois na forma do art. 33 da CRFB/88, os Territórios não são pessoas políticas, possuindo mera capacidade administrativa, configurando simples descentralização administrativo-territorial da União Federal, com natureza de autarquia. Segundo o art. 33, parágrafo 1º da CRFB/88, os mesmos poderão ser, entretanto, divididos em Municípios.	0 a 0,60	
	Valor Total:	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) O art. 75 da CRFB/88 fundamenta a obrigatoriedade da criação de Corte de Contas nos Estados, a qual, em nome do princípio da simetria, deverá ter atribuições similares às do Tribunal de Contas da União, sob pena da declaração de inconstitucionalidade das normas estaduais. Dessa forma, não pode a Constituição do Estado outorgar competência para que a assembleia legislativa julgue as contas referidas sem o auxílio da Corte de Contas Estadual.	0 a 0,65	
b) São julgados perante o STJ, na forma do art. 105, I, a, da CRFB/88 quando cometem crimes comuns e de responsabilidade.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A igualdade interna é o próprio livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre as opções existentes, enquanto a liberdade externa é a expressão externa do querer individual, que deve ser limitada, sob pena de gerar um desequilíbrio social.	0 a 0,65	
b) Na isonomia formal fica proibida a discriminação arbitrária, é a igualdade perante a lei, enquanto que na isonomia material é exigido do Poder Público que tome providências concretas que diminuam a desigualdade em busca de uma igualdade real.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 7

► Peça Processual – VALOR 5,0

Getúlio, brasileiro, médico, trabalha em diversos hospitais públicos do Estado M, teve sua apelação julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado M, tendo sido analisada pelo órgão julgador a sua alegação, devidamente comprovada, de violação ao ato jurídico perfeito pela Lei Estadual 1111/16, sancionada pelo Governador do Estado, réu na ação ordinária ajuizada pelo autor. Importante destacar que tal decisão afetará um considerável número de médicos também atingidos pela referida lei, que prevê, dentre outras violações, o desfazimento de contratos temporários sem pagamento de salários atrasados, em razão da crise econômica que assola o referido Estado.

Sabendo-se que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado M violou diretamente o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, e que não há obscuridade, omissão ou contradição na mesma, na qualidade de advogado de Getúlio, apresente a peça judicial cabível para impugnar a decisão judicial citada.

► Questão 1

Sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, responda:

- Explique o que são as normas de eficácia plena, contida e limitada de acordo com a Teoria Tripartida Clássica brasileira de José Afonso da Silva. Cite um exemplo de cada. (Valor: 0,65)
- O que seria a denominada “eficácia negativa das normas constitucionais”? Explique. (Valor: 0,60).

► Questão 2

Para cumprir promessa feita em sua propaganda eleitoral, a atual Presidente da República convocou plebiscito sobre a legalização de algumas substâncias entorpecentes através de lei delegada. Sobre tal fato, responda:

- Agiu corretamente a Presidente? A matéria poderia ser veiculada por tal espécie normativa? Explique. (Valor: 0,65)
- Há alguma forma de controle de tal ato normativo pelo Congresso Nacional? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 3

A forma de governo pretende analisar de que maneira se dá a instituição do exercício do poder na sociedade e a verdadeira relação entre governantes e governados. O sistema de governo, por sua vez, busca analisar como se opera o relacionamento entre os Poderes, especialmente o Legislativo e o Executivo, no exercício das funções governamentais.

Sobre o tema, responda aos seguintes questionamentos:

- Qual é a forma e o sistema de governo adotado pelo Brasil? Explique. (Valor: 0,65)
- Quais requisitos devem ser preenchidos para que um cidadão comum possa vir a ser eleito para o cargo de Presidente da República? Explique e fundamente. (Valor: 0,60)

► Questão 4

A Constituição Federal prevê a criação do controle de constitucionalidade tendo por parâmetro a Constituição Estadual, ocasião em que será competente para exercê-lo o Tribunal de Justiça Estadual. Sobre o tema, responda aos seguintes questionamentos:

- A lei orgânica municipal pode ser parâmetro do controle no âmbito municipal? Explique. (Valor: 0,65)
- O que seria a denominada “inconstitucionalidade progressiva”? Explique. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado M	0 a 0,40	
Identificação da peça: Recurso Extraordinário – art. 102, III, “a” da CRFB/88 e arts. 1.029 e ss do CPC Competência do Supremo Tribunal Federal.	0 a 0,60	
Recorrente: Getúlio (0,20) Recorrido: Governador do Estado M. (0,30)	0 a 0,50	
Cabimento do Recurso: art. 102, III, “a” da CRFB/88. Tempestividade – art. 1.003, parágrafo 5º do CPC.	0 a 0,60	
Preparo – art. 1.007 do CPC (0,20) Prequestionamento – Súmula 282 do STF (0,20)	0 a 0,40	
Repercussão geral – Art. 102, § 3º, CRFB/88 e art. 1.035 do CPC	0 a 0,50	

Questão avaliada	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Fundamentação: - Direito ao Recurso Extraordinário – art. 102, III, “a” da CRFB/88; - Princípio da segurança das relações jurídicas. Art. 5º, XXXVI, da CRFB/88; - O ato jurídico perfeito como aquele que foi validamente praticado sob a égide da legislação que vigia no momento da sua realização; - Do ato jurídico perfeito irradiam efeitos que se incorporam à esfera jurídica do agente, nascendo direitos adquiridos.	0 a 1,00	
Pedidos: - Provimento ao recurso para que seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado M e a manutenção dos contratos temporários e declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal 1111/16; - Intimação do Procurador Geral da República; - Condenação do Recorrido nos ônus sucumbenciais.	0 a 1,00	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) As normas de eficácia plena são aquelas que desde o momento de sua entrada em vigor na Constituição estariam plenamente aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos essenciais. São autoaplicáveis e têm incidência direta, imediata e integral. O art. 1º da CRFB/88 é um exemplo. As normas de eficácia contida também estão plenamente aptas a realizar todos os seus efeitos jurídicos essenciais desde a sua entrada em vigor, produzindo, igualmente, incidência direta, imediata, mas não integral, pois podem sofrer restrições ou ampliações futuras por parte do Poder Público. O art. 5º, XIII da CRFB/88 é um exemplo. As normas constitucionais limitadas produzem efeitos jurídicos reduzidos, tendo em vista que dependem da atuação futura por parte do Poder Público. Dividem-se em programáticas e institutivas (ou organizatórias). As primeiras traçam objetivos, metas ou ideais que deverão ser delineados pelo Poder Público para que produzam seus efeitos jurídicos essenciais (o art. 196 da CRFB/88 é um exemplo). As últimas criam novos institutos, serviços, órgãos ou entidades que precisam de legislação futura para que ganhem vida real (o art. 93, <i>caput</i>, da CRFB/88 é um exemplo).	0 a 0,65	
b) Toda e qualquer norma constitucional está plenamente apta a produzir três efeitos jurídicos essenciais, que representam a sua eficácia negativa. São eles: todas as normas servem como parâmetro no controle de constitucionalidade; como fonte de interpretação constitucional e também como parâmetro para a recepção ou não recepção das normas do direito ordinário anterior.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não agiu corretamente o Presidente da República, pois de acordo com o art. 68, § 1º e art. 49, XV da CRFB/88, lei delegada não pode tratar de tal matéria, pois é de competência exclusiva do Congresso Nacional.	0 a 0,65	
b) Sim. Há possibilidade de sustação, pelo Congresso Nacional, dos atos normativos do Poder Executivo nas hipóteses previstas no art. 49, V da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) O Brasil adotou a República como forma de governo, em que a instituição do poder se dá por meio de eleições e por um período certo de tempo. O Governo representa seu povo e tem o dever de prestar contas. O nosso sistema de governo é o Presidencialista, em que o Presidente exerce o Poder Executivo em toda sua inteireza, acumulando as funções de Chefe de Estado e de Chefe de Governo. Nesse sistema, o órgão do Legislativo não está sujeito à dissolução, eis que os seus membros são eleitos pelo povo para um mandato fixo.	0 a 0,65	
b) Devem ser preenchidos os requisitos de elegibilidade do art. 14, § 3º, da CRFB/88: nacionalidade brasileira originária (art. 12, § 3º, da CRFB/88), o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de trinta e cinco anos.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) No que tange ao município, não existe controle de constitucionalidade em face de Lei Orgânica Municipal. Entende a doutrina que a mesma não tem natureza de Constituição, admitindo apenas o controle de legalidade, realizado no sistema difuso.	0 a 0,65	
b) Os ministros do STF já citaram tal expressão para se referir a um estágio transitório entre a constitucionalidade e a inconstitucionalidade de uma lei.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

SIMULADO 8

► Peça Processual – Valor 5,0

Mévio das Neves, brasileiro, casado, tem impedimentos físicos de longo prazo em razão de acidente sofrido na infância e trabalhou durante trinta anos como médico do quadro do hospital universitário ligado à Universidade Federal ABC. Em conversa com um advogado, Mévio descobriu que em razão da deficiência física poderia requerer aposentadoria especial, com base no inciso I, § 4º do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Após tentativa administrativa, o seu pedido foi denegado pelo Poder Público sob a alegação da falta de lei complementar regulamentando a aposentadoria especial. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Mévio, redija a petição inicial da ação cabível para a defesa dos interesses de seu cliente, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos: a) competência do órgão julgador; b) legitimidade ativa e passiva; c) argumentos de mérito; d) requisitos formais da peça judicial proposta.

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não será pontuada.

► Questão 1

A Lei Distrital 6060/2011, assim estabelece: “Art. 1º Fica vedada a realização de manifestações públicas, com a utilização de carros aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios e Praça do Buriti e vias adjacentes”. O Partido Político X, por meio do seu Diretório Nacional, apresenta perante o STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em face da lei, alegando violação ao texto da Constituição. Em face do exposto, responda:

- a) A lei objeto de análise é constitucional? (Valor: 0,65).
- b) Se o Partido X mudar de opinião durante o trâmite da ação pode requerer a desistência? (0,30)
- c) Diretório Regional de partido político pode ser autor de ADI? (Valor: 0,30).

► Questão 2

Ana Beatriz, servidora pública estadual, ingressou no serviço público antes da edição da Constituição da República de 1988, e é regida pela Lei 111/86, estatuto dos servidores públicos do Estado-membro. Sobre a situação funcional de Ana Beatriz, responda justificadamente:

- A) O que ocorrerá com a Lei 111 caso ela não tenha sido editada conforme os trâmites do processo legislativo previstos pela atual Constituição (de 1988)? (Valor: 0,65)
- B) É possível que Ana Beatriz questione, em ação individual, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade formal da referida lei perante a constituição revogada? (Valor: 0,60)

► Questão 3

Dino Silvestre dos Santos, após vinte e três anos de serviço militar, já sendo Tenente Coronel da aeronáutica, veio a sofrer sua primeira punição disciplinar: a pena de perda de patente.

- a) Com base no caso hipoteticamente apresentado acima, responda: o *habeas corpus* é o remédio jurídico adequado ao caso? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Explique o princípio da universalidade no que tange à legitimidade ativa na ação de *habeas corpus*. (Valor: 0,60)

► Questão 4

O Governador do Estado da Saudade, extremamente populista e visando sua reeleição, sancionou lei que ficou conhecida como "Lei do Café com Leite e Pãozinho" que determina que os empregadores sejam obrigados a fornecer aos seus funcionários um café da manhã, caso estes consigam chegar ao local de trabalho até quinze minutos antes do horário marcado para início das tarefas. A lei é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por uma entidade de âmbito nacional que representa os interesses dos empregadores. Com base no exposto, responda os itens a seguir:

- a) A referida lei social é compatível com a Constituição Federal? (Valor: 0,65);
- b) No julgamento da ação o STF pode adotar efeitos prospectivos ou pro futuro? Se afirmativo, com base em qual dispositivo legal? (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.	0 a 0,40	
Identificação da peça: Mandado de Injunção – art. 5º, LXXI, da CRFB/88 e Lei 13.300/16	0 a 0,60	
Legitimidade ativa: Mécio das Neves Legitimidade passiva: Presidente da República – art. 61, § 1º, II, "c", da CRFB/88	0 a 0,50	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Fundamentação: – Direito ao Mandado de Injunção – Art. 5º, LXXI, da CRFB/88 e art. 2º, da Lei 13.300/16; – Direito fundamental a aposentadoria especial pendente de regulamentação – art. 40, § 4º, I, da CRFB/88; – Competência para julgamento – STF (art. 102, I, “q”, da CRFB/88); – Ato omissivo do Presidente da República – art. 61, § 1º, II, “c”, da CRFB/88; – Omissão inconstitucional/ Jurisprudência do STF.	0 a 2,00	1
Pedidos: – Notificação da autoridade omissa para prestar informações; – Ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica; – Intimação do Representante do MP; – Condenação do Impetrado em custas processuais; – Procedência do pedido para determinar prazo razoável para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora; – Juntada de documentos.	0 a 1,00	
Valor da causa: R\$ 1.000 para efeitos procedimentais.	0 a 0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, a lei é inconstitucional por vício material, tendo em vista que viola a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5º, IV, da CRFB/88) e a liberdade de reunião (art. 5º, XVI, da CRFB/88).	0 a 0,65	
b) Não há desistência na ADI. Art. 5º, da Lei 9868/99.	0 a 0,30	
c) Não. Segundo a jurisprudência do STF, somente o Diretório Nacional.	0 a 0,30	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Ana Beatriz continuará sendo regida pela lei 111/86, que não é formalmente inconstitucional, pois quando nova constituição é editada, somente são consideradas não recepcionadas as normas que contenham incompatibilidade material com a mesma. Ou seja, a incompatibilidade analisada é a de conteúdo e não de forma, que é regida pelo princípio do <i>tempus regit actum</i> .	0 a 0,65	
b) É possível que se questione perante qualquer órgão jurisdicional, em um caso concreto, incidentalmente, a invalidade formal de ato legislativo que foi editado em desacordo com os requisitos exigidos para a sua formação.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois de acordo com a súmula 694 do STF não é cabível o HC contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Não há risco à liberdade de locomoção.	0 a 0,65	
b) Tal princípio traduz que qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, em favor de si ou de outra pessoa, ou pessoa jurídica, em favor de pessoa natural, poderá ajuizar a ação. Também não há necessidade de advogado para impetrar o HC.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Arendimento ao quesito
a) Não, pois a lei versa sobre direito do trabalho, matéria de competência privativa da União, de acordo com o art. 22, I da CRFB/88. Logo, não pode o estado-membro legislar sobre tal matéria, sendo a referida lei inconstitucional por vício formal subjetivo ou orgânico.	0 a 0,65	
b) Sim. De acordo com o art. 27 da Lei 9868/99. É a técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão e depende do voto de 2/3 dos Ministros para ser adotada.	0 a 0,60	
	Valor Total:	

SIMULADO 9

► Peça Processual – Valor: 5,0

Ivanilda Cardoso, brasileira, divorciada, enfermeira, é portadora de hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), rara patologia que causa a destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, cujo tratamento necessita da utilização do medicamento Eculizumab, conforme comprovado por laudos médicos. Como o produto não é produzido no Brasil e não possui recursos para adquiri-lo, Ivanilda solicitou à Secretaria de Saúde do Estado TUV o referido medicamento, mas a mesma, por meio do Secretário de Saúde, manifestou-se por escrito acerca da ausência do Eculizumab, por não fazer parte do Programa de Medicamentos Excepcionais do SUS. Ademais, nesse documento, o Secretário de Saúde do Estado alegou que o ente federativo em referência tem envidado esforços no sentido de prover a população dos serviços de saúde de forma ampla e eficiente, inclusive o fornecimento de medicamentos em geral; todavia, os recursos públicos são limitados, o que impele o gestor público a adotar uma política que atente aos princípios da economicidade das ações e do custo-benefício dos tratamentos. Ivanilda, que depende desse medicamento para manter-se viva, procura o seu escritório de advocacia, objetivando ingressar com ação para obter com urgência o referido medicamento, tendo em vista que o documento denegando o remédio foi recebido ontem. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Ivanilda, redija a petição inicial da ação cabível com procedimento especial para a defesa dos interesses de sua cliente, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos: a) pedido de assistência judiciária gratuita; b) competência do órgão julgador; c) legitimidade ativa e passiva; d) argumentos de mérito; e) tutela de urgência.

► Questão 1

Lei produzida no Distrito Federal determina a submissão das desapropriações à aprovação prévia da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sobre o assunto, responda:

- a) A referida norma é constitucional? Justifique. (Valor: 0,60)
- b) Lei do Distrito Federal pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade? A lei Orgânica do Distrito Federal é parâmetro do controle de constitucionalidade? (Valor: 0,65)

► Questão 2

Mévio, cidadão residente e eleitor do Estado C, viveu sua infância no Estado D. Por entender que certo Deputado Federal, no exercício de sua função, e no âmbito ter-

ritorial do Estado D, praticou ato lesivo ao patrimônio público do ente ao qual está vinculado, Mévio propôs ação popular em vara federal da seção judiciária de D. O Deputado Federal, em sua contestação, alega a incompetência do juízo de 1º grau, com o fundamento de que possui foro privilegiado, e a ilegitimidade ativa de Mévio.

Responda aos seguintes questionamentos:

- a) Qual o órgão competente para conhecer a ação popular ajuizada em face do Deputado Federal? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Mévio teria legitimidade ativa para ajuizar a ação popular na seção judiciária de F? (Valor: 0,60)

► Questão 3

Está disposto na Constituição do Estado do Pará que:

“Vagando os cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.”

À luz da jurisprudência do STF, responda os questionamentos a seguir:

- a) A referida norma estadual é compatível com a Constituição Federal? Justifique. (Valor: 0,65).
- b) As normas de observância obrigatórias presentes na Constituição do Estado podem ser parâmetro do controle estadual? (Valor: 0,60).

► Questão 4

Marco é Deputado Estadual pelo Estado X, em exercício do segundo mandato consecutivo no cargo. Em face do exposto, responda:

- a) Sua filha, Lara, poderá concorrer ao cargo de Prefeita pelo Município P, localizado no Estado X? Seu cunhado, Francisco, poderá concorrer ao cargo de vereador pelo Município K, localizado no mesmo Estado? (Valor: 0,65)
- b) Para concorrer à reeleição, Marco deverá se desincompatibilizar? (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado TUV	0 a 0,50	
Identificação da peça: Mandado de Segurança – art. 5º, LXIX e Lei 12.016/09	0 a 0,50	
Impetrante: Ivanilda Cardoso (0,20) Impetrado: Secretário de Saúde do Estado TUV (0,15) e Estado TUV (0,15)	0 a 0,50	
Tempestividade – art. 23, da Lei 12.016/09	0 a 0,30	
Pedido de gratuidade de justiça – preenchimento dos requisitos contidos – no art. 99, § 3º, do CPC (0,20) – e art. 5º, LXXIV, da CRFB/88. (0,20)	0 a 0,40	
Tutela de Urgência (cautelar/liminar) – art. 7º, III, da Lei 12.016/09 e art. 300 do CPC. Fumus boni iuris e Periculum in mora ou probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.	0 a 0,40	
Fundamentação: – Existência de prova pré constituída; (0,20) – Direito ao mandado de segurança – art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09; (0,20) – Direito líquido e certo ao medicamento; (0,20) – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CRFB/88); (0,20) – Direito à vida; (0,20) – Direito à saúde (arts. 6º e 196 da CRFB/88) (0,30)	0 a 1,30	
Pedidos: – Concessão da cautelar/liminar; (0,10) – Notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender pertinentes ao caso; (0,10) – Que seja dada ciência à pessoa jurídica; (0,10) – A intimação do Representante do Ministério Público; (0,10) – A condenação do impetrado em custas processuais; (0,10) – A juntada dos documentos; (0,10) – Que ao final seja julgado procedente o pedido para que a impetrante receba o medicamento necessário ao seu tratamento. (0,10)	0 a 0,70	
Valor da causa: R\$ 1.000,00.	0 a 0,40	
	Valor Total:	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não. A norma é inconstitucional, pois invade a competência legislativa privativa da União estabelecida no art. 22, II da CRFB/88.	0 a 0,60	
b) Tendo em vista a competência legislativa híbrida do DF, só podem ser objeto de ADI os atos normativos editados no exercício de competência estadual. Os editados no exercício de competência municipal não poderão ser objeto da referida ação. A lei orgânica do DF tem natureza de Constituição Estadual, sendo, portanto, parâmetro para o controle de constitucionalidade abstrato de normas distritais.	0 a 0,65	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A ação foi proposta no órgão competente, ou seja, em órgão de 1º grau da Justiça Federal, em virtude do disposto no art. 5º da Lei n. 4.717/65 e no art. 102 da CRFB/88. O STF já decidiu reiteradamente que o rol de competências originárias fixadas na CRFB/88 é taxativo, e que a prerrogativa de foro, unicamente invocável em procedimentos de caráter penal, não se estende às causas de natureza civil. Logo, não são de sua competência originária as ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha foro por prerrogativa de função no STF.	0 a 0,65	
b) Sim, pois conforme jurisprudência do STJ, o fato de o cidadão ser eleitor em Município diverso daquele onde ocorreram as irregularidades não o impede de ajuizar ação popular, o que poderá ser feito em qualquer seção judiciária, pois a legitimidade ativa da ação é deferida ao cidadão. A condição de eleitor configura meio de prova documental da cidadania.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, pois segundo orientação do STF, em nome da autonomia e auto-organização do Estado o art. 81, § 1º, da CRFB/88 não é de observância obrigatória no plano estadual.	0 a 0,65	
b) Segundo a orientação do STF todas as normas da Constituição do Estado servem como parâmetro do controle estadual.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sua filha e seu cunhado poderão concorrer aos cargos apontados, tendo em vista que a inelegibilidade reflexa, estabelecida no art. 14, § 7º, da CRFB/88, refere-se à família dos membros do Poder Executivo apenas, não se estendendo aos membros do legislativo.	0 a 0,65	
b) Não, pois a desincompatibilização, estabelecida no art. 14, § 6º da CRFB/88 não é exigida para os cargos do legislativo, estando associada aos chefes do Poder Executivo.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 10

► Peça Processual – Valor: 5,0

Em decisão em sede de ADI publicada no dia 29 de outubro de 2013, o Plenário do STF assentou o entendimento de que o art. 78 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 13/09/00, ao admitir a liquidação “em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos” dos “precatórios pendentes na data de promulgação” da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e atentou, ainda, contra a independência do Poder Judiciário, razão por que suspendeu a eficácia do art. 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, que introduziu o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de Apelação cível, no dia 1º de agosto de 2016, com fundamento na aplicação do referido dispositivo negou provimento ao recurso impetrado por Mévio, beneficiário de precatório atingido pela referida emenda.

Diante da clara violação à decisão do STF na ADI mencionada, redija o instrumento processual constitucional adequado para levar o caso de Mévio diretamente perante a Corte Constitucional.

► Questão 1

Conforme preceitua o art. 62, *caput*, da CRFB/88: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.”

Sobre a temática, responda aos seguintes questionamentos:

- a) Quais os limites para edição de Medidas Provisórias? (Valor: 0,65)
- b) É possível Constituição Estadual prever edição de medida provisória pelo Governador do Estado? Nesse caso, a norma constitucional estadual poderia estabelecer limites diferentes daqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil? Seria possível o controle jurisdicional dos requisitos de relevância e urgência da medida provisória? (Valor: 0,60)

► Questão 2

Ricardo, viciado em jogos de azar, contraiu dívidas com Bruno a fim de pagar seu adversário, a quem devia cinquenta mil reais em razão de vultosas apostas em moeda

corrente. Ricardo sabe que tem direito constitucional a liberdade, já que a Constituição Federal de 1988 não admite a prisão civil por dívida de tal espécie. Ocorre que na última semana foi publicada a Lei 899/15, que veio a restringir o direito de liberdade do cidadão, autorizando a prisão em tal caso, em afronta à Constituição.

Ricardo encontra-se na iminência de sofrer violação de direito seu assegurado constitucionalmente, podendo se socorrer do Poder Judiciário para evitar a incidência dessa norma violadora de seu direito.

Diante do caso hipoteticamente apresentado, responda fundamentadamente:

- a) Explique as diferenças entre o sistema de controle de constitucionalidade que poderá ser suscitado em juízo por Ricardo, e o controle de constitucionalidade que poderá vir ser realizado pela OAB, considerando que esta, no caso, não é lesada. (Valor: 0,65)
- b) O objeto principal das duas ações será o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 3

A atual redação da Constituição da República pode ser alterada, conforme previsto em seu texto. Trata-se de reforma constitucional, que pode ser realizada pelo chamado Poder reformador, espécie do Poder Constituinte derivado. Com base no exposto, responda aos quesitos a seguir:

- a) O texto da Constituição pode ser modificado como bem entenda o órgão reformador? Caso negativo: existem limitações para a reforma do seu conteúdo? Quais seriam? (Valor: 0,65)
- b) Sabemos que o voto hoje é obrigatório. Seria possível que após uma reforma política se pretendesse instituir o voto facultativo por meio de emenda constitucional? (Valor: 0,60)

► Questão 4

Antônio foi condenado pela Justiça Federal de primeiro grau pela prática de crimes que colocaram em risco a própria estrutura institucional do país, conhecidos como crimes políticos. Contratado como advogado de Antônio para defendê-lo na fase recursal, responda os questionamentos a seguir:

- a) Qual é o recurso a ser interposto em face da referida decisão? (Valor: 0,45)
- b) É possível que lei ordinária ou complementar federal amplie as competências do STF? (Valor: 0,40)
- c) Que significa o instituto da Repercussão Geral em recurso extraordinário, criado pela EC 45/04? (Valor: 0,40)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.	0 a 0,50	
Identificação da peça: Reclamação Constitucional – art. 102, I, “I” da CRFB/88 e art. 988, II do CPC.	0 a 1,00	
Fundamentação: – Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que descumpriu decisão proferida pelo STF. – Art. 102, § 2º da CRFB/88 e art. 28, parágrafo único da Lei 9868/99; – Art. 988, II do CPC; – Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – art. 5º, XXXVI da CRFB/88; – Princípio da separação de poderes.	0 a 2,00	
Pedidos: – Concessão da tutela de urgência para suspender a decisão impugnada; – Citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar a sua contestação; – Oitiva/requisição da autoridade Reclamada; – Oitiva do Procurador-Geral da República; – Juntada de documentos; – Procedência do pedido para que seja cassada a decisão judicial e proferida nova decisão.	0 a 1,00	
Valor da Causa: R\$ 1.000,00	0 a 0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A medida provisória encontra limites materiais (§ 1º, do art. 62, da CRFB/88), limites temporais (§§ 2º e 7º do referido artigo) e limites circunstanciais (§ 10 do mesmo dispositivo).	0 a 0,65	
b) Sim, pois a Constituição Estadual poderá criar Medidas Provisórias. Por outro lado, a norma constitucional estadual deverá guardar os mesmos requisitos e limites da norma da Constituição Federal, face ao mandamento da simetria das normas. O STF admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionais, em que a ausência desses pressupostos seja evidente.	0 a 0,60	
Valor Total: _____		

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) O controle de constitucionalidade realizado por Ricardo, próprio lesado, segue a via difusa, como defesa de direito assegurado constitucionalmente. O controle de constitucionalidade realizado pela OAB segue a via concentrada, sendo cabível a ação direta de inconstitucionalidade.	0 a 0,65	
b) A declaração de inconstitucionalidade é o pedido específico da ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB. No caso do controle difuso, o pedido é a proteção do direito assegurado constitucionalmente e violado pela Lei 899/15, dessa forma, o Poder Judiciário analisará incidentalmente a constitucionalidade da lei que é necessária para solucionar o litígio, não sendo o objeto principal da ação.	0 a 0,60	
Valor Total: _____		

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, existem. O conteúdo da CRFB/88 encontra-se protegido de forma expressa pelas chamadas “cláusulas pétreas”, previstas no art. 60, § 4º. Segundo parte da doutrina, além dos limites expressos, as emendas enfrentam limitações materiais implícitas, tais como: a forma republicana de Governo; o sistema presidencialista de governo, a titularidade do poder constituinte e a impossibilidade de alteração do próprio artigo 60, da CRFB/88 visando facilitar o processo legislativo referente às emendas;	0 a 0,65	
b) Sim, pois a obrigatoriedade do voto não está prevista expressamente no art. 60, § 4º, II, da CRFB/88. Logo, o voto obrigatório não é cláusula pétrea, podendo vir a ser objeto de emenda constitucional que pretenda transformá-lo em facultativo.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Recurso Ordinário dirigido ao STF, de acordo com o art. 102, II, “b” da CRFB/88.	0 a 0,45	
b) Não. As competências dos Tribunais Superiores e do STF só podem ser alteradas por emendas constitucionais, e não por norma infraconstitucional.	0 a 0,40	
c) Trata-se de um requisito de admissibilidade do recurso, instrumento de filtragem recursal. O recorrente deverá comprovar a relevância da matéria, em um de seus aspectos (social, cultural, econômico ou político) e, também, a transcendência dos interesses subjetivos das partes na causa, conforme art. 102, § 3º da CRFB/88 e art. 1.035 do CPC.	0 a 0,40	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 11

► Peça Processual – Valor 5,0

O Partido Político da Alegria, interessado nas discussões relacionadas aos planos de saúde, pretende questionar a qualidade da Lei Estadual 777/16, que fixou prazos máximos, segundo a faixa etária dos usuários, para a autorização de exames pelas operadoras de plano de saúde.

Um dos líderes do Partido, advogado estudioso, sustenta que a referida lei pretende regulamentar relações contratuais, o que não seria possível.

Na qualidade de advogado (a) do partido político, elabore a peça cabível, observando: a) competência do juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) requisitos formais da peça; e) tutela de urgência.

► Questão 1

Em razão de investigações promovidas por Comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério Público Federal, empresários do ramo imobiliário e da construção civil estão na iminência de serem denunciados por terem, juntamente com Deputados Federais, promovido esquema de compra de votos. Na qualidade de advogado(a) contratado(a) pelos empresários envolvidos no caso apresentado, responda aos seguintes questionamentos:

- a) O STF será competente para processar e julgar os acusados que não são parlamentares? (Valor: 0,65)
- b) Caso o STF decida pela condenação dos parlamentares, como deverão ser interpretados os dispositivos do art. 55, VI, c/c § 2º, da CRFB/88? (Valor: 0,60)

► Questão 2

A Emenda Constitucional 26/2015, que alterou a Constituição do Estado da Surpresa, instituiu a possibilidade de que a Corte de Contas Estadual sustasse diretamente contratos administrativos irregulares e que também anulasse procedimentos licitatórios. Sobre o enunciado responda aos quesitos abaixo fundamentadamente:

- a) A Emenda acima anunciada é compatível com a Constituição Federal? (0,45)
- b) Como é feita a nomeação dos membros do Tribunal de Contas Estadual? (0,40)
- c) A vedação prevista no art. 31, § 4º, da CRFB/88 se estende aos Estados? É possível a criação de Cortes de Contas Municipais? (0,40)

► **Questão 3**

Sabe-se que a violação de normas constitucionais pelo poder público pode ocorrer não só por ação, mas também por omissão. A Constituição da República traz instrumentos que garantem a sua própria supremacia diante de omissões. Tais instrumentos, apesar de aparentemente semelhantes, possuem características distintas.

Identifique tais instrumentos e faça uma análise comparativa dos mesmos, apontando as principais diferenças entre eles. (Valor: 1,25)

► **Questão 4**

A Empresa Imaginação Ltda. impetrou mandado de segurança em face da Caixa Econômica Federal visando anular ato do Presidente da Comissão de Licitação que, nos autos do contrato para prestação de serviços de reforma nas agências bancárias, aplicou a penalidade de multa por atraso da obra. Diante da narrativa, responda:

- a) O mandado de segurança é o mecanismo adequado para impugnar a multa imposta pela Caixa Econômica? (Valor: 0,65)
- b) É cabível mandado de segurança contra lei em tese? (Valor: 0,60)

► **Espelho**

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal	0 a 0,50	
Identificação da peça: Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 102, I, “a”, da CRFB/88 e Lei 9.868/99	0 a 0,50	
Legitimidade ativa: Partido Político da Alegria – legitimado universal (0,25) Demonstração da representação do Partido no Congresso Nacional (0,25)	0 a 0,50	
Representação do Partido Político por seu Diretório Nacional	0 a 0,50	
Medida Cautelar – arts. 10 a 12 da Lei 9.868/99. <i>Fumus boni iuris</i> e <i>Periculum in mora</i>	0 a 0,50	
Fundamentação: – Art. 102, I, “a”, CRFB/88; – Lei 9.868/99; – Violação de competência federativa – violação formal; – Competência da União para legislar sobre direito civil, art. 22, I, da CRFB/88; – A repartição de competências e o princípio da predominância de interesses.	0 a 1,50	

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Pedidos: - Concessão da medida cautelar para suspender a norma impugnada e, ao final, a procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 777/16; - Juntada de documentos; - Que sejam solicitadas informações ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa Estadual; - Citação do Advogado Geral da União; - Oitiva do Procurador-Geral da República.	0 a 0,70	
Valor da causa: R\$ 1.000,00	0 a 0,30	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, conforme a súmula 704, STF.	0 a 0,65	
b) De acordo com o entendimento do STF, a Casa Legislativa não poderá deixar de cumprir a decisão judicial.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não. A Constituição Estadual deve estabelecer atribuições similares às previstas na Constituição Federal em nome do princípio da simetria, de acordo com o art. 75 da CRFB/88. Não há dispositivo semelhante ao criado pela EC 26/2015 na CRFB/88.	0 a 0,45	
b) A nomeação é feita de acordo com o art. 75, parágrafo único da CRFB/88 e súmula 653 do STF.	0 a 0,40	
c) Não. A vedação é dirigida exclusivamente aos municípios. Desde a promulgação da CRFB/88 não podem ser criados tais órgãos no âmbito municipal.	0 a 0,40	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
O MI é remédio constitucional que inaugura um processo subjetivo, enquanto a ADO é ação do controle concentrado de constitucionalidade, instaurando um processo objetivo; A finalidade do MI é a defesa de normas constitucionais relacionadas a direitos fundamentais dependentes de regulamentação, enquanto a ADO visa defender as normas constitucionais dependentes de regulamentação; Os efeitos da decisão no MI são, via de regra, <i>inter partes</i> , enquanto na ADO são <i>erga omnes</i> ; No MI não se admite cautelar, enquanto na ADO é admitida; A competência do MI é do STF, STJ e TJs dos Estados, já na ADO a competência é do STF; Quanto a legitimidade ativa, no MI dependerá da modalidade da ação, já na ADO os legitimados são os elencados no art. 103, I a IX da CRFB/88.	0 a 1,25	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, por se tratar de ato de gestão comercial, que não se submete às normas de direito público, de acordo com o art. 1º, § 2º da Lei 12.016/09.	0 a 0,65	
b) Não, de acordo com a Súmula nº 266 do STF. No MS é possível se discutir a lei apenas de forma incidental.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 12

► Peça Processual – Valor 5,0

Tícia, brasileira, casada, é hipertensa, cardiopata, portadora de marca-passo, e necessita, sob risco de vida, de diversos medicamentos de uso contínuo, conforme indicado, documentalmente, pelo médico do hospital municipal LMN que a acompanha. Em razão dos altos custos dos medicamentos, Tícia tentou junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e farmácias populares obter os mesmos, sem êxito. Após diversos contatos com a Prefeitura bem como requerimentos formais, em razão do seu péssimo estado de saúde, a mesma recebeu resposta administrativa do Prefeito do Município da Fé, capital do Estado da Perseverança, afirmando que os medicamentos estariam em falta, não sendo possível atender seu pleito.

Indignada, então, Tícia procurou um escritório de advocacia para que fosse apresentada ação adequada na defesa de seu direito, tendo o advogado impetrado um Mandado de Segurança, de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Perseverança.

O remédio fora denegado, no mérito, sob o argumento da inexistência do referido direito líquido e certo mencionado pela Impetrante. Na qualidade de advogado(a), elabore a peça cabível, contra a decisão que denegou a segurança, observando: a) competência do juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; d) os requisitos formais da peça; e) adequação do recurso.

► Questão 1

O Presidente da República, diante da grave perturbação da ordem pública no Estado de Alagoas, decretou estado de defesa, com fundamento nos artigos 84, X e 136, ambos da Constituição Federal. Dispensando a consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, determinou a medida de exceção pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, por uma única vez, por igual período. O Decreto ainda determinou possibilidade de violação domiciliar durante a noite, desde que com mandado judicial, restrições à liberdade de pensamento e de manifestação artística, bem como suspensão da liberdade de reunião, além de possibilitar a incomunicabilidade de presos, quando necessária à execução das medidas. O ato foi apresentado ao Congresso Nacional em 48 (quarenta e oito) horas para que o apreciasse.

Face ao exposto, analise os requisitos e as medidas determinadas pelo Decreto, à luz da doutrina e da Constituição. (Valor: 1,25)

► Questão 2

Os artigos 34, § 1º, e 170, I, da Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dispõem que o pedido assinado por um terço dos Deputados Estaduais para a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito será submetido à deliberação em plenário da casa legislativa estadual. Entendendo que houve ofensa ao modelo federal de criação e instauração das Comissões Parlamentares de Inquérito, a Mesa do referido órgão legislativo ajuíza Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF em face dos dispositivos legais. Com base no exposto, responda os itens a seguir:

- a) A ação merece prosperar? Se afirmativo, sob quais argumentos? (Valor: 0,45)
- b) A CPI federal pode convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações? (Valor: 0,40)
- c) A CPI federal pode determinar a constrição de bens dos investigados? E determinar a violação do sigilo telefônico? (Valor: 0,40)

► Questão 3

A EC 45/04 criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. É órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura cuja base constitucional se encontra no art. 103-B da CRFB/88. Sobre o assunto, responda:

- a) As resoluções do CNJ podem ser objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade? Qual é o órgão responsável para apreciar as ilegalidades cometidas pelo Conselho? (Valor: 0,65)
- b) A criação do CNJ violou o pacto federativo, pois teria trazido a supervisão de órgãos judiciários estaduais por um órgão federal? (Valor: 0,60)

► Questão 4

Frederico é prefeito do Município da Luz, cuja população foi submetida a um recente plebiscito para fins de desmembramento do novo Município da Paz, na forma do art. 18, parágrafo 4º da CRFB/88. O povo aprovou a criação do novo Município, que foi instituído pela Lei do Estado PQR, em 10 de maio de 2012. Ricardo, irmão de Frederico, resolve então se candidatar ao cargo de Prefeito pelo Município recém-criado. Com base no exposto, responda aos quesitos abaixo:

- a) A candidatura de Ricardo é válida à luz da jurisprudência do STF? (Valor: 0,65)
- b) Avalie a constitucionalidade da lei estadual PQR que criou o Município da Paz. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição ao Tribunal de Justiça do Estado da Perseverança	0 a 0,50	
Identificação da peça: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança – art. 105, II, “b” da CRFB/88 e arts. 1.027 e 1.028 do CPC. Competência do STJ	0 a 0,50	
Recorrente: Tícia (0,20) Recorrido: Prefeito do Município da Fé (0,30)	0 a 0,50	
Tempestividade: 15 dias (art. 1.003, parágrafo 5º do CPC). Preparo: art. 1.007 do CPC.	0 a 0,50	
Fundamentação: – Cabimento do Recurso: art. 105, II, “b”, da CRFB/88; – Direito a saúde como um direito social – art. 6º da CRFB/88; – Princípio da dignidade da pessoa humana – art. 1º, III da CRFB/88; – Princípio do mínimo existencial; – Direito líquido e certo; – Direito ao mandado de segurança: art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09.	0 a 1,50	
Pedidos: Postulação de reforma da decisão para garantir o direito líquido e certo aos medicamentos; Condenação do Recorrido nos ônus de sucumbência.	0 a 1,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Um dos fundamentos para decretação encontra-se equivocado, sendo o correto, o art. 84, IX da CRFB/88, que dispõe sobre o estado de defesa; No que tange a consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional, esta não poderia ter sido dispensada, tendo sido violados os arts. 90, I, 91, § 1º, II e 136 da CRFB/88; Quanto à medida de exceção, de acordo com o art. 136, § 2º da CRFB/88, não pode ser superior a 30 dias, podendo haver apenas uma prorrogação, o que também não foi observado pelo Presidente da República; Em relação às determinações de suspensão da liberdade de reunião, restrições à liberdade de pensamentos e todas as demais apontadas, elas não encontram respaldo constitucional, pois não são admitidas, conforme art. 136, § 1º, da CRFB/88; A apresentação do ato ao Congresso Nacional deve se dar em até 24 hs, conforme preceitua o art. 136, § 4º da CRFB/88, o que também não foi respeitado pelo Presidente da República.	0 a 1,25	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, pois houve violação da norma estadual ao art. 58, § 3º da CRFB/88, tendo sido também violado o princípio da simetria, bem como o direito das minorias parlamentares.	0 a 0,45	
b) Sim, de acordo com o art. 50 da CRFB/88.	0 a 0,40	
c) Segundo entendimento do STF, a CPI não pode determinar a constrição de bens do investigado, tendo em vista os princípios da reserva de jurisdição e da separação de poderes. Em contrapartida, pode determinar a quebra do sigilo telefônico, ou seja, dos dados telefônicos dos investigados.	0 a 0,40	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Segundo a orientação do STF, as resoluções do CNJ são consideradas normas primárias, extraídas diretamente da Constituição (art. 103-B) e, por isso, podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade. O STF, na forma do art. 102, I, “r” da CRFB/88.	0 a 0,65	
b) De acordo com o STF o CNJ não é órgão da União, mas sim do Poder Judiciário nacional, não havendo que se falar, assim, em supervisão administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar dos órgãos judiciários estaduais por órgão da União. Ademais, a composição do Conselho reverencia e contempla as duas esferas federativas dotadas de “Justiças”, a União e os Estados-membros, os quais contam com representantes das respectivas magistraturas (art. 103-B, I a IX da CRFB/88). Conclui-se que o Conselho não anula, mas reafirma o princípio federativo.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois segundo o STF é inelegível para o cargo de prefeito de Município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual chefe do Poder Executivo do município-mãe. Inelegibilidade reflexa/relativa, art. 14, parágrafo 7º da CRFB/88.	0 a 0,65	
b) A lei é inconstitucional por violar o art. 18, parágrafo 4º da CRFB/88. Ademais, a EC 57/08, ao acrescentar o art. 96 ao ADCT, regularizou apenas os Municípios criados até 31/12/2006.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 13

► Peça Processual – Valor 5,0

Caio, brasileiro, farmacêutico, precisa realizar uma artroplastia a fim de sanar grave problema na coluna cervical. Nesse procedimento, o disco lesionado é retrado e substituído por uma prótese articulada, que estabiliza e tenta reproduzir o movimento normal da coluna. Apesar de já ter conseguido agendar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, Caio dependia da prótese modelo TTT, de alto custo, para realização da mesma. Entretanto, não obteve êxito, pois o Estado HHH sustentou que não forneceria tal objeto.

A fim de solucionar seu problema, contratou um advogado que, com base na Lei Federal 111/13, que garante a liberação ao SUS de inúmeras próteses gratuitamente, inclusive a referida, atribuindo a responsabilidade a todos os entes federados, propôs ação de obrigação de fazer contra o Estado TTT, tendo obtido procedência na sentença. Entretanto, o Estado apresentou apelação questionando, de forma incidental, a constitucionalidade da referida Lei, pugnando pela reforma da sentença. A 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da mesma, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido do autor.

Sabendo-se que a decisão do referido órgão violou o art. 97 da Constituição Federal, e que não há obscuridade, omissão ou contradição na mesma, na qualidade de advogado de Caio, apresente a peça cabível para impugnar a decisão judicial citada.

► Questão 1

Conforme o art. 58, § 3º, da Constituição da República, as comissões parlamentares de inquérito (CPIs) “terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. Tendo em vista a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação do texto constitucional destacado, explicita as possibilidades e limites da atuação das CPIs em relação às seguintes medidas:

- a) Demonstrado, em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, que é indispensável a interceptação das comunicações telefônicas de um dos investigados, a Comissão pode decretar, por ato próprio, a referida interceptação? As decisões da CPI podem ser tomadas pelo Relator da comissão? (0,65)
- b) A CPI pode impedir a participação do advogado acompanhando o seu cliente, seja ele investigado ou testemunha? (0,60)

► Questão 2

Adelaine logrou êxito no vestibular de Medicina da Universidade Federal do Estado JJJ, autarquia federal, em abril de 2015. Quando foi apresentar a documentação necessária à matrícula na referida instituição, foi surpreendida com a cobrança de uma suposta “taxa de matrícula”, instituída como “ajuda de custo” para compra de materiais de limpeza, higiene e demais utensílios de escritório, como papéis, canetas e lápis, em que pese se tratar de um estabelecimento oficial, mantido pela União Federal. Na iminência do início das aulas, Adelaine então procurou um advogado que informou que há, inclusive, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal indicando que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal. Diante da situação hipotética apresentada, responda:

- a) Na qualidade de advogado contratado por Adelaine, qual é a peça judicial aplicável ao caso? (0,65)
- b) Súmula Vinculante pode ser objeto de ADPF? (0,60)

► Questão 3

Como há muitas farmácias no Município da Saudade, lei local proibiu a instalação de nova farmácia a menos de 400 (quatrocentos) metros de estabelecimento da mesma natureza. À luz da jurisprudência do STF, responda os quesitos abaixo:

- A) Pode-se considerar que a lei municipal é constitucional? Se negativo, quais são os princípios pela lei violados? (0,65)
- B) Quais são as formas de impugnação de uma lei municipal no controle de constitucionalidade brasileiro? (0,60)

► Questão 4

“Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República. (...)” (RTJ 150/223-224, Rel. Min. Celso de Mello). Em face do exposto, responda:

- a) Qual é o princípio que a reserva de plenário visa defender? O art. 97, da CRFB/88 se aplica ao controle difuso e ao concentrado? (0,65)
- b) As Turmas Recursais de Juizados Especiais precisam observar o princípio da reserva de plenário? Quando a decisão declara a revogação da norma pré constitucional, há necessidade de se respeitar o referido princípio? (0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado TTT	0 a 0,40	
Identificação da peça: Recurso Extraordinário – art. 102, III, “a” da CRFB/88 e arts. 1.029 e ss do CPC. Competência do Supremo Tribunal Federal.	0 a 0,60	
Recorrente: Caio (0,20) Recorrido: Estado TTT (0,30)	0 a 0,50	
Cabimento do Recurso: art. 102, III, “a” da CRFB/88. Tempestividade – art. 1.003, parágrafo 5º do CPC.	0 a 0,60	
Preparo – art. 1.007 do CPC (0,20) Prequestionamento – súmula 282 do STF (0,20)	0 a 0,40	
Repercussão geral – Art. 102, § 3º, da CRFB/88 e art. 1.035 do CPC	0 a 0,50	
Fundamentação: – Direito ao Recurso Extraordinário – art. 102, III, “a” da CRFB/88; – Direito à saúde – art. 196 da CRFB/88; – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; – Violação ao Princípio da Reserva de Plenário – art. 97 da CRFB/88.	0 a 1,00	
Pedidos: – Provimento ao recurso para que seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado TTT; – Intimação do Procurador Geral da República; – Condenação do Recorrido nos ônus sucumbenciais.	0 a 1,00	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Segundo a jurisprudência do STF a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode decretar a interceptação telefônica na forma do art. 5º, XII da CRFB/88, vez que tal ato só pode ser determinado por autoridade judiciária, tendo em vista os princípios da reserva de jurisdição, do poder de cautela do juiz e da separação de poderes. As decisões em sede de CPI não podem ser tomadas pelo Relator, pois devem observar o princípio da colegialidade.	0 a 0,65	
b) A CPI não pode impedir a presença de advogado, diante do art. 133, da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A peça judicial adequada ao caso é o Mandado de Segurança, previsto no art. 5º, LXIX da CRFB/88, com base no art. 103-A, § 3º da CRFB/88 c/c art. 7º, § 1º da Lei 11.417/06.	0 a 0,65	
b) Segundo jurisprudência do STF as súmulas, vinculantes ou não vinculantes, não podem ser objeto de ADPF.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A lei municipal é inconstitucional por violar os princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade do exercício das atividades econômicas, que informam o modelo de ordem econômica consagrado pela Constituição da República (art. 170). Houve ofensa à Súmula 646 do STF e também à Súmula Vinculante 49.	0 a 0,65	
b) No controle concentrado federal de constitucionalidade brasileiro, a única ação que pode ter como objeto uma lei municipal é a ADPF. Também é possível impugnar lei municipal em sede de controle difuso de constitucionalidade. No plano estadual, também pode ser objeto de RI (art. 125, § 2º, da CRFB/88).	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Visa defender o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. O art. 97 da CRFB/88 deve ser observado no controle difuso e também no concentrado.	0 a 0,65	
b) As turmas recursais não se configuram como tribunais. Portanto, não precisam observar o princípio da reserva de plenário. Também não é necessária a observância ao princípio no caso de não recepção de normas anteriores à Constituição Federal, pois nesse caso não há declaração de inconstitucionalidade da norma.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

SIMULADO 14

► Peça Processual – Valor 5,0

Em abril de 2015, o Ministério Público abriu inquérito civil para checar atos de improbidade administrativa realizados pelo Prefeito de Cachoeira Bonita, município situado no interior do Estado AAA. Os atos de improbidade consistiriam na realização de diversas compras para o município com burla ao procedimento licitatório estabelecido pela Lei 8.666/93 e que envolveriam atuações do próprio Prefeito, Sr. Autran, e do chefe do gabinete civil, Sr. Gilberto. Ficou comprovado, no curso das investigações, que o chefe do gabinete civil recebeu vantagem econômica, em dinheiro, de várias empresas que contratavam com o poder público. Ficou comprovado, também, o aumento patrimonial do chefe do gabinete civil, desproporcional aos seus ganhos, mas não o do Prefeito. Com isso, já agora em fevereiro de 2016, o Ministério Público ajuíza ação civil pública em face do Prefeito, do Município e de seu chefe de gabinete, fazendo menção a todos os atos de improbidade realizados por esse último, perante o Tribunal de Justiça do Estado AAA. Transtornado com a ação proposta o Prefeito procura você para apresentar a sua defesa.

► Questão 1

Sabe-se que a saúde pública no país está bem aquém do que determina a Constituição de 1988. Diante de inúmeras ações judiciais sobre medicamentos e no intuito de desenvolver um debate com a sociedade sobre o tema, o Presidente do STF convocou uma audiência pública. Sobre o tema, responda:

- a) Quem será ouvido em audiência pública? Quais dispositivos regulam a matéria? (Valor: 0,65)
- b) Entidades já admitidas no processo na qualidade de *amicus curiae* precisam se inscrever para participar da audiência? (Valor: 0,60)

► Questão 2

Considere a seguinte situação hipotética:

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu prerrogativa de foro funcional para julgamento dos Vereadores por crimes comuns, bem como imunidade material no âmbito territorial de cada Município, em harmonia com o art. 29, VIII, da CRFB/88.

Sobre o assunto, responda:

- a) Qual é o órgão competente para julgar vereadores por crimes dolosos contra a vida no Rio de Janeiro? (Valor: 0,65)
- b) A prerrogativa de foro e a imunidade material podem ser objeto de renúncia? (Valor: 0,60)

► **Questão 3**

O Estado da Fé aprovou a lei 222/16 que incluiu a disciplina de formação para o trânsito nos currículos do 1º e do 2º graus de ensino da rede pública estadual.

A esse respeito, responda aos itens a seguir:

- A) A referida lei estadual é constitucional? (Valor: 0,65)
- B) Um Governador de outro Estado pode ajuizar ADI ou ADPF contra esta lei? Explique. (Valor: 0,60)

► **Questão 4**

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou uma resolução proibindo o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Diante de muitas decisões judiciais controvertidas sobre a aplicação da resolução, o Conselho Federal da OAB propôs uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o STF para defender a constitucionalidade da norma.

A respeito da situação acima, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso.

- a) É possível a propositura da ADC para defender a constitucionalidade da referida resolução? (Valor: 0,45)
- b) O Conselho Federal da OAB tem legitimidade para a propositura daquela ADC? (Valor: 0,40)
- c) Pode um Estado instituir uma ADC no plano estadual? Nesse caso, qual o instrumento jurídico apto à criação do instituto? (Valor: 0,40)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado AAA	0 a 0,50	
Identificação da peça: Contestação à ação civil pública – art. 335 e ss. do CPC	0 a 0,50	
Tempestividade – art. 335 do CPC	0 a 0,50	
Preliminar: – Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado AAA (1,50).	0 a 1,50	
Fundamentação: – Princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB/88); – Ausência de provas; – Má-fé; – Não há violação aos princípios que norteiam a Administração Pública (art. 37, caput da CRFB/88).	0 a 1,00	
Pedidos: – Preliminarmente, seja reconhecida a preliminar de incompetência absoluta do Tribunal; – No mérito, que julgue improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor nos ônus da sucumbência; – Provar o alegado por todos os meios de prova previstos em lei, especialmente pelos documentos ora juntados aos autos.	0 a 1,00	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Serão ouvidos especialistas em questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas. Pessoas com experiência e autoridade na matéria submetida ao Tribunal, de acordo com os arts. 13, XVII, e 21, XVII, do RISTF. A matéria é regulada pelos seguintes dispositivos: art. 9º, § 1º, da Lei 9.868/99; art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/99.	0 a 0,65	
b) Sim. A entidade, se entender conveniente, poderá indicar especialista e solicitar participação na audiência.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Será competente o Tribunal do Júri, de acordo com a Súmula 721 do STF e a Súmula Vinculante 45.	0 a 0,65	
b) Não, pois pertencem ao cargo, e não ao parlamentar, já que funcionam como garantias de independência de exercício funcional.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A lei é constitucional, pois o art. 24, IX, da CRFB/88 atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Esta lei trata de educação no trânsito e não sobre trânsito e transporte, que seria de competência privativa da União Federal (Art. 22, XI, CRFB/88).	0 a 0,65	
b) Não, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do STF, o Governador do Estado é legitimado especial, o que significa que só pode ajuizar a ação se demonstrar a existência de pertinência temática entre o interesse do Estado e o objeto da ação, o que não ocorre no caso concreto.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim. De acordo com a jurisprudência do STF, as resoluções do CNJ são consideradas normas primárias, extraídas diretamente da Constituição (art. 103-B da CRFB/88) e por isso podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade.	0 a 0,45	
b) Sim. De acordo com o art. 103, VII da CRFB/88.	0 a 0,40	
c) Sim. O instrumento jurídico apto para sua criação é a Constituição Estadual ou uma emenda à Constituição do Estado.	0 a 0,40	
	Valor Total: _____	

SIMULADO 15

► Peça Processual – Valor: 5,0

Antônio Paulo, professor, casado, cidadão brasileiro em dia com suas obrigações tributárias, tentou obter acesso aos dados concernentes ao pagamento de seus tributos, constantes no Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica (Sincor), mantido pela Secretaria da Receita Federal. Tais dados são de seu interesse e necessários para serem utilizados como prova em futura ação judicial.

Tendo em vista a negativa da referida informação em todas as instâncias administrativas, por escrito e fundamentada no sigilo, em razão do último ato praticado pelo Ministro da Fazenda, na qualidade de advogado (a) de Antônio, redija a petição inicial da ação a ser proposta para acessar os dados observando: Competência do juízo; Legitimidade ativa e passiva; Fundamentos de mérito constitucionais e legais vinculados; Os requisitos formais da peça inaugural.

► Questão 1

Lei do Município da Aprovação, de iniciativa da Câmara de Vereadores, estipulou novo plano de carreira para determinada categoria de servidores municipais, impondo remunerações escalonadas, fixando pisos mínimos e vinculando a remuneração global ao percebido por servidores do Poder Legislativo local.

Com base no relatado, responda aos itens a seguir:

- a) Observadas as regras constitucionais, há vício na referida lei? (Valor: 0,65)
- b) A vinculação de remunerações entre Poderes é acolhida no texto constitucional? (Valor: 0,60)

► Questão 2

Considere a seguinte situação hipotética:

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou projeto lei criando a obrigatoriedade de uso do cinto de segurança nos transportes coletivos como ônibus e trem. O Governador do Estado vetou o projeto e o veto foi posteriormente derrubado pelo órgão legislativo. A norma foi promulgada no dia 30 de março de 2016, mas só entrará em vigor no dia 15 de setembro do mesmo ano. Pergunta-se:

- a) A referida lei pode ser objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade antes da publicação? No caso de ajuizamento simultâneo da ação direta no plano federal e estadual, o que deverá acontecer? (Valor: 0,65)

- b) O quórum para derrubada do veto do Governador pode ser de maioria simples dos membros da Assembleia Legislativa? (Valor: 0,60)

► **Questão 3**

Após reiteradas decisões sobre determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou enunciado de Súmula Vinculante determinando que “a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV da Constituição”. O Estado do Rio de Janeiro, contudo, não concordando com a posição do Supremo Tribunal Federal (STF), edita lei dispondo exatamente sobre a possibilidade de cobrança de matrícula nas universidades públicas do Estado.

De acordo com o acima narrado, responda:

- a) É cabível o ajuizamento de uma Reclamação Constitucional em face da lei do Estado do Rio de Janeiro? (Valor: 0,65)
- b) Marco Antônio, cidadão engajado na luta pela melhoria do sistema educacional do país, pode ajuizar uma ação popular diretamente em face da Lei estadual? (Valor: 0,60)

► **Questão 4**

O Governador do Estado de Alagoas ajuiza uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da primeira parte do art. 7º da Lei 9.709/98 (“Nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º, entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada”) por entender que somente a população do Estado a ser desmembrado que dever ser consultada. Com base no exposto, responda:

- a) Qual é o conceito de “população diretamente interessada” segundo o STF? (0,65)
- b) O plebiscito previsto no art. 18, § 3º, da CRFB/88 é convocado por qual órgão? (0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça	0 a 0,50	
Identificação da peça: Habeas Data – art. 5º, LXXII, “a” da CRFB/88 e Lei 9.507/97	0 a 0,50	
Legitimidade ativa: Antônio Paulo (0,20) Legitimidade Passiva: Ministro da Fazenda (0,30)	0 a 0,50	
Fundamentação: – Art. 5º, LXXII, “a” da CRFB/88; – Art. 5º, XXXIII da CRFB/88 (direito à informação como direito fundamental); – Competência para julgamento do STJ – art. 105, I, “b” da CRFB/88; – O Impetrante é o titular do dado pessoal que se pretende conhecer; – Da prova da recusa à informação – art. 8º, I da Lei 9.507/97.	0 a 2,00	
Pedidos: Notificação da autoridade coatora; Procedência do pedido para que seja assegurado o acesso às informações de interesse da Impetrante; Intimação do Representante do Ministério Público; Juntada de documentos.	0 a 1,00	
Valor da causa: R\$ 1.000 (mil reais) para efeitos procedimentais.	0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, há vício de iniciativa. De acordo com o art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, a CRFB/88, atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa quanto ao tema servidores públicos, norma que, por simetria, deve ser observada pelos Estados e Municípios.	0 a 0,65	
b) Não, pois do art. 37, XIII, da CRFB/88 veda a equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, poderá ser objeto de ADI desde a promulgação, pois esta já recai sobre a lei, servindo para atestar sua validade e executoriedade. No caso de ajuizamento simultâneo, a representação de inconstitucionalidade estadual ficará suspensa até o julgamento final da ADI proposta perante o STF, a fim de evitar decisões contraditórias.	0 a 0,65	
b) Não, pois o art. 66, parágrafo 4º da CRFB/88 é norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, de acordo com a jurisprudência do STF. O quórum no plano estadual deverá seguir o modelo federal: maioria absoluta.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois as súmulas vinculantes não vinculam o Poder Legislativo em sua função legiferante, de acordo com o art. 103-A, caput, da CRFB/88.	0 a 0,65	
b) Não. Marco Antônio poderia questionar a constitucionalidade da referida lei de forma incidental, mas não diretamente.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com a jurisprudência do STF, “população diretamente interessada” significa que é necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial. Dessa forma, no caso de desmembramento, a consulta deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente.	0 a 0,65	
b) O plebiscito é convocado pelo Congresso Nacional, na forma do art. 3º da Lei 9.709/98, c/c art. 49, XV, da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 16

► Peça Processual – Valor 5,0

Foi divulgada em diário oficial a decisão do Governador do Estado X, lastreada por laudo do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Estado, determinando a demolição do Estádio de Futebol Pelé para a construção de um novo estádio para sediar evento esportivo mundial em 2018.

João das Neves, deputado estadual, é contra a referida medida por entender que a demolição é danosa ao meio ambiente e ao patrimônio artístico do Estado. Além do mais, defende que haja uma adaptação do Estádio Pelé às exigências da Federação Internacional de Futebol (FIFA), em vez da derrubada do Estádio para a construção de outro, orçada, a princípio, em 400 milhões de reais, o que acarretará irreversível desperdício de dinheiro público.

Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por João, redija a petição inicial da ação cabível, atentando, necessariamente, para os seguintes aspectos:

- A) competência do órgão julgador;
- B) legitimidade ativa e passiva;
- C) argumentos de mérito;
- D) requisitos formais da peça judicial proposta;
- E) tutela de urgência.

► Questão 1

Suponha que determinado Estado da federação esteja diante da grave perturbação da ordem pública. E que, diante disso o Presidente da República pretenda decretar estado de defesa com fundamento nos artigos art. 84, IX e 136 da Constituição Federal. Pergunta-se:

- a) O Presidente da República poderá dispensar a consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional? Explique. (Valor: 0,65)
- b) É possível que se determine a medida de exceção pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis, por uma única vez, por igual período? E, ainda, que se estabeleçam restrições à liberdade de pensamento e de manifestação artística, bem como suspensão da liberdade de reunião, além de possibilitar a incomunicabilidade de presos, quando necessária à execução das medidas? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ... Vara da Fazenda Pública da Comarca ... do Estado X.	0 a 0,50	
Identificação da peça: Ação Popular – art. 5º, LXXIII da CRFB/88 e Lei 4.717/65.	0 a 0,50	
Legitimidade ativa: João das Neves (0,20) Legitimidade Passiva: Governador do Estado X, Estado X e Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Estado X. (0,30)	0 a 0,50	
Fundamentação: Art. 5º, LXXIII, da CRFB/88; Art. 37, <i>caput</i> (princípio da moralidade); Art. 2º, “d” da Lei 4.717/65; Art. 225, da CRFB/88. Defesa do meio ambiente. Defesa do patrimônio artístico do Estado.	0 a 1,50	
Tutela de Urgência: Concessão de medida cautelar/liminar – Art. 5º, § 4º da Lei 4.717/65 e art. 300 do CPC: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.	0 a 0,50	
Pedidos: Concessão de medida cautelar/liminar para suspender o contrato; Procedência do pedido para invalidar a decisão do Governador do Estado X; Citação dos Réus; Intimação do Representante do Ministério Público; Condenação dos Réus em custas e em honorários advocatícios; Produção de todos os meios de provas em direito admitidas; Juntada de documentos. – Em cumprimento ao art. 319, VII do CPC, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação.	0 a 1,00	
Valor da causa: R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).	0 a 0,50	
	Valor Total: _____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, pois a consulta prévia ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional não pode ser dispensada, sob pena de violação aos arts. 90, I, 91, § 1º, II e 136 da CRFB/88. Importante destacar que o parecer dos Conselhos não é vinculante.	0 a 0,65	
b) Não, pois a medida de exceção, de acordo com o art. 136, § 2º da CRFB/88, não pode ser superior a 30 dias, podendo haver uma prorrogação. Em relação às determinações de suspensão da liberdade de reunião, restrições à liberdade de pensamentos e todas as demais apontadas, elas não encontram respaldo constitucional, pois não são admitidas, conforme art. 136, § 1º da CRFB/88. A incomunicabilidade do preso é expressamente vedada pelo art. 136, § 3º, IV da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A lei é inconstitucional, pois usurpa competência legislativa outorgada à União pela Constituição Federal. De acordo com o art. 24, IX da CRFB/88, educação é matéria de competência concorrente. Logo, cabe a União estabelecer normas gerais e o Distrito Federal deverá complementar a lei (§§ 1º e 2º do art. 24 da CRFB/88). Violação ao direito à educação.	0 a 0,65	
b) Sim. O Governador do Estado pode ajuizar a ADI, pois é legitimado ativo, conforme o art. 103, V da CRFB/88 e a pertinência temática foi comprovada.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) O remédio adequado é o Habeas Corpus, tendo em vista que as peças de informação coletadas ao longo da investigação poderão ser apresentadas posteriormente ao MP com o objetivo de lastrear eventual ação penal que poderá cominar numa condenação com pena privativa de liberdade. O órgão competente é o STF, por força do art. 102, I, I, da CRFB/88.	0 a 0,65	
b) Segundo a jurisprudência do STF a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode decretar a interceptação telefônica na forma do art. 5º, XII da CRFB/88, e nem mesmo a penhora de bens, vez que tais atos só podem ser determinados por autoridade judiciária, tendo em vista o princípio da reserva de jurisdição.	0 a 0,60	
Valor Total: _____		

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não, por força da imunidade material prevista no art. 53, <i>caput</i> da CRFB/88. Como a matéria tem conteúdo político, também não haverá responsabilidade.	0 a 0,65	
b) Sim, na forma do art. 29, VIII da CRFB/88, mas a imunidade material está limitada ao próprio Município.		
Valor Total: _____		

SIMULADO 17

Joaquim Alves, portador de doença celíaca que causa prejuízo na absorção dos nutrientes, vitaminas, sais minerais e água, ingressou com uma ação ordinária com obrigação de fazer em face do Secretário de Saúde do Município Y para entrega do medicamento Glúten Free, inserido na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, mas em falta nos postos de saúde do referido Município. A tutela antecipada pretendida foi denegada pelo Juiz de Direito competente, sob a alegação de que não foi feita prova suficiente do estado de saúde de Joaquim para justificar a pretensão de urgência. Ressalte-se que ele apresentou na petição inicial laudos médicos e documentos suficientes para comprovar o alegado. Prepare o recurso cabível da decisão que rejeitou a concessão da medida de urgência, registrando toda a matéria de direito processual e material pertinente ao caso apresentado. É indispensável o pedido de antecipação de tutela recursal.

► Questão 1

Estevão, candidato à Presidência da República, prepara-se para os debates a serem realizados nos próximos meses pela imprensa. Desejando um discurso impactante, promete dar resposta à sociedade no que tange aos últimos escândalos envolvendo o Poder Legislativo brasileiro. Para tanto, pretende anunciar uma Proposta de Emenda Constitucional prevendo a extinção do “Estatuto dos Congressistas” da Carta Constitucional de 1988.

- a) Caso Estevão venha a ser eleito, será legitimado a apresentar a PEC? A referida alteração pretendida é constitucional? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Suponha que, tendo em vista tal situação, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados se mobilizem no sentido de apresentar PEC que ponha fim as imunidades do Presidente da República. Tal proposta prosperaria? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 2

O Estado da Esperança, por meio do Governador, apresentou um projeto de lei dispondo sobre a possibilidade de acúmulo das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, determinando a transferência dos minutos não utilizados no mês de sua aquisição, enquanto não forem utilizados, para os meses subsequentes. Ao receber tal projeto, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela sua inconstitucionalidade.

- a) O parecer da CCJ está correto? Caso positivo, aponte o(s) vício(s) presente(s) no projeto. (Valor: 0,65)
- b) O que ocorre com o projeto de lei diante do parecer da Comissão pela sua inconstitucionalidade? (Valor: 0,60)

► Questão 3

No Estado FGH foram divulgadas denúncias de irregularidades praticadas em compras de medicamentos, com indícios de desvio de dinheiro público. Diante da situação apontada, Deputados Estaduais, em número suficiente, pretendem instalar Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias.

- a) É possível a criação de CPI no plano estadual? Pode a CPI estadual apurar irregularidades ocorridas no âmbito municipal? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Diante da possibilidade de esgotamento do prazo para conclusão dos trabalhos, pergunta-se: é possível que haja prorrogação do mesmo? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 4

Sabe-se que o controle de constitucionalidade brasileiro é pautado em alguns princípios constitucionais. Com base em tais princípios, responda fundamentadamente:

- a) Pode-se dizer que a lei goza de presunção relativa ou absoluta de constitucionalidade? Há alguma norma no ordenamento jurídico pátrio que goze de presunção absoluta de constitucionalidade? (Valor: 0,65)
- b) O princípio da reserva de plenário, estabelecido pelo art. 97 da CRFB/88, deve ser observado para que seja declarada a inconstitucionalidade de uma norma. Aponte duas situações em que não será necessária a observância ao princípio. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado...	0 a 0,50	
Identificação da peça: Agravado de Instrumento – Art. 1.015, I, do CPC	0 a 0,50	
Agravante: Joaquim Alves (0,20) Agravado: Secretário de Saúde do Município Y (0,30)	0 a 0,50	
Tempestividade – art. 1.003, parágrafo 5º do CPC (0,25) Preparo – art. 1.007 e art. 1.017, parágrafo 1º do CPC (0,25)	0 a 0,50	
Antecipação da tutela recursal – art. 1.019, I e art. 300 do CPC.	0 a 0,50	
Juntada de peças obrigatórias – art. 1.017, I, do CPC.	0 a 0,50	
Fundamentação: – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da CRFB/88); – Direito à vida; – Direito à saúde (arts. 6º e 196 da CRFB/88).	0 a 1,00	
Pedidos: – Concessão da antecipação da tutela recursal; – A juntada dos documentos; – Intimação do Agravado; – Postulação de reforma da decisão para garantir o direito ao medicamento em sede de medida de urgência.	0 a 1,00	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Caso seja eleito será legitimado a apresentar a PEC, conforme art. 60, II da CRFB/88. A alteração pretendida é inconstitucional, tendo em vista que afronta a limitação material explícita no texto constitucional, prevista no art. 60, § 4º, III da CRFB/88, pois o fim do “Estatuto dos Congressistas” abalaria a separação dos Poderes, que é cláusula pétrea.	0 a 0,65	
b) A proposta não prosperaria, pois seria também inconstitucional, já que o fim das imunidades do Presidente da República enfraqueceria a separação dos Poderes, que é cláusula pétrea, de acordo com o art. 60, § 4º, III da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, o parecer está correto. O projeto de lei viola o disposto no art. 22, IV da CRFB/88, pois legislar sobre telecomunicações é competência privativa da União, não podendo o Governador do Estado legislar sobre a matéria. Trata-se de inconstitucionalidade formal subjetiva.	0 a 0,65	
b) Na forma do Regimento Interno das casas do Congresso Nacional, o parecer da CCJ pela inconstitucionalidade da lei gera o arquivamento do projeto, salvo se houver manifestação dos membros da Casa em defesa do projeto que será levado ao Plenário. Art. 58, § 2º, I, da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) É possível a criação de CPI nos estados, desde que siga os requisitos estabelecidos pela Constituição Federal (art. 58, § 3º) Em nome do Princípio Federativo a CPI estadual não poderá ser aberta para investigar questões locais.	0 a 0,65	
b) Sim. A jurisprudência do STF permite que haja sucessivas prorrogações do prazo inicialmente fixado para o término dos trabalhos, desde que não ultrapasse o da legislatura na qual a CPI foi instaurada.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) As leis gozam de presunção relativa de constitucionalidade. Segundo a jurisprudência do STF, as normas constitucionais originárias são as únicas que gozam de presunção absoluta de constitucionalidade, não podendo ser declaradas inconstitucionais.	0 a 0,65	
b) Não será necessária a observância ao referido princípio no caso previsto no art. 949, p. único do CPC. Também não é necessária sua observância pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, pois não se configuram como sendo "Tribunais".	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 18

► Peça Processual – Valor 5,0 (cinco pontos)

Irineu da Silva, brasileiro, casado, aprovado no concurso público para o cargo de Procurador do Estado da Bahia, apresentou um requerimento administrativo ao Governador do referido Estado, autoridade responsável pelo concurso, tendo em vista a alegação de violação ao art. 37, IV, da CRFB/88 (“IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;”), uma vez que a autoridade reputada coatora não o nomeara para o cargo pleiteado, embora tivesse sido aprovado dentro do número de vagas anunciadas pelo edital do concurso. Em resposta administrativa publicada ontem, o Governador alegou que não há direito líquido e certo de nomeação em concurso público e sim uma mera expectativa de direito. Irineu, então, procura seu escritório de advocacia para que seja apresentada ação adequada na defesa do seu direito. Há necessidade de tutela de urgência.

► Questão 1

Determinado estado editou lei que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia móvel para fins de segurança pública, impondo obrigação diretamente relacionada ao objeto da concessão, ao determinar que as empresas forneçam à polícia judiciária informações sobre a localização de aparelhos, estabelecendo prazos, dispondo acerca do uso dos números de emergência e impondo o pagamento de multa, em caso de descumprimento. Responda fundamentadamente:

- a) A referida lei é constitucional? Explique e aponte eventuais vícios. (Valor: 0,65)
- b) Qual o princípio basilar que fundamenta todo o controle de constitucionalidade brasileiro? Discorra sobre ele. (Valor: 0,60)

► Questão 2

Caio da Silva, estudante dedicado já aprovado em duas etapas do concurso público pretendido, foi surpreendido com sua eliminação em razão de ter sido reprovado em exame psicotécnico. Tendo requerido o acesso ao resultado do mesmo, foi surpreendido com resposta administrativa negativa. Diante do caso apresentado, responda:

- a) Aponte o instrumento jurídico apto à obtenção do acesso ao resultado do exame. Fundamente. Há possibilidade de pleitear tutela de urgência? Justifique. (Valor: 0,65)
- b) Florinda, mãe de Caio, poderá se valer desse instrumento jurídico para defesa do direito de seu filho? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 3

O Poder Legislativo realiza como uma de suas atividades típicas a função de fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, mediante controle externo, auxiliado pelo Tribunal de Contas.

De acordo com o art. 73 da CRFB/88:

“O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.”

Sobre o tema, responda aos questionamentos abaixo:

- a) É correto afirmar que o Tribunal de Contas da União não pode, no desempenho de suas atribuições, realizar controle de constitucionalidade, sob pena de estar usurpando competência do STF? Fundamente. (Valor: 0,65)
- b) Explique a expressão “jurisdição” mencionada no art. 73 da CRFB/88. O TCU exerce atividade jurisdicional típica? (Valor: 0,60)

► Questão 4

Com a chegada de uma nova Constituição, inaugura-se um momento também novo na vida de um país e, por isso, faz-se imperiosa a análise sobre o que acontece com as normas preexistentes, constitucionais e infraconstitucionais.

Sobre o tema, responda fundamentadamente:

- a) Explique a Teoria da revogação global e da Recepção. (Valor: 0,65)
- b) Quais são as diferenças entre Repristinação e Efeitos Repristinatórios? (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	0 a 0,50	
Identificação da peça: Mandado de Segurança – art. 5º, LXIX e Lei 12.016/09	0 a 0,50	
Impetrante: Irineu da Silva (0,20) Impetrado: Governador do Estado da Bahia e Estado da Bahia (0,30)	0 a 0,25	
Tempestividade – art. 23, da Lei 12.016/09	0 a 0,25	
Tutela de Urgência (cautelar/liminar) – art. 7º, III, da Lei 12.016/09 e art. 300 do CPC. <i>Fumus boni iuris</i> e <i>Periculum in mora</i> ou probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.	0 a 0,50	
Fundamentação: Existência de prova pré constituída. Direito ao mandado de segurança – art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09; Direito líquido e certo à nomeação; Princípio do concurso público, art. 37, II e IV, da CRFB/88. Princípios da legalidade impessoalidade e moralidade (37, caput)	0 a 1,50	
Pedidos: – Concessão da cautelar/liminar; – Notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender pertinentes ao caso; – Que seja dada ciência à pessoa jurídica; – A intimação do Representante do Ministério Público; – A condenação do Impetrado em custas processuais; – A juntada dos documentos; – Que ao final seja julgado procedente o pedido para que o impetrante seja nomeado ao cargo de Procurador do Estado da Bahia.	0 a 1,00	
Valor da causa: R\$ 1.000,00	0 a 0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A lei é inconstitucional, pois a competência para legislar sobre telecomunicações é da União, de acordo com o art. 22, IV da CRFB/88, não podendo o estado dispor sobre a matéria. Trata-se de inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de competência (ou inconstitucionalidade formal orgânica).	0 a 0,65	
b) O Princípio da Supremacia da Constituição, pois é o que permite que os atos estatais, que hierarquicamente estão abaixo da Carta Maior, sejam controlados caso contrariem direta ou indiretamente os dispositivos constitucionais.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Poderá ser impetrado um <i>habeas data</i> , de acordo com o art. 5º, LXXII, "a" da CRFB/88. É possível a concessão de tutela de urgência, apesar da ausência de previsão expressa na Lei 9507/97, aplica-se, subsidiariamente o art. 300 do CPC, segundo doutrina majoritária.	0 a 0,65	
b) Não, pois trata-se de remédio constitucional personalíssimo, só podendo se impetrado, em regra, pelo titular do dado.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Não é correta tal afirmação, pois de acordo com a Súmula 347 do STF, o TCU pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público no exercício de suas atribuições, e, assim sendo, pode rejeitar a prestação de contas fundada em lei inconstitucional. Ao realizar tal controle, não usurpa competência do STF, pois trata-se de um controle incidental, realizado diante dos casos concretos submetidos à sua apreciação.	0 a 0,65	
b) A expressão “jurisdição” é utilizada em seu sentido administrativo, tendo em vista que o referido tribunal não exerce atividade jurisdicional típica. Seus atos são de natureza técnica e administrativa e não integra o Poder Judiciário, pois é órgão auxiliar do Congresso Nacional.	0 a 0,60	
	Valor Total:	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A Teoria da revogação global afirma que a Constituição nova revoga a Constituição que a antecedeu, deixando esta última de produzir seus efeitos jurídicos. Por serem normas de mesma hierarquia e versarem igualmente sobre matéria constitucional, aplica-se o princípio geral do direito no sentido de que a lei nova revoga completamente a anterior. No Brasil, entre um ordenamento constitucional novo e as normas constitucionais anteriores sempre se operou o fenômeno da revogação global. Segundo a teoria da recepção, se houver compatibilidade de conteúdo, assunto, com a nova Constituição, as normas do direito ordinário anterior serão bem-vindas e recebidas perante a nova ordem constitucional e continuarão a produzir completamente seus efeitos jurídicos. Se, por sua vez, não existir harmonia de matéria, as normas não serão recebidas. É o que tratam os fenômenos da recepção e da não recepção.	0 a 0,65	

Questão avaliada	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Importante ressaltar que a recepção é um fenômeno de natureza material porque não analisa o processo legislativo que fundamentou a elaboração das normas, fixando-se na análise de seu conteúdo. É fenômeno automático.	1	
b) Pela teoria da repristinação, de acordo com o art. 2º, parágrafo 3º da LINDB, é possível que mediante disposição expressa, a lei nova, revogadora de outra, que revogou a que antecedeu repristina, ou seja, restaure os efeitos jurídicos, de uma norma já revogada, realizando o fenômeno da repristinação. Já no “efeito repristinatório”, que ocorre em sede de controle concentrado de constitucionalidade, se a lei cuja suspensão se pede em caráter liminar for revogadora de outra, a concessão da cautelar opera a retomada da eficácia daquela que, em tese, havia sido revogada. Tal fenômeno acontece automaticamente, exceto se o tribunal quiser excluir o efeito repristinatório da lei revogada pela suspensão liminar da norma revogadora, de acordo com o art. 11, parágrafo 2º, da Lei 9.868/99.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

SIMULADO 19

► Peça Processual – Valor 5,0 (cinco) pontos

Mévio Santos, portador de HIV (vírus da imunodeficiência humana), em posse de laudo médico comprovando a doença, ingressou com um mandado de segurança em face do Secretário do Estado Y para entrega dos **medicamentos** antirretrovirais, inseridos na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, mas em falta nos postos de saúde do referido Estado. O mandado foi improvido pelo juiz de primeiro grau, que entendeu que não é obrigação do Estado a entrega do referido medicamento e que tendo em vista o princípio da reserva do possível, não há medicamento disponível para todos os cidadãos por falta de recursos públicos. Prepare o recurso cabível da decisão de mérito que negou provimento ao referido remédio, abordando toda a matéria de direito processual e substancial pertinente ao caso apresentado.

► Questão 1

De acordo com o art. 5º, LXXIII da CRFB/88: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

Ação popular é um remédio constitucional sob procedimento especial com previsão constitucional e infraconstitucional de acordo com a Lei 4.717/1965. Sobre o tema, responda fundamentadamente:

- É possível o controle de constitucionalidade incidental em sede a Ação Popular? O cidadão do Estado A pode ajuizar uma Ação Popular em face de um contrato irregular assinado pelo Governador do Estado B? Justifique. (Valor: 0,65)
- Existe prazo para a propositura da Ação? Explique. (Valor: 0,60)

► Questão 2

O processo legislativo é composto por um conjunto de atos preordenados que visam à criação de uma norma legal, de acordo com a Constituição. Funciona como uma grande orquestra, onde os instrumentos devem estar bem afinados e os cantores com vozes harmoniosas.

Sobre o tema:

- Em que consiste o procedimento legislativo sumário? Fundamente. (Valor: 0,65)
- Explique a iniciativa popular a projetos de lei. Tal iniciativa também pode se dar em âmbito estadual e municipal? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Questão 3

Determinado Estado-membro publicou lei que dispõe sobre o regime jurídico a que os policiais militares estariam sujeitos no caso de eleição para cargo público, acabando por tratar, de certa forma, da elegibilidade do Policial Militar. Determinada associação afirma que tal lei é inconstitucional. Responda de maneira fundamentada:

- a) A associação está correta? A referida lei é inconstitucional? Em caso positivo, qual(is) o(s) vício(s) que a mesma apresenta? (Valor: 0,65)
- b) Explique o que vem a ser a “declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto”. (Valor: 0,60)

► Questão 4

A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) perante o STF, na qual se indicava como ato lesivo a preceito fundamental um determinado projeto de lei:

- a) De acordo com a jurisprudência do STF, projetos de leis podem ser objeto de ADPF? (Valor: 0,65)
- b) É possível a modulação temporal dos efeitos da decisão em sede de ADPF? (Valor: 0,60).

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento da petição de interposição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da ... vara ... da Comarca Y (0,30) Endereçamento da petição de razões: Ao Tribunal de Justiça do Estado Y (0,20)	0 a 0,50	
Identificação da peça: Recurso de Apelação – art. 14 da Lei 12.016/09, art., 1.009, do CPC.	0 a 0,50	
Recorrente: Mévio Santos (0,20) Recorrido: Secretário do Estado Y (0,30)	0 a 0,50	
Pedido de gratuidade de justiça – preenchimento dos requisitos contidos – no art. 99, § 3º, do CPC (0,20) – e art. 5º, LXXIV, da CRFB/88. (0,20)	0 a 0,50	
Cabimento do Recurso: art. 1.009 do CPC e art. 14 da Lei 12.016/09 Tempestividade – art. 1.003, § 5º, do CPC	0 a 1,00	
Fundamentação: Direito ao mandado de segurança – art. 5º, LXIX da CRFB/88 e Lei 12.016/09; Direito fundamental à saúde – arts. 6º e 196 da CRFB/88; Princípio da Dignidade da Pessoa Humana – art. 1º, III da CRFB/88; Direito à vida – art. 5º, caput da CRFB/88; Princípio do mínimo existencial;	0 a 1,00	
Pedidos: Postulação de reforma da sentença para garantir o direito líquido e certo ao medicamento; Condenação nos ônus sucumbenciais.	0 a 1,00	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim. Atualmente a posição jurisprudencial e doutrinária dominantes é favorável ao referido controle desde que a ação não seja apresentada com a finalidade única de declarar a inconstitucionalidade da lei, pois a lei em tese só pode ser analisada nas ações do controle concentrado de constitucionalidade. Sim, pois conforme jurisprudência, o fato de o cidadão ser eleitor em Estado diverso daquele onde ocorreu as irregularidades não o impede de ajuizar ação popular. Afinal, a legitimidade ativa da ação é deferida ao cidadão. A condição de eleitor configura meio de prova documental da cidadania.	0 a 0,65	
b) Na ação popular preventiva, aquela que é proposta antes de consumada a lesão, não há prazo. Na ação popular repressiva, após a consumação do dano, a mesma deverá ser proposta no prazo de cinco anos, na forma do art. 21 da Lei 4.717/1965.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) De acordo com o art. 64, § 1º da CRFB/88, consiste na discussão e votação de projetos de lei de iniciativa apenas do Presidente da República quando este solicitar urgência na aprovação dos mesmos.	0 a 0,65	
b) A iniciativa popular permite ao povo a apresentação de projeto de lei complementar ou ordinária, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 61, § 2º da CRFB/88. Tal iniciativa pode se dar em âmbito estadual e municipal, de acordo, respectivamente, com os arts. 27, § 4º e 29, XIII da CRFB/88.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim, a lei é inconstitucional, pois viola a competência privativa da União para legislar sobre Direito Eleitoral, de acordo com o art. 22, I da CRFB/88. Trata-se de inconstitucionalidade formal subjetiva (ou orgânica).	0 a 0,65	
b) Trata-se de modalidade de decisão que pode ser adotada pelo STF em sede de ADI e ADC, pois pode acontecer de uma lei ser incompatível com a Constituição se aplicada a uma determinada hipótese, mas fora desta, a mesma é válida. O STF analisa as diversas hipóteses em que a lei admite aplicação e declara a sua nulidade se aplicada naquela onde ocorra a violação da Constituição. Art. 28, p. único da Lei 9.868/99.	0 a 0,60	
Valor Total: _____		

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Segundo jurisprudência do STF, projetos de lei não podem ser objeto de ADPF, que é ação do controle repressivo de constitucionalidade.	0 a 0,65	
b) Sim. A modulação temporal dos efeitos da decisão é possível, de acordo com o art. 11 da Lei 9.882/99.	0 a 0,60	
Valor Total: _____		

SIMULADO 20

► Peça Processual – Valor 5,0

Kátia Helena, funcionária da Autarquia Federal ABC, foi demitida em março de 2016, depois de ter sido submetida a diversos exames psiquiátricos pela Presidência da mesma. Lúcia, sua amiga de longos anos, integrante da Diretoria da mesma, disse à Kátia que soube dos resultados de seus exames, afirmando que um deles havia apontado o seu perfil como sendo “prejudicial à empresa”, o que motivou a decisão de demissão.

Inconformada com a notícia, Kátia Helena buscou acesso a sua pasta funcional, a fim de verificar os resultados dos exames para atestar a veracidade da informação, já que nunca apresentou doenças psiquiátricas e deseja buscar a reintegração ao quadro da empresa. Entretanto, lhe foi negado o acesso às informações pessoais em todas as instâncias administrativas. A última decisão foi do próprio Presidente da referida autarquia.

Na qualidade de advogado (a) contratado (a) por Kátia Helena, redija a peça cabível ao tema, observando: a) competência do juízo; b) legitimidade ativa e passiva; c) fundamentos de mérito constitucionais; d) requisitos formais da peça inaugural.

► Questão 1

Foi elaborada uma Proposta de Emenda a Constituição que visa acabar com a licença maternidade para as mulheres brasileiras. Sabe-se que a licença maternidade (ou licença-gestante) é benefício de caráter previdenciário, introduzido pela CF de 1998 (art. 7º, XVIII), que consiste em conceder, à mulher que deu à luz, licença remunerada de 120 dias.

Considerando a situação hipotética, responda aos questionamentos:

- A referida PEC é constitucional? Explique. (Valor: 0,65)
- Qual o Poder legítimo a reforma formal do texto constitucional? É possível que haja a “mudança informal” do texto constitucional? Explique. Em caso positivo, aponte as limitações a essa “reforma informal”. (Valor: 0,60)

► Questão 2

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,

a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”

O texto acima reproduzido, preâmbulo da Constituição, apresenta ao País uma Carta Constitucional compromissória, motivada pela esperança necessária ao povo brasileiro depois de vinte e um anos de ditadura militar.

Sobre o tema, responda fundamentadamente:

- a) O preâmbulo da Constituição é provido de eficácia jurídica? (Valor: 0,65)
- b) Trata-se de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros? Ele serve como paradigma valorativo para a declaração de inconstitucionalidade das leis? (Valor: 0,60)

► Questão 3

João, português residente no Brasil desde o ano de 2000 já se considera um “cidadão” brasileiro, pois é apaixonado pelo país do futebol e sequer pensa em voltar a residir em Portugal.

Diante da situação hipoteticamente apresentada, na qualidade de advogado(a) contratado(a) por João, responda aos seus questionamentos.

- a) João ouviu dizer que poderá recorrer a algum procedimento para que seja “equiparado” a um brasileiro. Tal informação procede? Em caso positivo, explique qual medida João deveria adotar. (Valor: 0,65)
- b) Há hipótese(s) na Constituição Federal de inalistabilidade? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Questão 4

Os partidos políticos são associações de pessoas com ideologias ou interesses comuns, que mediante uma organização estável, influenciam a orientação política de um país. A Constituição Federal assegura aos partidos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias, sendo vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Sobre o tema, responda aos questionamentos abaixo:

- a) Qual(is) o(s) limite(s) a tal liberdade de organização partidária? Explique. (Valor: 0,65)
- b) Como se dá a criação dos partidos políticos? Fundamente. (Valor: 0,60)

► Espelho

Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
Endereçamento: Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da ... Vara Federal ... da Seção Judiciária do Estado ...	0 a 0,40	
Identificação da peça: Habeas Data – art. 5º, LXXII, “a” da CRFB/88 e Lei 9.507/97. Competência do Juiz Federal – art. 20, I, “d” da Lei 9.507/97.	0 a 0,40	
Legitimidade ativa: Kátia Helena (0,20) Legitimidade passiva: Presidente da Autarquia Federal ABC (0,20)	0 a 0,40	
Comprovação de recusa de informação por parte da autoridade administrativa – Súmula 2 do STJ e art. 8º, parágrafo único da Lei 9.507/97.	0 a 0,30	
Fundamentação: Cabimento da ação – art. 5º, LXXII, “a” da CRFB/88; Lei 9507/97. Direito à intimidade e vida privada, art. 5º, X, da CRFB/88. Direito à informação – art. 5º, XXXIII, da CRFB/88. Remédio Personalíssimo.	0 a 2,00	
Pedidos: Notificação da autoridade coatora (Presidente da autarquia ABC); Intimação do Representante do MP; Procedência do pedido para que a Impetrante tenha acesso ao dado pretendido; Juntada de documentos.	0 a 1,00	
Valor da Causa: R\$ 1.000,00 (mil reais)	0 a 0,50	
	Valor Total: ____	

Questão 1		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) A PEC é inconstitucional, pois esbarra em limitação material expressa prevista no art. 60, § 4º, IV da CRFB/88. Segundo a doutrina majoritária, tal limitação deve ser interpretada de forma a proteger não só os direitos de primeira geração, mas também os de segunda e terceira gerações, pois são uma expressão da dignidade da pessoa humana. O STF já entendeu que a licença maternidade é uma cláusula pétrea, reforçando, portanto, a tendência da doutrina.	0 a 0,65	
b) O Poder Constituinte Derivado Reformador, que no texto constitucional é exteriorizado por meio das emendas constitucionais e das emendas revisionais. Ao lado do processo formal de mudança da Constituição está a possibilidade de mutação constitucional, que seria uma reanálise do sentido e alcance das normas constitucionais sem mudança de texto. Além de dever o respeito à própria essência da Constituição, a mutação não poderá contrariar as cláusulas pétreas do art. 60, § 4º da CRFB/88, sob pena de se transformar numa verdadeira "mutação inconstitucional".	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 2		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Segundo orientação jurisprudencial do STF, o preâmbulo situa-se no campo da política, como reflexo da posição ideológica do constituinte no momento de sua elaboração, sendo desprovido de eficácia jurídica.	0 a 0,65	
b) Não é norma de reprodução obrigatória para as Constituições Estaduais, tampouco serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis, ainda que seja fonte de interpretação constitucional.	0 a 0,60	
	Valor Total: _____	

Questão 3		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Sim. João poderá requerer a sua equiparação em direitos e deveres civis, se dirigindo ao Ministério da Justiça, que é o órgão competente para cuidar de tal processo de equiparação, de acordo com o art. 12, § 1º da CRFB/88 e o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. (Decreto 3.927/01)	0 a 0,65	
b) Sim. De acordo com o art. 14, § 2º da CRFB/88, há vedação aos estrangeiros, salvo o caso do português equiparado, e, durante o período do serviço militar obrigatório, aos conscritos.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	

Questão 4		
Quesito avaliado	Valores possíveis	Atendimento ao quesito
a) Tal liberdade não é absoluta, pois devem ser resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos contidos no art. 17, I a IV da CRFB/88.	0 a 0,65	
b) De acordo com o art. 8º da Lei 9.096/1995, deve ser apresentado o requerimento do registro de partido político ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, da Capital Federal. O mesmo deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a cento um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, e deverá ser acompanhado de diversos documentos elencados no referido artigo. Após adquirida a personalidade jurídica, o partido promove a obtenção de apoio mínimo de eleitores (art. 7º, § 1º da Lei 9.096/1.995) e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes. Feita a constituição e designação dos mesmos, estes promoverão o registro do estatuto do partido junto ao TSE.	0 a 0,60	
	Valor Total: ____	